Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Legislazione Bancaria 1

Dispensa del corso

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
9 capitoli · 67 slide di riferimento

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

1 Introduzione alla Legislazione Bancaria e Fonti Normative della Materia 1

2 Il Testo Unico Bancario (TUB): struttura, idee di fondo e definizioni dell'Articolo 1 19

3 Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB) 31

4 Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12, cenni all'art. 129 e abusivismo artt. 130-133) 56

5 Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi 82

6 Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche 107

7 Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali 129

8 Titolo II, Capo V TUB: Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo 150

9 La riforma delle BCC del 2016 e il Titolo V (soggetti operanti nel settore finanziario) 172

1 | Introduzione alla Legislazione Bancaria e Fonti Normative della Materia

Fonte: LEGB1_Appunti_01_Introduzione-e-Fonti-Normative.pdf — *10 pagine*

1.1. Introduzione: legislazione bancaria vs. diritto bancario, e struttura del corso

Non bisogna confondere la **legislazione bancaria** con il **diritto bancario**.

- Il **diritto bancario** fa riferimento all'operatività delle banche e agli strumenti (prevalentemente di tipo contrattuale) con cui esse operano. Oltre al codice civile, lo studio del diritto bancario richiede di tenere presenti tre corpi normativi: la disciplina sulla trasparenza, la disciplina antiriciclaggio e la disciplina di contrasto dell'usura.
- La **legislazione bancaria** si occupa invece di profili diversi, anche se complementari. È una materia:
  - **parzialmente privatistica**: la banca è vista come impresa, con riferimenti al diritto privato e al diritto commerciale;
  - **parzialmente pubblicistica**: nel caso della vigilanza svolta da autorità pubbliche e per i risvolti nel diritto penale.

Il corso è un lungo commento al corpo normativo che in Italia disciplina la legislazione bancaria, il **Testo Unico Bancario (TUB)**, che segue idealmente la banca lungo tutto il suo ciclo di vita.

- **Corso I**: la parte più istituzionale, cioè nozioni fondamentali, nascita della banca, articolazione sul territorio, organi, elementi di specialità (come le banche popolari e le banche di credito cooperativo).
- **Corso II**: una parte più tecnica, cioè la vigilanza, i gruppi bancari e la crisi dei gruppi.

La distinzione si coglie anche guardando al rapporto che ciascuna materia disciplina: il diritto bancario riguarda il rapporto banca-cliente, la legislazione bancaria il rapporto banca-autorità (chi può fare la banca, con quale forma societaria e quale patrimonio, con quali assetti proprietari ed esponenti, sotto quali controlli). Anche il TUB contiene però una parte rivolta alla clientela, il Titolo VI sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti: è una disciplina di protezione del cliente e non una disciplina tipologica dei contratti bancari, i cui

tipi restano nel codice civile. Fanno eccezione le norme sulle particolari operazioni di credito (Titolo II, Capo VI: credito fondiario e alle opere pubbliche, credito agrario e peschereccio, altre operazioni) e la disciplina del credito ai consumatori (Titolo VI, Capo II).

Il carattere misto della materia ha un riscontro nel testo: l'art. 4, comma 3, richiama, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo (profilo pubblicistico), e il Titolo VIII contiene anche sanzioni penali. Il ciclo di vita della banca si legge nella successione dei Titoli: la banca nasce (Titolo II, Capo II, autorizzazione all'attività bancaria), si articola sul territorio (artt. 15 e 16, succursali e libera prestazione di servizi), è vigilata (Titolo III) ed entra eventualmente in crisi (Titolo IV, "Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa"). *(pagina 1–2)*

1.2. L'evoluzione del panorama internazionale: il nuovo contesto globale

La legislazione bancaria è una materia disciplinata dal **Testo Unico Bancario (TUB, d.lgs. 1/9/93 n. 385, entrato in vigore l'1/1/94)**.

Il legislatore nel '93, sulla spinta di alcuni provvedimenti dell'ex Comunità Economica Europea (CEE), è intervenuto modificando le leggi. A pesare fu però anche il cambiamento profondo dell'ambiente in cui le banche operavano, rispetto agli anni '30 (quando era stata scritta la vecchia legge bancaria, 1936-38). I fenomeni evolutivi principali furono:

- **Internazionalizzazione dell'attività bancaria e della finanza in generale**: oggi è cosa ovvia, ma non lo era alla fine degli anni '80 (quando iniziarono i lavori sul TUB). Le banche italiane dell'epoca erano poco internazionalizzate e il corpo normativo non teneva conto di questo fenomeno (esisteva solo un articolo che parlava genericamente di filiali di banche estere);
- **Evoluzione e ampliamento della gamma dei prodotti offerti dalle banche**: secondo il codice civile esistevano solo 6 tipologie di contratti bancari, ma nel concreto ne esistevano già molti di più. Inoltre le banche iniziavano a svolgere attività finanziaria e a offrire servizi che in passato era loro vietato offrire;
- **De-specializzazione**: il vecchio sistema finanziario era fortemente specializzato (banche, assicurazioni, agenti di cambio operavano ciascuno nel proprio ambito separatamente); nel nuovo contesto le banche offrono prodotti assicurativi, le imprese di investimento offrono prodotti a cavallo tra il finanziario e l'assicurativo, e si diffondono le cd. "aree grigie" di contiguità tra i diversi tipi di intermediari;
- **Informatizzazione e digitalizzazione dell'attività bancaria** (cartolarizzazione);
- **Nuovi meccanismi di concorrenza**: fra banche, fra banche e altri intermediari finanziari non bancari (un tempo esistevano solo tre operatori nel mercato, cioè banche, assicurazioni e agenti di cambio; poi si sono affacciati nuovi attori come SICAV, SGR, SIM, fondi pensione ecc.) e fra ordinamenti.

(pagina 3)

1.3. Le peculiarità italiane e la spinta verso la riforma

Su questo scenario di tipo globale si innestavano alcune peculiarità del sistema bancario italiano:

- **Dimensioni delle banche italiane**: in Italia vi era un'infinità di banche, tutte di piccole dimensioni. Anche le maggiori banche italiane dell'epoca non rientravano tra le prime banche europee per dimensioni (la Banca Nazionale del Lavoro era la più grande a livello italiano, ma non era neanche centesima a livello europeo). Il sistema bancario italiano non conosceva banche di grosse dimensioni, e ci si interrogava su come competere con i colossi stranieri, visti i processi di internazionalizzazione in corso.
- **Sistema bancario italiano fortemente specializzato**: osservando la vecchia legge bancaria del '36-38 (nata dopo la grande crisi del '29) si nota come l'obiettivo del legislatore dell'epoca fosse garantire la stabilità delle e fra le banche. La stabilità era garantita riducendo ai minimi termini la concorrenza (che almeno nel breve termine genera instabilità), attraverso la specializzazione delle banche. Per non farsi concorrenza tra loro, ad esempio, in Italia una sola banca poteva erogare credito cinematografico, solo due potevano erogare credito sportivo, ecc.
- **Numero degli sportelli bancari**: in Italia vi erano pochissimi sportelli bancari a causa delle esigenze di stabilità (pochi sportelli implicano bassa concorrenza), e questi pochi sportelli offrivano anche pochi servizi.
- **Massiccia presenza di banche pubbliche** (non solo in Italia, anche in Germania): una quota considerevole del sistema era infatti in mano pubblica. Gli enti creditizi di diritto pubblico non erano società, non avevano azionisti e non potevano raccogliere capitale di rischio sul mercato: il problema fu affrontato prima del TUB dalla cd. **legge Amato** (legge 30 luglio 1990, n. 218, con il d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356), che li trasformò in società per azioni separando l'attività bancaria, conferita alla società conferitaria, dalla funzione non profit, rimasta all'ente conferente (da cui sono nate le fondazioni di origine bancaria). Il TUB ne prende atto: ammette l'autorizzazione solo se è adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. a) e dispone che operatività, organizzazione e funzionamento delle banche pubbliche residue siano disciplinati dal TUB, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate (art. 151).
- **Sistema di vigilanza molto rigido e vincolante**: efficace (la vigilanza di Banca d'Italia era considerata tra le migliori al mondo), ma protettivo: si puntava sulla stabilità e non sulla concorrenza.

Il quadro era molto diverso da quello attuale. Si comincia a parlare di "mercato unico" e di "abbattimento delle frontiere": in questo modo le banche più grosse avrebbero potuto entrare in Italia. Esse avrebbero avuto dimensioni, livello di patrimonializzazione, tecnologie e gamme di servizi tali da creare molte difficoltà alle banche italiane.

La concorrenza riguardava ormai anche gli ordinamenti giuridici, oltre che le banche: con il cd. "**Patentino europeo**" una banca con sede legale in un altro Stato UE avrebbe potuto operare

direttamente in Italia. *(pagina 3–4)*

1.4. Le prime leggi bancarie in Italia (1926, 1936-38)

Nel **1926** venne emanata la cd. "**prima legge bancaria**", che ebbe però vita breve a causa della crisi del '29.

Nel **1936-38** venne emanata una nuova legge bancaria (di seguito "lb"), costituita da una serie di provvedimenti collegati tra loro che alla fine hanno dato vita a un corpo unico. Questa legge era imperniata sull'idea che una legge elastica fosse anche longeva, ed enunciava alcuni principi che potevano essere interpretati e applicati anche in modo diametralmente opposto (poteva quindi funzionare sia in sistemi più liberali che in sistemi più restrittivi). Ad esempio era sancito che "la Banca d'Italia autorizza l'apertura di nuovi sportelli", ma non erano specificati i criteri e i requisiti: Banca d'Italia godeva in buona sostanza di piena discrezionalità in tal senso. La liberalizzazione nell'apertura degli sportelli in Italia si è avuta solo negli anni '90, con il TUB.

Questa legge del '36-38 rimase in vigore fino all'entrata in vigore del TUB, l'1/1/94.

La legge bancaria è il r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, ed è così che la individua l'art. 161 TUB. Il problema che intendeva risolvere era l'instabilità sistemica nata dall'intreccio fra banca e industria: la cd. **banca mista** raccoglieva a breve e impiegava a lungo termine, anche assumendo partecipazioni nel capitale delle imprese, sicché quando le imprese cadevano cadeva anche la banca, e con essa il risparmio dei depositanti. La risposta fu duplice: separare il credito ordinario dal credito mobiliare (da qui la specializzazione per tipi di ente, per scadenze e per settori) e ridurre la concorrenza fra gli intermediari, per la quale si ricorreva alla **vigilanza strutturale**: le autorità creditizie potevano incidere sulla struttura stessa del mercato, decidendo quante banche potessero esistere, dove e con quanti sportelli.

La dottrina amministrativistica (in particolare Giannini) ha descritto il settore del credito disegnato da questa legge come un **ordinamento sezionale**: un ordinamento particolare, inserito nell'ordinamento generale ma dotato di soggetti propri (gli enti creditizi), di un'organizzazione propria (le autorità di settore) e di una normazione propria (gli atti di queste autorità). L'appiglio testuale era l'art. 1 della legge bancaria, che qualificava la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito come "funzioni di interesse pubblico". In questa lettura gli enti creditizi sono soggetti che svolgono una funzione e non imprenditori, l'accesso e la permanenza nel settore dipendono da valutazioni discrezionali dell'autorità e la normazione di settore è in larga parte prodotta dall'autorità stessa, senza criteri legali predeterminati. È una ricostruzione dottrinale, non una norma, e il TUB la supera su ciascuno di questi punti: l'art. 1, comma 1, lett. b), definisce la banca come l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria e l'art. 10, comma 1, afferma che l'attività bancaria "ha carattere d'impresa"; l'art. 14, comma 1, elenca le condizioni dell'autorizzazione, che è negata quando non risulti garantita la sana e prudente gestione (comma 2); l'art. 4, comma 2, impone alla Banca d'Italia di determinare e rendere pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza, e l'art. 5 fissa per legge le finalità della vigilanza. Resta un fondo di verità nella lettura sezionale, perché il settore bancario conserva autorità

dedicate, una riserva di attività (art. 10, comma 2), una normazione secondaria molto densa e un regime di crisi derogatorio rispetto al diritto comune; ma il fondamento di questo statuto speciale è oggi la tutela degli interessi pubblici che l'art. 5 enumera tra le finalità della vigilanza (sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia), e non più la natura pubblicistica del soggetto.

L'abrogazione disposta dal TUB non fu però integrale. L'art. 161, comma 1, abroga il r.d.l. 375/1936 "fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b)", e l'art. 147 stabilisce che le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti da quegli articoli. Il TUB li richiama per numero senza riprodurli: il loro contenuto resta quello del testo del 1936. *(pagina 5)*

1.5. Fonti costituzionali: artt. 47, 41 e 117 Cost.

Art. 47 Cost. (inserito anche all'interno della cd. Costituzione Economica):

> "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese."

È compito dell'ordinamento bancario (e quindi della legislazione bancaria) tutelare il risparmio: questo principio è imposto dalla Costituzione stessa. Si aggiunge "in tutte le sue forme", perché possono esistere più forme di risparmio: quello consapevole (tramite investimenti) e quello inconsapevole (tramite risparmio bancario). Bisogna quindi tutelare in egual modo sia il risparmiatore che l'investitore.

Si prevede poi che la Repubblica "disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito": poiché la Costituzione impone di "disciplinare", la Repubblica non può non avere una legislazione bancaria, e deve quindi esistere una regolamentazione specifica dell'attività bancaria (il TUB, tuttavia, non è legge costituzionale, ma legge ordinaria).

I tre verbi indicano funzioni distinte: normativa (disciplina), di indirizzo (coordina) e di vigilanza (controlla). Nell'ordinamento attuale sono ripartite fra il legislatore e le autorità creditizie indicate dall'art. 1, comma 1, lett. a), cioè CICR, Ministro dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia, che il Titolo I del TUB disciplina. L'art. 47 parla però di "Repubblica" e non costituzionalizza alcuna autorità determinata: l'assetto delle autorità creditizie è una scelta del legislatore ordinario, e infatti è cambiato nel tempo (da ultimo con il trasferimento di compiti alla BCE). Allo stesso modo la norma impone che esista una disciplina in grado di tutelare il risparmio, non questa specifica disciplina.

Il secondo comma dell'art. 47 è un enunciato di indirizzo, di cui si leggono tracce nella disciplina speciale del credito fondiario (artt. 38 e ss. TUB) e del credito agrario (artt. 43 e ss.). Nel TUB il precetto costituzionale trova riscontro nell'art. 2, comma 1, che attribuisce al

CICR l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, e nell'art. 5, che indica le finalità cui le autorità creditizie hanno riguardo nell'esercizio dei poteri di vigilanza: sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Le due forme di risparmio ricordate sopra sono tutelate con tecniche diverse: il risparmio inconsapevole (il depositante) con la vigilanza prudenziale e con i sistemi di garanzia dei depositanti (artt. 96 e ss.), il risparmio consapevole (l'investitore) con regole di trasparenza e di condotta.

Art. 41 Cost.:

> "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."
>
> **Nota (aggiornamento normativo):** il testo riportato è anteriore alla riforma costituzionale (l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1): l'art. 41 vigente aggiunge, tra i limiti all'iniziativa economica, il danno «alla salute, all'ambiente» e prevede che l'attività possa essere indirizzata e coordinata «a fini sociali e ambientali».

Questa norma è frutto di un compromesso tra la componente liberale e quella socialista. La libertà d'impresa fa parte della libertà di iniziativa economica, e se la banca è riconosciuta come impresa allora vi sarà anche libertà d'impresa bancaria. Lo Stato può comunque intervenire per disciplinare e vincolare l'attività economica al fine di indirizzarla a fini sociali. La banca, in quanto impresa, è disciplinata anche dall'art. 41. Si nota inoltre una **riserva di legge**: è vero che il TUB è una legge ordinaria come un'altra, ma nell'ambito della legislazione bancaria si opera molto spesso tramite **delegificazione**, termine che indica il fatto che il legislatore delega i propri poteri ad autorità secondarie (in questo caso le autorità creditizie) e non l'assenza di leggi.

La riserva di legge dell'art. 41, terzo comma, è una riserva **relativa**: la legge deve determinare i programmi e i controlli, ma non è tenuta a disciplinarli in modo esaustivo e può limitarsi a fissare i criteri rinviando il resto a fonti subordinate. È questa relatività a rendere costituzionalmente legittima la delegificazione su cui è costruito il TUB. Delegificare significa spostare il livello normativo, senza deregolamentare: il risultato è spesso una regolazione più fitta. Ne sono esempi l'art. 53, comma 1, che affida alla Banca d'Italia disposizioni di carattere generale su materie come l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, il governo societario, i controlli interni, i sistemi di remunerazione e l'informativa al pubblico, senza predeterminarne il contenuto tecnico; l'art. 11, comma 3, che affida al CICR la fissazione dei limiti e dei criteri in base ai quali la raccolta presso specifiche categorie, individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro, non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico; l'art. 14, comma 1, lett. b), che rimette alla Banca d'Italia la determinazione del capitale minimo; l'art. 26, comma 3, che affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, la determinazione dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti.

La delegificazione passa attraverso la tecnica del **rinvio**: la norma primaria, invece di disciplinare direttamente la fattispecie, ne affida la disciplina a un'altra fonte. Il rinvio può essere mobile, cioè richiamare la fonte in quanto tale, sicché si applica la disciplina vigente pro tempore, oppure fisso, cioè richiamare un testo determinato; in una materia in continua evoluzione tecnica il rinvio mobile evita di cristallizzare la disciplina. L'interprete deve però ricostruire vere e proprie catene normative, dalla norma primaria alla fonte che detta davvero il precetto, spesso attraverso più passaggi. Il contrappeso è procedurale: l'art. 4, comma 2, impone alla Banca d'Italia di determinare e rendere pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza, e il comma 3 le impone di indicare i motivi delle decisioni, applicando in quanto compatibili le disposizioni della legge 241/1990.

Resta da chiarire il rapporto fra l'art. 47 e l'art. 41. Si potrebbe pensare che l'art. 47, essendo speciale (poiché si occupa specificamente di banche), debba prevalere sull'art. 41 (che si occupa di imprese in maniera generale). I due articoli vanno invece conciliati: vi è libertà di impresa, e tale attività può essere indirizzata a fini sociali, ma per quanto riguarda l'attività bancaria la scelta di indirizzare e coordinare a fini sociali è stata compiuta a monte dal legislatore costituzionale, proprio a causa della sua importanza.

Art. 117 Cost.:

> "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale."

Questo articolo, oltre a ricordare nel primo comma che la potestà legislativa è esercitata anche nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento comunitario, stabilisce nel secondo comma i rapporti di competenza tra Stato e Regioni (da cui si evince che la tutela del risparmio è materia di competenza statale esclusiva). Il terzo comma presenta invece termini ormai desueti, come le "aziende a carattere regionale".

Le categorie che il terzo comma elenca (casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale) non esistono più come categorie distinte, per effetto della despecializzazione istituzionale operata dal TUB, che prevede soltanto banche in forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. a). La competenza concorrente è quindi rimasta, nel testo costituzionale, priva di un oggetto corrispondente alle categorie di banche oggi esistenti, mentre il riparto effettivo è quello del secondo comma. Il TUB considera le competenze regionali nell'art. 159, dedicato alle Regioni a statuto speciale: nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli artt. 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante (comma 2). Il vincolo europeo del primo comma trova la sua applicazione settoriale nell'art. 6 TUB,

secondo cui le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. *(pagina 5–6)*

1.6. Fonti sovranazionali (I): Trattato di Roma, LI/LPS e le prime due direttive bancarie

Si tratta delle fonti di diritto dell'Unione Europea (non si usa più il termine "comunitario", perché non esiste più la Comunità Economica Europea), come i regolamenti e le direttive. Il **regolamento** è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza bisogno di atti di recepimento; la **direttiva** vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi, e deve quindi essere recepita nell'ordinamento interno (in Italia, di regola con decreto legislativo delegato). Per buona parte della sua storia la disciplina bancaria europea è stata una disciplina per direttive; oggi la disciplina prudenziale sostanziale è contenuta in un regolamento.

La prima fonte normativa rilevante è il **Trattato di Roma** (firmato il 25 marzo 1957, in vigore dal 1° gennaio 1958), con cui si sancisce la nascita della Comunità Economica Europea. L'obiettivo era la creazione di un mercato unico europeo. Gli strumenti individuati come essenziali per raggiungere tale fine (e che ancora oggi si ritrovano nella disciplina bancaria) erano:

- il principio della **Libertà di Insediamento (LI)**: le imprese (come le banche) hanno libertà di istituire sedi secondarie (sportelli, nel caso delle banche) anche in Paesi europei diversi da quello d'origine (dove la società ha la sede legale);
- il principio della **Libera Prestazione di Servizi (LPS)**: libertà per l'impresa di prestare servizi in altri Paesi UE diversi da quello d'origine, senza istituirvi una succursale (operando direttamente dal Paese d'origine).

Nel TUB le due libertà si traducono rispettivamente negli artt. 15 (succursali) e 16 (libera prestazione di servizi). La succursale è, secondo l'art. 1, comma 2, lett. e), una sede priva di personalità giuridica che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività per la quale la banca è autorizzata: è parte della banca, a differenza della filiazione, che è una società distinta.

Il primo tentativo di varare una legge bancaria europea risale al **1962**, ma fallì per un problema allora insormontabile: ogni Paese UE aveva una propria nozione di "banca" o "attività bancaria".

Una prima direttiva in materia bancaria (considerata oggi una sorta di "direttiva zero", la **direttiva 183 del 1973**) prevedeva la soppressione delle restrizioni nelle legislazioni bancarie nazionali in merito a LI e LPS.

La vera e propria "**Prima direttiva in materia bancaria**" (**direttiva 780 del 1977**) cercò di armonizzare le legislazioni bancarie nazionali. Al suo interno prevedeva:

- un **glossario** per definire in maniera univoca alcuni concetti, tra cui "banca";
- il **rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria sulla base di presupposti oggettivi**: l'attività bancaria non è infatti libera, ma necessita di un'autorizzazione per poter essere svolta;

- le prime **norme di coordinamento e collaborazione** tra le varie autorità nazionali.

Questa direttiva creò qualche difficoltà all'Italia, a causa della vecchia legge bancaria che non specificava i criteri secondo cui Banca d'Italia potesse rilasciare l'autorizzazione alle banche: con la direttiva, i requisiti richiesti dovevano diventare oggettivi. L'Italia subì una procedura di infrazione per non avere recepito in tempo la direttiva; il recepimento avvenne solo nel **1985**, con il **dpr. 350/1985**.

Il dpr. 350/1985 è fra i provvedimenti che l'art. 161, comma 2, TUB colloca nell'abrogazione differita. Dei contenuti della prima direttiva si ritrova traccia nel TUB: i presupposti oggettivi dell'autorizzazione sono le condizioni che l'art. 14, comma 1, elenca per il rilascio dell'autorizzazione, e la collaborazione fra le autorità è oggi disciplinata dagli artt. 6 (rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU) e 7 (segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità).

La "**Seconda direttiva di coordinamento**" (**direttiva 646 del 1989**) afferma tre principi, posti alla base del TUB:

- il **Principio del mutuo riconoscimento o dell'autorizzazione unica**: quando una società ottiene l'autorizzazione all'attività bancaria in uno Stato membro, può automaticamente svolgere l'attività bancaria anche in tutti gli altri Paesi dell'odierna UE. Le varie autorità di vigilanza si riconoscono a vicenda le autorizzazioni rilasciate;
- il **Principio dell'armonizzazione minima**: l'armonizzazione è minima perché è necessario procedere per gradi, con l'intento di accrescerla nel tempo;
- il **Principio dell'Home country control**: la vigilanza è affidata all'autorità del Paese d'origine, cioè dove la banca ha la sede legale e la direzione generale (principio funzionale ad avere una visione d'insieme della banca).

Esistono tuttavia **3 eccezioni** a questo principio, cioè fattispecie nelle quali vige il principio opposto dell'**Host country control** (vigilanza affidata all'autorità del Paese ospitante):

- vigilanza sulla liquidità delle banche;
- tutela del cliente: disciplina della trasparenza bancaria;
- motivi di ordine pubblico: disciplina anti-usura e antiriciclaggio.

La ragione delle tre eccezioni è che si tratta di materie in cui l'interesse tutelato è radicato nel mercato ospitante e non in quello d'origine.

Il **mutuo riconoscimento** riguarda le attività e non la banca in quanto tale, e il TUB lo costruisce in due passaggi. Definisce anzitutto la "banca dell'Unione europea" come la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia (art. 1, comma 2, lett. b). Ne delimita poi l'oggetto con l'elenco delle "attività ammesse al mutuo riconoscimento" (art. 1, comma 2, lett. f), che comprende quindici voci, dalla raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione alle operazioni di prestito, dal leasing finanziario ai servizi di pagamento, fino alla gestione di patrimoni e alla locazione di cassette di sicurezza; l'ultima voce (n. 15) rinvia alle attività aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia 89/646/CEE, fonte europea ormai storica il cui richiamo

è rimasto nel testo. Per le attività fuori elenco il riconoscimento non opera: l'art. 17 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare il loro esercizio in Italia da parte delle banche comunitarie. Il beneficio è esteso, alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale e controllate da banche italiane (art. 18, comma 1). Il cd. "patentino europeo" opera quindi nei limiti dell'elenco.

Ancora oggi questi tre principi sono i pilastri della legislazione bancaria a livello europeo. Questa volta l'Italia, nonostante la grande mole di lavoro, riuscì a recepire rapidamente la direttiva tramite due deleghe:

- delega a recepire la seconda direttiva banche, che portò al **d.lgs. 481/92** (cd. "decreto di passaggio");
- delega che autorizzava il governo a predisporre un testo unico per ordinare la materia e abrogare la vecchia legge bancaria del '36-38 e il decreto 481/92, delega che portò al **d.lgs. 385/93** (il TUB).

Il preambolo del TUB richiama gli artt. 76 e 87 della Costituzione e l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE. Il TUB è infatti un testo unico **innovativo**: riscrive la normativa esistente invece di limitarsi a riordinarla (introduce la despecializzazione, riscrive l'autorizzazione all'attività bancaria, rifonda la vigilanza), e per questo è un atto avente forza di legge, fondato su una delega legislativa ai sensi dell'art. 76 Cost. e sottoposto ai limiti che la delega pone quanto a oggetto, principi e criteri direttivi e termine; un testo unico compilativo, che non innova, non richiederebbe delega. Il decreto è del 1° settembre 1993: il 1° gennaio 1994 è la data di entrata in vigore, fissata dall'art. 162. Avendo forza di legge ordinaria, il TUB può essere modificato da qualunque fonte primaria successiva, come in effetti è avvenuto con grande frequenza.

Nonostante la velocità dell'Italia nel recepire la seconda direttiva banche, il d.lgs. 481/92 ebbe vita breve, perché dal '94 sarebbe entrato in vigore il TUB. Anche un decreto destinato a essere assorbito conserva tuttavia qualche disposizione autonoma: l'art. 161, comma 1, lo abroga fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6. Il TUB si compone di numerosi articoli, ma qui interessa sapere che l'**art. 161** elenca tutte le norme abrogate, distinguendo due tipi di abrogazione:

- **immediata** ("sono abrogati");
- **differita** ("sono abrogati, ma continuano ad applicarsi fino a quando non saranno entrate in vigore le norme attuative del Testo Unico destinate a sostituirle").

Il comma 1 si apre con la formula "Sono o restano abrogati" e l'elenco comprende un gran numero di provvedimenti; l'abrogazione immediata è però spesso soltanto parziale, perché per molte voci è fatta eccezione per singole disposizioni (oltre ai casi della legge bancaria e del d.lgs. 481/92, si pensi alla legge 10 maggio 1938, n. 745 e al r.d. 25 maggio 1939, n. 1279, in parte ancora in vigore e richiamati dall'art. 48 TUB per il credito su pegno). Per l'abrogazione differita il comma 2 dispone che i provvedimenti elencati "sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo": vi rientra, fra gli altri, il dpr. 350/1985. I commi 3

e 3-bis prevedono due casi di ultrattività a termine: gli artt. 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art. 152, e i commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del dpr. 31 marzo 1988, n. 148, benché abrogati, fino all'attuazione dell'art. 155, comma 5. Il comma 4 aggiunge una clausola di chiusura di abrogazione implicita ("è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo"), mentre il comma 5 prolunga l'efficacia delle disposizioni emanate dalle autorità creditizie in base a norme abrogate o sostituite, fino all'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti. Il meccanismo evita il vuoto normativo fra l'abrogazione delle norme precedenti e l'emanazione dei provvedimenti attuativi del TUB. *(pagina 6–8)*

1.7. Fonti sovranazionali (II): dalle direttive di semplificazione al SEVIF e all'Unione Bancaria

Col passare degli anni, in Italia sono state recepite tutta una serie di direttive di natura più tecnica.

Nel **2000** è stata emanata la **Direttiva di semplificazione (direttiva 12/2000)**, che era una sorta di testo unico e che abrogava la prima direttiva banche (quella del '73) e la seconda (89/646). Non innovava in modo sostanziale: raccoglieva e riordinava in un solo atto la stratificazione di direttive tecniche prodotta dall'armonizzazione minima (fondi propri, coefficiente di solvibilità, grandi fidi, vigilanza consolidata).

A causa del rapido cambiamento della materia, si ha un nuovo intervento del legislatore europeo con la **direttiva n. 48 del 2006** (da alcuni chiamata anche "terza direttiva"). Anch'essa dà vita a un ulteriore pseudo testo unico delle direttive in materia bancaria. Siamo ormai alle soglie della crisi del 2008. Oltre a riordinare la materia, questa direttiva, insieme alla direttiva 2006/49/CE, recepisce nel diritto europeo l'accordo di Basilea II e i suoi tre pilastri. È la disciplina in vigore all'inizio della crisi; le due direttive saranno abrogate dalla direttiva 2013/36/UE (CRD IV), attuata in Italia con il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

Di fronte ai primi segnali di crisi, nel **2009** l'UE decise di creare un **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)**, divenuto concretamente attivo dal 2011. Il sistema ha portato alla creazione di alcune autorità a livello europeo con forme di vigilanza regolamentare:

- a livello **macro prudenziale**, venne istituita la **ESRB (European Systemic Risk Board)**, per fronteggiare il rischio sistemico, con compiti di vigilanza macro prudenziale (a livello di sistema e non di singole banche);
- a livello **micro prudenziale** vennero istituite:
  - l'**EBA (European Banking Authority)**, che si occupa del settore bancario. Non ha poteri di vigilanza diretta sulle banche, ma ha il potere di dettare linee guida e orientamenti incisivi nell'ottica della vigilanza; lo strumento più importante finora varato dall'EBA è il **Single Rulebook**, un testo che orienta l'attività di vigilanza dei vari Stati nazionali;

- la **EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)**, che si occupa del comparto assicurativo e dei fondi pensione;
- l'**ESMA (European Securities and Markets Authority)**, che si occupa dei mercati finanziari.

Il SEVIF non ha creato una vigilanza unica a livello europeo, ma ha favorito il processo di armonizzazione tramite la creazione di autorità che hanno cominciato a scrivere regole, anche tecniche, comuni.

Nel TUB il SEVIF è definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-bis): ne fanno parte le tre autorità settoriali (EBA, EIOPA ed ESMA, che il TUB chiama ABE, AEAP e AESFEM, istituite rispettivamente dai regolamenti (UE) nn. 1093, 1094 e 1095 del 2010), il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, il CERS (istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010) e le autorità di vigilanza degli Stati membri. L'art. 6 TUB prevede inoltre che le autorità creditizie applichino i regolamenti e le decisioni dell'Unione e provvedano in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria (comma 1), e che la Banca d'Italia sia parte del SEVIF e del MVU (comma 3).

Infine, su decisione del Consiglio Europeo, si è giunti alla costituzione dell'**Unione Bancaria nel 2012** (pur avendo richiesto alcuni anni per essere pienamente implementata), basata su tre pilastri:

1. **Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU o SSM)**: istituito tramite il **regolamento UE 1024/2013**, divenuto operativo nel 2014, ha affidato la vigilanza delle "more significant banks" alla BCE e delle "less significant banks" alle singole autorità di vigilanza nazionali. Con l'avvento della moneta unica, la politica monetaria era stata trasferita in capo alla BCE, ma la vigilanza era rimasta affidata alle autorità nazionali ai sensi dell'art. 127 (ex art. 105) del Trattato sul funzionamento dell'UE. Per poter trasferire i poteri di vigilanza alla BCE senza dover modificare il Trattato (cosa che in alcuni Paesi avrebbe comportato referendum confermativi, che si voleva evitare, oltre a richiedere molto tempo), è stato varato il Regolamento 1024/2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e istituisce l'Unione Bancaria (il regolamento è in vigore dal 3 novembre 2013, mentre la BCE ha assunto i compiti di vigilanza il 4 novembre 2014);
2. **Meccanismo di Risoluzione Unico delle crisi bancarie (SRM)**: realizzato attraverso diversi provvedimenti per armonizzare le norme relative alle crisi bancarie (cosa che le passate direttive non erano riuscite a fare). Lo strumento principale è la **BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)**;
3. **Sistema di garanzia dei depositi** (per la protezione dei depositanti): a oggi non ancora compiutamente realizzato a livello europeo; i vari Stati mantengono i propri strumenti, come i fondi a tutela dei depositanti.

Quanto al **primo pilastro**, il regolamento (UE) n. 1024/2013 è un regolamento del Consiglio del 15 ottobre 2013, adottato sulla base dell'art. 127, paragrafo 6, TFUE, che contiene già una clausola abilitante: consente al Consiglio di affidare alla BCE compiti specifici in materia di

vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Il regolamento non deroga quindi al Trattato né lo modifica: si limita ad attivare quella clausola. Il suo funzionamento concreto è disciplinato dal regolamento quadro della BCE n. 468/2014, che regola la cooperazione fra BCE e autorità nazionali e al quale l'art. 1, comma 2, lett. d), TUB rinvia per la nozione di "soggetto significativo" (art. 2, n. 16).

La **significatività** si misura sui parametri generali di dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di uno Stato membro partecipante e rilevanza delle attività transfrontaliere (art. 6, par. 4, reg. 1024/2013), che il regolamento traduce in condizioni puntuali. Un ente non è considerato meno significativo, salvo particolari circostanze, quando: il valore totale delle attività supera 30 miliardi di euro; oppure il rapporto fra attività totali e PIL dello Stato membro partecipante in cui è stabilito supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro; oppure l'autorità nazionale competente notifica che l'ente ha importanza significativa per l'economia nazionale e la BCE, all'esito di una propria valutazione approfondita, conferma tale significatività. La BCE può inoltre considerare significativo di propria iniziativa l'ente con filiazioni in più di uno Stato partecipante e rilevanti attività o passività transfrontaliere; non sono mai considerati meno significativi gli enti che abbiano richiesto o ricevuto direttamente assistenza finanziaria pubblica dal FESF o dal MES; e la BCE vigila inoltre, salvo particolari circostanze, sui tre enti creditizi più significativi di ciascuno Stato membro partecipante.

Il riparto per significatività non è una separazione netta: distribuisce la vigilanza corrente senza separare due ordinamenti. Per i soggetti meno significativi le decisioni di vigilanza sono adottate dalle autorità nazionali, ma nel quadro definito dalla BCE: questa emana regolamenti, orientamenti e istruzioni generali, esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema e può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità nazionale, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri su uno o più enti meno significativi (art. 6, par. 5). Alcune competenze, inoltre, non seguono la significatività: l'autorizzazione all'attività bancaria è di competenza della BCE per tutti gli enti creditizi (art. 4, par. 1, lett. a, reg. 1024/2013) e il TUB dispone che sia rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 2; art. 6-bis, comma 2, lett. a); la Banca d'Italia, d'altra parte, è l'autorità nazionale designata per le misure richiamate dall'art. 5 del reg. 1024/2013 e può esercitare i poteri di vigilanza attribuiti dal TUB, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi (art. 53-ter).

Il **secondo pilastro** è il Meccanismo di risoluzione unico, che l'art. 1, comma 1, lett. e-quinquies), TUB definisce come il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati partecipanti. La BRRD è la direttiva 2014/59/UE, recepita in Italia con i d.lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181: il d.lgs. 180/2015 contiene la disciplina della risoluzione, mentre il d.lgs. 181/2015 modifica il TUB (fra l'altro sostituendo la rubrica del Titolo IV, oggi "Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa").

Quanto al **terzo pilastro**, poiché il sistema europeo di garanzia dei depositi non è stato realizzato, la tutela dei depositanti resta nazionale, armonizzata dal diritto dell'Unione ma non accentrata: per l'Italia si vedano gli artt. 96 e ss. TUB. Le banche italiane aderiscono a uno

dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia (art. 96, comma 1); i sistemi hanno natura di diritto privato e le risorse sono fornite dalle banche aderenti (comma 4), ma la Banca d'Italia li riconosce approvandone gli statuti e vigila sul rispetto della disciplina della sezione (art. 96-ter, comma 1). Le succursali di banche comunitarie possono aderire a un sistema italiano per integrare la tutela offerta dal sistema dello Stato di appartenenza (comma 2): è una facoltà e non un obbligo perché la banca comunitaria è coperta dal sistema dello Stato d'origine, coerentemente con l'home country control. Il rimborso è limitato a 100.000 euro per ciascun depositante (art. 96-bis.1, comma 3, limite adeguato ai sensi dell'art. 6, par. 7, direttiva 2014/49/UE), con deroghe temporanee per alcuni depositi di persone fisiche (comma 4), e restano esclusi, fra gli altri, i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento e di assicurazione, OICR, fondi pensione ed enti pubblici (comma 2): la garanzia è rivolta al risparmio inconsapevole di cui all'art. 47 Cost. e non copre i depositi degli operatori finanziari e degli enti pubblici.

Restano tuttavia dei problemi aperti: con l'attribuzione dei poteri di vigilanza alla BCE, l'EBA non è stata soppressa, e ci si chiede quali rapporti debbano intercorrere tra EBA, BCE e le autorità nazionali.

Il problema è risolto con regole di procedura e doveri di collaborazione, senza una gerarchia fra le autorità. L'EBA ha un ambito diverso da quello della BCE: opera per l'intera Unione, mentre il MVU riguarda i soli Stati partecipanti, e ha funzioni regolamentari e non di vigilanza diretta. Il rischio di sovrapposizione (più autorità che intervengono sullo stesso profilo) o di vuoto (nessuna autorità che si ritiene competente) è governato da strumenti procedurali: il regolamento quadro n. 468/2014 disciplina la cooperazione fra BCE e autorità nazionali; l'art. 6, comma 2, impone obblighi di comunicazione verso le autorità e i comitati del SEVIF e del MRU e verso la BCE; l'art. 6, comma 4, consente alla Banca d'Italia di concludere accordi con l'EBA e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri, anche con ripartizione di compiti e delega di funzioni, e di ricorrere all'EBA per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere; l'art. 6-bis, comma 5, impone a Banca d'Italia e BCE di operare in stretta collaborazione secondo il principio di leale cooperazione.

Il **single rulebook** è il corpo unico di regole prudenziali applicabili agli intermediari dell'Unione, di cui l'EBA è l'artefice istituzionale: propone alla Commissione le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (RTS e ITS), che sono atti dell'Unione, ed emana orientamenti e raccomandazioni. Nasce come risposta al limite dell'armonizzazione minima: finché la disciplina prudenziale viaggiava su direttive, ogni recepimento nazionale introduceva varianti, e le varianti diventavano leve di concorrenza fra ordinamenti. Per questo, con la riforma del 26 giugno 2013, il legislatore europeo ha separato la materia in due atti: il **regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)**, che contiene la disciplina prudenziale sostanziale ed è direttamente applicabile, e la **direttiva 2013/36/UE (CRD IV)**, che riguarda l'accesso all'attività e la vigilanza e va recepita (in Italia con il d.lgs. 72/2015). Collocare le regole prudenziali sostanziali in un regolamento toglie agli Stati il margine del recepimento.

Il regolamento non entra nel TUB, perché un regolamento non si recepisce: entra nel presupposto dei poteri che il TUB attribuisce. L'art. 6, comma 3-bis, stabilisce infatti che le autorità

creditizie esercitano i poteri d'intervento attribuiti dal TUB anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli artt. 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'EBA direttamente applicabili.

Accanto agli atti vincolanti c'è un'area di **soft law**: orientamenti e raccomandazioni dell'EBA, guide e aspettative di vigilanza della BCE. Non sono fonti del diritto in senso proprio e non vincolano di per sé, ma producono effetti reali attraverso il meccanismo del *comply or explain* (l'autorità nazionale che non intende conformarsi deve dichiararlo e motivarlo) e attraverso il loro assorbimento nella normativa secondaria nazionale, che a quel punto è pienamente cogente.

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** il riparto EBA–BCE si è assestato in senso *funzionale* e non gerarchico: l'EBA fa regolazione (Single Rulebook, orientamenti, stress test EU-wide), la BCE-SSM vigila direttamente sulle banche significative applicando le metodologie EBA, le autorità nazionali sulle meno significative; la BCE segue gli orientamenti EBA ma non ne è gerarchicamente subordinata. Il terzo pilastro (EDIS, schema europeo unico di garanzia dei depositi) **non è stato realizzato**: la riforma CMDI (proposta 2023, accordo politico 2025, DGSD II e BRRD III in vigore dal 2026) rafforza la gestione delle crisi delle banche medio-piccole ma è meno ambiziosa del disegno originario; il full EDIS resta rinviato.

(pagina 8–9)

1.8. Il recepimento nel diritto interno: gli interventi sul TUB dopo il 1993

Dopo il 1993 il TUB è stato riscritto da una lunga serie di interventi, ciascuno collegato a un atto europeo o a un'esigenza specifica. I principali:

- **legge 28 dicembre 2005, n. 262** (tutela del risparmio), risposta interna agli scandali finanziari dei primi anni Duemila: il suo art. 39, comma 1, dispone il raddoppio delle pene previste dal TUB entro i limiti posti dal codice penale per ciascun tipo di pena;
- **d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72**: attua la direttiva 2013/36/UE (CRD IV). Inserisce gli artt. 53-bis (poteri di intervento) e 53-ter (misure macroprudenziali) e il comma 3-bis dell'art. 6, sostituisce integralmente l'art. 26 sugli esponenti aziendali e riscrive le lettere d) ed e) dell'art. 14, comma 1;
- **d.lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181**: attuano la direttiva 2014/59/UE (BRRD). Il d.lgs. 180/2015 contiene la disciplina della risoluzione; il d.lgs. 181/2015 modifica il TUB, fra l'altro sostituendo la rubrica del Titolo IV e inserendo il comma 4-bis dell'art. 4;
- **d.lgs. 14 novembre 2016, n. 223**: adegua il TUB al regolamento (UE) n. 1024/2013 (MVU). Inserisce l'art. 6-bis e il comma 01 dell'art. 15, sostituisce l'art. 53-ter e interviene sull'art. 14: dove prima si leggeva "La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria" e "La Banca d'Italia nega l'autorizzazione", oggi l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia ed è negata dalla Banca d'Italia o dalla BCE (art. 14,

comma 2). Il comma 01 dell'art. 15 prevede che le banche italiane possano stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU; alla Banca d'Italia resta il potere di vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo, per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto (art. 15, comma 1). L'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia è prevista per le succursali delle banche italiane in uno Stato terzo (art. 15, comma 2) e per le succursali in Italia di banche di Stato terzo (art. 14, comma 4; art. 15, comma 4); per la libera prestazione di servizi delle banche comunitarie in Italia basta che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza (art. 16, comma 3).

Accanto a questi interventi corrono le due riforme del settore cooperativo: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 sulle banche popolari (convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33) e il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 sulle banche di credito cooperativo.

1.9. Cenni di norme secondarie: le circolari di Banca d'Italia

Alcune delle circolari di Banca d'Italia di nostro interesse, in successione storica:

- **Circolare n. 4**, *Istruzioni di Vigilanza per gli enti creditizi*: abrogata e sostituita dalla successiva;
- **Circolare n. 229**, *Istruzioni di vigilanza per le banche*: attualmente le "istruzioni di vigilanza" non esistono più; quasi tutta la circolare è stata a sua volta abrogata e sostituita dalla successiva;
- **Circolare n. 263**, *Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*: era la circolare emanata in attuazione di Basilea II, ma è stata abrogata e sostituita dalla successiva;
- **Circolare n. 285**, *Disposizioni di vigilanza per le banche*: è la circolare più importante nel nostro studio, essendo quella attuativa del TUB.

La Circolare n. 229 è del 21 aprile 1999, la n. 263 del 27 dicembre 2006 e la n. 285 del 17 dicembre 2013. Quest'ultima poggia sui poteri normativi secondari che il TUB attribuisce alla Banca d'Italia: l'art. 4, comma 1 (regolamenti "nei casi previsti dalla legge", istruzioni e provvedimenti di carattere particolare), l'art. 53, comma 1 (disposizioni di carattere generale su materie come l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, il governo societario, i controlli interni, i sistemi di remunerazione, l'informativa al pubblico) e, per i gruppi, l'art. 67. Il rapporto con il TUB non è di semplice gerarchia ma di delega: la fonte primaria individua le materie e i fini, la fonte secondaria detta i contenuti tecnici, entro i limiti dell'attribuzione e delle finalità dell'art. 5, sicché una disposizione che eccedesse la delega sarebbe illegittima e non soltanto subordinata. Le disposizioni secondarie sono cogenti per i destinatari e possono fondare misure correttive e provvedimenti sanzionatori. Nella Circolare la Parte Prima contiene il recepimento della CRD IV, mentre la Parte Seconda riguarda l'applicazione del CRR e si limita, per i profili sostanziali, a un'indicazione ricognitiva (il regolamento è direttamente applicabile,

e indicarlo fra le fonti non equivale a recepirlo).

Gli Accordi di Basilea, a cui si collegano le circolari n. 263 e n. 285, non sono una fonte del diritto: sono standard elaborati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, un consesso di autorità di vigilanza privo di potere normativo, e quindi soft law internazionale. Producono effetti giuridici solo attraverso una catena a tre anelli: lo standard ("Basilea 2", "Basilea 3"); il recepimento nel diritto dell'Unione (la direttiva 2006/48/CE per Basilea II, il CRR e la CRD IV per Basilea 3); l'attuazione nella normativa secondaria nazionale, a quel punto cogente. La Circolare n. 263 attuava Basilea II; la n. 285 nasce per l'applicazione, dal 1° gennaio 2014, degli atti europei che traspongono Basilea 3. *(pagina 10)*

1.10. Il sistema delle fonti dell'ordinamento bancario: sintesi

Ogni norma dell'ordinamento bancario si colloca su più livelli, dall'alto verso il basso. La Costituzione fornisce la ratio (artt. 41 e 47: l'equilibrio fra libertà d'impresa e tutela del risparmio) e il riparto di competenza (art. 117); il diritto europeo pone il vincolo; la legge interna, a partire dal TUB, costruisce l'architettura; la normativa secondaria stabilisce il contenuto tecnico.

Livello	Atti tipici	Efficacia
Costituzione	artt. 41, 47, 117 Cost.	Fondamento e limite di ogni fonte interna; l'art. 117, comma 1, vincola il legislatore al rispetto dell'ordinamento europeo
Diritto dell'Unione	regolamenti (CRR, reg. 1024/2013), direttive (CRD IV, BRRD), RTS e ITS adottati dalla Commissione	Primato sul diritto interno incompatibile; il regolamento è direttamente applicabile, la direttiva va recepita
Legge interna	TUB (d.lgs. 385/1993), decreti legislativi di recepimento, leggi speciali	Fonte primaria ordinaria, modificabile da ogni fonte primaria successiva
Normativa secondaria	delibere del CICR, decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, regolamenti, istruzioni e provvedimenti della Banca d'Italia (Circ. n. 285)	Cogente per i destinatari, nei limiti della delega (artt. 4 e 53 TUB)
Soft law	orientamenti e raccomandazioni dell'EBA, guide e aspettative della BCE, standard del Comitato di Basilea	Non vincolante in sé: opera con il comply or explain o se assorbita in un atto vincolante

Il rapporto fra diritto dell'Unione e diritto interno non è gerarchico ma di competenza e di primato (artt. 11 e 117, comma 1, Cost.): la norma interna incompatibile con una norma europea direttamente applicabile non è invalida, ma viene disapplicata dal giudice e dall'amministrazione, fermo il limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale (i cd. controlimiti). Neppure il rapporto fra TUB e circolari è un semplice rapporto di grado, ma di delega. Ne segue che la regola applicabile non sta quasi mai in un solo luogo: la sua ricostruzione parte dalla norma primaria, risale alla fonte europea che la condiziona e scende alla fonte secondaria che la attua.

Il TUB non esaurisce l'ordinamento finanziario: accanto ad esso c'è il Testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), che disciplina i servizi di investimento e i mercati. Il confine passa dall'art. 10, comma 3: le banche esercitano ogni altra attività finanziaria "secondo la disciplina propria di ciascuna" e sono salve le riserve di attività previste dalla legge. Il TUB descrive il soggetto e rinvia al TUF per l'abilitazione all'attività: ad esempio l'art. 16, comma 4, richiama l'art. 29-ter TUF e l'art. 106, comma 2, lett. b), consente agli intermediari finanziari di prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, TUF. I due testi si sono spartiti la materia anche riscrivendosi a vicenda: l'art. 160 TUB, che confermava le disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari, è stato abrogato dall'art. 211, comma 4, TUF. Sul piano delle autorità, la CONSOB è definita dall'art. 1 (comma 1, lett. d) ma non è autorità creditizia: le autorità creditizie sono soltanto il CICR, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia (art. 1, comma 1, lett. a).

2 | Il Testo Unico Bancario (TUB): struttura, idee di fondo e definizioni dell'Articolo 1

Fonte: LEGB1_Appunti_02_TUB-Struttura-e-Definizioni.pdf — *5 pagine*

2.1. Struttura del TUB

Il Testo Unico Bancario (TUB) è strutturato nel seguente modo:

- **Articolo 1** definitorio
- **Titolo I**: Autorità creditizie
- **Titolo II**: Banche
  - Capo I: Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
  - Capo II: Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
  - Capo III: Partecipazioni nelle banche
  - Capo IV: Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali
  - Capo V: Banche cooperative
- **Titolo III**: Vigilanza
- **Titolo IV**: Disciplina delle crisi
- **Titolo V**: Soggetti operanti nel settore finanziario
- **Titolo V-bis**: Moneta elettronica e istituti di moneta elettronica
- **Titolo V-ter**: Istituti di pagamento
- **Titolo VI**: Trasparenza
- **Titolo VI-bis**: Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
- **Titolo VII**: Altri controlli
- **Titolo VIII**: Sanzioni
- **Titolo IX**: Disposizioni finali

  Nota (aggiornamento): il Titolo IV, qui indicato come "Disciplina delle crisi" (dizione sintetica/storica), nel TUB vigente è rubricato "Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa", a seguito del recepimento della BRRD. Inoltre, nel TUB vigente il Titolo II comprende, oltre ai Capi I–V qui elencati, anche il Capo VI (norme relative a particolari operazioni di credito, artt. 38–48-bis) e il Capo VII (assegni circolari, artt. 49–50), qui omessi.

Il Titolo I (artt. 2-9) riguarda le autorità creditizie e non i soggetti vigilati; il Titolo II si apre con la nozione di attività bancaria (Capo I, artt. 10-12-ter); il Titolo III disciplina la vigilanza sulle banche (Capo I, artt. 51-58, con la vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva agli artt. 51, 53 e 54) e la vigilanza su base consolidata (Capo II, a partire dall'art. 59), con la disciplina del gruppo bancario nella Sezione I (art. 60 e seguenti). Il Titolo V comprende, nel Capo I, la concessione di finanziamenti, incentrata sull'albo degli intermediari finanziari dell'art. 106, e, nel Capo II, l'acquisto e la gestione di crediti in sofferenza (artt. 114.1-114.14). I Titoli V-bis e V-ter riguardano la moneta elettronica e gli istituti di pagamento; il Titolo VI-bis, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Il Titolo VII, «Altri controlli», contiene il solo art. 129, in forza del quale la Banca d'Italia può richiedere segnalazioni periodiche, dati e informazioni a chi emette od offre strumenti finanziari, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. Il Titolo VIII raccoglie le sanzioni, con l'abusivismo bancario e finanziario e l'abuso di denominazione agli artt. 130-133 (Capo I), e il Titolo IX, rubricato «Disposizioni transitorie e finali», chiude il Testo unico. *(pagina 1)*

2.2. Idee di fondo del TUB: scelte e linee guida adottate

Prima di analizzare gli articoli del TUB conviene capire in che cosa le idee espresse dal TUB stesso differiscono dai principi alla base della precedente legge bancaria. Gli aspetti principali sono cinque.

1. Riconoscimento e valorizzazione del carattere imprenditoriale dell'attività bancaria (e autonomia dell'imprenditore bancario)

L'attività bancaria è un'attività di impresa, pertanto la banca è un'impresa. Poiché l'attività bancaria tocca rilevanti interessi pubblici, in passato molti ne mettevano in discussione il carattere imprenditoriale, ritenendola un servizio pubblico. L'art. 10, comma 1, afferma il carattere d'impresa qualificando l'attività e non il soggetto: la qualificazione non dipende quindi dalla natura pubblica o privata della banca.

2. Valorizzazione della concorrenza tra banche

In quanto imprese, le banche sono inserite in un contesto imprenditoriale. La passata legge bancaria era invece incentrata sulla stabilità e limitava la concorrenza tra banche. La concorrenza tra banche è finalizzata al raggiungimento dell'efficienza. Lo conferma l'art. 5, comma 1, secondo cui le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza avendo riguardo, oltre che alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario.

3. Despecializzazione

Anche la despecializzazione distingue il TUB dalla passata legge bancaria. Si può considerare sotto tre profili:

- *(De)Specializzazione istituzionale*: nella scorsa legge bancaria (ex art. 5) esistevano tanti tipi di banche ed ognuna aveva le proprie regole. Il TUB ha introdotto ed affermato

il principio opposto: la despecializzazione istituzionale. Attualmente le banche possono operare soltanto se la forma societaria scelta è quella di Società per Azioni (SpA) o di Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata (SCARL; in questo caso o sono Banche Popolari o Banche di Credito Cooperativo).

- *(De)Specializzazione temporale*: le banche, nello svolgimento delle loro normali attività, affrontano un rischio di mismatching delle scadenze. Per poter monitorare/affrontare questo rischio la passata legge prevedeva tipi di banche diverse in base all'orizzonte temporale in cui operavano. Esistevano le **aziende di credito**, banche autorizzate ad operare nel breve termine (fino a 18 mesi), e gli **istituti di credito** (o di credito speciale), che operavano nel medio-lungo termine (oltre 18 mesi). Il TUB ha previsto anche la despecializzazione temporale: nel testo si parla solo di banche, che possono operare quindi sia nel breve che nel medio o lungo termine. I rischi di liquidità si affrontano attraverso norme apposite, tecniche di vigilanza e modelli di analisi moderni.
- *(De)Specializzazione operativa*: le varie categorie di banche si differenziavano anche perché, almeno con riferimento ad alcune operazioni, ciascuna di esse poteva offrire alla clientela alcuni servizi bancari ma non altri (ad esempio solo alcune banche potevano concedere credito cinematografico, poche altre quello sportivo, poche altre ancora il credito alle opere pubbliche, ecc.). Nella passata legge bancaria quindi il sistema era frammentato ex lege. Anche questa forma di specializzazione è venuta meno col TUB: adesso tutte le banche possono svolgere tutte le attività.

Il risultato d'insieme è la banca universale, il cui oggetto sociale è quello ampio dell'art. 10, comma 3: attività bancaria, ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna, attività connesse o strumentali, salve le riserve di attività previste dalla legge. Un esempio è il credito fondiario, che l'art. 38, comma 1, definisce come la concessione «da parte di banche» di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili: non è un'attività riservata a istituti speciali, ma un'operazione tipizzata che può essere svolta da qualunque banca. Lo stesso vale per altre «particolari operazioni di credito» del Capo VI (artt. 38-48-bis): l'art. 47, comma 1, ad esempio, consente a tutte le banche di erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle leggi di agevolazione, alle condizioni ivi indicate. Restano le banche in forma cooperativa, disciplinate dal Capo V.

4. Vigilanza

Anche la vigilanza è cambiata nel tempo. La passata legge bancaria era improntata alla stabilità e rispondeva ad un modello di **vigilanza strutturale**: alle autorità di settore erano assegnati molti poteri, che consentivano loro di incidere sulla struttura del mercato del credito. Questo era permesso anche dall'elasticità della passata legge bancaria, che conferiva una notevole discrezionalità nell'esercizio dei poteri di vigilanza alle autorità creditizie. Ad esempio, Banca d'Italia aveva ampia discrezionalità nel concedere nuove autorizzazioni, nel permettere di aprire nuovi sportelli, nel gestire le crisi, ecc.

La vigilanza strutturale è incompatibile però con l'idea della banca come impresa. Si è passati infatti ad un modello di **vigilanza prudenziale**, nel quale le autorità di settore predeterminano

alcune regole tecniche (considerate proprie del "bravo banchiere"), ma rispettate queste regole, considerate minime, le banche operano liberamente.

Un esempio del cambio di modello è la libertà di articolazione territoriale. Oggi l'art. 15, comma 01, consente alle banche italiane di stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari «in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU» (il Meccanismo di vigilanza unica), e il comma 1 prevede che la Banca d'Italia possa vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo, per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto. La vigilanza strutturale non è però scomparsa del tutto: sopravvivono residui a carattere autorizzatorio, come l'autorizzazione all'attività bancaria (art. 14), quella all'acquisto di partecipazioni (art. 19) e quella all'emissione di assegni circolari (art. 49). Le autorizzazioni degli artt. 14 e 19 sono subordinate all'accertamento di presupposti indicati dalla legge, e non a valutazioni di programmazione del mercato.

5. Delegificazione

Il legislatore sa di non poter seguire da vicino l'evolversi della materia e preferisce, ove necessario, ricorrere alla delegificazione, cioè delegare alle fonti secondarie i suoi poteri.

Il riparto dei poteri delegati è tripartito e sta nel Titolo I. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal TUB o da altre leggi (art. 2, comma 1); il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza, con facoltà di sottoporli preventivamente al CICR, e in caso di urgenza sostituisce il CICR (art. 3); la Banca d'Italia formula le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza (art. 4, comma 1). Alcuni esempi: al CICR l'art. 11, comma 3, affida i limiti e i criteri in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro, e il comma 4-quater i criteri e i limiti, anche in deroga al codice civile, per la raccolta dei soggetti che concedono finanziamenti al pubblico. Al Ministro l'art. 106, comma 3, attribuisce il compito di specificare, sentita la Banca d'Italia, il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti e le circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico. Alla Banca d'Italia l'art. 14, comma 4-bis, affida le disposizioni attuative dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'art. 17 la disciplina delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento, l'art. 19, comma 9, i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole, l'art. 12, commi 5, 6 e 7, la disciplina delle emissioni di obbligazioni, titoli di deposito e prestiti subordinati, l'art. 129, comma 2, le disposizioni attuative sulle segnalazioni relative agli strumenti finanziari emessi od offerti.

Oltre alla mobilità della materia, motivi della delega sono la competenza tecnica della Banca d'Italia, che esercita già la vigilanza, e l'origine europea di molta disciplina. Il TUB pone però due vincoli: l'art. 5 fissa le finalità dei poteri di vigilanza e l'art. 4, comma 2, impone alla

Banca d'Italia di determinare e rendere pubblici previamente i princìpi e i criteri dell'attività di vigilanza. *(pagina 1–3)*

2.3. Articolo 1: definizioni generali del TUB

L'articolo 1 del TUB è molto lungo e "definitorio": contiene una lunga serie di nozioni che servono a comprendere gli articoli successivi. Nel TUB un articolo definitorio è un'innovazione della tecnica legislativa, perché gli articoli definitori sono tipici dei sistemi di *common law*. In Italia, in precedenza, le norme di legge non avevano articoli di questo genere, ma essi sono molto comodi perché evitano fraintendimenti sui termini usati.

Comma 1, lettera a — "autorità creditizie": indica il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Banca d'Italia (BI)[1].

D'ora in poi si usano le abbreviazioni CICR, MEF e BI. Non sono annoverate le autorità europee o altre autorità che hanno comunque poteri nei confronti delle banche, perché non sono autorità creditizie ma di vigilanza.

L'elenco è tassativo: la BCE, definita a parte (comma 1, lettera b-bis), non è un'autorità creditizia, eppure rilascia l'autorizzazione all'attività bancaria, su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 2), e ne dispone la revoca (art. 14, comma 3-bis). Il legislatore non ha riscritto la lettera a) e ha inserito definizioni autonome per le autorità europee, regolando i rapporti con esse nell'art. 6 (rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU) e nell'art. 6-bis, secondo cui nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite da queste. Anche la CONSOB, definita al comma 1, lettera d), non figura fra le autorità creditizie.

Comma 1, lettera b — "banca": indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria.

Dalla lettera b si evince che:

- la banca è **un'impresa** (e non un servizio pubblico): ulteriore valorizzazione della natura imprenditoriale;
- la banca è un'impresa **autorizzata**: non è possibile svolgere liberamente l'attività bancaria; in mancanza dell'autorizzazione non si può parlare di banca. L'autorizzazione all'attività bancaria ha efficacia costitutiva;
- la banca **non ha un oggetto sociale libero**: la banca svolge infatti attività bancaria e non è banca se non la svolge. Il TUB pone l'accento sull'attività bancaria e non sulle banche in quanto tali.

La definizione è data per relationem: il TUB non dice che cosa sia una banca per poi elencarne le operazioni, ma descrive un'attività (art. 10, comma 1) e qualifica banca l'impresa autorizzata

[1] Un tempo era il Ministro del Tesoro e non quello dell'Economia.

a svolgerla. Non vi è circolarità, perché la fattispecie oggettiva dell'art. 10 è autonoma e serve, fra l'altro, a individuare chi opera abusivamente (art. 131). L'efficacia costitutiva dell'autorizzazione è rafforzata sul piano procedurale: non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione (art. 14, comma 3). L'attività bancaria non può mancare: l'art. 14, comma 3-bis, lettera c), prevede la revoca dell'autorizzazione quando sia accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi.

Comma 1, altre lettere

Il comma 1 è cresciuto per stratificazioni successive e oggi contiene un ampio apparato definitorio, frutto dell'europeizzazione della materia. Accanto alle tre autorità creditizie si trovano, per esempio, l'«autorità di risoluzione» (lettera a-bis), la «BCE» (lettera b-bis), la CONSOB (lettera d), la COVIP (lettera d-bis), l'IVASS (lettera e), il Meccanismo di vigilanza unica e le relative «disposizioni» (lettere e-bis ed e-ter), l'UIF (lettera e-quater), il Meccanismo di risoluzione unico (lettera e-quinquies), lo «Stato dell'Unione europea» (lettera g), lo «Stato di origine» e lo «Stato ospitante» (lettere g-bis e g-ter), lo «Stato terzo» (lettera h), il SEVIF con le autorità europee che lo compongono (lettera h-bis) e lo «Stato partecipante al MVU» (lettera h-ter). Le lettere f) e m) sono soppresse.

Comma 2, lettera a — "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia.

La nazionalità di una banca dipende dunque dalla sede legale.

Comma 2, lettera b — "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia[2].

Sede legale e amministrazione centrale sono richieste congiuntamente (poste insieme) per evitare varie forme di elusione, e devono trovarsi in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia. L'Italia è esclusa perché si applica il principio del mutuo riconoscimento: la nozione di banca comunitaria identifica le banche che beneficiano del mutuo riconoscimento, cioè le banche di un Paese europeo che, per operare in Italia, non hanno bisogno dell'autorizzazione di BI, perché hanno già ottenuto l'autorizzazione da parte dell'autorità del Paese d'origine.

La richiesta cumulativa di sede legale e amministrazione centrale impedisce che una banca collochi la sede legale in uno Stato dalla regolazione più flessibile e mantenga altrove il centro effettivo dell'attività, scegliendosi in sostanza l'autorità di vigilanza. Il passaporto europeo non prevede infatti un filtro autorizzativo dello Stato ospitante e presuppone regole e prassi omogenee: in loro assenza si apre il rischio di arbitraggio regolamentare e di una concorrenza fra ordinamenti al ribasso (la «competition in laxity»). Le due nozioni su cui poggia il meccanismo sono lo «Stato di origine», cioè lo Stato dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP è stato autorizzato all'esercizio dell'attività (comma 1, lettera g-bis), e lo «Stato ospitante», cioè lo Stato dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi (comma 1, lettera g-ter).

[2]Si parla di "comunitario" perché il TUB è del 1993, ma attualmente non c'è più la Comunità Europea, bensì l'Unione Europea.

Quanto al lessico, il testo vigente dell'art. 1 parla di «banca dell'Unione europea» (comma 2, lettera b) e di «Stato dell'Unione europea» (comma 1, lettera g), espressioni adottate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182, ma il TUB non è uniforme: gli artt. 11 (comma 4, lettera a), 13, 15, 16, 17, 18 (comma 2), 114-bis (comma 2) e 114-sexies conservano ancora le vecchie espressioni («banche comunitarie», «Stati comunitari»), e gli artt. 13, 15 (comma 4) e 16 (comma 4) usano anche «banche extracomunitarie».

Comma 2, lettera c — "banca extracomunitaria"[3]: la banca avente sede legale in uno Stato terzo.

Per queste banche non opera il mutuo riconoscimento: lo stabilimento in Italia della prima succursale è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle dell'art. 14, comma 1, lettere b), c) ed e), e tenendo conto della condizione di reciprocità (art. 14, comma 4). Anche le succursali successive richiedono l'autorizzazione della Banca d'Italia (art. 15, comma 4), così come l'operatività in Italia senza succursale, rilasciata anch'essa tenendo conto della reciprocità (art. 16, comma 4).

La nozione di **banca autorizzata** include sia le banche italiane sia le banche extracomunitarie, perché entrambe necessitano dell'autorizzazione di Banca d'Italia.

La definizione di «banca autorizzata» non figura più nel testo vigente: il comma 2, lettera d), definisce oggi il «soggetto significativo» (i soggetti definiti dall'art. 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU) e la lettera d-bis) il «soggetto meno significativo» (i soggetti sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU diversi dai precedenti). È la distinzione su cui il MVU articola la cooperazione fra la BCE e le autorità nazionali (art. 6-bis, comma 1), e il TUB la usa, per esempio, nell'art. 15, comma 1, dove il potere di vietare lo stabilimento di una nuova succursale è riferito al soggetto italiano meno significativo. L'espressione «banche autorizzate in Italia» compare ancora nell'art. 78.

Comma 2, lettera e — "succursali"

Nel linguaggio comune si usano termini come *filiali* o *sportelli*, ma il termine più corretto è **succursali**: parti di una banca sprovviste di personalità giuridica autonoma.

Il testo della lettera e) è più ampio: la succursale è «una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato». Gli elementi sono due: l'assenza di personalità giuridica, per cui la succursale non è un soggetto distinto ma un'articolazione della stessa impresa, e lo svolgimento diretto, in tutto o in parte, dell'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato. Il regime dello stabilimento è all'art. 15: le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della

[3]Come per "comunitaria", il termine riflette la formulazione del 1993: il TUB vigente usa l'espressione "banca di Stato terzo".

Repubblica e degli altri Stati comunitari secondo le procedure del MVU (comma 01), mentre per le succursali in uno Stato terzo occorre l'autorizzazione della Banca d'Italia (comma 2).

Comma 2, lettera f — "attività ammesse al mutuo riconoscimento"

Esistono attività per le quali si ha mutuo riconoscimento (e quindi è sufficiente l'autorizzazione ottenuta nel paese di origine, come nel caso delle banche comunitarie) e attività non ammesse al mutuo riconoscimento. Per queste ultime è espressamente prevista la necessità di un'autorizzazione da parte di BI. L'art. 17 attribuisce alla Banca d'Italia il compito di disciplinare l'esercizio di tali attività in Italia da parte delle banche comunitarie.

L'elenco ha derivazione europea: la voce 15 lo collega a quello allegato alla seconda direttiva in materia creditizia, n. 89/646/CEE (direttiva poi abrogata). Comprende quindici voci, raggruppate qui per materia:

- **attività bancarie in senso stretto**: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito, comprendenti in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo e il credito commerciale incluso il «forfaiting»;
- **finanziamento e pagamenti**: 3) leasing finanziario; 4) prestazione di servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui non rientra nel punto 4; 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- **mercati e finanza d'impresa**: 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazione di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
- **gestione e servizi**: 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza;
- **clausola di apertura**: 15) le altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco.

L'elenco non coincide con le attività bancarie, che restano quelle dell'art. 10, comma 1, né con l'oggetto sociale possibile di una banca italiana, che l'art. 10, comma 3, estende ad ogni altra attività finanziaria e alle attività connesse o strumentali: serve a delimitare il passaporto europeo. Poiché il TUB non definisce l'attività finanziaria, può essere usato anche come catalogo indicativo delle attività finanziarie tipiche.

Il mutuo riconoscimento riguarda le attività e non i soggetti: ciò che viene riconosciuto è l'autorizzazione dello Stato di origine, e soltanto per le attività dell'elenco. Per queste la banca dell'Unione europea può operare in Italia stabilendo una succursale (art. 15, commi 01 e 3) oppure in libera prestazione di servizi, senza stabilimento, dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità dello Stato di appartenenza (art. 16, comma 3): nessuna delle due

strade richiede una nuova autorizzazione della Banca d'Italia. Il passaporto elimina però il filtro autorizzativo dello Stato ospitante, non ogni suo controllo. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, quando il controllo spetta all'autorità dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a questa e, in attesa dei suoi provvedimenti, può adottare per ragioni di urgenza le misure provvisorie necessarie a tutela dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi (art. 79, comma 1); quando il controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta essa stessa le misure necessarie a prevenire o reprimere le irregolarità (art. 79, comma 4). L'art. 18 estende infine il regime alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a vigilanza prudenziale, la cui partecipazione di controllo sia detenuta da una o più banche italiane e che rispettino le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia (comma 1), e a quelle degli altri Stati comunitari controllate da banche del medesimo Stato (comma 2).

Comma 2, lettere g), h), h-bis), h-sexies) e seguenti — gli altri soggetti e le altre nozioni

Accanto alla banca l'art. 1 definisce gli altri soggetti dell'ordinamento creditizio, quasi sempre per differenza rispetto ad essa. Gli «intermediari finanziari» (lettera g) sono i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106; gli «istituti di moneta elettronica» (lettera h-bis) sono «le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica»; gli «istituti di pagamento» (lettera h-sexies) sono «le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento». La «moneta elettronica» (lettera h-ter) è il valore monetario memorizzato elettronicamente, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, emesso per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente; non lo sono il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, né quello utilizzato per le operazioni di pagamento previste dalla lettera n) dello stesso comma. I «servizi di pagamento» (lettera h-septies.1) comprendono i depositi e i prelievi di contante su un conto di pagamento e le relative operazioni di gestione, l'esecuzione di operazioni di pagamento (addebiti diretti, carte, bonifici) anche quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata, l'emissione di strumenti di pagamento e il convenzionamento di operazioni di pagamento, la rimessa di denaro, i servizi di disposizione di ordini di pagamento e i servizi di informazione sui conti. Per le somme che ricevono a questo titolo gli IMEL e gli istituti di pagamento non fanno raccolta del risparmio tra il pubblico, come stabilisce l'art. 11, che ai commi 2-bis e 2-ter esclude da tale nozione la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica e quella di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.

Gli «stretti legami» (lettera h) sono i rapporti fra una banca e un soggetto, italiano o estero, che la controlla, ne è controllato, è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca, partecipa al suo capitale in misura pari ad almeno il 20% del capitale con diritto di voto o è partecipato dalla banca nella stessa misura. La nozione serve all'autorizzazione all'attività bancaria, che richiede che non sussistano, fra la banca o i soggetti del suo gruppo e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 14, comma 1,

lettera f). I legami non sono vietati in sé, ma solo se ostacolano la vigilanza. Il comma 3 dell'art. 1 consente alla Banca d'Italia di qualificare ulteriormente la definizione per evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Le «partecipazioni» (lettera h-quater) sono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, c.c. L'art. 1 non definisce invece le «partecipazioni rilevanti»: la lettera h-quinquies), che le definiva, è stata soppressa dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, e l'espressione «partecipazione qualificata» non compare affatto nel testo del TUB, che parla di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole o che attribuiscono quote almeno pari alle soglie dell'art. 19 (10, 20, 30 e 50 per cento). La partecipazione qualificata è una nozione di derivazione europea (art. 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013).

2.4. Le riserve di attività: l'impianto generale

L'attività bancaria è attività d'impresa, ma è impresa riservata, e la riserva trova il proprio fondamento negli interessi pubblici che l'art. 47 Cost. affida alla Repubblica, cioè la tutela del risparmio e il controllo dell'esercizio del credito. Molte norme sulle attività e sui soggetti definiscono il perimetro di quella riserva, la cui violazione è sanzionata nel Titolo VIII.

Una riserva scomposta. La riserva copre il binomio raccolta-credito e anche i suoi segmenti, perché presidiare solo il binomio consentirebbe di eluderla scomponendo l'attività. Le riserve rilevanti sono:

- l'**attività bancaria** nel suo complesso, riservata alle banche (art. 10, comma 2);
- la sola **raccolta del risparmio tra il pubblico**, vietata ai soggetti diversi dalle banche (art. 11, comma 2);
- la sola **concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico**, riservata agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106, comma 1);
- l'**emissione di moneta elettronica**, riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica (art. 114-bis, comma 1);
- la **prestazione di servizi di pagamento**, riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento (art. 114-sexies);
- la **gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti**, riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo dell'art. 106, ai gestori autorizzati ai sensi dell'art. 114.6 e ai gestori di crediti dell'Unione europea operanti in Italia (art. 114.3, comma 1).

Il TUB non prevede una figura soggettiva «FinTech»: chi offre al pubblico, ad esempio, depositi, piccoli finanziamenti e pagamenti rientra in una delle categorie esistenti (banca, intermediario finanziario, istituto di moneta elettronica, istituto di pagamento) o resta fuori dal perimetro riservato. Il servizio va quindi scomposto nelle attività riservate che lo compongono, individuando per ciascuna la norma di riserva e i soggetti legittimati. La qualificazione dipende dalla sostanza dell'operazione e non dal nome: la raccolta del risparmio è l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso «sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma» (art. 11, comma 1). Vanno poi

considerate le esclusioni (art. 11, commi 2-bis e 2-ter) e le deroghe al divieto (art. 11, comma 4); nei casi del comma 4, lettere c) e d), restano comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (art. 11, comma 5).

Il piano soggettivo. Solo chi è autorizzato può esercitare l'attività, e l'autorizzazione dell'art. 14 ha efficacia costitutiva della qualità di banca. Alla Banca d'Italia spetta poi iscrivere la banca in un apposito albo, fermo quanto previsto dalle disposizioni del MVU sulla pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, e le banche devono indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo (art. 13): l'iscrizione non è costitutiva, perché la qualità di banca deriva dall'autorizzazione (art. 1, comma 1, lettera b), ma rende conoscibile ai terzi chi è legittimato a operare. Ogni riserva ha il proprio elenco dei legittimati. La Banca d'Italia tiene, oltre all'albo delle banche, l'albo dei gruppi bancari (art. 64), quello degli intermediari finanziari (art. 106, comma 1), quello degli istituti di moneta elettronica (art. 114-quater, comma 1), quello degli istituti di pagamento (art. 114-septies) e quello dei gestori di crediti in sofferenza (art. 114.5), oltre all'elenco dei soggetti del microcredito (artt. 111 e 113). Altri elenchi sono tenuti da organismi di natura privatistica: quello dei confidi dall'Organismo dell'art. 112-bis, quelli degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi dall'Organismo dell'art. 128-undecies.

La violazione della riserva. La violazione delle riserve di attività è punita come reato nel Titolo VIII, Capo I, in modo speculare alla scomposizione del binomio:

- art. 130, raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11: arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da euro 12.911 a euro 51.645 (contravvenzione);
- art. 131, abusiva attività bancaria, cioè raccolta in violazione dell'art. 11 e insieme esercizio del credito: reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.065 a euro 10.329 (delitto);
- art. 131-bis, emissione di moneta elettronica in violazione della riserva dell'art. 114-bis, senza essere iscritti nell'albo previsto dall'art. 13 o in quello previsto dall'art. 114-bis, comma 2: reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.066 a euro 10.329;
- art. 131-ter, prestazione di servizi di pagamento in violazione della riserva dell'art. 114-sexies, senza essere autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies: reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.066 a euro 10.329;
- art. 132, abusiva attività finanziaria, cioè lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attività dell'art. 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione dell'art. 107 o dell'iscrizione degli artt. 111 o 112: reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.065 a euro 10.329.

Gli importi sono quelli riportati nel testo del TUB; la nota al Titolo VIII richiama l'art. 39, comma 1, della l. 28 dicembre 2005, n. 262, che ha raddoppiato le pene previste dal TUB entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. La differenza fra gli artt. 130 e 131 è la traduzione penalistica del binomio: chi raccoglie senza erogare non è banca abusiva ai sensi dell'art. 131 e risponde della sola contravvenzione dell'art. 130, mentre chi concede finanziamenti al pubblico con fondi propri, senza raccogliere risparmio, viola l'art. 106 e, in assenza dell'autorizzazione dell'art. 107 o dell'iscrizione degli artt. 111 o 112, risponde

dell'art. 132. L'art. 132-bis prevede inoltre che, se vi è fondato sospetto che una società svolga raccolta del risparmio, attività bancaria, emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli artt. 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia (o l'UIC, come ancora indicato nel testo) possa denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dei provvedimenti dell'art. 2409 c.c., oppure richiederli direttamente al tribunale; le spese per l'ispezione sono a carico della società.

La riserva di denominazione. L'art. 133, comma 1, vieta ai soggetti diversi dalle banche l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria. I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater estendono il divieto all'espressione «moneta elettronica» (consentita agli IMEL e alle banche), a «istituto di pagamento» (consentita agli istituti di pagamento) e alla parola «finanziaria» (consentita agli intermediari finanziari dell'art. 106), mentre il comma 2 permette alla Banca d'Italia di determinare in via generale i casi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole protette possano essere usate da altri soggetti. La sanzione non è penale ma amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 5 milioni di euro, e per le società e gli enti da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato; le stesse sanzioni colpiscono chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività dell'art. 111 (comma 3). La riserva di denominazione è autonoma rispetto alle riserve di attività: una stessa condotta può violarle entrambe, ma si può violare l'una senza l'altra.

(pagina 4–5)

3 | Titolo I: Autorità Creditizie (artt. 1-9 TUB)

Fonte: LEGB1_Appunti_03_Titolo-I-Autorita-Creditizie.pdf — *12 pagine*

3.1. Le autorità creditizie e i modelli di vigilanza

Ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. a, le **autorità creditizie** sono tre: **CICR**, **MEF** e **BI** (Banca d'Italia); sono i soggetti vigilanti.

Questa scelta, nella precedente legge bancaria, corrispondeva all'attuazione di un **modello di vigilanza per soggetti**: le banche (comparto bancario) erano vigilate dalle autorità creditizie, gli agenti di cambio (comparto finanziario) erano vigilati dall'autorità del settore finanziario (CONSOB), le imprese di assicurazione (comparto assicurativo) erano vigilate da una loro autorità (IVASS, ex ISVAP). A ciascuna categoria di soggetti corrispondeva la sua (o le sue) autorità di vigilanza. Questo modello era appropriato poiché le banche non potevano svolgere altre attività.

Col tempo questo sistema è stato messo sempre più in crisi. Nel 1991 erano state istituite le SIM; la vecchia legge bancaria (poi abrogata) prevedeva al comma 1 che la vigilanza sulle SIM fosse affidata alla CONSOB. Nel comma 2 specificava però che, siccome i servizi di investimento possono essere prestati anche da una banca, in quel caso la vigilanza è affidata a BI. Nel comma 3 si definiva che la stabilità fosse un compito affidato a BI, la tutela della clientela alla CONSOB. Nel comma 4 si prevedeva che BI e CONSOB potessero firmare protocolli per accordarsi fra loro nell'esercizio delle loro funzioni. Ne risultava un assetto scarsamente organizzato.

Si è pensato nel tempo di ridurre il numero delle autorità, ma è stato soppresso solo l'**UIC** (Ufficio Italiano Cambi), le cui funzioni sono state inglobate da BI. Attualmente, in Italia vige un modello di vigilanza che potremmo definire **misto**, in quanto presenta elementi di entrambi i modelli di vigilanza. Se si sceglie di avere più autorità occorre che queste si coordino e collaborino tra loro.

Il modello contrapposto al modello per soggetti è il **modello di vigilanza per funzioni**: a ciascuna funzione corrisponde un'autorità di vigilanza, a prescindere dal soggetto che svolge tale attività.

Si affianca poi il **modello per finalità**, in cui a ciascuna autorità è assegnato un obiettivo e non una categoria di soggetti o di attività: la stabilità a una, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti a un'altra, la concorrenza a una terza. Ogni intermediario risulta allora vigilato da più autorità, ciascuna per il proprio fine. Ne è un esempio il TUF, che sui medesimi

intermediari affida alla Banca d'Italia il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione e alla CONSOB la trasparenza e la correttezza dei comportamenti (art. 5 TUF); l'art. 7, comma 5, TUB ne registra la conseguenza organizzativa, cioè l'obbligo di collaborare. Il modello per finalità regge alla despecializzazione, perché l'autorità segue l'obiettivo e non il soggetto, ma moltiplica gli interlocutori del singolo intermediario e impone costi di coordinamento, che gli artt. 20 e 21 della legge 262/2005 cercano di contenere. Con il MVU si aggiunge un ulteriore asse di riparto, dimensionale, fra soggetti significativi e meno significativi (v. art. 6-bis).

Confronto internazionale: in Francia e Germania è stato adottato un modello di vigilanza per soggetti. La Gran Bretagna aveva adottato un sistema di vigilanza per soggetti fino agli anni '90; a seguito della crisi di una grande banca venne istituita un'unica grande autorità a cui venne affidata la vigilanza su tutti i comparti (pensando fosse quella la soluzione a tutti i mali), ma dopo numerose crisi si è tornati ad avere più soggetti distinti che esercitassero le funzioni di vigilanza.

L'elenco dell'art. 1, comma 1, lett. a, è **tassativo e nazionale**. L'art. 1 definisce molte altre autorità: la BCE (lett. b-bis), la CONSOB (lett. d), la COVIP (lett. d-bis), l'IVASS (lett. e), la UIF (lett. e-quater), l'autorità di risoluzione (lett. a-bis), il MVU, il MRU e il SEVIF (lett. e-bis, e-quinquies, h-bis), le «autorità competenti» (lett. l, definite in modo relazionale: «a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari»). Nessuna di queste è un'autorità creditizia: sono definizioni funzionali agli articoli successivi, e nel Titolo I CONSOB, COVIP e IVASS ricompaiono soltanto come controparti della collaborazione dell'art. 7, comma 5. «Autorità creditizia» è quindi un'etichetta tecnica interna al decreto, che non coincide con «autorità che ha poteri sulle banche»: queste sono molte di più, BCE compresa.

La tripartizione CICR-MEF-BI è un'eredità della legge bancaria precedente (un organo politico di indirizzo, un vertice ministeriale, un organo tecnico): il TUB ne ha conservato l'architettura, ma ha svuotato progressivamente i due poli politici concentrando la sostanza dei poteri su BI, in coerenza con l'esigenza europea di un'autorità di vigilanza indipendente dal Governo.

(pagina 1)

3.2. Art. 2 TUB — Il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio)

Nonostante sia ancora formalmente un'autorità creditizia a tutti gli effetti, sul piano sostanziale il CICR gode di pochissimi poteri. Ha perso sempre più importanza, sia per le mancate convocazioni in situazioni di crisi sia con l'Unione Bancaria.

Comma 1: *Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro*

dell'economia e delle finanze, che lo presiede (…). Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.

Inizialmente BI sottostava alle linee guida (principi di carattere generale) del CICR, che aveva un indirizzo politico; ciò era coerente con la precedente legge bancaria e il modello di vigilanza strutturale. Attualmente questa autorità rischia invece di essere "incompatibile" con il nuovo sistema di vigilanza prudenziale, ed è per questo che i suoi poteri sono stati ridimensionati. Non si sa perché sia stato inserito il termine "alta vigilanza": non esiste in parallelo una "bassa vigilanza"; è un termine ripreso pari passo dalla vecchia legge bancaria.

Il **Ministro dell'economia e delle finanze** ha due ruoli distinti: è lui stesso un'autorità creditizia ed è presidente del CICR. Fanno parte del CICR anche altri ministri individuati sempre dall'articolo 2, come il Ministro dello Sviluppo Economico ecc. Il **Governatore della BI non fa parte del CICR** (essendo un comitato interministeriale) e non gode del diritto di voto.

Secondo il testo dell'art. 2, comma 1, oltre al MEF che lo presiede il CICR è composto dai Ministri del commercio internazionale, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, delle infrastrutture, dei trasporti e per le politiche comunitarie (elenco modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303); alcune denominazioni ministeriali sono nel frattempo cambiate. Il Governatore partecipa alle sedute ma non è tra i componenti elencati. Il CICR non è un organo a competenza generale: delibera «nelle materie attribuite alla sua competenza» dal TUB o da altre leggi, quindi soltanto dove una norma lo prevede espressamente.

Comma 2: *Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi.*

Un tempo i ministri invitati godevano del diritto di voto, e ciò permetteva al Ministro dell'economia di costruire le maggioranze a piacere. Attualmente i ministri invitati alle singole riunioni non possono votare, perché la partecipazione è specificata solo per fini consultivi. Un'ulteriore novità è la possibilità che il MEF inviti presidenti di altre autorità (oltre al Governatore di Banca d'Italia, che partecipa sempre) laddove necessario in base all'argomento trattato (anche queste eventuali autorità invitate sono prive di diritto di voto). L'invito ai presidenti delle altre autorità vale per le singole riunioni in cui vengono trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.

Comma 3: *Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.*

Sono previsti due quorum distinti, come per qualsiasi organo collegiale: un quorum costitutivo (la maggioranza dei membri) e un quorum deliberativo (la maggioranza dei presenti).

Comma 4: *Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.*

Il CICR è libero di organizzarsi come preferisce, ma non ha personale proprio (essendo un comitato di ministri) e si avvale della Banca d'Italia. Attualmente il CICR si riunisce solo per assumere deliberazioni imposte dalla legge; BI a sua volta delibera ciò che è stato deliberato a monte dal CICR: si tratta sostanzialmente di un duplicato inutile.

Le competenze residue del CICR si concentrano soprattutto in due ambiti. Il primo è la raccolta del risparmio (art. 11): il CICR stabilisce limiti e criteri per individuare i casi in cui la raccolta presso specifiche categorie, individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro, non costituisce raccolta tra il pubblico (comma 3); determina i criteri per individuare gli strumenti finanziari la cui emissione costituisce raccolta del risparmio (comma 4-bis); se la materia non è disciplinata dalla legge, fissa limiti all'emissione e, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti diversi dalle obbligazioni (comma 4-ter); a tutela della riserva di attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga al codice civile, per la raccolta di chi esercita nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti (comma 4-quater). Il secondo è il Titolo VI sulla trasparenza, dove ricorre il rinvio alle deliberazioni del CICR (ad esempio per le modalità di calcolo del TAEG, art. 121, comma 3, o per gli annunci pubblicitari, art. 123, comma 2) e dove l'art. 127, comma 3, precisa che le deliberazioni del CICR previste nel titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Altre competenze minori sono sparse nel testo (ad esempio in materia di credito fondiario, art. 38, comma 2).

La regolazione prudenziale non spetta al CICR: l'art. 53, comma 1, dispone che «la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale» su adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, partecipazioni detenibili, governo societario e informativa al pubblico, senza rinvio alle deliberazioni del CICR. *(pagina 1–2)*

3.3. Art. 3 TUB — Il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF)

Si parla del **Ministro**, non del Ministero. Rispetto alla passata legge bancaria anche questa autorità creditizia ha perso molti poteri, in linea con l'idea di volere autorità indipendenti e non "di parte". Con decreto ministeriale determina i requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza degli esponenti bancari. Non dispone più il provvedimento di amministrazione straordinaria (oggi disposta dalla Banca d'Italia, art. 70 TUB), né la risoluzione, affidata al SRM (Single Resolution Mechanism); la liquidazione coatta amministrativa resta invece disposta con suo decreto, su proposta della Banca d'Italia (art. 80 TUB).

Comma 1: *Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.*

I poteri del MEF sono stati pesantemente ridimensionati: può determinare i requisiti dei soci rilevanti e degli esponenti aziendali. Viene inoltre specificato che ha **facoltà** e non obbligo di sottoporre i provvedimenti al CICR.

Tra i poteri che restano al MEF vi sono il decreto, adottato sentita la Banca d'Italia, con cui individua i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei titolari delle partecipazioni (art. 25, comma 2) e i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali (art. 26, comma 3: requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, criteri di competenza e di correttezza, limiti al cumulo di incarichi, cause di sospensione dalla carica), e il decreto di liquidazione coatta amministrativa delle banche, che il MEF può disporre solo su proposta della Banca d'Italia (art. 80, comma 1), se ricorrono i presupposti dell'art. 17 del d.lgs. 180/2015 ma non quelli previsti dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto per disporre la risoluzione. Risoluzione e liquidazione coatta amministrativa sono quindi due procedure distinte, con autorità diverse: la prima spetta al Comitato di risoluzione unico o alla Banca d'Italia secondo il riparto del reg. (UE) 806/2014 (art. 1, comma 1, lett. a-bis), la seconda a un decreto del MEF.

Comma 2: *In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.*

Questo comma prevede un caso eccezionale di urgenza. Il CICR gode di poteri deliberativi di carattere generale, ma nel caso in cui vi sia una situazione di urgenza (e non si possa aspettare una riunione del CICR) è concessa al MEF la facoltà di intervenire direttamente, sostituendosi al CICR e adottando i provvedimenti di sua competenza. In ogni caso, entro 30 giorni, deve convocare il CICR perché questo ratifichi le decisioni assunte in via d'urgenza. Ci sono stati casi in cui il MEF si è avvalso di questo potere, ad esempio fra il dicembre del '92 e il gennaio del '93.

Il potere del comma 2 è sostitutivo, non proprio: il MEF esercita la competenza del CICR e può quindi adottare in via d'urgenza solo gli atti che avrebbe potuto adottare il Comitato.

(pagina 2–3)

3.4. Art. 4 TUB — Banca d'Italia: le funzioni non di vigilanza e la funzione di tesoreria

Comma 1: *La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (…)*

Il TUB si occupa di BI solo in riferimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e non considera tutti i suoi poteri; l'unica eccezione è l'art. 146 TUB, sulla sorveglianza sui sistemi di pagamento. Fra le altre cose, infatti, BI è un istituto di emissione (inserito nel SEBC), un operatore del mercato monetario, è stato prestatore di ultima istanza (al passato, perché oggi non può più aiutare le banche in crisi), svolge funzioni valutarie ecc.

Una funzione svolta da BI "propria" del sistema italiano è la funzione di **tesoriere centrale dello Stato**. Attraverso un accordo periodicamente rinnovato, il tesoriere dello Stato è BI (lo Stato paga e incassa attraverso BI). Lo strumento tecnico attraverso cui viene svolta la funzione di tesoreria è il conto corrente: il MEF ha un conto corrente aperto presso la BI, denominato **Conto Corrente di Tesoreria** (produce dati molto affidati/attendibili).

In passato (soprattutto fra gli anni '70 e '80) succedeva di frequente che il conto corrente di tesoreria fosse in passivo per svariati miliardi di Lire, ma il Tesoro aveva tutto l'interesse a mantenere la situazione tale, perché era come se la BI stesse finanziando il debito pubblico. Per una serie di motivi (soprattutto di matrice europea) è stato disposto il **divorzio** fra BI e Ministro del Tesoro/Economia sotto un duplice punto di vista:

- il saldo del conto corrente di tesoreria deve essere sempre positivo (a zero verrà chiuso); il debito pregresso è stato assegnato a BI;
- BI determinava, nell'erogazione dei fondi come prestatore di ultima istanza, un **tasso di sconto** scelto dal Ministro del Tesoro; per garantire l'autonomia, la scelta del tasso di sconto venne spostata a BI. Attualmente comunque non esiste più il tasso di sconto ma un tasso di riferimento deciso dalla BCE.

Il divorzio ha oggi il suo presidio nel divieto europeo di finanziamento monetario, che preclude alla banca centrale scoperti di conto e ogni altra facilitazione creditizia a favore del Tesoro: la banca centrale non finanzia più il disavanzo e non riceve più dall'organo politico l'indicazione del tasso, ed è su questo che si fonda la sua indipendenza finanziaria.

La sorveglianza sul sistema dei pagamenti è disciplinata dall'**art. 146**. Il comma 1 ne fissa le finalità: regolare funzionamento, affidabilità ed efficienza del sistema e tutela degli utenti di servizi di pagamento. Il comma 2 attribuisce a BI, nei confronti di chi emette o gestisce strumenti di pagamento, presta servizi di pagamento, gestisce sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, poteri informativi (lett. a), regolamentari (lett. b), ispettivi (lett. c) e di provvedimento specifico, fino al divieto di determinate operazioni, alla restrizione delle attività e, nei casi più gravi, alla sospensione dell'attività (lett. d). Il comma 4 precisa che BI «partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento»: così la funzione nazionale si collega a quella europea. Nell'art. 146, a differenza che nell'art. 5, fra le finalità compare espressamente la tutela degli utenti. *(pagina 3–4)*

3.5. Storia, natura giuridica e organi della Banca d'Italia

BI nasce nel **1893** dalla fusione tra alcune banche (ex istituti di emissione) degli stati della penisola, unificati successivamente con l'unità d'Italia. Ha un capitale sociale proprio (un tempo di 300 milioni di Lire) pari a **7,5 miliardi di Euro**, non rappresentato da azioni ma da **quote di partecipazione** (oggi dematerializzate; le quote in questione non possono essere detenute da persone fisiche, ma da banche, compagnie di assicurazione, istituti di previdenza ecc.). Fino a pochi anni fa BI aveva una filiale in tutti i capoluoghi di provincia (con l'aumento del numero delle province si è smesso di aprirle) e sedi nei luoghi in cui vi erano gli ex istituti di emissione e in pochi altri luoghi rilevanti. Molte filiali sono poi state chiuse o specializzate (ad esempio centrale dei rischi, trattamento del contante ecc.).

Nonostante la sua struttura organizzativa e di governance richiami molto quella di una SPA, **BI è un ente pubblico a tutti gli effetti**. Confronto con gli organi di una SPA:

- **Consiglio di amministrazione** (SPA) → BI non lo ha, ma ha il **Consiglio Superiore** (non è l'omologo del CdA), che amministra BI solo per quanto riguarda i compiti organizzativi interni e non ha nessun potere in materia di vigilanza. Ogni sede della BI presente sul territorio individua il proprio consigliere superiore (di solito a livello regionale); i consiglieri superiori possono essere scelti solo tra imprenditori che godono di una certa reputazione, esponenti del mondo dell'economia o docenti universitari, tutti considerati rappresentativi della realtà economica che li ha espressi.
- **Presidente** (SPA) → BI ha un **Governatore**; un tempo aveva poteri autonomi, oggi non ne ha quasi più: li ha solo come componente del SEBC (non più in materia di vigilanza).
- **Comitato esecutivo** (SPA) → BI ha il **Direttorio**, organo che assume le decisioni in materia di vigilanza. I poteri del Direttorio sono stati riformati: in passato era un organo con funzioni meramente consultive (e non deliberative), composto da quattro membri che per prassi si riunivano tutti i giorni a fini consultivi. Attualmente i poteri di vigilanza sono attribuiti al Direttorio, composto da **cinque membri**: Governatore, Direttore Generale e tre Vicedirettori Generali.
- **Collegio Sindacale** (SPA) → BI ha anch'essa un **Collegio Sindacale**, con compiti analoghi a quelli del collegio sindacale di una SpA.
- **Assemblea dei soci** (SPA) → BI ha l'**Assemblea dei Partecipanti**, costituita da banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, fondazioni ex bancarie, istituti di previdenza, fondi pensione; ha il potere di approvare il bilancio della Banca d'Italia (unica analogia con l'organo della SPA) ma non può nominare gli altri organi sociali.

La composizione del Direttorio in cinque membri non deriva dal TUB né dalla legge 262/2005 ma dallo Statuto dell'Istituto.

Il Governatore non è nominato dall'Assemblea ma con decreto del Presidente della Repubblica (art. 19, comma 8, della legge 262/2005, v. oltre).

La qualificazione di ente pubblico incide sul regime degli atti (forma scritta e motivazione, art. 19, comma 5, della legge 262/2005; art. 4, comma 3, TUB), sulla responsabilità (limitata ai casi di dolo o colpa grave, art. 4, comma 4-bis, TUB) e sulla posizione dei dipendenti, che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali (art. 7, comma 2, TUB).

(pagina 4)

3.6. Art. 4 TUB, commi 1-3 — Poteri regolamentari, principi di vigilanza e trasparenza amministrativa

Comma 1: *La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.*

Le "istruzioni" a cui viene fatto riferimento in questo articolo sono le **"istruzioni di vigilanza"**; attualmente, nei provvedimenti più recenti, si parla di **"disposizioni di vigilanza"**, ma in pratica sono la stessa cosa.

Il comma 1 riunisce quattro poteri di natura diversa, uno nel primo periodo e tre nel secondo:

formulare le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel Titolo II; emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge; impartire istruzioni; adottare i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Il **potere di proposta** spiega come funziona il sistema nella pratica: le deliberazioni del CICR sulle materie del Titolo II nascono da un'iniziativa di BI; insieme all'avvalimento dell'art. 2, comma 4, ciò descrive un rapporto in cui l'organo politico delibera su istruttoria e proposta dell'organo tecnico. Il **potere regolamentare** non è generale: è esercitabile «nei casi previsti dalla legge» e richiede quindi un'abilitazione legislativa specifica. Istruzioni e disposizioni sono atti amministrativi generali a contenuto normativo, vincolanti per i destinatari: oggi la sede della disciplina prudenziale è la Circolare n. 285 del 2013, mentre le «Istruzioni di vigilanza per le banche» erano raccolte nella Circolare n. 229 del 1999. I **provvedimenti di carattere particolare** sono gli atti individuali (autorizzazioni, divieti, rimozioni).

Comma 2: *La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.*

La vigilanza a cui si fa riferimento in questo articolo è quella **regolamentare prudenziale**, non quella strutturale (e discrezionale), che non esiste più.

Il comma 2 mostra il passaggio dalla vigilanza strutturale a quella prudenziale. Nel modello precedente la discrezionalità delle autorità era amplissima (autorizzazioni e aperture di sportelli concesse o negate in base a valutazioni di opportunità economica non predeterminate), perché l'attività bancaria era intesa più come servizio pubblico che come impresa. Il TUB riconosce invece che l'attività bancaria «ha carattere d'impresa» (art. 10, comma 1): la vigilanza si limita a fissare regole tecniche minime e, rispettate quelle, l'imprenditore opera liberamente. Una regola tecnica può però svolgere questa funzione solo se è conoscibile in anticipo, e da qui l'obbligo di rendere pubblici *previamente* principi e criteri: i criteri resi noti vincolano BI, che non può discostarsene senza motivare, e valgono come parametro di legittimità dei provvedimenti successivi.

L'impianto è stato rafforzato dall'art. 23 della legge 262/2005, che per gli atti di natura regolamentare o di contenuto generale richiede la motivazione, una relazione sull'impatto della regolazione, il rispetto del principio di proporzionalità (esercizio del potere adeguato al fine con il minore sacrificio per i destinatari) previa consultazione dei soggetti vigilati e dei consumatori, e la revisione periodica almeno ogni tre anni.

Comma 3: *La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

La legge n. 241 del 1990 è la legge sulla trasparenza amministrativa; le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto di alcuni obblighi specifici previsti in questa legge. Le disposizioni di tale legge però si applicano **in quanto compatibili**: i poteri di vigilanza sono finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi, e la trasparenza non deve comprometterne il perseguimento. Basti pensare a cosa succederebbe se, per applicare il concetto di trasparenza, si desse

immediatamente notizia della volontà di aprire nei confronti di una banca una procedura di liquidazione coatta amministrativa: il risultato sarebbe una corsa agli sportelli che genererebbe solo più danni del necessario.

3.6.1. Art. 4 TUB, commi 4 e 4-bis — Relazione annuale e responsabilità

Comma 4: *La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.*

La relazione dell'art. 4, comma 4, TUB si aggiunge a quella al Parlamento e al Governo prevista dall'art. 19, comma 4, della legge 262/2005 (v. oltre): sono due obblighi di fonte diversa.

Comma 4-bis: *Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.*

Il comma, inserito dal d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, rinvia a una disposizione della legge sul risparmio che limita ai casi di dolo o colpa grave la responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di controllo. *(pagina 4–5)*

3.7. La legge 262/2005 e la riforma della governance della Banca d'Italia (artt. 19, 20, 21 legge 262/2005)

Nella storia recente si ebbe un attrito fra l'esecutivo e BI (si chiese addirittura ad Antonio Fazio, governatore dell'epoca, di dimettersi), che portò a conseguenze sul piano legislativo. In questo contesto si inserisce la **legge 262/2005**, rubricata "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"; in particolare sono opportuni gli articoli 19, 20 e 21. Questa legge nasce con un intento punitivo nei confronti di BI (e questo si nota anche dal fatto che della CONSOB non si parla, se non per un articolo), togliendo poteri al Governatore per trasferirli al Direttorio.

3.7.1. Art. 19 legge 262/2005

I primi 4 commi non vengono riportati per esteso perché non c'è nulla di particolare: si conferma l'indipendenza di BI (comma 1), la sua natura di ente pubblico (comma 2, che almeno ha chiarito questo aspetto, visto che in passato, in termini di rapporti di lavoro, ci si chiedeva se BI fosse più simile a un ente pubblico, privato o una via di mezzo) e che deve operare, per quanto possibile, nel rispetto del principio di trasparenza definito ai sensi della legge 241/1990 nell'esercizio delle funzioni di vigilanza (comma 3). Nel comma 4 emerge già maggiormente l'intento punitivo, poiché viene richiesta la presentazione di una relazione **semestrale** (quando per le altre autorità è a cadenza annuale): *Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività.*

> **Nota (aggiornamento normativo):** il testo citato è quello originario della l. 262/2005; il comma 4 è stato poi sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 29 dicembre 2006,

n. 303, che ha reso la relazione **annuale** (trasmessa «entro il 30 giugno di ciascun anno» e riferita «all'attività svolta nell'anno precedente»), allineandola a quella delle altre autorità. La cadenza "semestrale" vale dunque solo a illustrare l'intento punitivo originario.

- **Comma 5**: *Gli atti emessi dagli organi della Banca d'Italia hanno forma scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale.* Si esplicita che gli atti devono essere scritti e motivati (sempre con rimando alla trasparenza della legge 241/90), perché il legislatore dell'epoca volle evitare che continuassero ad essere posti in essere comportamenti di **moral suasion** (i cosiddetti orientamenti informali).
- **Comma 6**: *La competenza ad adottare i provvedimenti aventi rilevanza esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio. Agli atti del direttorio si applica quanto previsto dal comma 5. Le deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso di parità dei voti prevale il voto del governatore. La disposizione contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle decisioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.* Sposta i poteri di vigilanza, precedentemente attribuiti al Governatore (parla anche di delega, ma non ci sono mai stati casi, quindi non se ne capisce il senso), al Direttorio. Questo comma porta quindi a una modifica della governance di BI, uniformandola a quella della CONSOB (CO infatti sta per commissione).
- **Comma 7**: *Il governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. In sede di prima applicazione i membri del direttorio diversi dal governatore cessano dalla carica secondo una articolazione delle scadenze disciplinata dallo statuto dell'Istituto, compresa in un periodo comunque non superiore ai cinque anni.* Esplicita che il mandato del Governatore non è più a vita (l'unico altro mandato a vita era quello del Papa) ma dura sei anni; la stessa durata della carica vale per i membri del Direttorio. Per entrambi si prevede un solo possibile rinnovo della carica (nota critica: uno che era vice-direttore generale può poi fare il direttore generale e dopo ancora il governatore?). Il motivo per cui inizialmente il mandato era a vita risiedeva nella convinzione che ciò avrebbe comportato una maggiore indipendenza e autonomia.
- **Comma 8**: *La nomina del governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il procedimento previsto dal presente comma si applica anche, nei casi previsti dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca del governatore. Le disposizioni del presente comma e del primo periodo del comma 7 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.* Specifica che la nomina (e la revoca) del Governatore è esterna a BI: il Consiglio Superiore di BI viene solo sentito e non gode di poteri di nomina o proposta (po-

tere che aveva in passato). Nulla viene detto sulle modalità di nomina degli altri membri del Direttorio.

La revoca del Governatore è agganciata ai soli casi previsti dall'art. 14.2 del Protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE: è una garanzia di diritto dell'Unione contro la rimozione politica dei governatori nazionali, sottratta alla disponibilità del legislatore nazionale. Il legislatore del 2005 ha quindi preferito alla durata indeterminata, ritenuta in origine la miglior garanzia di autonomia, una durata certa con cause di revoca tassative, che è oggi lo standard europeo.

L'indipendenza della banca centrale ha fondamento europeo prima che nazionale e si manifesta in quattro dimensioni:

- **istituzionale**: divieto di ricevere istruzioni dagli organi politici (per la vigilanza nel MVU, l'art. 19 del reg. (UE) 1024/2013 impone alla BCE e alle autorità nazionali competenti di agire in modo indipendente);
- **personale**: mandato di durata predeterminata, rinnovabilità limitata e cause di revoca tassative (i sei anni con un solo rinnovo e la revoca solo nei casi del Protocollo);
- **funzionale**: separazione fra politica monetaria e vigilanza, imposta alla BCE dall'art. 25 del reg. (UE) 1024/2013 (personale separato anche nella struttura gerarchica, riunioni e ordini del giorno del Consiglio direttivo rigorosamente separati);
- **finanziaria**: il divieto europeo di finanziamento monetario, punto d'arrivo del divorzio fra BI e Tesoro.

A bilanciare l'indipendenza ci sono gli obblighi di rendiconto: la relazione al Parlamento e al Governo (art. 19, comma 4), la motivazione degli atti (art. 19, comma 5) e, per la vigilanza europea, la relazione annuale della BCE al Parlamento europeo e le audizioni previste dagli artt. 20 e 21 del reg. (UE) 1024/2013.

3.7.2. Art. 20 legge 262/2005, comma 1

La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento.

3.7.3. Art. 21 legge 262/2005, comma 1

La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

In questo comma è usato, invece di "cooperazione", il termine **collaborazione**: il coordinamento (art. 20) prevede vi sia un coordinatore, e quindi non tutte le autorità sono sullo stesso piano; la collaborazione (art. 21) lascia invece intendere che ci sia una situazione paritaria (norma scritta un po' male). L'art. 20 riguarda le forme di coordinamento (protocolli d'intesa, comitati di coordinamento), l'art. 21 lo scambio di informazioni: i dati comunicati da un'autorità all'altra restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo la disciplina dell'autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima. Un criterio analogo, fondato sul consenso dell'autorità che ha fornito il dato, si trova nell'art. 7, comma 6, TUB: le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti «salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni». *(pagina 5–7)*

3.8. Art. 5 TUB — Finalità e destinatari della vigilanza

Probabilmente è la norma più importante di tutto il TUB (alcuni l'hanno definita addirittura **meta norma**); nella precedente legge bancaria non era presente una norma simile. Questa norma sancisce l'effettivo passaggio dalla **vigilanza strutturale** a quella **prudenziale**.

Il fondamento costituzionale della vigilanza è duplice. L'art. 47, primo comma, Cost. stabilisce che la Repubblica «incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme» e «disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»: tre verbi che presuppongono un'attività svolta da privati e sottoposta a regolazione pubblica, e che il TUB traduce nel carattere d'impresa dell'attività bancaria (art. 10, comma 1). L'art. 41 Cost. afferma dal canto suo che l'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (limite a cui la l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 ha aggiunto la salute e l'ambiente) e che la legge determina i programmi e i controlli opportuni. Dalle due norme discende un criterio di lettura valido per tutto il Titolo I: i poteri delle autorità creditizie sono poteri funzionalizzati, ammessi nella misura in cui servono le finalità dell'art. 5. Per questo l'art. 5 è una meta-norma: fissa lo scopo dei poteri, e quindi anche il limite oltre il quale il loro esercizio non è legittimo, senza attribuirne alcuno (i poteri stanno altrove: artt. 4, 51, 53, 53-bis, 54). L'art. 47, a sua volta, è una norma di scopo, neutra rispetto alla scelta fra vigilanza strutturale e prudenziale o fra autorità unica e autorità plurime: il passaggio dall'una all'altra è avvenuto per legge ordinaria.

Comma 1: *Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.*

Il primo comma dell'articolo 5 necessita di alcuni approfondimenti; bisogna rispondere a 3 domande: (1) Cosa implicano le singole finalità elencate? (2) In che rapporto sono le finalità fra di loro? (3) Mancano alcune finalità (ad esempio la tutela del consumatore)?

(1) Le singole finalità:

- **Sana e prudente gestione dei soggetti vigilati**: il concetto nasce col diritto europeo e viene introdotto nella direttiva del 1989, ma solo come requisito per i detentori di par-

tecipazioni all'interno della banca (requisito rimasto comunque ai sensi dell'art. 19 TUB). Attualmente è anche una delle finalità esplicite dell'attività di vigilanza e indica lo stato di salute di una banca. Per dare un senso compiuto ai termini di questa espressione bisogna rifarsi alle disposizioni di vigilanza e alla dottrina: tendenzialmente ci si riferisce con il termine "sana" al mantenimento di comportamenti corretti, e con "prudente" al rispetto dei requisiti della vigilanza (per l'appunto prudenziale) e alla modalità di gestione dei rischi. Viene specificato "dei soggetti vigilati", quindi questa finalità è in ottica **microeconomica** (singole banche).

- **Stabilità complessiva**: stabilità è il contrario di situazione di crisi ed è invece una finalità **macroeconomica**. L'obiettivo di BI non deve essere quello di salvare banche in crisi, ma deve intervenire affinché il sistema bancario nel suo complesso sia stabile.
- **Efficienza e competitività**: le banche sono imprese (come già detto a più riprese) che operano in un contesto (il sistema finanziario) che BI contribuisce a mantenere efficiente e competitivo.
- **Osservanza delle disposizioni in materia creditizia**: BI controlla che le banche rispettino le norme per quanto previsto dalle leggi in materia creditizia ma non solo; se necessario, sempre per salvaguardare la sana e prudente gestione, può "agire" anche in altri ambiti.

(2) Il rapporto fra le finalità:

Si potrebbe pensare che alcuni obiettivi siano incompatibili (ad esempio stabilità e concorrenza). Da un'analisi più approfondita emerge tuttavia che gli obiettivi sono **complementari** gli uni agli altri e sono tutti ugualmente importanti (nel caso di stabilità e concorrenza, basti pensare che una competizione nel breve termine porta all'eliminazione degli istituti bancari inefficienti, permettendo di raggiungere nel lungo termine la stabilità degli istituti restanti). Nell'analisi del rapporto che sussiste fra le finalità, nel tempo sono state date tre interpretazioni:

1. sono tutte sullo stesso piano;
2. le finalità sono state indicate secondo un ordine di priorità (poco plausibile, pensando che l'osservanza delle norme sarebbe così collocata all'ultimo posto);
3. tutte le finalità sono sullo stesso piano perché separate da virgole, tranne l'ultima che è preceduta da "nonché".

(3) Finalità mancanti — la tutela del consumatore:

Pare effettivamente anomalo che nel TUF e nel Codice delle Assicurazioni si parli rispettivamente di "tutela dell'investitore" e "tutela dell'assicurato", mentre nel TUB non sia stata inserita una forma di tutela di questo genere fra le finalità. Le motivazioni potrebbero essere diverse: il TUB è antecedente al TUF e al Codice delle assicurazioni, e la giustificazione potrebbe essere che il legislatore ha maturato l'attenzione alla tutela del cliente nel tempo; oppure si è pensato che gli ambiti finanziario e assicurativo, prevedendo prodotti più complessi di quelli bancari, necessitassero di una maggiore tutela del cliente. Resta una grave carenza.

Approfondimento (ricerca ottobre 2026): la carenza è reale (l'art. 5 non è stato modificato) ma è colmata *per via sistematica*: l'art. 127, comma 01, TUB (introdot-

to dal d.lgs. 141/2010, attuativo della dir. 2008/48/CE) eleva la trasparenza e la correttezza verso la clientela a finalità di vigilanza, sia pure limitatamente al Titolo VI; si aggiungono gli artt. 124 ss. e l'Arbitro Bancario Finanziario (art. 128-bis TUB). Quanto al **rapporto fra le finalità** dell'art. 5, resta un **dibattito dottrinale aperto**: i tre modelli (paritetico, gerarchico, misto) convivono e il "misto" è il più diffuso ma non è diritto vivente. Nessuna giurisprudenza lo ha risolto.

La «sana e prudente gestione» come clausola generale:

«Sana e prudente gestione» è una clausola generale: il legislatore la pone come finalità senza definirla, e il suo contenuto va riempito dalla normativa secondaria, dalla prassi e dalla dottrina. Fonda i poteri di vigilanza in due modi:

- come parametro per valutare fattispecie non tipizzate: l'art. 14, comma 2, consente di negare l'autorizzazione all'attività bancaria quando dalla verifica delle condizioni del comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione; l'art. 19, comma 5-bis, impone a BI di proporre alla BCE il diniego dell'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione quando non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca; l'art. 25, comma 1, e l'art. 26, comma 2, la pongono come parametro dei requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali; l'art. 56, comma 1, richiede che le modificazioni degli statuti non contrastino con una sana e prudente gestione, e l'art. 57, comma 1, lo stesso per le fusioni e le scissioni;
- come base di provvedimenti individuali incisivi: l'esempio più netto è l'art. 53-bis, comma 1, lett. e, che consente a BI di disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali «qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca». Non occorre accertare la violazione di una norma puntuale, e la rimozione non è disposta se ricorrono gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo urgenza di provvedere: la clausola generale opera cioè in via residuale rispetto alle fattispecie tipizzate.

Il rischio di arbitrio che ogni clausola generale porta con sé è contenuto dalla pubblicità preventiva dei criteri (art. 4, comma 2), dall'obbligo di motivazione (art. 4, comma 3) e dal sindacato giurisdizionale.

Comma 2: *La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.*

Esplicita i soggetti sottoposti a vigilanza. Vi sono inseriti appositamente i **gruppi bancari**, poiché possono farne parte anche soggetti su cui normalmente BI non potrebbe svolgere attività di vigilanza (quindi soggetti non bancari e non finanziari).

Le categorie non bancarie sono definite dall'art. 1, comma 2, e disciplinate da titoli propri. Gli intermediari finanziari sono i soggetti iscritti nell'elenco dell'art. 106 (lett. g): l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari autorizzati e iscritti in un albo tenuto da BI (Titolo V). Gli istituti di moneta elettronica (lett. h-bis) e gli istituti di pagamento (lett. h-sexies) sono, per definizione

espressa, imprese diverse dalle banche (rispettivamente Titolo V-bis e Titolo V-ter), autorizzate da BI (artt. 114-quinquies e 114-novies). L'intermediario finanziario eroga credito ma non raccoglie risparmio tra il pubblico, e per questo non è una banca: manca una delle due componenti dell'attività bancaria (art. 10, comma 1). I gruppi bancari, invece, non sono definiti nell'art. 1: la loro disciplina è nel Titolo III, capo II. Il perimetro dell'art. 5, comma 2, è più largo di quello del MVU, che riguarda soltanto gli enti creditizi: l'europeizzazione della vigilanza di cui parlano gli artt. 6 e 6-bis non ha investito l'intero perimetro dei vigilati.

Comma 3: *Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.*

Esistono leggi speciali apposite che si occupano di questi poteri.

3.8.1. L'art. 127 TUB (Regole Generali) e la tutela della trasparenza

È utile riprendere anche l'**art. 127 TUB**, rubricato "Regole Generali", inserito nel Titolo VI (trasparenza); nel 2010, in seguito al recepimento di una direttiva UE sul credito al consumo, sono stati premessi all'articolo due commi (01 e 02).

Comma 01: *Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.*

Si evince quindi come la finalità di tutela della trasparenza e correttezza nei confronti della clientela sia stata inserita nel TUB (bicchiere mezzo pieno); il problema è che questa tutela del cliente è diventata una finalità di vigilanza solo in relazione ai poteri che BI ha nell'ambito della trasparenza, perché specificato "dal presente titolo" (bicchiere mezzo vuoto).

Il secondo periodo del comma 01 consente a BI, a questi fini e in conformità delle deliberazioni del CICR, di dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. Il comma 02 rinvia a quanto stabilito dal CICR per l'applicazione del Titolo VI ai confidi iscritti nell'elenco dell'art. 112; il resto dell'art. 127 conferma la natura protettiva della disciplina: le disposizioni del titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente (comma 1), le informazioni sono rese almeno in lingua italiana (comma 1-bis) e le nullità operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice (comma 2: nullità di protezione). *(pagina 7–9)*

3.9. Art. 6 e 6-bis TUB — Rapporti con il diritto UE, il SEVIF e il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)

3.9.1. Art. 6: Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF e nel MVU

Questo articolo è stato riscritto in seguito alla ricezione della CRD IV e all'avvento del MVU.

Comma 1: *Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposi-*

zioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

Di questo comma conta soprattutto la locuzione "in armonia con le disposizioni dell'Unione Europea": nell'esercizio dei propri poteri le autorità creditizie devono sempre tenere conto del diritto sovranazionale (ad esempio nei processi di interpretazione delle norme). Oltre all'obbligo di applicare gli atti direttamente efficaci (regolamenti e decisioni), «in armonia» funziona come canone ermeneutico: le norme nazionali vanno interpretate in senso conforme al diritto dell'Unione e la discrezionalità amministrativa va esercitata coerentemente con esso. Il riferimento alle raccomandazioni, atti non vincolanti, conferma la portata ampia dell'obbligo: le autorità devono «provvedere in merito», cioè prenderle in considerazione.

Comma 2: *Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e il MRU, della BCE e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.*

Comma 3: *La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle attività che essi svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.*

Come parte del SEVIF e del MVU, la Banca d'Italia deve tener conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo. SEVIF, MVU e MRU sono tre sistemi distinti. Il SEVIF (art. 1, comma 1, lett. h-bis) comprende l'ABE, l'AEAP, l'AESFEM, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, il CERS e le autorità di vigilanza degli Stati membri. Il MVU (lett. e-bis) è il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati partecipanti, cioè quelli la cui moneta è l'euro o che hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE (lett. h-ter). Il MRU (lett. e-quinquies) è il sistema di risoluzione istituito dal reg. (UE) 806/2014, composto dal Comitato di risoluzione unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati partecipanti. La rubrica dell'art. 6, che oggi cita anche il MRU, è stata sostituita dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

Comma 3-bis: *Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.*

Collega i poteri nazionali alla disciplina prudenziale europea di rango regolamentare: il CRR è direttamente applicabile e non ha bisogno di trasposizione, ma la sua violazione attiva i poteri d'intervento del TUB.

Comma 4: *Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per*

la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Il comma contiene due istituti distinti. Il primo è l'accordo con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che preveda la ripartizione di compiti e la delega di funzioni: è consentito solo «nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea», quindi presuppone una base europea. Il secondo è il ricorso all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. I rapporti con la BCE nel MVU sono disciplinati invece dall'art. 6-bis.

3.9.2. Art. 6-bis: Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia

Comma 1: *Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.*

Oltre a riprendere il concetto per cui i poteri di BI vengono esercitati nei limiti delle disposizioni del MVU, viene esplicitata la distinzione fra:

- **More Significant Bank**: sottoposte alla vigilanza diretta della BCE (**vigilanza diretta**);
- **Less Significant Bank**: vigilate dalle autorità di vigilanza nazionali (**vigilanza decentralizzata**).

Il reg. (UE) 1024/2013 muove dalla constatazione che la frammentazione del settore finanziario poteva minacciare l'integrità della moneta unica e del mercato interno (considerando 2). È stato adottato sulla base dell'art. 127, par. 6, TFUE, che consente di affidare alla BCE «compiti specifici» in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione, con procedura legislativa speciale. Gli Stati la cui moneta non è l'euro possono partecipare solo tramite cooperazione stretta con la BCE (art. 7 del regolamento).

I poteri restano alla Banca d'Italia, ma il loro esercizio dipende dal quadro europeo. Il MVU è il sistema composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati partecipanti (art. 1, comma 1, lett. e-bis), quindi non si identifica con la sola BCE, e per «disposizioni del MVU» si intendono il reg. (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione (lett. e-ter). Le autorità nazionali sono rimaste e fanno ora parte di un sistema in cui la BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'insieme; esse la assistono nella preparazione e nell'attuazione degli atti e ne seguono le istruzioni, e le due parti cooperano in buona fede scambiandosi le informazioni (art. 6 del regolamento). Nel TUB questi principi trovano espressione nei commi 2 e 5.

3.9.3. I poteri della Banca d'Italia nel MVU (art. 6-bis, commi 2-5)

Comma 2: *Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare:*

- formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14) e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni (art. 19) (lett. a);
- fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, fermo restando il potere della BCE di ottenerle dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni (lett. b);
- assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti (lett. c);
- informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU (lett. d);
- esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal TUB nelle materie del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informandola delle attività svolte in esito alla richiesta (lett. e);
- esercita i poteri che il TUB le attribuisce e che le disposizioni del MVU non attribuiscono alla BCE (lett. f).

Comma 5: *Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.*

Il ricorso all'ABE previsto dall'art. 6, comma 4, riguarda invece le controversie con le autorità di altri Stati membri. I commi 3 e 4 sono trattati più avanti (sanzioni e diritto applicabile).

3.9.4. Il riparto fra BCE e autorità nazionali: procedimenti comuni e significatività

L'art. 4, par. 1, del reg. 1024/2013 attribuisce alla BCE una competenza esclusiva, nei confronti di tutti gli enti creditizi degli Stati partecipanti, su compiti elencati tassativamente: rilascio e revoca dell'autorizzazione, valutazione delle acquisizioni e cessioni di partecipazioni qualificate, rispetto dei requisiti prudenziali (fondi propri, grandi rischi, liquidità, leva), governo societario e requisiti degli esponenti, valutazioni prudenziali e prove di stress, vigilanza su base consolidata, piani di risanamento e misure di intervento precoce (con esclusione dei poteri di risoluzione). Tutto ciò che non è nell'elenco resta alle autorità nazionali (art. 1 del regolamento), ed è la logica dell'art. 6-bis, comma 2, lett. f. «Esclusiva» riguarda la titolarità del compito: l'esercizio concreto è distribuito dall'art. 6 secondo la significatività del soggetto, con due eccezioni trasversali, i **procedimenti comuni** (autorizzazione e partecipazioni qualificate), che restano alla BCE per tutte le banche, anche per le less significant.

Nel TUB i procedimenti comuni sono disciplinati dagli artt. 14 e 19. L'istanza di autorizzazione all'attività bancaria si presenta alla Banca d'Italia, che se le condizioni sono soddisfatte propone alla BCE il rilascio (l'autorizzazione «è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia»: art. 14, comma 2), altrimenti respinge essa stessa la domanda (art. 14, par. 2, del regolamento). L'autorizzazione è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica

delle condizioni del comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione; il progetto di decisione si ritiene adottato dalla BCE se questa non solleva obiezioni entro dieci giorni lavorativi (art. 14, par. 3, del regolamento). La revoca è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa (comma 3-bis), e dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, anche nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80 (comma 3-ter). Per le partecipazioni qualificate l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 19, comma 5), e BI propone il diniego quando non risulti garantita la sana e prudente gestione (comma 5-bis); se l'acquisizione avviene nell'ambito di una risoluzione ai sensi del d.lgs. 180/2015, i provvedimenti sono invece adottati dalla Banca d'Italia (comma 5-ter). Il regolamento costruisce la decisione della BCE sulle partecipazioni come divieto («decide se vietare l'acquisizione»), mentre il TUB parla di autorizzazione. Le less significant non sono dunque vigilate dalla sola Banca d'Italia: per i procedimenti comuni la Banca d'Italia propone e la BCE decide.

Il TUB definisce «soggetti significativi» i soggetti individuati dall'art. 2, n. 16, del reg. (UE) n. 468/2014 (il regolamento quadro sul MVU), sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta (art. 1, comma 2, lett. d), e «soggetti meno significativi» per differenza, cioè i soggetti sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU diversi dai primi (lett. d-bis). I criteri stanno nell'art. 6, par. 4, del reg. 1024/2013: dimensioni, importanza per l'economia dell'Unione o di uno Stato partecipante, significatività delle attività transfrontaliere. Un ente non è considerato meno significativo, salvo particolari circostanze, quando ricorre una di queste condizioni:

- attività totali superiori a 30 miliardi di euro;
- attività totali superiori al 20% del PIL dello Stato partecipante in cui è stabilito, a meno che il valore totale delle attività sia comunque inferiore a 5 miliardi di euro;
- importanza significativa per l'economia nazionale, notificata dall'autorità nazionale competente e confermata dalla BCE dopo una valutazione approfondita;
- assistenza finanziaria pubblica richiesta o ricevuta direttamente dal FESF o dal MES.

La BCE vigila inoltre, salvo circostanze particolari, sui tre enti creditizi più significativi di ciascuno Stato partecipante, e può considerare significativo di propria iniziativa un ente con filiazioni in più Stati partecipanti e rilevanti attività o passività transfrontaliere. La valutazione si fa su base consolidata, al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati partecipanti: un gruppo può essere significativo anche se nessuna delle banche che lo compongono lo sarebbe singolarmente (è il caso dei gruppi bancari cooperativi). La qualificazione si modifica solo in caso di cambiamenti sostanziali e non transitori delle circostanze.

Restano alle autorità nazionali, oltre ai compiti non elencati dall'art. 4 del regolamento (fra cui la tutela dei consumatori e il contrasto al riciclaggio, che neppure per le banche significative sono passati alla BCE), gli istituti di diritto interno che non derivano dal diritto dell'Unione: l'accertamento sulle modificazioni statutarie (art. 56), l'autorizzazione di fusioni e scissioni (art. 57, non necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'art. 14) e le istruzioni sulla cessione in blocco di rapporti giuridici (art. 58).

3.9.5. Vigilanza diretta, vigilanza decentrata e decisioni della BCE

Per le banche significative la BCE esercita la vigilanza diretta su tutti i compiti dell'art. 4, avvalendosi dell'assistenza delle autorità nazionali attraverso i Joint Supervisory Team, gruppi composti da personale della BCE e delle autorità nazionali. Per le less significant la vigilanza è decentrata: le autorità nazionali assolvono i compiti dell'art. 4 diversi dai procedimenti comuni, ne sono responsabili e adottano le pertinenti decisioni (art. 6, par. 6). La BCE conserva comunque dei poteri sulle meno significative: può emanare regolamenti, orientamenti o istruzioni generali, esercitare la sorveglianza sul sistema, chiedere informazioni, avvalersi dei poteri di indagine e di ispezione e, quando è necessario per garantire l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, avocare a sé la vigilanza su uno o più enti meno significativi (art. 6, par. 5, lett. b). Anche la vigilanza decentrata è quindi vigilanza nell'ambito del MVU, esercitata secondo orientamenti e sotto la sorveglianza della BCE.

Il Consiglio di vigilanza è un organo interno della BCE (un presidente, un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato partecipante: per l'Italia, la Banca d'Italia) che non decide, ma prepara e propone al Consiglio direttivo progetti di decisione completi. Il progetto è considerato adottato se il Consiglio direttivo non muove obiezioni entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi (quarantotto ore in situazioni di emergenza); l'eventuale obiezione va motivata per iscritto, in particolare con riferimento a questioni di politica monetaria, perché il Consiglio direttivo, organo anche della politica monetaria, interviene come garante della separazione fra le due funzioni. Formalmente decide dunque il Consiglio direttivo, sostanzialmente il Consiglio di vigilanza, con un silenzio-assenso istituzionale.

3.9.6. Il diritto applicato dalla BCE, le sanzioni e le misure macroprudenziali

Il **comma 4** precisa il significato di due espressioni dell'art. 4, par. 3, del regolamento, che impone alla BCE di applicare, oltre al diritto dell'Unione, la legislazione nazionale di recepimento delle direttive e quella di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti. Per «legislazione nazionale» il TUB intende le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive e per l'esercizio delle opzioni, quando non esercitate dalla BCE. La BCE, vigilando su una banca significativa italiana, applica quindi anche le disposizioni adottate da BI a questo titolo e non soltanto il diritto europeo.

Il **comma 3** rinvia, per le sanzioni nelle materie del MVU, all'art. 144-septies, che si applica alle violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale. Rispetto a questi soggetti BI può applicare le sanzioni del Titolo VIII esclusivamente su richiesta della BCE e solo quando ricorra almeno una di tre condizioni: la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione direttamente applicabili; la sanzione è diretta a persone fisiche (nei casi degli artt. 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies); la sanzione ha natura non pecuniaria. La procedura segue l'art. 145 e la conclusione e l'esito sono comunicati alla BCE (art.

144-septies, comma 3); BI può chiedere alla BCE di formulare la richiesta (comma 4). Il comma 5 dello stesso articolo riserva alla BCE l'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei suoi regolamenti e delle sue decisioni, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi.

Un ulteriore criterio di riparto è quello macroprudenziale, in cui la competenza non si misura sulla dimensione del soggetto ma sull'obiettivo (rischi sistemici anziché rischi della singola banca). L'art. 53-ter dispone che BI è «autorità nazionale designata» per l'adozione delle misure dell'art. 5 del reg. 1024/2013 (comma 1) e che i poteri di vigilanza attribuiti a BI dal TUB possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi (comma 2): in questo ambito la soglia di significatività non è un limite. L'autorità nazionale designata e l'autorità nazionale competente sono figure distinte, che in Italia coincidono nella BI. Nel regolamento la competenza di prima battuta è nazionale (riserve di capitale, anche anticicliche, e misure contro i rischi sistemici), con notifica alla BCE dieci giorni lavorativi prima e obiezione motivata entro cinque; la BCE può invece applicare in luogo delle autorità nazionali solo requisiti più elevati e misure più rigorose, mai più permissive, con lo stesso preavviso di dieci giorni lavorativi. La Banca d'Italia è autorità competente per la vigilanza (art. 6-bis), autorità designata per le misure macroprudenziali (art. 53-ter) e, nell'ambito del riparto di competenze del reg. (UE) 806/2014, autorità di risoluzione (art. 1, comma 1, lett. a-bis). *(pagina 9–10)*

3.10. Art. 7 TUB — Segreto d'ufficio e collaborazione fra autorità

Comma 1: *Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.*

L'attività di vigilanza svolta da BI è coperta dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni. Le eccezioni al segreto d'ufficio sono **tre**: il **MEF** (non in quanto autorità creditizia ma in quanto presidente del CICR), l'**autorità giudiziaria** e l'**amministrazione finanziaria**. Per l'autorità giudiziaria viene specificato che vale solo qualora le informazioni siano necessarie in ambito penale; per l'amministrazione finanziaria, quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.

Comma 2: *I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.*

I dipendenti di Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono pubblici ufficiali e sono tenuti anch'essi a mantenere il segreto. I pubblici ufficiali (la regola non vale per i comuni cittadini), laddove vengano a conoscenza di una notizia di reato (non serve la certezza, basta

un sospetto), sono obbligati a riferirlo all'autorità giudiziaria, altrimenti commettono il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p.). Il TUB deroga qui a questa regola: i dipendenti di BI, pur essendo pubblici ufficiali a tutti gli effetti, hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al **Direttorio** (questo per evitare, ad esempio, corse agli sportelli e fughe di notizie). Il Direttorio, prima di inoltrare la segnalazione all'autorità giudiziaria (che deve obbligatoriamente essere inoltrata), può adottare, se lo ritiene necessario, tutte le misure cautelari e preventive del caso che evitino i possibili effetti negativi derivanti dalla diffusione della notizia di reato, sempre per garantire le finalità di cui all'art. 5 TUB.

L'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio non permette a BI di tacere alla magistratura: l'obbligo di denuncia resta e si sposta sull'organo collegiale, e il comma 1 rende comunque il segreto inopponibile all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Le due previsioni operano su piani diversi, il flusso interno e l'opponibilità esterna. La parola «Direttorio» ha sostituito «Governatore» con il d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, in coerenza con il trasferimento di poteri operato dalla legge 262/2005. L'ultimo periodo, aggiunto dal d.lgs. 14 novembre 2016, n. 223, fa salve le disposizioni del MVU sulla comunicazione delle informazioni alla BCE.

Comma 3: *I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa sono vincolati dal segreto d'ufficio.*

Il vincolo riguarda chiunque lavori per BI a qualunque titolo, consulenti ed esperti compresi, e sopravvive alla cessazione del rapporto («hanno lavorato», «si è avvalsa»).

Comma 4: *Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.*

BI oppone il segreto d'ufficio alle PA, ma non può avvenire il contrario, salvo la presenza di norme o situazioni specifiche.

Comma 5: *La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.*

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, BI, CONSOB, COVIP e IVASS sono tutte sullo stesso piano in termini di importanza; non possono quindi opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio (vige sempre il principio di leale collaborazione). Anche fra BI e la UIF il segreto d'ufficio non è reciprocamente opponibile. La UIF (art. 1, comma 1, lett. e-quater) è l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2007: è istituita presso BI e svolge funzioni proprie, distinte dalla vigilanza prudenziale. Gli elenchi dell'art. 7, comma 5, e degli artt. 20 e 21 della legge 262/2005 non coincidono: il TUB menziona BI, CONSOB, COVIP e IVASS (e, per il rapporto bilaterale con BI, la UIF), la legge sul risparmio BI, CONSOB, ISVAP (oggi IVASS), COVIP e Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Comma 6: *Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.*

Dal momento che BI è inserita in un contesto di vigilanza sovranazionale, vige il principio di leale collaborazione con le autorità europee. BI può anche trasmettere le informazioni ricevute, **salvo diniego** dell'autorità che le ha fornite. La collaborazione europea si è allargata: accanto a SEVIF e MVU il comma include oggi il MRU e, fra gli interlocutori degli Stati dell'Unione, le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio (definite dall'art. 1, comma 1, lett. l-bis, come le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati ai fini del rispetto della direttiva (UE) 2015/849).

Comma 7: *Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.*

Nei confronti degli istituti esterni al MVU, BI gode di una maggiore discrezionalità: non ha più l'obbligo di collaborare, ma **può** scambiare informazioni. Nel valutare se scambiare o meno informazioni, BI deve tener conto della presenza di due criteri: "accordi di cooperazione" e "equivalenti obblighi di riservatezza". Devono quindi essere presenti delle condizioni di reciprocità nello scambio di informazioni, e non deve trattarsi di un flusso unilaterale.

Comma 8: *La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.*

Comma 9: *La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.*

Comma 10: *Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.*

Comma 10-bis: *La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.*

Il comma 8 vale per il contesto tipizzato delle procedure di liquidazione o di fallimento e consente lo scambio anche con autorità giudiziarie; non contraddice il comma 1, che disciplina l'opponibilità del segreto a fronte di una richiesta esterna, mentre il comma 8 riguarda un'iniziativa di BI in una situazione tipizzata. Per le autorità di Stati terzi rinvia al comma 7. Il comma 9 prevede una facoltà («può») di comunicare ai sistemi di garanzia le informazioni e i dati necessari al loro funzionamento; verso i sistemi esteri la riservatezza opera come condizione. Il comma 10 è una clausola di chiusura che rinvia alle disposizioni dell'Unione europea. Il comma 10-bis, aggiunto dalla l. 23 dicembre 2021, n. 238, è una disposizione organizzativa: individua BI come punto di contatto per le richieste delle autorità degli altri Stati membri sui contratti di credito immobiliare ai consumatori (è cosa diversa dal «punto di contatto centrale» dell'art. 1, comma 2, lett. i, designato dall'intermediario europeo che opera in Italia tramite agenti). *(pagina 10–11)*

3.11. Art. 8 TUB — Pubblicazione di provvedimenti e dati statistici

In passato, Banca d'Italia doveva pubblicare i propri provvedimenti di carattere generale e particolare sul bollettino di vigilanza mensile. Attualmente invece pubblica sul proprio sito web solo i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie e i provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

Il comma 1, nel testo sostituito dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, impone a BI di pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie e gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti vigilati. Il comma 2 distingue invece la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale secondo la fonte e i destinatari: le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del MEF vi sono sempre pubblicati, mentre quelli di carattere generale di BI soltanto quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza. Il comma 3 prevede che BI pubblichi elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti vigilati.

L'art. 8 disciplina la pubblicità successiva (la conoscibilità degli atti adottati), l'art. 4, comma 2, quella preventiva (la conoscibilità dei criteri), e l'art. 4, comma 3, impone la pubblicazione dei provvedimenti di carattere generale. Anche l'albo delle banche richiama il MVU: l'art. 13, comma 1, esordisce con «fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati». I due registri hanno oggetto diverso: l'albo attesta chi è abilitato all'attività bancaria, l'elenco pubblicato dalla BCE indica quali soggetti sono significativi e quali no. Le due qualificazioni sono indipendenti: una banca meno significativa è iscritta all'albo come una significativa. *(pagina 11–12)*

3.12. Art. 9 TUB — Reclamo al CICR

Comma 1: *Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte*

di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Nei confronti di un atto delle PA (e quindi anche di BI) ci si può rivolgere al **TAR** (Tribunale Amministrativo Regionale) come primo grado di giudizio, o al **Consiglio di Stato** come secondo grado di giudizio. Questo articolo prevede però un'altra via: il reclamo al CICR. Sapendo però che il CICR non ha suoi funzionari ma si avvale di BI, è come far reclamo a BI stessa (in effetti questo strumento è stato usato pochissime volte).

Il rinvio al capo I del d.P.R. 1199/1971, che disciplina il ricorso gerarchico, qualifica il reclamo come ricorso amministrativo: più esattamente un ricorso gerarchico improprio, perché fra CICR e BI non corre alcun rapporto di sovraordinazione.

Comma 2: *Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.*

Comma 3: *Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.*

La consultazione delle associazioni di categoria introduce una forma di partecipazione collettiva al procedimento decisorio, ma solo quando la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

Le tutele contro gli atti di vigilanza sono le seguenti:

- per i provvedimenti diversi da quelli sanzionatori: reclamo al CICR oppure ricorso al giudice amministrativo (TAR, con appello al Consiglio di Stato);
- per i provvedimenti sanzionatori: l'art. 145, comma 4, ammette ricorso alla corte d'appello di Roma, da notificare a pena di decadenza a BI entro trenta giorni dalla comunicazione (sessanta se il ricorrente risiede all'estero) e da depositare in cancelleria entro trenta giorni dalla notifica; l'opposizione non sospende l'esecuzione, salva la sospensione per gravi motivi disposta dalla corte con ordinanza non impugnabile (comma 5);
- per le decisioni della BCE adottate nell'esercizio dei poteri del MVU: la Commissione amministrativa del riesame prevista dall'art. 24 del reg. (UE) 1024/2013, che opera un riesame amministrativo interno e fa salvo il diritto di ricorrere alla Corte di giustizia dell'Unione europea (art. 24, par. 11).

(pagina 12)

4 | Titolo II TUB, Capo I: l'attività bancaria (artt. 10, 11, 12, cenni all'art. 129 e abusivismo artt. 130-133)

Fonte: LEGB1_Appunti_04_Titolo-II-Capo-I-Attivita-Bancaria.pdf — *8 pagine*

4.1. Introduzione: l'oggetto del Capo I

Il Capo I del Titolo II del TUB tratta la **nozione di attività bancaria** e la **raccolta di risparmio fra il pubblico**.

Un punto di metodo: il TUB **non fornisce una definizione di banca** ma una definizione di **attività bancaria**, e sposta così l'attenzione dal soggetto (la banca) all'attività svolta (l'attività bancaria).

Alle riserve definite dagli artt. 10 e 11 corrisponde, nel Titolo VIII, il sistema sanzionatorio dell'abusivismo bancario e finanziario (artt. 130-133), che colpisce chi le viola. *(pagina 1)*

4.2. Art. 10 comma 1: la nozione di attività bancaria e il "binomio"

Comma 1: *"La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria."*

Perché si abbia attività bancaria è necessaria la **contestuale presenza** di:

- raccolta di risparmio tra il pubblico; **e**
- esercizio del credito.

Questo è il cosiddetto **"binomio"**. Se un soggetto raccoglie risparmio senza erogare finanziamenti, o viceversa eroga credito senza raccogliere risparmio, **non** si tratta di una banca.

Il TUB non definisce la banca se non **per relationem**: l'art. 1, comma 1, lett. b), la indica come *"l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria"*. La circolarità è solo apparente (banca è chi svolge attività bancaria, attività bancaria è ciò che svolge la banca autorizzata), perché la fattispecie oggettiva dell'art. 10 è autonoma e serve, tra l'altro, a individuare chi opera

abusivamente. Dalla definizione si ricavano tre corollari: la banca è **impresa**, non ente pubblico né gestore di un pubblico servizio; è impresa **autorizzata**, e l'autorizzazione è costitutiva della qualità di banca e non solo abilitativa; non ha un oggetto sociale libero, perché non è banca chi non svolge attività bancaria e perché l'art. 10, comma 3, delimita ciò che la banca può aggiungervi.

La ragione economica del binomio sta nell'abbinamento fra raccolta rimborsabile e impiego rischioso: la banca finanzia gli impieghi con fondi raccolti a titolo di debito presso il pubblico e assume su di sé la trasformazione delle scadenze e il rischio che ne deriva, ed è questo abbinamento a giustificare la riserva di attività e la vigilanza prudenziale. Chi concede finanziamenti con mezzi propri non espone il risparmio altrui allo stesso modo ed è sottoposto a un regime diverso, quello degli intermediari finanziari dell'art. 106.

Un esempio di raccolta senza erogazione è Poste Italiane, che raccoglie risparmio tra il pubblico ma non può concedere finanziamenti nei confronti del pubblico (art. 2, comma 8, d.p.r. 144/2001): mancando il binomio, non c'è attività bancaria e Poste non è una banca. La sua raccolta è consentita perché rientra tra le ipotesi "espressamente consentite dalla legge" dell'art. 11, comma 4, lett. d); gli artt. 114-bis, comma 2, e 114-sexies includono inoltre Poste Italiane fra i soggetti che possono emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento. *(pagina 1)*

4.3. Art. 10 comma 1: il carattere d'impresa dell'attività bancaria — il caso Giuffrè e il dibattito dottrinale

Comma 1 (seconda parte): *"Essa ha carattere d'impresa."*

4.3.1. La cornice normativa: l'art. 2195 c.c.

L'art. 2195 c.c., rubricato *"Imprese soggette a registrazione"*, elenca una serie di attività che, se esercitate, comportano l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese; chi le esercita è considerato **imprenditore commerciale**. Fra i soggetti tenuti all'iscrizione vi sono gli imprenditori che esercitano *(…) 4) Attività bancaria o assicurativa.*

Bisogna capire come si sia arrivati a stabilire che l'attività bancaria ha carattere d'impresa, soprattutto alla luce della precedente legge bancaria, che all'art. 1 affermava: *"la raccolta di risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico"*. Questa norma non forniva una definizione di attività bancaria, ma si limitava a dire che tali attività erano funzioni di interesse pubblico; l'idea era che, affinché un'attività fosse qualificata come bancaria, dovessero essere svolte contemporaneamente le due attività, ma non era un'opinione condivisa da tutti.

4.3.2. Il caso Giuffrè

La questione se l'impresa bancaria fosse o meno attività commerciale era importante anche ai fini pratici: la banca doveva fallire o essere sottoposta a procedura coatta amministrativa? (Domanda collegata: quali reati commettono i dipendenti di una banca, quelli di un privato o

quelli di un dipendente pubblico?)

Un caso divenuto emblematico è il **caso Giuffrè**. Questo soggetto, per la ristrutturazione di beni ecclesiastici, raccoglieva fondi impegnandosi a restituirli con tassi di interesse altissimi (compresi fra il 45% e il 100%).

- **Primo grado**: il tribunale, rifacendosi all'art. 2082 c.c. (nozione di imprenditore), stabilì che il signor Giuffrè era un imprenditore a tutti gli effetti, essendo rispettati i requisiti di professionalità, economicità e organizzazione; non poteva però essere considerato imprenditore agricolo, né tanto meno piccolo imprenditore. In via residuale si optò per trattarlo come imprenditore commerciale, il che significava farlo rientrare in una delle categorie specificate dall'art. 2195 c.c.: fu di fatto equiparato ad una banca, pur svolgendo soltanto attività di raccolta fra il pubblico. Nella scelta se sottoporlo alla disciplina del fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa, il tribunale optò per la **prima**, affermando che esistessero due definizioni di attività bancaria: una nella legge bancaria (dove deve sussistere il binomio) e una nel codice civile (dove è sufficiente lo svolgimento di una sola delle due attività).
- **Secondo grado**: la Corte d'Appello contestò l'attribuzione della nozione di banchiere a Giuffrè, perché sarebbe stato illogico avere due diverse definizioni di attività bancaria.

Il Tribunale di Bologna (sentenza del 10 marzo 1961) aveva ricondotto Giuffrè all'art. 2195, n. 4, c.c. come banchiere "lato sensu", concetto più ampio di quello della legge bancaria e riferibile a qualsiasi impresa che compia operazioni aventi per oggetto la moneta come tale; aveva inoltre ritenuto irrilevante lo scopo di beneficenza dell'impiego dei fondi, perché per qualificare l'imprenditore contano il metodo economico dell'attività e non la destinazione dei risultati.

La Corte d'Appello di Bologna (sentenza del 12 giugno 1962) confermò il dispositivo, e quindi il fallimento, ma riformò la motivazione: la nozione di attività bancaria è **unica** ed è quella della legge speciale, che richiede la compresenza di raccolta ed esercizio del credito. L'art. 2195, n. 4, c.c. si limita a stabilire quali imprenditori sono soggetti a iscrizione nel registro delle imprese, senza voler modificare la nozione di impresa bancaria né le condizioni per esercitarla. Giuffrè aveva raccolto in modo sistematico e indiscriminato (tramite una rete capillare di fiduciari e di intermediari ecclesiastici) ma non esercitava il credito: finanziava le opere edilizie senza alcun obbligo di restituzione a carico dei beneficiari, e l'unico finanziamento documentato era un fatto isolato e occasionale. Non era quindi banchiere, ma restava imprenditore commerciale in quanto intermediario nella circolazione del bene "denaro" (art. 2195, n. 2, c.c.), e come tale fallibile.

Dalla massima della Corte, per cui la raccolta non accompagnata dall'esercizio del credito, e del pari l'esercizio del credito con mezzi propri, non costituiscono se praticati disgiuntamente attività bancaria, discendono due ipotesi che oggi il TUB disciplina a parte: le società finanziarie che erogano senza raccogliere tra il pubblico (Titolo V) e le società che raccolgono risparmio emettendo obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari per impiegarlo nella propria impresa (art. 11, comma 4, lett. c). Se la vicenda si ripetesse oggi, Giuffrè risponderebbe di abusiva raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 130 e non dell'art. 131, perché mancherebbe l'esercizio del credito.

4.3.3. Il dibattito dottrinale: pubblico servizio o attività d'impresa?

Per lungo tempo si è acceso un dibattito fra:

- i sostenitori della tesi per cui le banche dovessero essere **enti pubblici** (i cultori del diritto amministrativo);
- coloro che ritenevano che le banche dovessero essere considerate **al pari delle altre aziende** (prevalentemente cultori del diritto commerciale).

Il **Prof. Massimo Severo Giannini** (esperto di diritto amministrativo) pubblicò un articolo concludendo che l'attività bancaria fosse, secondo lui, un **pubblico servizio**. La nozione di pubblico servizio è cambiata nel tempo: ai tempi della pubblicazione vigeva una nozione **"soggettiva"**, per cui era considerato pubblico servizio ogni servizio effettuato da un soggetto pubblico (all'epoca gran parte delle banche erano banche pubbliche). In quel contesto storico si ritenne quindi che l'attività bancaria integrasse un pubblico servizio.

Non tutte le banche erano però pubbliche. Secondo Giannini, quando l'attività bancaria non veniva esercitata da un soggetto pubblico, la banca privata stava comunque esercitando un servizio pubblico per conto dello Stato tramite **concessione** (**teoria della riferibilità mediata**): l'attività bancaria viene riferita allo Stato direttamente (banche pubbliche) o indirettamente (soggetti privati che non esercitano l'attività nel loro esclusivo interesse, ma esercitando un servizio pubblico per conto dello Stato). In questo modo Giannini giustificava l'esistenza delle banche private qualificandone comunque l'attività come servizio pubblico. Giannini basò la propria teoria sull'art. 1 della precedente legge bancaria, dove raccolta di risparmio ed esercizio del credito erano definite funzioni di interesse pubblico.

Questa tesi fu sempre contestata dai cultori del diritto commerciale: secondo il **Prof. Ferri**, l'attività bancaria era attività d'impresa, deduzione ricavabile dall'art. 2195 c.c. Certamente era un'attività condizionata da interessi pubblici, ma non di per sé un servizio pubblico; la locuzione dell'art. 1 "funzioni di interesse pubblico" non è sinonimo di "servizio pubblico" (altrimenti si compirebbe un'operazione di "ortopedia della norma").

A partire dagli anni '60 cambiò anche la nozione di servizio pubblico, passando da "soggettiva" a **"oggettiva"**: è l'attività in sé a dover essere o meno servizio pubblico. Gli amministrativisti, in base a questa nuova nozione, continuarono a considerare l'attività bancaria un vero e proprio servizio pubblico, basandosi sempre sull'art. 1 della legge bancaria e sull'**art. 47 Cost.**

4.3.4. Il contrasto giurisprudenziale del 1981 e la soluzione legislativa

Normalmente, per dirimere ogni controversia, la Cassazione si pronuncia a Sezioni Unite. Tuttavia:

- nell'autunno del 1981 una pronuncia della **Cassazione penale a Sezioni Unite** sancì che l'attività bancaria fosse un servizio pubblico (a prescindere dal fatto che la banca fosse pubblica o privata), optando per una forma di equiparazione verso l'alto della pena;

- dopo pochissimo tempo (meno di tre settimane) la **Cassazione civile a Sezioni Unite** si pronunciò di nuovo sullo stesso tema, scrivendo tra le motivazioni: *"l'attività bancaria, che come noto ha carattere d'impresa, […]"*.

Neanche le Sezioni Unite riuscirono quindi a risolvere la controversia. La questione fu risolta dal punto di vista legislativo con il **d.p.r. 350/85** (in recepimento della prima direttiva banche), in cui viene scritto che l'attività bancaria ha carattere d'impresa.

Nella dottrina, comunque, tutti erano convinti di avere avuto ragione: secondo gli amministrativisti era stata necessaria una norma per sancire che l'attività bancaria fosse attività d'impresa (quindi prima non lo era pacificamente); secondo i cultori del diritto commerciale la norma aveva solo ribadito un concetto già acquisito.

Il carattere d'impresa non esclude l'interesse pubblico: l'art. 47 Cost., la riserva di attività, l'autorizzazione e la vigilanza sono tutti modi con cui un interesse pubblico condiziona un'impresa privata, e la formula dell'art. 10 non lo nega ma gli assegna una tecnica diversa dalla qualificazione dell'attività come servizio pubblico. Il carattere d'impresa è riferito all'attività e non al soggetto, e vale quindi a prescindere dalla natura pubblica o privata della banca. Neppure la liquidazione coatta amministrativa delle banche (art. 80 ss.) è oggi la conseguenza di una natura pubblicistica dell'attività. *(pagina 1–3)*

4.4. Art. 10 comma 2: la riserva di attività bancaria

Comma 2: *"L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche."*

L'esercizio dell'attività bancaria nell'ordinamento italiano **non è libero**: occorre avere ottenuto una specifica autorizzazione. È vero che nell'articolo non si fa esplicito riferimento a un'autorizzazione, ma se l'attività bancaria è riservata alle banche, e queste sono imprese autorizzate, allora l'autorizzazione è un presupposto necessario.

Nel nostro ordinamento le attività riservate possono essere esercitate solo dai soggetti autorizzati. La violazione della riserva di attività costituisce in Italia il **reato di esercizio abusivo** (art. 131 TUB), il cosiddetto **abusivismo bancario**.

Il nostro ordinamento riserva l'attività bancaria nel suo complesso e, separatamente, anche **l'attività di raccolta** e **quella di erogazione del credito**.

La riserva si articola quindi su più livelli, ciascuno con il proprio presidio: l'art. 10, comma 2, riserva alle banche il binomio; l'art. 11, comma 2, vieta ai soggetti diversi dalle banche la sola raccolta tra il pubblico; l'art. 106, comma 1, riserva agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti in un albo tenuto dalla Banca d'Italia *"l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma"*, cioè la sola erogazione. A questi si aggiungono, per segmenti più specifici, l'art. 114-bis, comma 1 (emissione di moneta elettronica, riservata a banche e istituti di moneta elettronica) e l'art. 114-sexies (servizi di pagamento, riservati a banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento). Presidiare solo il binomio consentirebbe di eludere la riserva scomponendo l'attività: il pericolo per il risparmio si manifesta già

con la sola raccolta rimborsabile, quello per l'ordinato funzionamento del mercato del credito già con la sola erogazione professionale. La sanzione penale segue la stessa scomposizione (artt. 130, 131 e 132).

La riserva opera inoltre su due piani. Sul piano **soggettivo**, solo chi ha ottenuto l'autorizzazione può esercitare l'attività: l'art. 14, comma 3, vieta di dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consta l'autorizzazione, e l'art. 13 impone l'iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Oggi l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 2). Sul piano **oggettivo** la riserva copre il binomio e, come visto, i singoli segmenti.

Il TUB non definisce neppure la concessione di finanziamenti, né dice quando l'attività è svolta nei confronti del pubblico: l'art. 106, comma 3, affida al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di specificare il contenuto dell'attività e le circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico (la fonte attuativa è il d.m. 2 aprile 2015, n. 53). Il requisito è il corrispondente, sul versante dell'erogazione, della "pubblicità" dell'art. 11, comma 2: tiene fuori dalla riserva il finanziamento occasionale o infragruppo, perché la riserva colpisce l'attività e non l'atto isolato.

La riserva, infine, non è a favore dei soli soggetti autorizzati in Italia: le banche dell'Unione europea possono operare nel territorio della Repubblica, con succursali (art. 15, comma 01) o senza stabilirvisi (art. 16, comma 3), per le attività ammesse al mutuo riconoscimento elencate nell'art. 1, comma 2, lett. f), senza una nuova autorizzazione italiana; per le attività non ammesse l'art. 17 rimette alla Banca d'Italia la disciplina del loro esercizio. *(pagina 3)*

4.5. Art. 10 comma 3: attività finanziarie, connesse e strumentali

Comma 3: *"Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge."* (Nota: sarebbe stato preferibile scrivere "possono esercitare" anziché "esercitano".)

La banca deve necessariamente svolgere attività bancaria, ma può svolgere anche altre attività: **attività finanziarie**, **connesse** o **strumentali** (salve le riserve di legge). L'articolo parla di **ogni altra** attività finanziaria, il che implica che, per il TUB, l'attività bancaria è essa stessa una forma di attività finanziaria (altrimenti non si sarebbe usata la locuzione "ogni altra").

Inoltre l'attività bancaria non deve neanche essere prevalente nell'oggetto sociale della banca (ad esempio Banca Mediolanum svolge prevalentemente attività finanziaria). L'oggetto sociale di una banca, tuttavia, non è libero: può comprendere solo attività bancaria, finanziaria, connessa o strumentale.

Il fatto che le banche possano svolgere altre attività oltre a quella bancaria ha portato la dottrina a distinguere fra **attività bancaria** e **attività delle banche**, distinzione che non è però presente nel testo del TUB.

Ciò che non può mai mancare è l'attività bancaria in quanto tale: se venisse meno del tutto verrebbe meno il presupposto dell'autorizzazione, e infatti l'art. 14, comma 3-bis, lett. c), prevede la revoca quando sia accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi. Il vincolo riguarda quindi la permanenza, non la prevalenza.

Le tre categorie, definite singolarmente:

- **Attività finanziaria**: il TUB contiene tre riferimenti all'attività finanziaria (uno in questo articolo, uno ai sensi dell'art. 59 relativo ai gruppi bancari, uno all'art. 1; un tempo ve n'era un quarto nel previgente art. 106 relativo ai soggetti operanti nel settore finanziario). Ci si può basare sull'art. 1, dove viene specificato che *"il TUB rinuncia a fornire una definizione di attività finanziaria"*: si sceglie quindi una definizione di finanziarietà comunemente accolta. Come detto, implicitamente per il TUB l'attività bancaria è attività finanziaria. Sono infine fatte salve le riserve di legge.
- **Attività connesse**: tutte le attività che presentano una connessione con l'attività bancaria o con quella finanziaria (facendo attenzione a non svolgere attività incompatibili). Esempi: una ricarica telefonica effettuata presso un bancomat; l'erogazione di un finanziamento per l'acquisto di un'automobile; la vendita di un biglietto per una crociera sotto forma di credito al finanziamento.
- **Attività strumentali (o ausiliarie)**: attività svolte dalla banca strumentali allo svolgimento dell'attività bancaria (o finanziaria). Esempi: corsi di aggiornamento per il personale; attività tipografica per la stampa dei moduli.

Alle attività strumentali si ricollega la nozione di «società strumentali» dell'art. 59, comma 1, lett. c), che rinvia all'art. 4, par. 1, punto 18, del reg. (UE) 575/2013: l'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà o nella gestione di immobili, nell'elaborazione dati o in altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti. Ai corsi di aggiornamento e alla stampa dei moduli si affiancano così, come esempi tipici, la gestione immobiliare e l'elaborazione dati.

Un ancoraggio indiretto per la nozione di attività finanziaria, che il TUB non definisce, è l'elenco delle attività ammesse al mutuo riconoscimento dell'art. 1, comma 2, lett. f), che comprende quindici voci (dalla raccolta di depositi e dalle operazioni di prestito al leasing finanziario, ai servizi di pagamento, alle garanzie, alle operazioni in strumenti finanziari, alla gestione di patrimoni e alla custodia di valori mobiliari) e funziona di fatto come catalogo delle attività finanziarie tipiche. Non è l'elenco delle attività bancarie: delimita il passaporto europeo, mentre l'attività bancaria resta quella dell'art. 10, comma 1.

Poiché l'attività bancaria è essa stessa attività finanziaria, il confine fra banche e intermediari finanziari dipende dalla fonte di provvista e non dalla natura dell'attività, che è finanziaria per entrambi: la banca impiega fondi raccolti a titolo di debito presso il pubblico, l'intermediario dell'art. 106 no. Per questo l'art. 11, comma 4-quater, consente al CICR di stabilire criteri e limiti per la raccolta di chi concede finanziamenti al pubblico, a tutela della riserva dell'attività bancaria.

La clausola finale, *"sono salve le riserve di attività previste dalla legge"*, distingue due situazioni. Alcune riserve il TUB le attribuisce alla banca in quanto tale, e per esse non serve alcun titolo ulteriore: la banca non deve iscriversi all'albo dell'art. 106 per concedere finanziamenti, perché l'erogazione è uno dei due termini della sua attività tipica; l'emissione di moneta elettronica le è riservata, insieme agli istituti di moneta elettronica, dall'art. 114-bis, comma 1, e i servizi di pagamento le sono riservati, insieme agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento, dall'art. 114-sexies, comma 1. Altre riserve appartengono a discipline di settore diverse dal TUB, e la banca deve procurarsi il titolo che quella disciplina richiede, *"secondo la disciplina propria di ciascuna"*.

L'esempio principale sono i servizi di investimento, riservati dal d.lgs. 58/1998 (TUF). Il TUB riconosce che l'attività di investimento fa parte del mestiere bancario (nell'elenco dell'art. 1, comma 2, lett. f), compaiono le operazioni in strumenti finanziari, la partecipazione alle emissioni, la gestione di patrimoni e la custodia di valori mobiliari: nn. 7, 8, 11 e 12), ma non ne disciplina l'esercizio, che resta al TUF; lo stesso rinvio compare, per gli intermediari finanziari, nell'art. 106, comma 2, lett. b), che consente di prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del TUF. Una banca che presti servizi di investimento senza l'abilitazione richiesta risponde secondo le norme di quel sistema e non secondo gli artt. 130-132. Un'attività connessa non può inoltre servire a svolgere, sotto altro nome, un'attività che la legge riserva a un titolo di cui la banca non dispone. *(pagina 3–4)*

4.6. Art. 11: la raccolta del risparmio

L'art. 11 è una norma **"nuova"**, in quanto non esiste una norma corrispondente nella vecchia legge bancaria: questa infatti non poneva la riserva di attività sulla singola attività di raccolta di risparmio, ma solo sull'attività bancaria nel suo complesso (binomio).

Per la raccolta del risparmio e per l'erogazione del credito il legislatore ha adottato un approccio opposto:

- per la **raccolta di risparmio** esiste una definizione, ma non viene scritto nulla circa i soggetti che esercitano questa attività senza erogare credito;
- per l'**esercizio del credito** non esiste una definizione nel TUB (esiste però nelle norme secondarie), ma esiste una disciplina puntuale dei soggetti che erogano credito senza raccogliere risparmio.

4.6.1. Comma 1 — la definizione

"Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma."

Il legislatore parla appositamente di "fondi", "depositi" e "altra forma" in maniera generica, senza inserire tecnicismi, perché ciò che conta è l'**obbligo di rimborso**: se chi svolge attività di raccolta non si obbliga a restituire quanto raccolto, non si tratta di raccolta di risparmio ai sensi del TUB.

La normativa secondaria precisa il contenuto dell'obbligo di rimborso con finalità dichiaratamente antielusive delle riserve di attività, presidiate da sanzioni penali (Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, in attuazione delle deliberazioni del CICR). L'obbligo sussiste anche quando tempi ed entità del rimborso sono condizionati da clausole di postergazione o dipendono da parametri oggettivi, compresi quelli legati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare per cui i fondi sono stati acquisiti; e sussiste anche quando, benché escluso o non previsto esplicitamente, sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari dell'operazione (entità, periodicità ed esigibilità dei flussi possono dare luogo di fatto a forme di rimborso). Non costituiscono invece obbligo di rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti dell'impresa né la ripartizione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione: è la linea di confine fra debito e capitale di rischio. Il criterio di qualificazione è sostanziale, perché la distinzione va operata "avendo riguardo alla complessiva struttura finanziaria dell'operazione concretamente posta in essere, indipendentemente dalla configurazione giuridica assunta dalla medesima": conta la sostanza economica e non il nomen iuris.

4.6.2. Comma 2 — la riserva e il requisito della "pubblicità"

"La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche."

Questo comma esplicita la **riserva di attività**. A differenza del comma 1, qui si parla di raccolta di risparmio "fra il pubblico": la riserva di attività richiede quindi il requisito della **pubblicità**.

Nella pratica non è sempre facile distinguere cosa sia "risparmio fra il pubblico" e cosa no; le disposizioni di vigilanza hanno chiarito che si può parlare di risparmio fra il pubblico solo quando la contrattazione avviene sulla base di **rapporti standardizzati**; quando vi sono trattative personalizzate, non si può parlare di risparmio fra il pubblico.

Il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 (Sezione III, par. 2) elenca le acquisizioni di fondi che non costituiscono raccolta tra il pubblico:

- quella connessa con l'emissione di moneta elettronica o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per servizi di pagamento (commi 2-bis e 2-ter);
- quella connessa con l'emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento (ad esempio le carte prepagate) utilizzabili solo presso la sede dell'emittente o, in base a un accordo commerciale, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi;
- la raccolta presso soci, dipendenti o società del gruppo (v. comma 3);
- la raccolta effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali l'operazione si inserisce di norma in una gamma più ampia di rapporti economici con il soggetto finanziato;
- l'acquisizione presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale: l'investitore professionale vigilato non è un risparmiatore da tutelare con la riserva.

La pubblicità non dipende dal numero dei contraenti ma dal modo in cui si arriva al contratto:

è pubblico ciò che è offerto in modo indifferenziato e standardizzato a una platea aperta. Le trattative personalizzate non sono però una franchigia illimitata: dal contratto deve risultare con chiarezza la natura di finanziamento del rapporto, e numerosità e frequenza delle operazioni non devono configurare di fatto una raccolta tra il pubblico: una trattativa individuale usata come schema seriale non salva chi la adotta.

Esempi di vicende avvenute in Italia:

- **Casse di mutualità in Campania e Basilicata**: alcuni soggetti raccoglievano fondi con obbligo di rimborso e li mettevano a disposizione di soggetti in difficoltà. L'attività era svolta in forma di società cooperativa e i fondi venivano raccolti fra i soci; ma per diventare soci bastava essere cittadini italiani, quindi si trattava a tutti gli effetti di una raccolta "fra il pubblico". I responsabili sono stati condannati per abusivismo bancario.
- **Banca Matica**: alcuni imprenditori vicentini avevano creato dei Totem, situati in grandi centri di aggregazione, che permettevano, previa registrazione del cliente, di depositare monete. Le monete conferivano punti utilizzabili per acquisti di "premi" da un catalogo. Furono indagati per abusivismo bancario, ma mancavano sia l'obbligo di rimborso sia l'erogazione del credito (al massimo si poteva parlare di una vendita a rate). Fu invece contestato l'abuso di denominazione bancaria (reato bancario, oggi depenalizzato e trasformato in sanzione amministrativa): è vietato l'uso della parola "banca", "banche" ecc. quando ciò possa indurre in errore il pubblico facendogli credere di trovarsi di fronte a una banca autorizzata.
- **Casse peote**: antichissime istituzioni della tradizione veneziana, nate per evitare che i marinai sperperassero i propri stipendi. Gli stipendi venivano affidati a un uomo sulla barca, il **tesoriere**, che li riconsegnava una volta tornati a terra. A causa della sfiducia verso le banche, in alcuni casi il tesoriere raccoglieva i risparmi delle persone per poi comprare regali da distribuire ai figli dei depositanti in occasione di una festa organizzata per l'Epifania: attività lecita, poiché non vi era obbligo di rimborso. In altri casi, però, le somme raccolte venivano investite (e talvolta perse): Banca d'Italia ricordò che tale esercizio era vietato, in quanto costituiva esercizio abusivo di Sicav. Nonostante un progetto di legge regionale non sia andato a buon fine, il legislatore ha apportato apposite modifiche all'art. 155 TUB (attualmente abrogato); una parte di queste modifiche sopravvive nell'**art. 112, comma 7, TUB**, che riguarda proprio le casse peote veneziane: queste infatti non sono definite banche, costituiscono una categoria ad esaurimento e non hanno scopo di lucro.

Lo stesso criterio governa il social lending (lending based crowdfunding), cioè la richiesta di fondi rimborsabili, per uso personale o per finanziare un progetto, che una pluralità di soggetti rivolge a una pluralità di finanziatori tramite piattaforme on-line. Il Provvedimento lo ammette nel rispetto delle riserve di attività e distingue tre posizioni. Il **finanziatore** di regola non viola alcuna riserva, perché l'art. 106, comma 1, colpisce soltanto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, che presuppone professionalità e sistematicità. Il **gestore** del portale non può limitarsi a incassare i fondi: la ricezione non è raccolta tra il pubblico solo se i fondi sono inseriti in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per servizi di pagamento, o sono connessi all'emissione di moneta elettronica, e il gestore è autorizzato

come istituto di pagamento, istituto di moneta elettronica o intermediario finanziario abilitato ai servizi di pagamento (art. 106, comma 2, lett. a). Il **prenditore** evita la qualificazione di raccolta tra il pubblico soltanto se le trattative sono realmente personalizzate, cioè se prenditori e finanziatori possono incidere con la propria volontà sulle clausole del contratto e il gestore si limita a supportare le trattative: deve quindi servirsi di piattaforme che assicurino questo carattere ed essere in grado di dimostrarlo. Restano in ogni caso precluse a gestori e prenditori la raccolta a vista e quella collegata a mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata: è il limite che il comma 5 pone per le deroghe del comma 4 e che la normativa secondaria estende.

4.6.3. Commi 2-bis e 2-ter — le esclusioni dalla fattispecie

Comma 2-bis: *"Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica."*

Comma 2-ter: *"Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento."*

Sono **esclusioni dalla fattispecie** e non deroghe al divieto: quei fondi non sono raccolta tra il pubblico, e la questione del divieto non si pone neppure. Nel comma 4, invece, la raccolta tra il pubblico c'è ma il divieto non si applica; la distinzione rileva per il comma 5, che richiama soltanto le deroghe del comma 4, lettere c) e d).

In entrambi i casi il soggetto riceve fondi e ha un obbligo di restituzione (l'istituto di moneta elettronica deve rimborsare la moneta elettronica ai sensi dell'art. 114-ter; l'istituto di pagamento deve eseguire l'ordine o restituire il denaro), ma i fondi non sono destinati all'impiego creditizio: non c'è trasformazione delle scadenze né rischio di credito trasferito sul risparmiatore, ma soltanto custodia di disponibilità monetarie destinate al pagamento. Viene meno il presupposto economico della riserva bancaria, e il legislatore circonda queste attività di presidi propri. L'art. 114-quater, comma 2, impone agli istituti di moneta elettronica di trasformare immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti; l'art. 114-bis, comma 3, vieta all'emittente di concedere interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica, per impedire che questa diventi un surrogato del deposito bancario. Il Provvedimento dell'8 novembre 2016 riprende queste esclusioni e vi aggiunge gli strumenti di pagamento utilizzabili solo presso l'emittente o in una rete limitata.

4.6.4. Comma 3 — i limiti fissati dal CICR

"Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro."

Il CICR stabilisce, tramite limiti e criteri, i casi nei quali la raccolta di risparmio **non** è considerata avvenire fra il pubblico (ad esempio in ragione di rapporti societari o di lavoro).

La disciplina di dettaglio è nelle Sezioni V, VI e VII del Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016. Il rapporto societario o di lavoro deve essere preesistente e qualificante, e non un espediente per allargare la platea; la facoltà di raccogliere deve essere prevista nello statuto, e restano comunque precluse la raccolta a vista e ogni forma di raccolta collegata a mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

- **Soci di società diverse dalle cooperative**: nessun limite quantitativo, ma la raccolta è ammessa solo presso soci che detengano almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. I due requisiti sono cumulativi e vanno riferiti al singolo socio finanziatore; nelle società di persone (per le s.a.s., con riguardo ai soli accomandatari) non sono richiesti.
- **Soci di società cooperative**: il presidio è quantitativo. I prestiti sociali non possono eccedere il triplo del patrimonio (capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili, comprese quelle indivisibili fra i soci), limite elevabile al quintuplo se almeno il 30% dei prestiti è assistito da garanzia di soggetti vigilati oppure se la cooperativa aderisce a uno schema di garanzia dei prestiti sociali. I limiti non si applicano alle cooperative con non più di 50 soci. Le cooperative che concedono finanziamenti al pubblico non possono raccogliere presso i soci se non emettendo strumenti finanziari, perché altrimenti la combinazione di raccolta e impiego riprodurrebbe l'attività bancaria.
- **Dipendenti**: la raccolta è ammessa se prevista dallo statuto ed entro il limite complessivo del patrimonio; per le cooperative si cumula con quella presso i soci.
- **Società del gruppo**: nessun limite presso controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e presso società controllate da una stessa controllante, perché la controparte non è un risparmiatore ma un'impresa legata da un rapporto di controllo o collegamento. "Gruppo" è qui il gruppo civilistico e non il gruppo bancario degli artt. 60 e 61: serve a escludere la pubblicità della raccolta e non alla vigilanza consolidata.

Il caso delle casse di mutualità mostra che cosa accade quando il rapporto qualificante è solo apparente. La raccolta avveniva formalmente presso i soci, cioè in una delle ipotesi che il comma 3 sottrae alla nozione di raccolta tra il pubblico, ma la qualità di socio era acquisibile da chiunque e non selezionava alcuna categoria: l'esclusione è venuta meno insieme alla qualificazione, e la raccolta è stata ritenuta rivolta al pubblico.

4.6.5. Comma 4 — le deroghe al divieto

"Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica: (…) c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari."

Questo comma è concettualmente diverso dal comma 2: qui si tratta di casi in cui, pur raccogliendo risparmio fra il pubblico, il divieto **non si applica**. Una società di capitali che emette obbligazioni (lett. c) sta raccogliendo risparmio presso il pubblico, ma le è concesso farlo.

Sono molti i soggetti che possono raccogliere senza erogare, soprattutto vista la nascita di titoli ibridi; per questo il TUB non contiene una disciplina specifica per questi casi, a differenza

di quanto accade per l'erogazione del credito.

Le deroghe sono quattro e seguono logiche diverse. Le lett. a) e b) guardano al **soggetto**: il divieto non si applica agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari e agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta è consentita dagli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari (lett. a), né agli Stati terzi e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano (lett. b). Sono la base del debito pubblico e dei prestiti degli organismi sovranazionali, e la lett. b) consente di riconoscere titoli abilitativi non riconducibili al TUB; il testo parla ancora di "Stati comunitari" e non di Stati dell'Unione europea, residuo di coordinamento terminologico. La lett. d) è la norma di chiusura: *"alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio"*, e richiede quindi una fonte primaria e una verifica di compatibilità, non una libera analogia; ne è esempio la raccolta di Poste Italiane.

La lett. c) è condizionata: vale per la raccolta effettuata *"ai sensi del codice civile"*, cioè entro i limiti che il codice civile pone all'emissione (oggi l'art. 2412, primo comma, c.c.: il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato). Se l'emissione viola le norme codicistiche, la deroga non opera e si ricade nel divieto del comma 2, con le conseguenze penali degli artt. 130 e 131. Per la lett. c) le note al testo rinviano anche all'art. 58 della l. 448/1998.

4.6.6. Commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies — i poteri del CICR e delle autorità di vigilanza

I commi successivi attribuiscono poteri di delegificazione sulla raccolta non bancaria al CICR e, per il comma 4-quinquies, alle autorità di vigilanza. Nella formulazione vigente, insieme al comma 3 e alla lett. d) del comma 4, risalgono alla riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 6/2003, nel testo coordinato con il TUB dal d.lgs. 37/2004).

Comma 4-bis: *"Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio."* È un potere di **qualificazione**: conta la funzione economica dello strumento, cioè l'obbligo di rimborso, e non il nome con cui è emesso.

Comma 4-ter: *"Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico."* È un potere di **contenimento quantitativo**; il coinvolgimento della CONSOB si spiega perché durata e taglio incidono sulla circolazione degli strumenti presso i risparmiatori, cioè su un terreno al confine fra la riserva bancaria e la tutela del mercato mobiliare.

Comma 4-quater: *"Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma."* Serve a impedire che l'intermediario del Titolo V si procuri la provvista come

una banca: chi eroga credito al pubblico e si finanzia sul mercato riproduce il binomio fuori dalla riserva.

Comma 4-quinquies: *"A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza."* Se la garanzia che rende collocabile il titolo presso il pubblico è prestata da un investitore professionale, questi deve essere patrimonialmente capiente, altrimenti la tutela è apparente.

La disciplina di dettaglio è nel Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016:

- sono "strumenti finanziari di raccolta" le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti che, comunque denominati e a prescindere dall'attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso (comprese le obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili o di subordinazione); la definizione è volutamente ampia, per evitare elusioni derivanti da una diversa qualificazione giuridica;
- per le società per azioni, in accomandita per azioni e cooperative, l'importo complessivo delle emissioni non può superare il doppio del patrimonio (capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili dell'ultimo bilancio approvato), in linea con l'art. 2412, primo comma, c.c.; il limite è superabile nelle ipotesi derogatorie dello stesso art. 2412 (sottoscrizione da parte di investitori professionali vigilati, destinazione alla quotazione, obbligazioni che danno diritto di acquisire o sottoscrivere azioni, garanzia ipotecaria di primo grado fino a due terzi del valore degli immobili);
- per le s.r.l. e le cooperative cui si applicano le norme sulle s.r.l., le emissioni seguono gli artt. 2483 e 2526 c.c. (sottoscrizione da parte di investitori professionali vigilati o qualificati);
- per gli strumenti diversi dalle obbligazioni è previsto un taglio minimo unitario di 50.000 euro (salvo quelli destinati alla quotazione), e la denominazione non deve ingenerare confusione con i titoli di raccolta bancari, come i certificati di deposito e i buoni fruttiferi;
- le cambiali finanziarie (l. 43/1994) sono strumenti di raccolta: titoli all'ordine emessi in serie, di durata compresa fra 1 e 36 mesi e di valore nominale unitario non inferiore a 50.000 euro; alle banche non è consentito emetterle;
- le società che concedono finanziamenti al pubblico (comma 4-quater) possono emettere strumenti di raccolta nel limite del patrimonio; se iscritte nell'albo dell'art. 106, fino al doppio del patrimonio, elevabile al quintuplo per gli strumenti destinati alla quotazione.

4.6.7. Comma 5 — il nucleo irriducibile della riserva

Comma 5: *"Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata."*

È il limite che le deroghe non possono superare: si possono consentire forme di raccolta non bancaria, ma non si può consentire a un soggetto non bancario di replicare il conto corrente. Il

testo riguarda solo le lett. c) e d): ne restano fuori le lett. a) e b) e le ipotesi dei commi 2-bis, 2-ter e 3, nelle quali non si è mai entrati nel divieto. La normativa secondaria generalizza invece il limite a ogni forma di raccolta non bancaria (soci, dipendenti, gruppo, social lending).

Per il Provvedimento dell'8 novembre 2016 è raccolta a vista quella che può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento, senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore; con preavviso pari o superiore a 24 ore la raccolta è comunque a vista se il soggetto che raccoglie si riserva la facoltà di rimborsare contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso. La definizione è antielusiva: non basta scrivere un preavviso in contratto, occorre che sia effettivo. Il divieto colpisce anche la rappresentazione: nelle comunicazioni al pubblico la raccolta non può essere qualificata come rimborsabile a vista, né come collegata a mezzi di pagamento.

La ratio è duplice. La raccolta a vista è la forma più intensa di esposizione del risparmiatore, perché genera l'aspettativa di una disponibilità immediata e il rischio di corsa agli sportelli, che l'ordinamento fronteggia con presidi riservati alle banche (riserva obbligatoria, requisiti di liquidità, garanzia dei depositi). Inoltre i depositi a vista e i mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata costituiscono moneta bancaria: consentirne la creazione a soggetti non vigilati come banche significherebbe consentire una creazione privata di mezzi di pagamento fuori dal perimetro della vigilanza. "Spendibilità generalizzata" significa che il mezzo è accettato da una platea indeterminata di esercenti; quelli utilizzabili solo presso l'emittente o in una rete limitata restano fuori. *(pagina 4–6)*

4.7. Art. 12: obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche

4.7.1. Comma 1 — l'emissione di obbligazioni

"Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore."

Nel 1993 solo le S.p.A. e le S.a.p.a. potevano emettere obbligazioni: questa norma era quindi una deroga, consentendo alle banche di emettere obbligazioni "in qualunque forma (fossero) costituite". Con la riforma del diritto societario del 2003 è stato concesso a tutte le società di emettere obbligazioni, facendo venire meno l'elemento di specialità di questo articolo: quelle che erano deroghe al diritto comune non sono più tali. È inoltre specificato che possano essere emesse anche obbligazioni convertibili; la convertibilità può essere di due tipi: **diretta** e **indiretta**.

Con l'espressione "in qualunque forma costituite" la norma consentiva l'emissione anche alle banche costituite come società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, una delle due forme ammesse dall'art. 14, comma 1, lett. a). Il comma 2 è abrogato (d.lgs. 415/1996).

4.7.2. Comma 3 — deliberazione dell'emissione e deroghe al codice civile

"L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414 bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile."

Questo comma riguarda le obbligazioni **non convertibili** e quelle **convertibili in titoli di altre società** (convertibilità indiretta). L'emissione è deliberata dall'**organo amministrativo** (come previsto dalla riforma del 2003), mentre nel 1993 tali emissioni erano deliberate dall'assemblea straordinaria nelle società di capitali. La deroga si spiega con il fatto che l'emissione di obbligazioni è attività tipica delle banche.

Per le obbligazioni bancarie non si applicano diversi articoli del codice civile, e altri hanno una disciplina molto diversa:

- **art. 2412**: alle banche non si applicano i limiti quantitativi all'emissione;
- **artt. 2415 e 2417**: per le obbligazioni bancarie non vi sono l'assemblea degli obbligazionisti né il rappresentante comune degli obbligazionisti.

I limiti dell'art. 2412 c.c. proteggono chi sottoscrive i titoli di un emittente non vigilato, ancorando l'indebitamento obbligazionario alla consistenza patrimoniale; per la banca questa tutela è sostituita, e largamente superata, dalla vigilanza prudenziale (requisiti patrimoniali, controlli interni, segnalazioni, poteri di intervento), e la deroga è la contropartita di un regime più severo. Per la banca, inoltre, l'emissione obbligazionaria è un atto ordinario di provvista e non un'operazione straordinaria sul capitale di rischio: per questo la competenza è dell'organo amministrativo e il contrappeso è prudenziale e non assembleare, nella disciplina che la Banca d'Italia detta ai sensi del comma 5.

Ne risultano tre regimi, con gradi diversi di libertà in funzione del titolo posseduto e della vigilanza sopportata: la banca emette obbligazioni in forza dell'art. 12, senza i limiti quantitativi del codice civile; la società non bancaria le emette in forza dell'art. 11, comma 4, lett. c), solo ai sensi del codice civile e quindi entro il limite dell'art. 2412; l'intermediario del Titolo V si colloca in mezzo, con i criteri e i limiti che il CICR può fissare in base all'art. 11, comma 4-quater. L'art. 12 non deroga alla riserva ma la presuppone: disciplina lo statuto della banca già autorizzata e non allarga la platea di chi può raccogliere.

4.7.3. Comma 4 — la convertibilità diretta

"Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412."

Questo comma riguarda la **convertibilità diretta**: in questo caso, eccetto i limiti quantitativi (art. 2412), si applica la disciplina di diritto comune: vi sarà quindi, ad esempio, l'assemblea degli obbligazionisti.

La disciplina delle obbligazioni convertibili in via diretta differisce marcatamente da quella delle altre perché la loro emissione induce un **aumento di capitale** sottostante, che costituisce

modifica dell'atto costitutivo e richiede pertanto l'assemblea straordinaria.

4.7.4. Commi 4-bis e 5 — strumenti assimilati e disciplina della Banca d'Italia

Comma 4-bis: *"I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis."* Il regime dei commi 3 e 4 si estende quindi agli strumenti che il codice civile assoggetta alla disciplina delle obbligazioni, compresi i cosiddetti senior non-preferred.

Comma 5: *"La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni."* È un altro caso di delegificazione, come i commi 6 e 7.

4.7.5. Comma 6 — i titoli di deposito

"Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia può disciplinarne le modalità di emissione."

I titoli di deposito più diffusi sono i **certificati di deposito (CD)**; le disposizioni di vigilanza dettano legge, in quanto questo articolo prevede delegificazione.

Per obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi le caratteristiche degli strumenti sono fissate dalla normativa secondaria (Istruzioni di vigilanza, Circ. 229, Titolo V, Capitolo 3, "Raccolta in titoli delle banche", oggi in larga parte superate dalla Circ. 285 e dalla disciplina europea dei fondi propri), mentre l'art. 12 non contiene soglie né durate. Per le obbligazioni era prevista una durata originaria minima di trentasei mesi (o inferiore, purché la durata media non fosse inferiore a ventiquattro) e il divieto di emettere titoli denominati "obbligazioni" con caratteristiche diverse da quelle prescritte, o con quelle caratteristiche ma diversamente denominati; per i certificati di deposito e i buoni fruttiferi, una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni. Le durate minime non tutelano il sottoscrittore ma la stabilità della banca emittente, perché impediscono che la raccolta in titoli si trasformi in raccolta di fatto a breve o a vista, in concorrenza con i depositi e senza le tutele che li assistono; il limite di cinque anni per i certificati di deposito impedisce invece che un deposito cartolarizzato diventi un'obbligazione priva della relativa disciplina. Il divieto di denominazioni difformi è la versione settoriale della logica antielusiva della riserva di denominazione dell'art. 133: nell'ordinamento bancario il nome dello strumento orienta le aspettative del pubblico.

I titoli di deposito non possono essere emessi da soggetti non bancari: incorporano un obbligo di rimborso e rientrano pienamente nella raccolta dell'art. 11, comma 1, sicché emetterli fuori dalla riserva, nei confronti del pubblico, integra l'abusiva raccolta dell'art. 130. Specularmente, alle banche non è consentita l'emissione di cambiali finanziarie, strumento di raccolta delle imprese non bancarie.

4.7.6. Comma 7 — i prestiti subordinati

"La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito."

Non è necessario che i prestiti subordinati assumano la forma di obbligazioni, ma è comunque la forma più usata. Le categorie sono due:

- **Prestito subordinato**: le obbligazioni subordinate possono essere rimborsate solo dopo che sono stati rimborsati tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. L'obbligazionista subordinato è quindi un creditore gerarchicamente inferiore. Le obbligazioni subordinate sono più rischiose e presentano perciò un rendimento più elevato. Nonostante questa maggiore rischiosità, il motivo per cui alcune banche le emettono è che, entro certi limiti, rientrano nel computo dei **fondi propri**.
- **Obbligazioni irredimibili**: sono sempre obbligazioni subordinate, ma rimborsabili soltanto previa autorizzazione di Banca d'Italia.

Il caso Veneto Banca: la banca, in un periodo di crisi, aveva deciso di vendere ai propri clienti (per lo più retail) obbligazioni subordinate, affermando che, essendo obbligazioni, sarebbero state sicure quanto un qualunque titolo di Stato. La banca fallì successivamente e i clienti non ottennero indietro neanche un euro. Ciò accadde perché mancava una normativa che riservasse la vendita delle obbligazioni subordinate soltanto alla clientela qualificata.

I prestiti baciati: erano finanziamenti a condizioni molto favorevoli erogati dalle banche in cambio della sottoscrizione, da parte del cliente, di proprie obbligazioni subordinate o azioni.

Interventi statali/UE: benché non vi sia altra disciplina specifica sulle obbligazioni bancarie e siano vietati gli aiuti di Stato, in situazioni particolari l'UE può autorizzare l'emissione di obbligazioni sottoscritte dallo Stato. In passato sono stati emessi:

- i **Tremonti Bonds** (utilizzati da MPS e pochi altri): non costituivano un vero e proprio aiuto di Stato, poiché le banche emettevano obbligazioni sottoscritte dallo Stato ma con un privilegio sul loro rimborso a favore dello Stato stesso; erano gravose per le banche e poco appetibili;
- i **Monti Bonds**, più appetibili dei precedenti.

4.7.7. Artt. 12-bis e 12-ter — strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale minimo

Sul collocamento di strumenti subordinati presso la clientela al dettaglio, di cui il caso Veneto Banca è un esempio, incide oggi l'**art. 12-ter**. Il comma 1 fissa in almeno **euro 200.000** il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca; il comma 2 fissa in almeno **euro 150.000** quello degli strumenti di debito chirografario di secondo livello dell'art. 12-bis; il comma 3 estende le due soglie agli stessi strumenti emessi da soggetti diversi dalle banche ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 180/2015. L'articolo è stato inserito dal d.lgs. 193/2021 e si applica solo alle obbligazioni e agli strumenti

di debito emessi dopo l'entrata in vigore del decreto. Il taglio minimo non vieta formalmente il collocamento al dettaglio, ma lo rende praticamente inaccessibile al piccolo risparmiatore. Le soglie sono due, e la più alta riguarda il subordinato, che nella graduazione dell'art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis), è posposto anche ai chirografari di secondo livello; questi ultimi sono a loro volta soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari.

L'**art. 12-bis** definisce gli **strumenti di debito chirografario di secondo livello** (senior non-preferred): obbligazioni e altri titoli di debito, emessi da una banca o da uno degli altri soggetti dell'art. 2 del d.lgs. 180/2015, che hanno tre caratteristiche: una durata originaria di almeno dodici mesi; l'assenza di natura derivata, di collegamento con strumenti derivati e di caratteristiche proprie dei derivati; l'indicazione, nella documentazione contrattuale e nell'eventuale prospetto, che rimborso del capitale e pagamento degli interessi sono disciplinati secondo l'art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis), che li colloca dopo tutti gli altri crediti chirografari e prima dei crediti subordinati. Le clausole difformi sono nulle senza che la nullità travolga il contratto (comma 2); una volta emessi, gli strumenti non possono essere modificati in modo da far venire meno tali caratteristiche e ogni pattuizione difforme è nulla (comma 3); la Banca d'Italia può disciplinarne l'emissione e le caratteristiche (comma 4). *(pagina 6–8)*

4.8. Cenni all'art. 129: emissione di strumenti finanziari

Un breve cenno all'**art. 129**, rubricato *"Emissione di strumenti finanziari"*. È l'unico articolo presente nel Titolo VII del TUB ("Altri controlli").

Nella sua formulazione originaria l'articolo era molto diverso: parlava di **"valori mobiliari"**. Quando una società emetteva valori mobiliari di importo consistente (valore superiore a 10 miliardi di lire), era necessario comunicarlo a Banca d'Italia, che poteva autorizzare, vietare o sospendere l'emissione.

Comma 1 (testo attuale): *"La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari."*

Attualmente Banca d'Italia interviene soltanto in via **consuntiva** sugli strumenti finanziari già emessi, senza alcuna forma di autorizzazione preventiva. Non si parla più inoltre di "valori mobiliari" ma di **strumenti finanziari**, categoria più ampia: i valori mobiliari sono infatti una sotto-categoria di strumenti finanziari, che a loro volta sono una sotto-categoria di prodotti finanziari (forse avrebbe avuto più senso parlare direttamente di "prodotti", visto che sono citati subito dopo nel testo dell'articolo).

Comma 2: *"La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo."* Le disposizioni attuative sono state adottate con il provvedimento della Banca d'Italia del 25 agosto 2015.

L'art. 129 non istituisce alcuna riserva di attività, non prevede alcun albo e non ha una fattispecie penale corrispondente nel Capo I del Titolo VIII: è un potere di osservazione del

mercato, non un filtro all'accesso. Il destinatario non è una categoria di soggetti autorizzati ma *"chi emette od offre strumenti finanziari"*, chiunque sia. Le informazioni sono, per espressa previsione, a carattere consuntivo: si guarda a ciò che è già avvenuto e non si autorizza ciò che deve avvenire. La finalità è conoscitiva, non prudenziale né di tutela del singolo risparmiatore. L'articolo sta nel Titolo VII e non nel Titolo III, dedicato alla vigilanza, ed è distinto dalla disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, che appartiene al TUF e alla CONSOB.

Il d.lgs. 303/2006 ha sostituito l'art. 129 e abrogato l'art. 143. Oggi l'inosservanza dell'art. 129, comma 1, rientra tra le violazioni sanzionate in via amministrativa dall'art. 144, comma 1, lett. a), ma soltanto nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea di quel comma (banche, intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, istituti di pagamento e di moneta elettronica e gli altri soggetti elencati): per l'emittente che non rientra fra quei soggetti l'art. 144, comma 1, non prevede alcuna sanzione.

Quanto al rapporto con l'art. 11, il comma 4-bis attribuisce al CICR il potere di determinare i criteri per individuare gli strumenti finanziari la cui emissione costituisce raccolta del risparmio, qualificazione che serve alla riserva; l'art. 129 consente invece di acquisire dati consuntivi su ciò che viene emesso, a fini conoscitivi, e non genera fattispecie. *(pagina 8)*

4.9. Artt. 130-133: l'abusivismo bancario e finanziario (Titolo VIII, Capo I)

Il Capo I del Titolo VIII del TUB, intitolato *"Abusivismo bancario e finanziario"*, comprende gli artt. da 130 a 133. È costruito **per specularità**: a ciascuna riserva di attività corrisponde una fattispecie incriminatrice (artt. 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132), alla quale si aggiungono la denunzia al pubblico ministero e al tribunale (art. 132-bis) e la riserva di denominazione (art. 133). La violazione della riserva integra quindi un reato e non soltanto un illecito amministrativo.

Norma	Rubrica	Riserva presidiata	Sanzione (testo del TUB)
art. 130	Abusiva attività di raccolta del risparmio	art. 11 (raccolta tra il pubblico)	arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da euro 12.911 a euro 51.645
art. 131	Abusiva attività bancaria	artt. 10 e 11 (raccolta ed esercizio del credito)	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.065 a euro 10.329
art. 131-bis	Abusiva emissione di moneta elettronica	art. 114-bis	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.066 a euro 10.329
art. 131-ter	Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento	art. 114-sexies	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.066 a euro 10.329
art. 132	Abusiva attività finanziaria	artt. 106, 107, 111 e 112	reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 2.065 a euro 10.329
art. 132-bis	Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale	tutte le precedenti	provvedimenti dell'art. 2409 c.c.

Norma	Rubrica	Riserva presidiata	Sanzione (testo del TUB)
art. 133	Abuso di denominazione	riserve di denominazione	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro

Le cifre sono quelle che il testo del TUB riporta per le pene; la nota al Titolo VIII richiama l'art. 39, comma 1, della l. 262/2005 (la legge sul risparmio), secondo cui le pene previste dal TUB sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

L'art. 130 è una **contravvenzione** (arresto e ammenda), gli artt. 131, 131-bis, 131-ter e 132 sono **delitti** (reclusione e multa), l'art. 133 è un illecito amministrativo. La graduazione riflette la gravità crescente dell'aggressione alla riserva: la sola raccolta abusiva non realizza ancora la trasformazione del risparmio in credito che è propria della banca, ed è l'aggiunta dell'esercizio del credito a giustificare il salto dalla contravvenzione al delitto.

4.9.1. Artt. 130 e 131 — raccolta abusiva e abusiva attività bancaria

Art. 130: *"Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 è punito […]"*. **Art. 131**: *"Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 ed esercita il credito è punito […]"*.

Gli elementi dell'art. 130 sono tre: lo svolgimento di un'**attività**, cioè di una condotta reiterata e non occasionale; la **raccolta del risparmio** come definita dall'art. 11, comma 1, cioè l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, in mancanza del quale non vi è raccolta ai sensi del TUB; il carattere **pubblico** della raccolta, richiesto dall'art. 11, comma 2, e assente nel comma 1. La raccolta non pubblica non è di per sé reato, e non lo è neppure quella che ricade nelle esclusioni dei commi 2-bis, 2-ter e 3 o nelle deroghe del comma 4, purché ne siano rispettati i limiti.

L'art. 131 riproduce la formulazione dell'art. 130 e vi aggiunge l'esercizio del credito: recepisce la nozione di attività bancaria dell'art. 10, comma 1, e ne fa la propria fattispecie tipica, sicché è il binomio, e non uno dei due termini, a integrare il reato più grave. Secondo la Cassazione (caso Romanelli) è un reato complesso che include in sé l'art. 130: l'abusiva raccolta può essere contestata sia ai sensi dell'art. 130 sia ai sensi dell'art. 131, e la riqualificazione in corso di giudizio da una fattispecie all'altra non lede il diritto di difesa. È inoltre un reato permanente, e il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dell'attività abusiva (art. 158 c.p.) e non dal primo atto di raccolta.

Le tre situazioni possibili sono così coperte: chi raccoglie tra il pubblico senza erogare risponde dell'art. 130; chi eroga nei confronti del pubblico senza raccogliere risponde dell'art. 132; chi fa entrambe le cose risponde dell'art. 131. La simmetria è con le riserve: art. 11 per la raccolta, art. 106 per l'erogazione, art. 10 per il binomio.

4.9.2. Art. 132 e le fattispecie speciali — abusiva attività finanziaria, moneta elettronica, servizi di pagamento

Art. 132: *"Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito […]".*

La condotta ha per oggetto le "attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1": poiché quel comma oggi ne prevede una sola, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la norma è sostanzialmente monofattispecie e il plurale è un residuo della formulazione anteriore. L'elemento negativo è triplice: manca l'autorizzazione dell'art. 107 (intermediari finanziari), oppure l'iscrizione dell'art. 111 (microcredito), oppure quella dell'art. 112 (confidi e altri soggetti); l'art. 132 copre quindi anche la violazione delle riserve minori ritagliate all'interno dell'art. 106. L'esercizio "nei confronti del pubblico" ricalca l'art. 106 e ne condivide la definizione, rimessa al Ministro dell'economia e delle finanze: chi presta denaro a un singolo conoscente non commette il reato, esattamente come non è raccolta tra il pubblico quella nata da trattative personalizzate. La norma non punisce l' "esercizio abusivo del credito" in quanto tale: rinvia alle attività dell'art. 106 e ne richiede lo svolgimento verso il pubblico. L'intermediario regolarmente iscritto non viola l'art. 132 concedendo finanziamenti, ma risponde dell'art. 131 se a quell'attività aggiunge la raccolta del risparmio tra il pubblico, che gli è vietata.

Le due fattispecie speciali seguono la stessa logica per riserve distinte. L'art. 131-bis punisce chi emette moneta elettronica in violazione della riserva dell'art. 114-bis senza essere iscritto negli albi previsti; l'art. 131-ter punisce chi presta servizi di pagamento in violazione della riserva dell'art. 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell'art. 114-novies.

4.9.3. Art. 132-bis — la denunzia al pubblico ministero e al tribunale

Art. 132-bis: *"Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società."* Il riferimento all'UIC è un residuo: nell'art. 1, comma 1, la lett. f) è soppressa e il TUB non definisce più l'UIC.

La norma collega la vigilanza bancaria al diritto societario. La società che opera abusivamente non è vigilata, perché non è iscritta ad alcun albo, e la Banca d'Italia non ha quindi nei suoi confronti i poteri informativi e ispettivi che il TUB riserva ai soggetti vigilati. L'unico potere che le resta è attivare, direttamente o tramite il pubblico ministero, il controllo giudiziario sulla gestione dell'art. 2409 c.c., che consente al tribunale di disporre l'ispezione dell'amministrazione della società e, nei casi più gravi, di revocare amministratori e sindaci e di nominare un amministratore giudiziario. La soglia è il "fondato sospetto" e non la prova, in coerenza con la natura cautelare dell'intervento; le spese dell'ispezione a carico della società hanno funzione dissuasiva.

Il limite strutturale è che la norma presuppone una **società**: il controllo dell'art. 2409 c.c. non è attivabile nei confronti di una persona fisica, ed è per questo che nel caso Giuffrè sarebbe stato inservibile.

4.9.4. Art. 133 — l'abuso di denominazione

Comma 1: *"L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche."*

È la **riserva di denominazione**: tutela l'affidamento del pubblico e non il nome commerciale, e per questo colpisce chiunque, a prescindere dal fatto che eserciti o meno attività bancaria. Le parole protette sono quattro («banca», «banco», «credito», «risparmio»), ma l'elenco non è tassativo, perché la norma vieta anche "altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno"; e il divieto copre la denominazione sociale, ogni segno distintivo e ogni comunicazione rivolta al pubblico, pubblicità compresa. La norma si è stratificata con la nascita delle nuove riserve: il comma 1-bis riserva l'espressione "moneta elettronica" agli istituti di moneta elettronica e alle banche, il comma 1-ter l'espressione "istituto di pagamento" agli istituti di pagamento, il comma 1-quater la parola "finanziaria" agli intermediari finanziari dell'art. 106.

Il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole protette possano essere usate da soggetti diversi da banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e intermediari finanziari. Le Istruzioni di vigilanza (Circ. 229, Titolo I, Capitolo 4, Sezione II) estendono il divieto alle sigle e abbreviazioni abitualmente usate dalle banche (come "popolare", "cassa", "risp") e ai termini delle operazioni tipiche ("depositi", "conti correnti"), e individuano due gruppi di usi legittimi: quelli giustificati da controlli amministrativi (la società finanziaria capogruppo, le società di un gruppo bancario, le società finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento, gli intermediari finanziari e gli enti previdenziali vigilati) e quelli giustificati da elementi di fatto, come nel caso di chi non svolge alcuna attività finanziaria e accompagna la parola riservata a un'espressione che esclude ogni equivoco (per esempio una società di software chiamata "Banca Dati").

Comma 3: la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro; se è commessa da una società o da un ente, la sanzione va da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività dell'art. 111 (la cosiddetta millantata vigilanza). Il comma 3-bis richiama l'art. 144, comma 9, che consente di elevare le sanzioni fino al doppio del vantaggio ottenuto, quando questo superi i massimali e sia determinabile. L'abuso di denominazione è quindi un illecito amministrativo e non più un reato: la condotta lede la trasparenza del mercato e l'affidamento del pubblico, non direttamente il risparmio.

La riserva di denominazione è autonoma dalla riserva di attività: si può violare l'una senza l'altra, e le sanzioni sono di natura diversa, penale la prima e amministrativa la seconda. Chi si presenta come "Banca X", raccoglie fondi dal pubblico e concede prestiti risponde sia dell'art. 131 sia dell'art. 133; chi si limita al nome risponde del solo art. 133. Nel caso Banca Matica, mancando l'obbligo di rimborso e l'esercizio del credito, l'abusivismo bancario non era configurabile, ma restava contestabile l'abuso di denominazione. Se i totem avessero consentito di riavere le monete depositate sarebbe comparso l'obbligo di rimborso, e quindi la raccolta tra il pubblico dell'art. 130; per l'art. 131 sarebbe servita anche l'erogazione del credito.

Dell'abuso di denominazione risponde "chiunque" contravvenga al divieto, per azione o per omissione: nel caso Romanelli la sanzione ha raggiunto anche i sindaci di una società che non era ancora una banca.

4.9.5. Le sanzioni amministrative degli artt. 144 e 145

Gli artt. 130-132 presidiano le **riserve di attività** e colpiscono chi opera senza titolo, chiunque esso sia; l'art. 144 presidia le **regole di esercizio** e colpisce il soggetto vigilato che, pur avendo il titolo, viola gli obblighi che esso comporta. L'art. 144, comma 1, prevede per banche, intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e mista, rispettive capogruppo, soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali e soggetti incaricati della revisione legale dei conti la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato; per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica il massimale è di 5 milioni di euro, ovvero il 10 per cento del fatturato quando tale importo è superiore e il fatturato è disponibile e determinabile. Le violazioni sono elencate per lettere e comprendono, fra le altre, l'inosservanza dell'art. 129, comma 1.

Per le sanzioni amministrative del titolo la procedura è nell'art. 145: la Banca d'Italia, contestati gli addebiti, applica le sanzioni con provvedimento motivato; gli interessati possono presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione e chiedere un'audizione personale, anche con l'assistenza di un avvocato; contro il provvedimento è ammesso ricorso alla corte di appello di Roma (comma 4). Chi è iscritto all'albo e sbaglia risponde quindi ai sensi dell'art. 144 e non degli artt. 130-132, che presuppongono l'assenza del titolo.

4.9.6. Il caso Romanelli

Romanelli Finanziaria s.p.a., società toscana iscritta dal 1988 nell'elenco degli intermediari finanziari, assunse nel luglio 2000 la denominazione di "banca" e chiese l'autorizzazione all'attività bancaria; la Banca d'Italia comunicò il diniego il 30 ottobre 2000, per mancanza dei requisiti di onorabilità. Nonostante il diniego la società iniziò l'attività nell'aprile 2002 aprendo cinque filiali e raccolse risparmio presso il pubblico con strumenti atipici (titoli fiduciari e warrant) e con conti correnti. Fu dichiarata fallita nel 2003 e gli amministratori furono condannati dalla Cassazione penale, sez. V, con la sentenza n. 2071/2009. La vicenda ha due filoni distinti: quello amministrativo, per le sanzioni dell'art. 133 (decreti della Corte d'appello di Roma del 2002), e quello penale, per gli artt. 130 e 131 e per l'art. 48 c.p. (Tribunale e Corte d'appello di

Firenze, fino alla Cassazione). Le contestazioni penali riguardavano la raccolta e l'esercizio del credito tramite la finanziaria (warrant emessi dal 1998 al 2002 e conti correnti), l'abusiva attività bancaria tramite la "banca" Romanelli s.p.a., subentrata alla finanziaria nella gestione dei crediti, e, in un capo distinto, la relazione di un consulente che dichiarava falso il provvedimento di diniego, su cui gli imputati avevano fondato una denuncia (art. 48 c.p., errore determinato dall'altrui inganno). Il Tribunale condannò per il solo art. 131, nel quale assorbì l'art. 130.

Gli argomenti difensivi furono respinti.

- **Silenzio-assenso**: il superamento dei novanta giorni fissati dalle Istruzioni di vigilanza per decidere sulla domanda (il diniego arrivò con diciassette giorni di ritardo) non produce silenzio-assenso, perché questo opera solo se una disposizione di legge lo prevede, mentre le Istruzioni sono normativa secondaria e pongono un termine ordinatorio. Il rilascio dell'autorizzazione presuppone inoltre valutazioni discrezionali (onorabilità, professionalità, indipendenza di giudizio degli esponenti), sicché il richiedente è titolare di un interesse legittimo e il giudice penale non può disapplicare il diniego. Oggi l'argomento sarebbe a maggior ragione inconfigurabile, perché l'autorizzazione è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 2).
- **Omologa e iscrizione nel registro delle imprese**: non tengono luogo dell'autorizzazione, perché l'art. 14, comma 3, vieta di dare corso all'iscrizione in mancanza di essa; la banca ottiene l'iscrizione nell'albo dell'art. 13 solo dopo l'autorizzazione, e solo le banche possono usare la parola "banca" (art. 133, comma 1).
- **Forma e sostanza**: i warrant erano "apparentemente rappresentativi solo di un diritto di opzione" ma "nella realtà, prodotti finanziari per la raccolta del risparmio". Il prezzo pagato per il warrant, sommato a quello di esercizio, corrispondeva al valore delle obbligazioni sottostanti, per cui il sottoscrittore aveva già anticipato l'intero valore e l'opzione era destinata a essere esercitata, senza alcuna alea; un vincolo contrattuale imponeva poi la retrocessione anticipata a un prezzo maggiorato. Era un'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, cioè raccolta ai sensi dell'art. 11, comma 1. La difesa invocava la deroga dell'art. 11, comma 4, lett. c), perché la raccolta sarebbe avvenuta con obbligazioni: la Corte ha risposto che la deroga vale solo entro i limiti del codice civile (allora l'art. 2410, che le obbligazioni sottostanti superavano di circa dieci volte) e che non può invocare la clausola di salvaguardia chi si è messo nelle condizioni, anche solo di fatto, di violare la norma. I conti correnti, con saldo attivo stabile, accrediti di stipendio, titolari anche non soci e prelievi anche a debito, erano strumenti di raccolta a vista presso terzi, vietata in ogni caso dall'art. 11, comma 5, e insieme di esercizio del credito attraverso le aperture di credito in conto: completavano quindi il binomio e integravano l'art. 131. Oggi un intermediario finanziario può aprire solo conti di pagamento utilizzati esclusivamente per servizi di pagamento (art. 11, comma 2-ter), se autorizzato ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. a).
- **Dolo**: i pareri professionali che attestavano la legittimità dei warrant non escludono il dolo quando l'autorità ha già contestato formalmente la violazione degli artt. 10 e 11 (diniego, contestazione dell'abuso di denominazione, accertamenti ispettivi) e l'agente prosegue. Chi ritiene illegittimo il diniego deve impugnarlo nelle sedi proprie e non operare come se non

esistesse.

- **Sindaci**: dell'abuso di denominazione risponde "chiunque", e quindi anche chi, tenuto a un'attività di controllo su altri (art. 2403 c.c.), abbia omesso la doverosa vigilanza (art. 3 l. 689/1981).

4.9.7. Abusivismo e usura

Abusivismo e usura sono illeciti autonomi, che spesso concorrono. Gli artt. 130-132 non contengono alcun riferimento al tasso praticato: si consumano con l'esercizio dell'attività in violazione della riserva, quale che sia il prezzo, e chi pratica tassi nella norma non per questo è escluso dall'abusivismo. Il tasso abnorme è al più un indizio dell'operatività irregolare e, nella raccolta, un indizio dell'obbligo di rimborso desumibile dai flussi finanziari. Nel caso Giuffrè era un tasso promesso al conferente; nel caso Romanelli un amministratore fu condannato per usura nel 2004, dopo il fallimento.

5 | Titolo II, Capo II TUB — Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Fonte: LEGB1_Appunti_05_Titolo-II-Capo-II-Autorizzazione.pdf — *8 pagine*

5.1. Struttura del Capo II

Il Capo II del Titolo II del TUB tratta tre materie:

- l'**autorizzazione all'attività bancaria**;
- le **succursali**;
- la **libera prestazione di servizi**.

Queste tre materie sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 13-14 (albo e autorizzazione), 15 (succursali) e 16-18 (libera prestazione di servizi e mutuo riconoscimento).

Il Capo si collega alla **riserva di attività** dell'art. 10: il comma 1 definisce attività bancaria la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le attribuisce carattere d'impresa; il comma 2 ne riserva l'esercizio alle banche; il comma 3 consente alle banche di svolgere anche ogni altra attività finanziaria e le attività connesse o strumentali, facendo salve le riserve di attività previste dalla legge. La raccolta del risparmio è l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sotto forma di depositi o sotto altra forma (art. 11, comma 1), ed è vietata ai soggetti diversi dalle banche quando avviene tra il pubblico (art. 11, comma 2). Poiché l'attività è riservata, serve un meccanismo che individui chi ne è titolare, e il Capo II lo fornisce: disciplina l'**accesso** al mercato, mentre i poteri di vigilanza sull'esercizio dell'attività stanno nel Titolo III.

Il principio dell'**home country control** vale per tutto il Capo: la banca autorizzata in uno Stato dell'Unione può operare negli altri Stati, con succursali o senza, senza una nuova autorizzazione dello Stato ospitante, perché la vigilanza spetta in via di principio all'autorità dello Stato d'origine (art. 1, comma 1, lett. g-bis e g-ter: «Stato di origine» è lo Stato dell'Unione in cui la banca è stata autorizzata, «Stato ospitante» quello in cui ha una succursale o presta servizi). A questo impianto si è aggiunto il Meccanismo di vigilanza unico (MVU, art. 1, comma 1, lett. e-bis): l'autorizzazione è oggi un procedimento comune, in cui la Banca d'Italia istruisce e propone e la BCE decide. *(pagina 1)*

5.2. Art. 13 TUB: l'Albo delle banche

Una società di capitali normalmente nasce con l'iscrizione nel **Registro delle imprese**, iscrizione che ha efficacia costitutiva (principio valido pure in ambito bancario, alla luce del riferimento dell'art. 2195 c.c.).

Per le banche, tuttavia, è previsto un adempimento ulteriore: l'iscrizione in un apposito **Albo tenuto dalla Banca d'Italia**. Questo adempimento è un'ulteriore forma di garanzia e permette di verificare in qualunque momento se un soggetto che svolge attività bancaria sia abusivo.

Comma 1: *"Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica".*

Comma 2: *"Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo".*

L'albo tenuto dalla Banca d'Italia è distinto dall'elenco dei soggetti vigilati pubblicato dalla BCE: la clausola di apertura del comma 1 fa salve le disposizioni del MVU sulla pubblicazione di quest'ultimo.

L'iscrizione ha funzione di **pubblicità notizia**: attesta che il soggetto è autorizzato all'attività bancaria e, di conseguenza, sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza, ma non costituisce lo status di banca. La società nasce con l'iscrizione nel registro delle imprese, che l'art. 14, comma 3, subordina all'autorizzazione; l'albo registra il risultato e lo rende conoscibile ai terzi. Per le banche italiane l'iscrizione avviene dopo l'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesta l'iscrizione nel registro delle imprese; le variazioni vanno comunicate entro dieci giorni dall'iscrizione nel registro della relativa delibera; la cancellazione interviene in caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione, di scioglimento della società o di modifica dell'oggetto sociale.

Per le succursali di banche comunitarie l'iscrizione ha anche una funzione operativa: le Disposizioni di vigilanza subordinano l'avvio dell'operatività all'iscrizione della succursale nell'albo, oltre che all'espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi italiane per l'apertura di sedi secondarie di società estere. Il titolo ad operare resta l'autorizzazione dello Stato d'origine, che opera per mutuo riconoscimento; l'iscrizione condiziona il momento da cui l'attività può essere svolta in Italia.

All'albo si affiancano i presidi contro l'abusivismo. L'art. 131 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 chi svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito: serve il **cumulo** dei due elementi, coerentemente con la nozione di attività bancaria dell'art. 10, comma 1, mentre la sola raccolta abusiva integra la diversa fattispecie dell'art. 130. L'art. 133 vieta ai soggetti diversi dalle banche di usare, nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, le parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» o altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria; la violazione è un illecito amministrativo (sanzione pecuniaria da 5.000 a 5 milioni

di euro e, se commessa da una società o da un ente, da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato), non un reato. Se vi è fondato sospetto che una società svolga abusivamente attività bancaria, la Banca d'Italia può denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dei provvedimenti dell'art. 2409 c.c. o rivolgersi direttamente al tribunale, con spese dell'ispezione a carico della società (art. 132-bis). *(pagina 1)*

5.3. Art. 14 TUB: il previgente sistema delle tre autorizzazioni

La **precedente legge bancaria** disciplinava l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 e prevedeva **tre diversi tipi di autorizzazione**:

- l'autorizzazione alla costituzione della banca;
- l'autorizzazione all'inizio delle operazioni;
- l'autorizzazione all'apertura di sportelli.

Nella fase costitutiva erano quindi previste due diverse autorizzazioni. Prima della stipula dell'atto costitutivo era necessario ottenere da Banca d'Italia (BI) l'**autorizzazione alla costituzione** della società bancaria; dopo aver stipulato l'atto costitutivo, prima dell'iscrizione al registro delle imprese, era necessaria l'**autorizzazione all'inizio delle operazioni**.

Queste due autorizzazioni erano volte ad assicurare coerenza fra l'atto costitutivo e quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione alla costituzione della banca. Inoltre, per poter operare, era necessario almeno uno sportello, e quindi venne prevista un'ulteriore **autorizzazione per l'apertura di sportelli**.

Rientrava in questo sistema il c.d. **"principio di discrezionalità"**: nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza strutturale, BI poteva negare o rilasciare l'autorizzazione a suo piacimento. Il criterio guida per l'epoca erano le "esigenze economiche del mercato". Per decenni BI ha negato l'autorizzazione alla costituzione di nuove banche sotto l'indicazione delle delibere del CICR, che aveva (ed ha) alta vigilanza.

Vi era inoltre un dibattito sulla **natura dell'attività bancaria**: si trattava di un'autorizzazione in senso tecnico o di una concessione?

- Nel caso della **concessione**, lo Stato concede l'utilizzazione di un suo diritto ad altri.
- Nel caso dell'**autorizzazione**, chi viene autorizzato ha in sé un diritto all'esercizio di una data attività; lo Stato si limita a verificare la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto.

La **prima direttiva banche del 1977**, recepita in Italia tramite il d.p.r. 350/1985, ha modificato il quadro normativo: per la prima volta il rilascio dell'autorizzazione è stato condizionato al possesso di una serie di **requisiti e condizioni oggettivi**.

La direttiva è la 77/780/CEE; il d.p.r. è del 27 giugno 1985, otto anni dopo, e il TUB lo elenca fra le norme abrogate che continuano a essere applicate fino all'emanazione dei provvedimenti delle autorità creditizie (art. 161, comma 2).

Il TUB scioglie il dubbio sulla natura nel senso dell'autorizzazione, e la scelta ha conseguenze pratiche: il richiedente ha una posizione soggettiva tutelabile, per cui il diniego deve essere motivato e resta sindacabile dal giudice, mentre con una concessione non vi sarebbe alcuna posizione da far valere. Il rilascio è ancorato a condizioni tassative e all'autorità è sottratto il giudizio sull'opportunità economica dell'ingresso: al criterio delle «esigenze economiche del mercato» subentra la finalità della sana e prudente gestione dell'art. 5, comma 1. *(pagina 1–2)*

5.4. Art. 14, comma 1: le condizioni oggettive per l'autorizzazione

Comma 1: *"L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni".*

Il comma parla di **autorizzazione all'attività bancaria**: non esistono quindi più le tre autorizzazioni della precedente legge bancaria, ma è prevista una **sola autorizzazione** (nota: non poteva essere altrimenti; se la nuova disciplina si fosse sovrapposta soltanto ad una delle due, l'altra autorizzazione sarebbe rimasta discrezionale da parte di BI). L'autorizzazione è inoltre rilasciata sulla base di una serie di **condizioni oggettive**, definite sempre al comma 1.

Le condizioni sono **sette**, nell'ordine del testo: lettere a), a-bis), b), c), d), e), f). Il comma 1 fa dipendere il rilascio dal ricorrere delle condizioni («è rilasciata quando ricorrano»), il che depone per la natura tendenzialmente **vincolata** del provvedimento; il comma 2 reintroduce però un margine di apprezzamento tecnico, perché consente il diniego quando dalla verifica delle condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Forma societaria (lett. a), sede e direzione generale (lett. a-bis) e capitale versato (lett. b) sono condizioni che ricorrono o non ricorrono.

La discrezionalità che resta è **tecnica**: l'autorità applica regole dell'esperienza bancaria a una fattispecie e deve motivare, mentre è scomparsa la discrezionalità di opportunità economica, cioè la ponderazione comparativa di interessi sul se il mercato abbia bisogno di una nuova banca. Il fondamento costituzionale sta nell'art. 41 Cost. (l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e può essere sottoposta a programmi e controlli) letto insieme all'art. 47 Cost. (la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito): l'autorizzazione bancaria controlla le condizioni dell'entrata. Il fine della valutazione, che le Disposizioni di vigilanza esplicitano (v. oltre), è assicurare che l'iniziativa sia in grado di fronteggiare i rischi della fase di avvio e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale. *(pagina 2)*

5.5. Lettera a): forma societaria e privatizzazione delle banche pubbliche

Lettera a): *"sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata".*

La lettera a) esplica il principio di **"despecializzazione istituzionale"**: le banche non sono più libere di scegliere una qualunque forma societaria, ma possono scegliere soltanto fra **SPA** e **SCARL**.

Rispetto alla precedente legge bancaria:

- sono state rimosse le banche pubbliche;
- è stata rimossa la possibilità di avere responsabilità illimitata;
- non è più possibile svolgere l'attività bancaria in forma individuale.

La scelta ha una duplice ratio. Sul piano della stabilità, la forma azionaria assicura una struttura patrimoniale idonea a sopportare i rischi tipici dell'attività e un capitale determinabile, misurabile e vincolabile, il che rende possibile la vigilanza prudenziale; sul piano della trasparenza, la standardizzazione dei tipi rende comparabili gli assetti proprietari e di governo. Rispetto all'art. 10, il comma 1 qualifica l'attività bancaria come attività d'impresa, il comma 2 ne riserva l'esercizio alle banche e la lett. a) stabilisce in quali vesti societarie si possa essere banca.

La forma cooperativa per azioni a responsabilità limitata copre le **banche popolari** (art. 29, comma 1) e le **banche di credito cooperativo** (art. 33, comma 1), disciplinate dal Capo V del Titolo II: l'art. 28 riserva alle sole popolari e BCC l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative. La forma societaria è una condizione di permanenza oltre che di ingresso. Per le popolari l'attivo non può superare 16 miliardi di euro, determinati a livello consolidato se la banca è capogruppo (art. 29, comma 2-bis); in caso di superamento l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso, e se entro un anno l'attivo non è ridotto né è deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, la Banca d'Italia può vietare nuove operazioni (art. 78), adottare i provvedimenti del Titolo IV, Capo I, Sezione I, oppure proporre alla BCE la revoca dell'autorizzazione e al Ministro dell'economia la liquidazione coatta amministrativa (art. 29, comma 2-ter).

5.5.1. Il processo di privatizzazione delle banche pubbliche

Va ricordato il processo di **privatizzazione** (privatizzare significa trasformare un organo da pubblico, come un ente, a privato, quindi una società) che ha riguardato le banche, avviato con la **Legge Amato 218/1990** (dal nome dell'allora ministro del Tesoro). Questa legge era stata redatta sulla base di un documento precedentemente stilato da BI, basato su un lavoro ricognitivo sulle banche italiane.

Questo lavoro aveva fatto emergere anche la distinzione, all'interno delle banche pubbliche, fra:

- banche a **struttura corporativa** (nelle quali si conoscono esattamente i partecipanti; ad esempio alcune casse di risparmio e la Banca Nazionale del Lavoro);
- banche a **struttura fondazionale** (nelle quali non si conoscono le identità dei partecipanti; ad esempio il Monte dei Paschi di Siena).

La legge Amato, fra le altre cose, ha eliminato tale distinzione.

Tappe principali della privatizzazione delle banche:

1. **Costituzione di nuove SPA partendo dagli enti pubblici già esistenti**: la banca ente pubblico (ente conferente) conferisce l'azienda bancaria alla neo costituita banca SPA (società conferitaria), che detiene il 100% delle azioni ed esercita l'attività. L'ente pubblico, a seguito del conferimento, diviene una **fondazione pubblica** (chiamata fondazione bancaria).
2. **Aumenti di capitale rivolti ai privati**: inizio del processo di privatizzazione sostanziale, ma la legge Amato vietava alle fondazioni bancarie di scendere al di sotto del 50% + 1 delle azioni possedute; per questo motivo questi aumenti di capitale non ebbero molto successo.
3. **Modifica della Legge Amato**: viene soppresso il divieto espresso al punto precedente e il ministro del Tesoro Lamberto Dini impose l'obbligo di scendere al di sotto del 50% + 1, pena il commissariamento.
4. **Legge Ciampi-Pinza del 1998**: legge decisamente più efficace, che impone ex-lege alle fondazioni bancarie di scendere al di sotto del 50% detenuto. Tale legge prevedeva anche che le fondazioni bancarie, nel momento in cui fossero scese al di sotto del 50%, non sarebbero più state fondazioni bancarie. *(Più precisamente la riforma è costituita dalla legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 e dal decreto attuativo d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153; "del 1998" si riferisce alla legge delega.)*

Le fondazioni, scese sotto la soglia, restano azionisti ma non di controllo: il punto d'arrivo della riforma è la dismissione del controllo, non l'uscita dal capitale. Il TUB rinvia al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 per individuare le fondazioni di origine bancaria (art. 30, comma 2-bis, che per le popolari consente agli statuti di fissare al 3 per cento, in deroga all'1 per cento del comma 2, la partecipazione delle fondazioni che già superino il limite per effetto di operazioni di aggregazione, senza possibilità di incrementarla). *(pagina 2–3)*

5.6. Lettere a-bis) e b): sede legale e capitale minimo

Lettera a-bis): *"la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica"*. Lettera autoesplicativa. La congiunzione richiede che entrambe siano in Italia: non basta la sede statutaria, occorre che si trovi in Italia anche il centro effettivo dell'amministrazione. La direzione generale può essere in una città diversa dalla sede legale purché entrambe siano nel territorio della Repubblica, e l'atto costitutivo ne indica l'ubicazione se distinta.

La ratio è duplice. Da un lato la norma individua l'autorità competente, perché la domanda di autorizzazione è presentata all'autorità nazionale dello Stato in cui avrà sede la banca; dall'altro, impedisce la costituzione di banche «cassetta postale», formalmente italiane ma dirette dall'estero, che renderebbero inefficace la vigilanza (la lett. f) risponde allo stesso ordine di preoccupazioni). Come le altre condizioni dell'art. 14 è un requisito di **permanenza** oltre che d'ingresso: il trasferimento della direzione generale all'estero farebbe venir meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata e aprirebbe l'ipotesi di revoca del comma 3-bis, lett. a).

La condizione vale per le banche italiane, comprese le filiazioni di banche estere, che sono

banche a tutti gli effetti e a cui si applicano integralmente le condizioni dell'art. 14. La banca comunitaria che voglia operare in Italia non deve invece spostare qui la propria sede, perché opera in forza dell'autorizzazione dello Stato d'origine; la banca di Stato terzo che intenda insediarsi opera tramite una succursale, e in tal caso sede legale e direzione generale restano per definizione nello Stato terzo.

Lettera b): *"il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia".*

Anche la lettera b) è un chiaro esempio di **delegificazione**: dal momento che la cifra richiesta può variare nel tempo, il legislatore ha preferito affidare questa scelta a BI. BI ha sempre previsto una disciplina diversa fra le banche stesse: SPA e BP da un lato, BCC dall'altro (nota: questo perché le BP in termini di operatività sono assimilabili alle SPA, mentre le BCC hanno un carattere locale definito ex lege).

Evoluzione del capitale minimo:

- per **SPA e BP**: inizialmente 12,5 miliardi di lire, poi divenuto 6,3 milioni di euro con il cambio, attualmente fissato a **10 milioni di euro**;
- per le **BCC**: inizialmente 2 miliardi di lire, poi divenuto 2 milioni di euro, attualmente fissato a **5 milioni di euro** (nota: la cifra di 2 milioni di euro sarebbe quasi il doppio rispetto al tasso di cambio; ciò è avvenuto perché BI osservò che la maggior parte delle BCC, più del 60%, di nuova costituzione falliva entro i primi 4 anni, e decise di alzare i requisiti inerenti al capitale).

Nelle banche il capitale è **interamente versato** (deroga rispetto al diritto comune) e la soglia di capitale minimo va mantenuta per tutto il ciclo di vita dell'impresa. Se il capitale dovesse scendere al di sotto della soglia, si avrebbe la **perdita dell'autorizzazione** per mancanza di requisiti oggettivi e la banca verrebbe sottoposta a **liquidazione coatta amministrativa**. Sul piano tecnico il capitale sotto il minimo è una delle ipotesi in cui sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata, ipotesi che l'art. 14, comma 3-bis, lett. a), prevede come causa di revoca da parte della BCE.

Le Disposizioni di vigilanza prevedono inoltre che i conferimenti in denaro siano depositati su un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca, utilizzabile solo per accrediti, con somme che non possono essere trasferite altrove né consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese; che i conferimenti in natura non possano eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale, salvo che avvengano nell'ambito di un medesimo gruppo bancario; e che, se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, oppure se il procedimento si chiude con un diniego, le somme depositate siano restituite ai sottoscrittori. Gli importi minimi tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività. *(pagina 3)*

5.7. Lettera c): il programma di attività iniziale e il procedimento autorizzativo

Lettera c): *"venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto".*

È l'unico punto **non completamente "oggettivo"**, per cui è prevista una forma di discrezionalità tecnica amministrativa, con obbligo di motivazione da parte di BI. Su questo punto vanno considerate anche alcune nozioni delle **Disposizioni di vigilanza**.

5.7.1. Il procedimento di valutazione

La Banca d'Italia **rigetta direttamente** le domande di autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la **sana e prudente gestione**. Negli altri casi, sottopone una proposta di decisione alla **Banca centrale europea (BCE)**, che concede o nega l'autorizzazione.

BI esplicita inoltre i criteri generali con cui valuterà i programmi di attività:

> *"Nella valutazione delle iniziative di costituzione, particolare attenzione è prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale."*

Il **programma iniziale** deve contenere:

- descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività;
- previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale;
- relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa.

La BCE e la BI valutano il programma di attività in un'ottica di **sana e prudente gestione** dell'intermediario e possono richiedere le modifiche a ciò necessarie.

Il testo della lett. c) è più ampio di quello riportato sopra: oltre al programma, all'atto costitutivo e allo statuto, richiede l'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché la descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Le Disposizioni di vigilanza precisano il contenuto dei tre blocchi del programma. Le previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale sono riferite a ciascuno dei primi tre esercizi: andamento dei volumi, evoluzione del portafoglio crediti e relative svalutazioni, struttura di costi e ricavi (per l'intera banca e per ogni succursale che si intende aprire nel triennio), prospetti previsionali di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, composizione dei fondi propri, calcolo dei requisiti minimi e stima del fabbisogno patrimoniale. Il programma

deve inoltre prefigurare **scenari avversi**, rappresentarne gli effetti prudenziali e individuare le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie con la stima dei relativi oneri. È previsto anche il **tutoring**: il programma può contenere soluzioni organizzative che comportino collaborazione e supporto della banca costituenda da parte di altri operatori bancari (ad esempio nei controlli interni, nella gestione del rischio di liquidità o nella formazione del personale), disciplinate da contratti trasmessi con l'istanza e idonei ad assicurare un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte del programma.

Per la predisposizione del programma la Circolare rinvia anche alle Guide della BCE sulla valutazione delle domande di autorizzazione e sugli enti creditizi fintech (marzo 2018).

L'**autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata o negata entro 180 giorni** dalla data di ricevimento della domanda da parte della Banca d'Italia. Il termine decorre dal ricevimento della domanda corredata della richiesta documentazione. La decisione della BCE è comunque adottata entro dodici mesi dalla ricezione della domanda regolare e completa.

Se la banca intende prestare servizi di investimento necessita di **un'altra autorizzazione**, sempre rilasciata da Banca d'Italia, in accordo con la **CONSOB** (aspetto disciplinato dal TUF).

L'autorizzazione dell'art. 14 legittima l'attività bancaria e le attività finanziarie, connesse o strumentali dell'art. 10, comma 3, ma non assorbe le riserve di attività previste da altre leggi, che lo stesso comma fa espressamente salve: per i servizi e le attività di investimento occorre l'autorizzazione dell'art. 19, comma 4, TUF, rilasciata dalla Banca d'Italia sentita la Consob. La banca costituenda presenta la relativa domanda contestualmente a quella di autorizzazione all'attività bancaria, indicando i servizi per cui è richiesta e allegando l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF; il termine è anch'esso di centottanta giorni. Il sistema di indennizzo degli investitori dell'art. 59 TUF è distinto dal sistema di garanzia dei depositanti degli artt. 96 ss. TUB. *(pagina 3–4)*

5.8. Lettere d), e), f) e commi 2-3: ulteriori condizioni, competenza BCE/BI, iscrizione

Lettera d): *"sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate".*

Il testo della lett. d) prosegue con un'alternativa: *"ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto".* La banca che nasce senza titolari di partecipazioni qualificate comunica dunque l'identità dei primi venti azionisti. Le Disposizioni di vigilanza inseriscono la documentazione sui partecipanti fra gli allegati della domanda di autorizzazione all'attività bancaria, così che la verifica dei presupposti dell'art. 19 confluisce nell'unico procedimento che si chiude con la decisione della BCE. Anche la valutazione dell'acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi spetta in via esclusiva alla BCE (art. 4, par. 1, lett. c, del regolamento MVU), per tutti gli enti degli Stati partecipanti, significativi o meno.

Lettera e): *"i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26".*

In sede di istruttoria si verifica anche l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza legate al divieto di *interlocking*, cioè delle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari (art. 36 d.l. 201/2011). Alla domanda va allegato il verbale della riunione in cui l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti dell'art. 26 e l'insussistenza di tali cause.

Lettera f): *"non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".*

Gli **stretti legami** sono definiti dall'art. 1, comma 2, lett. h), come i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

- controlla la banca;
- è controllato dalla banca;
- è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
- partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
- è partecipato dalla banca nella stessa misura.

La Banca d'Italia può ulteriormente qualificare la definizione per evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 1, comma 3). La BCE e la Banca d'Italia valutano inoltre che la struttura del gruppo non pregiudichi l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata, tenendo conto della localizzazione delle società estere.

Le lettere d), e) ed f) riguardano il **contesto** in cui la banca opera: chi la controlla, chi la amministra, in quale gruppo è inserita. I requisiti dei partecipanti e degli esponenti sono disciplinati una sola volta (art. 19 per i partecipanti, art. 26 per gli esponenti) e richiamati in sede di autorizzazione; devono sussistere all'ingresso e permanere per tutta la vita della banca.

Alla domanda vanno allegate, fra l'altro, le informazioni sulla provenienza delle somme con cui è sottoscritto il capitale (in raccordo con la disciplina antiriciclaggio del d.lgs. 231/2007), e il programma di attività deve indicare il responsabile antiriciclaggio e descrivere i presidi organizzativi e di controllo. Non sono condizioni ulteriori rispetto alle sette del comma 1. La documentazione relativa ai partecipanti, al versamento del capitale e ai requisiti degli esponenti deve avere data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda.

Comma 2: *"L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione".*

Questo comma è cambiato: un tempo era BI a rilasciare l'autorizzazione per quelle banche dove risultava garantita la sana e prudente gestione. Adesso, invece, è la **BCE a rilasciare l'autorizzazione** all'attività bancaria, ma **su proposta di BI**.

Il fondamento europeo è l'art. 4, par. 1, lett. a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 (regolamento MVU), che attribuisce alla BCE la competenza **esclusiva** nel rilasciare e revocare l'autorizzazione nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti. L'autorizzazione è un **procedimento comune**, che la BCE tratta sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi (art. 1, comma 2, lett. d e d-bis), a differenza della vigilanza corrente, che per i meno significativi resta in capo all'autorità nazionale: la distinzione rileva per la vigilanza, non per l'accesso, e infatti il potere di divieto dell'art. 15, comma 1, riguarda i soli soggetti meno significativi. Anche l'autorizzazione di una BCC è quindi decisa dalla BCE. Le banche già autorizzate dalle autorità nazionali al 3 novembre 2013 sono state considerate autorizzate a norma dell'art. 14 del regolamento (art. 33, par. 5): continuità del titolo, senza una nuova domanda, e solo spostamento della competenza.

Il procedimento, disegnato dall'art. 14 del regolamento, è di tipo composto: istruttoria nazionale e decisione europea. La domanda è presentata all'autorità nazionale dello Stato di futura sede. Se il richiedente soddisfa le condizioni del diritto nazionale, l'autorità nazionale adotta un **progetto di decisione** con cui propone il rilascio, notificato alla BCE e al richiedente; negli altri casi **respinge direttamente** la domanda, senza coinvolgere la BCE. Il progetto si ritiene adottato dalla BCE se questa non solleva obiezioni entro dieci giorni lavorativi, prorogabili una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati; la BCE può obiettare solo se le condizioni stabilite dal diritto dell'Unione non sono soddisfatte e deve motivare per iscritto. La decisione è notificata al richiedente dall'autorità nazionale. La Banca d'Italia ha un potere di rigetto autonomo ma nessun potere di rilascio, mentre la BCE non riceve domande dirette ma soltanto progetti di decisione. Il TUB continua a elencare le condizioni sostanziali perché il regolamento ha spostato la titolarità della decisione, non la norma: la BCE applica anche il diritto nazionale di recepimento (art. 4, par. 3).

Il richiedente conserva una posizione soggettiva tutelabile. Prima della decisione ha diritto di essere sentito (art. 22 del regolamento MVU) e, per l'atto della Banca d'Italia, gli sono comunicati i motivi ostativi (art. 10-bis l. 241/1990, applicabile in quanto compatibile ai procedimenti della Banca d'Italia: art. 4, comma 3, TUB); il diniego è motivato e sindacabile. Contro il rigetto della Banca d'Italia, che è atto nazionale, si ricorre al giudice amministrativo; contro la decisione della BCE si ricorre al giudice dell'Unione, previa eventuale richiesta di riesame alla Commissione amministrativa del riesame (art. 24 del regolamento MVU), che di per sé non ha effetto sospensivo.

Comma 3: *"Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1".* *(pagina 4)*

5.9. L'iter costitutivo della banca

Il comma 3 dell'art. 14 non è particolarmente chiaro, ma si desume anche da altre disposizioni di vigilanza che l'**iter** da seguire è il seguente:

1. **Stipula dell'atto costitutivo**;

2. **Autorizzazione all'attività bancaria** (l'art. 2329 c.c. prevede che leggi speciali possano prevedere specifiche autorizzazioni prima dell'iscrizione nel registro delle imprese);
3. **Iscrizione nel registro delle imprese** (qui nasce a tutti gli effetti la banca);
4. **Iscrizione presso l'albo delle banche**.

Nel dettaglio, i promotori informano preventivamente la Banca d'Italia dell'iniziativa, prima della stipula dell'atto costitutivo. L'atto costitutivo indica il sistema di amministrazione e controllo adottato e nomina i membri degli organi; il capitale è versato su un conto corrente indisponibile. Dopo la stipula e **prima** che si dia corso all'iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione della domanda, che il legale rappresentante inoltra alla Banca d'Italia con atto costitutivo e statuto, programma di attività, elenco dei partecipanti diretti e indiretti con la documentazione sui requisiti dei partecipanti qualificati, attestazione del versamento del capitale e informazioni sulla provenienza delle somme, descrizione del gruppo e verbale di verifica dei requisiti degli esponenti.

Ottenuta l'autorizzazione, il notaio può procedere al deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, da cui nasce la società: il termine utile è di novanta giorni dal rilascio. La banca invia poi alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione e, a decorrere da quella data, la Banca d'Italia la iscrive nell'albo. Se l'iscrizione nel registro fosse avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro (art. 223-quater disp. att. c.c.).

Gli adempimenti finali sono l'adesione a un sistema di garanzia dei depositanti (art. 96, comma 1: le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi istituiti e riconosciuti in Italia), l'adesione a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (art. 128-bis, comma 1) e, prima di operare con assegni o carte di pagamento, l'assolvimento degli obblighi verso la Centrale di Allarme Interbancaria. L'operatività, che va comunicata alla Banca d'Italia dopo l'iscrizione all'albo, deve iniziare entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, altrimenti è dichiarata la decadenza (v. oltre). Quanto al primo sportello non serve alcuna autorizzazione, perché l'apertura di succursali in Italia è liberalizzata (v. art. 15).

Le **banche di credito cooperativo (BCC)** possono presentare la domanda di autorizzazione attraverso la **federazione locale** delle banche di credito cooperativo.

Dopo la riforma del 2016 l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è **condizione di legge** per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC (art. 33, comma 1-bis), fatto salvo quanto previsto dall'art. 37-bis, comma 1-bis, che consente alle BCC delle province autonome di Trento e di Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi o di adottare sistemi di tutela istituzionale. Il comma 1-ter, in modo speculare all'art. 14, comma 3, vieta di dare corso all'iscrizione nell'albo delle società cooperative (art. 2512, secondo comma, c.c.) se non consti tale autorizzazione. Fra gli allegati alla domanda vi sono l'attestazione dell'impegno ad aderire al gruppo, l'attestazione della capogruppo sull'idoneità della banca istante a soddisfare i requisiti di ammissione previsti dal contratto di coesione e una relazione sul rispetto dei requisiti di mutualità prevalente. I soci devono inoltre attestare di risiedere, avere

sede oppure operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della costituenda banca (art. 34, comma 2).

Fino ad alcuni anni fa, l'iter costitutivo delle società prevedeva anche un **giudizio di omologazione** (altro non era che un controllo di legittimità) da parte del tribunale prima dell'iscrizione nel registro delle imprese (questa fase era inserita fra l'autorizzazione all'attività bancaria e l'iscrizione nel registro delle imprese). Oggi il giudizio di omologazione non è più previsto, perché è direttamente il **notaio** che verifica le condizioni di legittimità.

Infine, esiste un **caso particolare**: non è sempre necessaria la costituzione di una nuova società per poter costituire una banca. Le disposizioni di vigilanza chiariscono che è possibile far nascere una banca per **mutamento dell'oggetto sociale** di una società preesistente (non è presente nessun divieto nel TUB). Il caso più frequente è quello di un intermediario finanziario che decide di mutare l'oggetto sociale e trasformarsi in banca (come ad esempio Italease).

Per questa via d'accesso valgono le stesse condizioni dell'art. 14 e lo stesso procedimento, con alcuni adattamenti. La domanda è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che ne sia richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese. Non è una trasformazione in senso tecnico, perché non cambia il tipo sociale ma l'oggetto: la società deve già avere, o assumere con la stessa delibera, una delle due forme ammesse dalla lett. a). Il programma di attività deve contenere in più la descrizione delle attività svolte in precedenza, con i bilanci degli ultimi tre esercizi, e le iniziative, con i relativi tempi, per adeguare le risorse umane e tecniche all'attività bancaria. Nella valutazione si presta particolare attenzione alle attività svolte e ai risultati economici conseguiti; la BCE e la Banca d'Italia accertano che le attività finanziarie della società non violino le riserve di attività previste dalla legge e possono chiedere la dismissione di determinati settori. La Banca d'Italia può inoltre richiedere una verifica sulla funzionalità della struttura aziendale e sull'esistenza e sull'ammontare del patrimonio, con accesso di propri ispettori o con una perizia di soggetti terzi. Per l'iscrizione all'albo il certificato da inviare è quello relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di modifica. *(pagina 5)*

5.10. Commi 3-bis, 3-ter e 4-bis: revoca e decadenza dell'autorizzazione

Le condizioni dell'art. 14 sono condizioni di permanenza, e la loro mancanza si riflette sul titolo.

Comma 3-bis: *"La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni: a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata; b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni; c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi".*

Comma 3-ter: *"La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80".*

Comma 4-bis: *"La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo"*. È la base espressa del potere regolamentare della Banca d'Italia in materia di accesso, che si esprime nella Circolare n. 285.

La revoca spetta dunque alla BCE, in coerenza con l'art. 4, par. 1, lett. a), del regolamento MVU, e la Banca d'Italia può soltanto proporla o essere sentita. L'art. 14, parr. 5 e 6, del regolamento aggiunge che la BCE può revocare di propria iniziativa, previa consultazione dell'autorità nazionale, oppure su proposta di questa. La consultazione deve lasciare alle autorità nazionali il tempo di decidere le azioni correttive necessarie, comprese eventuali misure di risoluzione; e finché le autorità nazionali restano competenti per la risoluzione, esse possono notificare alla BCE un'obiezione motivata quando ritengano che la revoca pregiudicherebbe l'adeguata attuazione della risoluzione o la stabilità finanziaria, nel qual caso la BCE si astiene dal procedere per un periodo concordato.

Sono condizioni di permanenza il capitale non inferiore al minimo (lett. b), la presenza in Italia della sede legale e della direzione generale (lett. a-bis) e, per le popolari, il rispetto del limite di attivo (art. 29, comma 2-ter).

La **decadenza** è un istituto diverso, perché consegue all'inerzia. Le Disposizioni di vigilanza prevedono che sia dichiarata quando la banca non abbia iniziato a operare entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente entro lo stesso termine; in presenza di giustificati motivi, su richiesta presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza, può essere concesso un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a tre mesi. Anche le pronunce di decadenza sono adottate dalla BCE secondo il regolamento quadro sul MVU (regolamento (UE) n. 468/2014). In caso di revoca o decadenza la Banca d'Italia cancella la banca dall'albo, e la società deve modificare l'oggetto sociale per escludere l'attività bancaria oppure porsi in liquidazione.

5.11. Comma 4: stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria

Comma 4: *"Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità"*.

Le banche che in Italia necessitano dell'autorizzazione per poter operare sono quelle **italiane** e quelle **extracomunitarie**; quelle **comunitarie** vengono autorizzate nel proprio paese d'origine.

Si tratta di una norma cambiata a seguito della **legge sul risparmio del 2005**; prima l'autorizzazione veniva concessa dal MEF. Si prevede inoltre che venga sentito il Ministro degli Affari Esteri, per salvaguardare interessi diplomatici, e devono sussistere condizioni di **reciprocità**. Il diritto comunitario ha specificato tuttavia che le condizioni di reciprocità valgano nei confronti di **tutti i Paesi dell'Unione Europea**.

Il testo oggi vigente parla di «banca di Stato terzo», cioè della banca avente sede legale in uno Stato non membro dell'Unione (art. 1, comma 1, lett. h, e comma 2, lett. c), e non più di «banca extracomunitaria»; la formula precedente compare ancora negli artt. 15, comma 4, e 16, comma 4. Il rinvio è parziale: richiama le sole lettere b), c) ed e) perché la succursale non è una società, non ha sede legale in Italia e non ha propri partecipanti. La competenza è della Banca d'Italia e non della BCE perché il regolamento MVU lascia alle autorità nazionali la vigilanza sugli enti creditizi dei Paesi terzi che aprono una succursale o prestano servizi transfrontalieri nell'Unione (considerando 28).

Le Disposizioni di vigilanza precisano le condizioni per autorizzare la prima succursale:

- sede legale e direzione generale della banca nello Stato terzo;
- fondo di dotazione della succursale non inferiore a dieci milioni di euro;
- programma di attività e idoneità dei responsabili della succursale;
- consenso preventivo dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine e sua attestazione sulla solidità patrimoniale e sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;
- impegno ad aderire a un sistema di garanzia dei depositanti italiano, a meno che la succursale partecipi a un sistema estero equivalente almeno quanto a livello e ambito di copertura (art. 96, comma 3), la cui equivalenza è verificata dalla Banca d'Italia (art. 96-ter, comma 1, lett. c);
- assenza di impedimenti all'esercizio efficace della vigilanza, regolamentazione adeguata nello Stato d'origine anche in materia antiriciclaggio e accordi per lo scambio di informazioni (o almeno assenza di ostacoli allo scambio).

Il termine del procedimento è di centoventi giorni. Se la banca intende prestare anche servizi di investimento, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia sentita la Consob nell'ambito dello stesso procedimento, ricorrendo le condizioni dell'art. 29-ter, commi 1 e 2, TUF.

La banca estera ha davanti due strade, **succursale** o **filiazione**. La succursale è una sede priva di personalità giuridica, parte della banca estera, e impegna direttamente la casa madre (per la nozione v. art. 15). La filiazione è invece una banca italiana a tutti gli effetti, con propria personalità giuridica, patrimonio, organi e autorizzazione: va autorizzata ai sensi dell'art. 14 e le si applicano tutte e sette le condizioni, compresa la lett. a-bis). Per le filiazioni di banche comunitarie non vi sono condizioni aggiuntive (se la banca è di uno Stato non partecipante al MVU, la BCE rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità dello Stato d'origine). Per le filiazioni di banche extracomunitarie le Disposizioni di vigilanza aggiungono condizioni sul sistema di vigilanza dello Stato d'origine: assenza di ostacoli alla vigilanza sul gruppo e sugli stretti legami, accordi o assenza di ostacoli allo scambio di informazioni, Stato non considerato non cooperativo dal GAFI, preventivo consenso e attestazione delle autorità di quello Stato; la BCE e la Banca d'Italia possono limitare l'ambito operativo della filiazione per esigenze di vigilanza. La filiazione, in quanto banca italiana, gode del passaporto europeo; la succursale di una banca di Stato terzo no, perché il mutuo riconoscimento opera soltanto fra Stati membri.

(pagina 5)

5.12. Art. 15 TUB: succursali

La **succursale** è una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca (o di un istituto di moneta elettronica o di pagamento) e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività per cui la banca è stata autorizzata (art. 1, comma 2, lett. e). Gli elementi qualificanti sono l'assenza di personalità giuridica, che la distingue dalla filiazione, e lo svolgimento diretto dell'attività. I confini della nozione sono tracciati dalle linee di orientamento delle Disposizioni di vigilanza, che rinviano per la definizione operativa all'art. 4, par. 1, punto 17, del CRR. Rientrano gli sportelli ad operatività particolare, ad esempio stagionali o saltuari; non rientrano le apparecchiature di home banking e gli sportelli automatici (ATM, POS) presso i quali non è presente personale della banca, gli uffici amministrativi anche quando vi ha accesso la clientela, i punti operativi temporanei presso fiere, mercati e manifestazioni occasionali. L'**ufficio di rappresentanza** è la struttura utilizzata esclusivamente per attività promozionale e di studio dei mercati e non è una succursale.

Comma 01: *"Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3".*

Le banche italiane possono aprire succursali in Italia e nei paesi UE, e viceversa.

I due casi seguono regimi diversi. Per l'apertura in un altro Stato membro opera il **passaporto europeo**: l'art. 35 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV) impone all'ente creditizio di notificare l'intenzione all'autorità del proprio Stato d'origine, allegando lo Stato di destinazione, un programma di attività con il tipo di operazioni e la struttura organizzativa, il recapito e i nominativi dei responsabili; l'autorità d'origine trasmette le informazioni a quella ospitante entro tre mesi, salvo che abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria. Per l'apertura in Italia l'art. 35 non si applica: vale la disciplina interna dell'articolazione territoriale (v. comma 1).

Il rinvio alle «procedure previste dalle disposizioni del MVU» (cioè il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione: art. 1, comma 1, lett. e-ter) riflette l'art. 17 del regolamento: fra gli Stati membri partecipanti le procedure di notifica fra autorità si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono attribuiti alla BCE dall'art. 4. Le procedure della direttiva restano quindi applicabili per i compiti non attribuiti alla BCE e nei rapporti con gli Stati membri non partecipanti. Per la banca italiana che apra una succursale in uno Stato membro non partecipante, l'autorità d'origine è la BCE (art. 4, par. 1, lett. b, del regolamento). «Stato partecipante al MVU» è lo Stato dell'Unione la cui moneta è l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE (art. 1, comma 1, lett. h-ter): la partecipazione non coincide con l'area dell'euro, e uno Stato non euro in cooperazione stretta è partecipante a tutti gli effetti, sicché per le sue banche non vale il comma 3.

Comma 1: *"Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare*

lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto".

Non si parla di **autorizzazione** in questo comma, perché l'apertura degli sportelli non è più "disciplinata"; questo comma riguarda un caso particolare (quello delle **less significant bank**) e comunque sempre per motivi attinenti alle finalità di vigilanza dell'art. 5 TUB.

Un tempo, per l'apertura degli sportelli bancari, era necessario compilare un apposito **modulo cartaceo** nel quale si inserivano una serie di informazioni (ad esempio, nella sezione 1 si chiedeva se si trattasse di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, etc.). Dal **2007**, BI ha richiesto alle banche di inviare semplicemente un documento che la banca stessa deve predisporre e inviare ogni due anni (il c.d. **progetto di sviluppo territoriale**). Si elimina quindi la comunicazione preventiva, e nel documento si barra solo la casella dell'apertura. Si deve comunque ricompilare segnando la comunicazione preventiva se si ipotizza di aprire una succursale non prevista nel progetto di sviluppo territoriale. Dal **2015**, BI ha implementato una procedura anagrafica per l'implementazione territoriale chiamata **Java**.

Il progetto di sviluppo territoriale concentra in un unico atto la comunicazione preventiva: le strategie di espansione sono illustrate in un documento approvato dall'organo amministrativo della banca (o, per i gruppi, della capogruppo), predisposto su orizzonti temporali di norma non superiori a due anni e comunicato alla Banca d'Italia almeno novanta giorni prima della data prevista per l'avvio della prima delle iniziative descritte; con lo stesso anticipo vanno comunicate le variazioni e integrazioni. È la modalità indicata per banche e gruppi di grandi e medie dimensioni o con operatività diversificata; le banche di minori dimensioni e a operatività tradizionale, in particolare le BCC, possono invece segnalare la singola apertura con il modello 3 SIOTEC, almeno novanta giorni prima, accompagnandola con una relazione dell'organo amministrativo sugli impatti dell'iniziativa. Prima del 2007 l'iniziativa si comunicava con il modello 3 SIOTEC e la Banca d'Italia poteva, entro novanta giorni, sospenderne l'attuazione per motivi attinenti all'adeguatezza organizzativa o alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale: era un procedimento di tipo autorizzatorio, fondato sul silenzio-assenso. Dal 2007 le banche possono dare corso alle iniziative di espansione alla data prevista, fermo restando il potere della Banca d'Italia di avviare d'ufficio, quando rilevi profili di problematicità, un procedimento per vietare l'apertura ai sensi dell'art. 15, che si conclude entro sessanta giorni. Le banche non appartenenti a gruppi bancari operanti da meno di due anni aprono in coerenza con il programma di attività esaminato in sede di autorizzazione, dandone comunicazione successiva.

La procedura è indicata nelle Disposizioni di vigilanza con la sigla G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) ed è operativa dal 3 giugno 2015: ha sostituito il modello 3 SIOTEC soltanto per le segnalazioni successive di inizio effettivo dell'attività, chiusura e aggiornamento o rettifica relative a succursali e uffici di rappresentanza, mentre non sostituisce le comunicazioni preventive, che restano con il modello previsto dalle disposizioni di vigilanza. Per le succursali di primo insediamento delle banche comunitarie l'avvio dell'operatività e le successive variazioni sono registrati nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia.

La formula «soggetto italiano meno significativo» e non «banca» si spiega perché, per il tramite dell'art. 18, comma 1, il potere di divieto copre anche le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento. Lo stesso potere di divieto, con termine di sessanta giorni, vale per lo stabilimento in altri Stati dell'Unione tramite agenti collegati (art. 29, comma 1, TUF), accanto a un autonomo divieto di modifica dell'operatività già comunicata, con termine di trenta giorni.

Comma 2: *"Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia".*

Fuori dall'Unione non opera il mutuo riconoscimento e serve la previa autorizzazione. Le Disposizioni di vigilanza fissano un termine di centoventi giorni e il contenuto della domanda: lo Stato in cui si intende operare, l'inquadramento dell'iniziativa nella strategia di espansione all'estero, le attività da esercitare, la struttura organizzativa, il recapito, i nominativi e un curriculum dei dirigenti responsabili e l'ammontare del fondo di dotazione, ove richiesto. Per le banche appartenenti a gruppi la domanda è inoltrata dalla capogruppo. Il rilascio è subordinato all'esistenza nello Stato terzo di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e all'assenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la succursale da parte della casa madre e dell'autorità di vigilanza. Per i gruppi bancari e per le banche non appartenenti a gruppo con fondi propri inferiori a un miliardo di euro la domanda deve inoltre dimostrare l'esistenza di rapporti positivi già in essere con clientela che risiede o opera nello Stato terzo prescelto. I provvedimenti decadono se entro dodici mesi l'iniziativa non ha avuto attuazione o se la banca vi rinuncia espressamente entro lo stesso termine.

Comma 3: *"Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. […] La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale".*

È il meccanismo classico della notifica fra autorità, che sopravvive soltanto verso gli Stati comunitari non partecipanti al MVU, nei confronti dei quali non opera l'art. 17 del regolamento MVU: comunicazione dell'autorità dello Stato di appartenenza alla Banca d'Italia e inizio dell'attività decorsi due mesi. Per le banche comunitarie le Disposizioni di vigilanza prevedono che, se la banca apre contemporaneamente più succursali, la comunicazione identifichi la succursale principale, cioè quella di primo insediamento, che tiene i rapporti con l'autorità competente; l'apertura di insediamenti successivi rientra fra le modifiche delle informazioni comunicate, e la Banca d'Italia può indicare le condizioni da rispettare.

Comma 4: *"Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia".*

La domanda indica l'attività che si intende svolgere, il recapito, la data prevista di apertura e i nominativi dei responsabili; la Banca d'Italia valuta tenendo conto del permanere delle condi-

zioni richieste per la prima succursale e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa. Non si ritiene però già insediata in Italia la banca extracomunitaria che abbia soltanto un ufficio di rappresentanza: chi intende trasformarlo in succursale segue la disciplina dell'autorizzazione alla prima succursale, e la Banca d'Italia, nel rilasciarla, verifica anche la correttezza dei comportamenti tenuti dall'ufficio.

Comma 5: *"La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane".*

Gli **uffici di rappresentanza** hanno un regime proprio. Per le banche comunitarie le Disposizioni di vigilanza prevedono il regime più leggero: nessuna disciplina di primo insediamento e il solo adempimento informativo tramite G.I.A.V.A. Per le banche extracomunitarie l'apertura richiede una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia (via posta elettronica certificata, secondo il modello previsto), con l'indicazione dell'attività che si intende svolgere (precisando che presso l'ufficio non possono essere svolte attività rientranti nella prestazione di servizi senza stabilimento), del recapito, della data prevista di apertura e dei responsabili, allegando lo statuto della banca e l'attestazione delle autorità dello Stato d'origine sull'adempimento delle eventuali formalità. L'ufficio inizia a operare, a pena di decadenza, trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia. La Banca d'Italia può esercitare controlli ispettivi volti a verificare che l'ufficio non svolga di fatto attività bancarie. Le banche italiane possono a loro volta aprire uffici di rappresentanza all'estero, secondo le procedure dello Stato ospitante e con le informazioni comunicate tramite G.I.A.V.A. *(pagina 5–6)*

5.13. Art. 16 TUB: libera prestazione di servizi

Laddove le attività bancarie vengano svolte fuori dalla sede della banca, devono essere realizzate da **dipendenti bancari** o da **consulenti finanziari** (ex promotori finanziari). Questo limite non vale per l'attività promozionale, ma per la conclusione effettiva dei rapporti.

L'attività fuori sede è definita dalle Istruzioni di vigilanza come quella svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle succursali ed è disciplinata a tutela del risparmiatore: è una norma **di interesse generale**, alla quale si attengono anche le banche estere che operano in Italia con succursali o in libera prestazione di servizi. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento è regolata dal TUF; la disciplina bancaria riguarda gli altri prodotti e servizi e si fonda su due nozioni: la «promozione», cioè la pubblicizzazione e la consulenza nei confronti di potenziale clientela, e il «collocamento», che consiste nella raccolta delle proposte contrattuali firmate dai clienti, in un'eventuale prima istruttoria e nel successivo inoltro della proposta alla banca. Ciò che si raccoglie fuori sede è dunque una proposta, e il contratto non si perfeziona fuori sede: nelle operazioni di finanziamento la valutazione del merito creditizio resta di esclusiva competenza della banca.

Per la promozione e il collocamento il Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 ha ampliato i soggetti utilizzabili: dipendenti e promotori finanziari, altre banche o SIM, imprese ed enti di assicurazione, agenti assicurativi, intermediari finanziari, agenti in attività finanziaria

e altri soggetti convenzionati che svolgano in via principale un'attività professionale o commerciale cui è funzionale la distribuzione di prodotti bancari. Resta fermo il principio per cui ciò che non si delega è la decisione di contrarre. L'apertura è bilanciata da presidi organizzativi: l'incarico è formalizzato in un contratto scritto che definisce condizioni, contenuti e limiti dell'operatività (livelli del servizio, reporting, trasparenza e riservatezza, attribuzione dei rischi), la clientela deve poter individuare in modo univoco la controparte bancaria e l'affidamento a soggetti esterni non esime la banca dal rispetto della disciplina di trasparenza, antiriciclaggio e tutela del consumatore.

Comma 1: *"Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia".*

Non è richiesta alcuna autorizzazione, ma operano gli adempimenti notificatori previsti dalle norme europee. Se la banca intende svolgere all'estero attività non ammesse al mutuo riconoscimento, deve inviare un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente dello Stato ospitante, oltre a rispettarne l'ordinamento.

Comma 2: *"Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia".*

Vale la stessa logica del comma 2 dell'art. 15: fuori dall'Unione manca il mutuo riconoscimento e serve un titolo nazionale. Il termine è di centoventi giorni; il rilascio è subordinato all'esistenza nello Stato terzo di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia antiriciclaggio, e all'assenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso l'eventuale struttura temporanea. Per le banche appartenenti a gruppi la domanda è inoltrata dalla capogruppo, e la Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente dello Stato terzo.

Comma 3: *"Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza".* Comma autoesplicativo: applica l'home country control, perché non occorre alcun atto italiano ma solo un flusso informativo fra autorità.

Comma 4: *"Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità. Allo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'articolo 29 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

Per le banche extracomunitarie, l'autorizzazione è rilasciata sempre da BI.

Per queste banche non esiste passaporto e serve un titolo nazionale. Le Disposizioni di vigilanza disciplinano il procedimento: la domanda, a firma del legale rappresentante, è corredata di un programma di attività con le attività e le **modalità** con cui la banca intende operare, e dell'attestazione dell'autorità dello Stato d'origine sull'assenso all'iniziativa, sulla solidità patrimoniale e sull'adeguatezza delle strutture della banca e del gruppo, e sull'effettivo esercizio nello Stato d'origine delle attività indicate. Il termine del procedimento è di centoventi giorni. La

Banca d'Italia valuta l'assenza di impedimenti a un esercizio efficace della vigilanza sul gruppo e sugli stretti legami, l'esistenza nello Stato d'origine di una regolamentazione adeguata anche in materia antiriciclaggio, l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni (o almeno l'assenza di ostacoli), e che le attività siano esercitate con le stesse modalità previste per le banche italiane, le quali devono poterle svolgere a condizioni di reciprocità nello Stato d'origine. L'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di vincoli all'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico. Dopo l'autorizzazione si applica un nucleo selezionato di disposizioni di vigilanza, e la Banca d'Italia può richiedere ogni dato necessario per l'osservazione dell'attività svolta sul territorio italiano.

Dalla lezione di LEGB-2 del 10 novembre 2026: banche di Stato terzo e libera prestazione di servizi. Il docente ha segnalato che, in attuazione della CRD 6, la norma sulla libera prestazione di servizi da parte di banche extracomunitarie non c'è più nei termini descritti qui: una banca di un paese terzo che voglia operare nell'Unione europea può farlo, per le attività bancarie principali, solo con una succursale, perché la libertà di stabilimento riguarda i soggetti europei e si è ritenuto rischioso consentire l'operatività senza nemmeno una succursale. Il testo del d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 5 dell'8 gennaio 2026) conferma la sostanza, ma con una tecnica diversa dalla semplice soppressione del comma:

- il nuovo art. 14-bis impone alla banca di Stato terzo di stabilire una succursale per esercitare la raccolta di depositi, i prestiti e il rilascio di garanzie (art. 1, comma 2, lett. f, nn. 1, 2 e 6), con deroghe per le prestazioni nei confronti di banche, di altre imprese del suo gruppo e di clienti che si rivolgono di propria iniziativa esclusiva alla banca (comma 3);
- il comma 4 dell'art. 16 non è abrogato ma sostituito: fermi restando l'art. 14-bis, commi 2 e 3, e l'art. 29-ter TUF, le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite, e la Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività; la comunicazione prende quindi il posto dell'autorizzazione, ma solo per ciò che resta fuori dall'obbligo di succursale;
- l'autorizzazione delle succursali di banche di Stato terzo passa all'art. 14-bis: sono abrogati l'art. 15, comma 4 (ulteriori succursali), e i commi 3-ter e 4 dell'art. 14 (prima succursale);
- le nuove norme si applicano dall'11 gennaio 2027 (art. 4, comma 1, d.lgs. 208/2025): fino a quella data restano in vigore gli artt. 14, 15 e 16 nella versione descritta in questa nota. Per i contratti conclusi prima dell'11 luglio 2026 la banca può continuare, senza succursale, le sole attività strettamente necessarie alla gestione, senza novazione né rinnovo, e i contratti a tempo indeterminato vanno estinti o trasferiti ad altri intermediari entro il 10 gennaio 2028.

Comma 5: *"La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane".*

Le Disposizioni di vigilanza definiscono la prestazione di servizi senza stabilimento come lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, inclusi i servizi e le attività di investimento, nel territorio di uno Stato estero in mancanza di succursali o di agenti collegati, con o senza un'organizzazione temporanea; vi rientra anche l'offerta effettuata con la presenza occasionale di personale incaricato. Per i servizi prestati per posta o con altri mezzi di comunicazione (telefonici o telematici) devono ricorrere **entrambe** due condizioni: il servizio è fornito a seguito di un'iniziativa commerciale, rivolta dal prestatore a soggetti residenti o aventi sede all'estero, che non si limiti alla promozione ma contenga un **invito a concludere il contratto**; e l'offerta precede lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti, oppure il contratto può essere concluso a distanza. Se non ricorrono, i servizi prestati senza spostamento del prestatore restano liberamente effettuabili e non rientrano nella disciplina.

Sono invece esclusi dalla libera prestazione e ricadono nello stabilimento i servizi resi con ATM installati nello Stato ospitante presso i quali è presente personale della banca (gli sportelli automatici privi di personale restano nella prestazione senza stabilimento) e i servizi prestati tramite soggetti terzi insediati nello Stato ospitante, compresi gli agenti collegati, quando ricorrano **congiuntamente** quattro condizioni:

- operano in via esclusiva per un'unica banca;
- hanno il potere di negoziare affari con terzi;
- possono obbligare la banca;
- agiscono in via continuativa.

Se ne manca anche una sola, i servizi prestati rientrano nella libera prestazione di servizi.

(pagina 6–7)

5.14. Art. 17 TUB: attività non ammesse al mutuo riconoscimento

Non è un articolo particolarmente importante: si specifica che per tutte le attività **non ammesse al mutuo riconoscimento** è sempre richiesta l'**autorizzazione** da parte di BI.

Comma 1: *"La Banca d'Italia disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica".*

Il testo attribuisce quindi alla Banca d'Italia il compito di disciplinare queste attività; l'autorizzazione di cui si è detto è quella che la normativa secondaria prevede per le succursali e per la prestazione di servizi senza stabilimento di banche comunitarie. Queste possono esercitare in Italia, nel rispetto delle norme di interesse generale, le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione dell'autorità dello Stato d'origine; possono esercitare attività **diverse** soltanto previa autorizzazione, a due condizioni: che le attività siano effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine e che l'autorità competente di quello Stato sia stata informata dell'intenzione di svolgerle in Italia tramite la succursale. Nella valutazione si tiene conto della circostanza che tali attività possano essere esercitate dalle banche italiane (parità

concorrenziale) e il termine del procedimento è di centoventi giorni. Specularmente, le banche italiane che vogliano svolgere all'estero attività non ammesse al mutuo riconoscimento inviano una comunicazione preventiva all'autorità dello Stato ospitante.

Il **mutuo riconoscimento** è il principio per cui la banca autorizzata in uno Stato dell'Unione può esercitare negli altri Stati, in stabilimento o in libera prestazione di servizi, le attività per cui è autorizzata nello Stato d'origine senza una nuova autorizzazione dello Stato ospitante: è il corollario dell'armonizzazione minima delle condizioni di accesso e dell'home country control. Opera soltanto fra Stati membri (per le banche di Stato terzo non esiste passaporto) e copre un perimetro definito di attività, elencate dall'art. 1, comma 2, lett. f):

- raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
- operazioni di prestito (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale incluso il forfaiting);
- leasing finanziario;
- prestazione di servizi di pagamento ed emissione e gestione di mezzi di pagamento;
- rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e d'interesse, valori mobiliari;
- partecipazione alle emissioni di titoli e prestazione di servizi connessi;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale, e consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
- servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
- gestione o consulenza nella gestione di patrimoni, custodia e amministrazione di valori mobiliari, servizi di informazione commerciale, locazione di cassette di sicurezza;
- le altre attività aggiunte, per misure di adattamento dell'Unione, all'elenco allegato alla seconda direttiva (89/646/CEE).

Fuori da quel perimetro torna a operare la competenza dello Stato ospitante.

L'home country control non esclude del tutto i poteri dello Stato ospitante. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche dell'Unione europea nel territorio della Repubblica, con le modalità da essa stabilite (art. 55), e le Disposizioni di vigilanza prevedono la facoltà di ispezione previa consultazione dell'autorità dello Stato d'origine. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione di disposizioni il cui controllo spetta all'autorità d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a questa e, **in attesa** dei suoi provvedimenti, se vi sono ragioni di urgenza, può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela di depositanti, risparmiatori e altri soggetti cui sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti (art. 79, comma 1). Se la violazione riguarda la liquidità, o in ogni caso di deterioramento della situazione di liquidità, può intervenire se le misure dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate (comma 2); quando i provvedimenti dell'autorità d'origine mancano o sono inadeguati può ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie fra autorità (comma 3); per le violazioni il cui controllo spetta già alla Banca d'Italia adotta direttamente le misure necessarie, compresa la chiusura della succursale (comma 4). Il

potere del comma 1 è quindi provvisorio e sussidiario, e non un potere ordinario di vigilanza sulla succursale comunitaria. *(pagina 7)*

5.15. Art. 18 TUB: attività finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

In Italia, al momento dell'entrata in vigore del TUB, erano ancora presenti banche che esercitavano esclusivamente il **binomio raccolta-impiego**, poiché era loro precluso poter svolgere altre attività. In Germania, al contrario, esisteva il modello della **banca universale** (da non confondere con il concetto di banca mista), che permetteva alla banca di svolgere anche attività finanziarie.

La **banca universale** è un modello ordinamentale, in cui alla banca è consentito svolgere direttamente anche attività finanziarie oltre al credito, ed è compatibile con la separatezza fra banca e industria. La **banca mista** è invece la prassi storica italiana anteriore al 1936, in cui la banca finanziava a breve l'impresa industriale e ne assumeva stabilmente partecipazioni, confondendo credito a breve e investimento di lungo periodo: è la commistione che la legge bancaria del 1936 intese superare con la specializzazione.

L'unico modo che aveva una banca italiana per poter svolgere altre attività era la costruzione del **gruppo bancario pluri- (o poli-) funzionale**: in pratica si costituivano e si assumevano la maggior parte delle partecipazioni in una società avente come oggetto sociale l'attività finanziaria che si desiderava svolgere.

Se la nozione di mutuo riconoscimento avesse riguardato solo le banche in quanto tali, ciò sarebbe andato fortemente a vantaggio delle banche tedesche e a svantaggio di quelle italiane. Durante i lavori preparatori della **seconda direttiva** la delegazione italiana ottenne l'estensione del beneficio del mutuo riconoscimento anche alle **società finanziarie partecipate da banche**. La partecipazione sarebbe dovuta però essere molto significativa: in particolare, la finanziaria sarebbe dovuta essere partecipata da una banca almeno nella misura del **90% del capitale**.

Le Disposizioni di vigilanza fissano oggi cinque condizioni cumulative:

- la società è controllata da una o più banche italiane;
- le banche controllanti detengono almeno il **90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria**: il requisito si aggiunge a quello del controllo, e capitale e diritti di voto possono divergere;
- le controllanti si sono dichiarate **garanti in solido** degli impegni assunti dalla società nello Stato in cui intende operare;
- la società è inclusa nella vigilanza consolidata cui sono sottoposte le controllanti;
- lo statuto consente di esercitare le attività che intende svolgere in ambito comunitario, e queste sono già effettivamente esercitate in Italia.

Comma 1: *"Le disposizioni dell'articolo 15, commi 01 e 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza*

prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia".

Questo comma si riferisce proprio all'estensione del principio del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche.

Comma 2: *"Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato".*

Viene specificato appositamente "in armonia con la normativa comunitaria" perché si vuole essere sicuri che valgano le condizioni di **reciprocità**: le finanziarie delle banche comunitarie possono, in modo speculare, operare in Italia.

Comma 3: *"La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2".*

Comma 4: *"Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54, commi 1, 2 e 3".*

Comma 5: *"Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 79, commi 1, 3 e 4".*

Il beneficio del passaporto si accompagna così alla soggezione ai poteri di controllo: l'art. 54 riguarda la vigilanza ispettiva e, per le finanziarie comunitarie, l'art. 79 i provvedimenti della Banca d'Italia in caso di violazioni o di rischi per i depositanti e i risparmiatori. *(pagina 7–8)*

6 | Titolo II TUB, Capo III: le partecipazioni nelle banche

Fonte: LEGB1_Appunti_06_Titolo-II-Capo-III-Partecipazioni.pdf — *5 pagine*

6.1. Introduzione: il Capo III e la nozione di partecipazione

Il Capo III del Titolo II TUB disciplina **le partecipazioni nelle banche**. Per "partecipazione" si intende qui la partecipazione al capitale della banca da parte dei soci, cioè una partecipazione **a monte**.

> Nota: questa nozione non va confusa con le *partecipazioni bancarie*, che sono invece le partecipazioni detenute da una banca in altre società (partecipazioni **a valle**): un discorso diverso, trattato separatamente.

Contesto storico. La precedente legge bancaria era nata, fra le altre cose, per evitare che si ripetessero le situazioni che avevano portato alla grande depressione del '29; una di queste era la commistione fra banca e industria (il termine "industria" è qui usato in senso lato, per indicare tutto ciò che non è banca o finanza). La legge bancaria aveva quindi introdotto il principio di **separazione fra banca e industria**. Gli obiettivi della disciplina erano:

- garantire la trasparenza degli assetti proprietari della banca;
- garantire, attraverso i principi autorizzativi, la separazione fra banca e industria;
- assicurare la sana e prudente gestione della banca.

L'impianto iniziale della precedente legge bancaria era molto simile a quello attuale: l'articolo 19 definiva (e definisce tuttora) la disciplina delle autorizzazioni, originariamente con una soglia fissata al 5%, e l'articolo 20 gli obblighi di comunicazione. Col tempo sono cambiati i contenuti, ma la struttura è rimasta quella.

Ratio. La banca raccoglie risparmio fra il pubblico e l'art. 47 Cost. impone di tutelarlo e di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito. Chi controlla la banca, o può influire in modo notevole sulla sua gestione, ne indirizza le scelte, e dalla qualità del socio dipende quindi la stabilità della banca. Per questo il controllo preventivo scatta già con l'influenza notevole o con una quota almeno pari al 10 per cento, che nelle società ad azionariato diffuso può essere decisiva. Oggi la disciplina ha una finalità solo prudenziale e non risponde più a un disegno di politica industriale.

Nozione di partecipazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-quater, TUB, sono «partecipazioni» le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. La nozione è volutamente ampia, perché ciò che interessa al legislatore è la possibilità di influire sulla società.

Ambito di applicazione. Gli artt. 19-24, compreso il 22-bis, si applicano in quanto compatibili anche agli intermediari finanziari (art. 110, comma 1), agli istituti di moneta elettronica (art. 114-quinquies.3, comma 1) e agli istituti di pagamento (art. 114-undecies, comma 1); per questi soggetti i provvedimenti previsti dall'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Per l'art. 61, comma 5, le disposizioni dei capi III e IV del Titolo II (salvo quanto previsto dall'art. 67-bis) si applicano anche alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, mentre nei confronti delle altre società del gruppo bancario e dei loro partecipanti la Banca d'Italia dispone dei poteri informativi dell'art. 21. *(pagina 1)*

6.2. Art. 19 TUB — Autorizzazioni (commi 1, 2, 3, 5)

Comma 1. È soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa, oppure che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al **10 per cento**, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

Comma 2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il **20 per cento**, il **30 per cento** o il **50 per cento** e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

Comma 3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1 (acquisizione **indiretta**).

Testo vigente del comma 1. I commi 1, 2 e 3 riportati sopra rispecchiano la struttura anteriore al d.lgs. 182/2021, che ha concentrato nel comma 1 tutte le fattispecie soggette ad autorizzazione preventiva e ha abrogato i commi 2 e 3 (il comma 4 era già stato abrogato nel 2016). Oggi il comma 1 elenca quattro ipotesi:

- **lett. a)** l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute (ingresso);
- **lett. b)** le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20, il 30 o il 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca (incrementi);
- **lett. c)** l'acquisizione, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lett. a), del controllo oppure di una quota dei diritti di voto o del capitale quando, per effetto

dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'art. 22, comma 1, lett. b), cioè il criterio del moltiplicatore (acquisizione indiretta);

- **lett. d)** l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole, oppure di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 20, 30 o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

Le lett. b) e c) riprendono il contenuto degli ex commi 2 e 3. La lett. d) disciplina il potere acquisito senza acquistare partecipazioni, ipotesi prima limitata al solo controllo e regolata dal comma 8-bis, oggi abrogato. Restano in vigore, oltre al comma 5, i commi 5-bis, 5-ter, 8 e 9, riportati più avanti.

Comma 5. L'autorizzazione è rilasciata dalla **BCE**, su proposta della **Banca d'Italia**. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:

- la reputazione del potenziale acquirente (ai sensi dell'art. 25);
- l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca;
- la solidità finanziaria del potenziale acquirente;
- la capacità della banca di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attività;
- l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza;
- la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti o le condizioni per il suo rilascio.

Comma 5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

Comma 5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.

Commento ai commi 5-bis e 5-ter. Il comma 5-ter, inserito nel 2016, è per le banche l'unica ipotesi in cui la competenza decisoria, che dal 2014 spetta alla BCE, torna alla Banca d'Italia. La ragione è funzionale: la risoluzione si svolge in tempi molto compressi e produce i suoi effetti attraverso la cessione di beni e rapporti a un acquirente o a un ente-ponte, sicché attendere il procedimento europeo di valutazione renderebbe lo strumento inutilizzabile. L'autorità competente cambia, ma l'acquirente deve comunque superare la valutazione del comma 5.

Il rinvio ai commi 2 e 3 non è stato coordinato con l'abrogazione operata dal d.lgs. 182/2021, che ne ha trasfuso il contenuto nelle lett. b) e c) del comma 1: va quindi letto come riferito alle fattispecie oggi contenute nel comma 1. La deroga riguarda la sola acquisizione effettuata nell'ambito di una risoluzione, non quelle in una banca semplicemente in difficoltà o in liquidazione coatta amministrativa.

Comma 8. La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui al comma 1.

Comma 9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nel presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b); i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.

Commento ai commi 8 e 9. Al MEF e al CICR non spetta alcun potere decisorio sul singolo procedimento: il comma 8 impone una semplice notizia, relativa alle domande e non ai provvedimenti, che costituisce un flusso informativo verso l'organo posto al vertice dell'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Il MEF conserva invece un potere normativo, perché è un suo decreto, sentita la Banca d'Italia, a individuare i requisiti dei partecipanti ai sensi dell'art. 25, comma 2. Le disposizioni attuative del comma 9 sono quelle della Banca d'Italia del 26 luglio 2022 in materia di assetti proprietari.

Commi abrogati. Sono stati abrogati nel 2010 i commi 6 (divieto di assunzione di partecipazione al capitale della banca da parte di imprese industriali per un valore non superiore al 15%) e 7, relativi alla separatezza banca-industria. Non esiste quindi più questa separatezza per le partecipazioni a monte (discorso a parte per quelle a valle).

Il comma 6 vietava di autorizzare l'acquisizione di partecipazioni ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari, quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta fosse superiore al 15 per cento o ne conseguisse comunque il controllo della banca. Il comma 7 imponeva alla Banca d'Italia di negare o revocare l'autorizzazione in presenza di accordi da cui derivasse durevolmente, in capo a quei soggetti, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca. L'abrogazione si spiega con l'armonizzazione europea, che vuole criteri di valutazione tassativi e di natura esclusivamente prudenziale: un divieto fondato sulla natura industriale dell'acquirente è una scelta di politica industriale. Oggi un gruppo industriale può quindi acquisire il controllo di una banca, purché superi la valutazione del comma 5; le commistioni pericolose si intercettano caso per caso, attraverso la reputazione dell'acquirente, l'idoneità della struttura del suo gruppo a consentire una vigilanza efficace e la capacità della banca di rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività. *(pagina 1–2)*

6.3. Art. 19 TUB — Commento: procedura, soglie e nozione di acquisizione

Significato di "autorizzazione preventiva". Come specificato nelle norme secondarie, l'autorizzazione preventiva è necessaria prima del perfezionamento dell'operazione relativa al trasferimento della partecipazione (quindi prima dell'acquisto). È utile, ma non obbligatorio, avvisare già Banca d'Italia (BI) dell'inizio delle trattative. BI fornisce una risposta entro **60 giorni lavorativi** (termine previsto dall'art. 22 della CRD IV, dir. 2013/36/UE).

Un'altra interpretazione del concetto di "preventiva", proposta in dottrina, riteneva che tale autorizzazione fosse propedeutica solo alla possibilità di esercitare i diritti di voto e non al trasferimento della partecipazione.

Se il contratto è stipulato prima della conclusione del procedimento, la sua efficacia deve essere subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione; in mancanza, operano le conseguenze dell'art. 24 (sospensione del voto e obbligo di alienazione), il che rende difficilmente sostenibile la tesi dottrinale appena ricordata. Le disposizioni attuative prevedono tempi particolari per tre ipotesi: nell'OPA o OPS l'istanza è presentata prima della promozione dell'offerta; per gli strumenti finanziari che si convertono automaticamente in partecipazioni al verificarsi di eventi legati all'andamento dell'impresa, prima dell'evento o, se questo non era prevedibile, subito dopo la conversione; per la maggiorazione del diritto di voto (art. 127-quinquies TUF), prima del compimento del periodo continuativo di possesso. L'unica deroga al carattere preventivo riguarda l'acquisizione involontaria, trattata più avanti. L'istanza presentata in ritardo vale per il futuro: non cancella l'illecito già consumato né la sospensione del voto che ne discende.

Rapporto con la disciplina OPA. In caso di acquisto di partecipazioni superiori al **30%** scatta l'obbligo di OPA ai sensi dell'art. 106 TUF. L'autorizzazione BCE/Banca d'Italia (art. 19 TUB) deve essere ottenuta **prima**, e solo successivamente la CONSOB approva il documento d'offerta. Ai sensi dell'art. 102, comma 4, TUF, la CONSOB approva il prospetto entro cinque giorni dalla comunicazione del rilascio delle autorizzazioni di settore (BCE/BI). I due procedimenti hanno oggetto diverso e non si assorbono: la CONSOB presidia la parità di trattamento degli azionisti e la trasparenza del mercato, l'autorizzazione dell'art. 19 la sana e prudente gestione della banca. L'istanza di vigilanza va presentata prima della promozione dell'offerta, e l'obbligo di OPA si innesta su un assetto proprietario già vagliato: l'art. 19 richiede l'autorizzazione già al raggiungimento del 10, del 20 e del 30 per cento.

Acquisizione vs. acquisto. L'articolo usa il termine *acquisizione* e non *acquisto* (compravendita) perché è un concetto più generale, che vale a qualsiasi titolo. Ciò che conta è il trasferimento dell'esercizio del diritto di voto. L'articolo si riferisce inoltre sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche.

Rientrano nell'acquisizione l'acquisto a titolo oneroso o gratuito, la successione, il conferimento, la fusione, l'esercizio di un diritto di conversione e, per la lett. d) del comma 1, l'acquisizione del potere in assenza di qualunque acquisto. Il comma 9 affida alla Banca d'Italia l'individuazione

dei soggetti tenuti a chiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare: nella scissione fra titolarità ed esercizio del voto l'obbligo grava su entrambi. Le disposizioni attuative tipizzano alcune ipotesi: l'accordo che prevede il trasferimento provvisorio dei diritti di voto; il deposito a garanzia, se il depositario può esercitare liberamente il voto e dichiara di volerlo esercitare; il pegno e l'usufrutto; la delega di voto che lasci al delegato margini di discrezionalità; il prestito titoli, il riporto e i pronti contro termine (obblighi su entrambe le parti). Nel trust il trustee è sempre soggetto all'obbligo di autorizzazione preventiva, mentre disponente e beneficiari lo sono salvo che il trustee dimostri che non possono esercitare alcuna influenza sull'esercizio dei diritti, né direttamente né indirettamente (un potere di revoca del trustee basta a configurare un'influenza indiretta). Nell'intestazione fiduciaria l'autorizzazione è richiesta sia al fiduciante sia al fiduciario, che calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nella stessa banca, comprese quelle detenute per conto di altri. L'obiettivo è impedire che uno schermo giuridico consenta di governare una banca restando invisibili alla vigilanza.

Acquisizione indiretta (comma 3). Questo comma richiede l'autorizzazione preventiva da parte di BI anche in caso di acquisizione indiretta di partecipazioni, cioè quando si acquisisce il controllo di una società che a sua volta detiene le partecipazioni rilevanti nella banca. Dopo il d.lgs. 182/2021 la fattispecie è nella lett. c) del comma 1 e rileva anche l'acquisizione di una quota che integra il criterio del moltiplicatore dell'art. 22, comma 1, lett. b).

Calcolo delle soglie. Il comma 9 affida alla Banca d'Italia i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini delle soglie, compresi i casi in cui i diritti di voto non sono computati. Le disposizioni attuative aggregano le partecipazioni acquisite o detenute direttamente e indirettamente e prevedono tre calcoli distinti: sul capitale (azioni da acquisire più quelle già possedute, rapportate al totale delle azioni emesse); sui diritti di voto (rapportati a tutti i diritti di voto esercitabili, anche se sospesi o limitati a particolari argomenti); e, se la banca ha emesso azioni a voto limitato a particolari argomenti, sui diritti di voto argomento per argomento. L'autorizzazione è dovuta quando una soglia è raggiunta o superata in base anche a uno solo dei tre calcoli: capitale e voti possono divergere (azioni a voto plurimo o limitato) e l'influenza può derivare dagli uni o dall'altro. Le azioni proprie della banca non si computano al denominatore; se nello stesso giorno vengono compiute più operazioni di acquisto e vendita, rileva la partecipazione risultante dall'ultima; il candidato somma le partecipazioni possedute direttamente, indirettamente o di concerto e quelle gestite.

Non si considerano ai fini dell'obbligo autorizzativo nove casi di detenzione strumentale e transitoria, senza intento di intervenire nella gestione: le partecipazioni acquisite al solo fine della compensazione e liquidazione entro il ciclo di negoziazione; quelle detenute dalle controparti centrali nelle procedure esecutive; quelle detenute in custodia, se il voto è esercitato solo su istruzioni scritte o elettroniche; quelle acquisite o cedute da una banca o impresa di investimento che agisce come market maker, a condizione di essere autorizzata alla negoziazione in conto proprio, di non intervenire nella gestione e di tenere le partecipazioni identificabili o contabilmente separate; quelle detenute nel collocamento con assunzione a fermo o di garanzia, se il voto non è esercitato e le partecipazioni sono cedute entro un anno; quelle del portafoglio di negoziazione,

se i diritti di voto non superano il 5 per cento e non sono usati per intervenire nella gestione; quelle acquisite per stabilizzazione ai sensi del Reg. (UE) 596/2014; quelle ricevute dalle banche centrali del SEBC nell'esercizio delle funzioni di autorità monetaria, con operazioni di breve durata e senza esercizio del voto; quelle acquisite in via temporanea in base a un programma negoziale predefinito, con impegno a cederle entro sette giorni e a non esercitare i diritti, previa comunicazione all'Autorità. Se il voto è esercitato per intervenire nella gestione, l'esenzione cade.

Influenza notevole. È il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative della banca senza averne il controllo, ed è una fattispecie autonoma dell'art. 19, comma 1, lett. a) e d): la sua acquisizione richiede l'autorizzazione anche quando nessuna soglia quantitativa è superata. Può derivare da una partecipazione inferiore al 10 per cento, dall'acquisto di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o i diritti dell'art. 2351, ultimo comma, c.c., oppure da un contratto con la banca o da una clausola statutaria. L'accertamento avviene per indici, valutando l'assetto proprietario e il governo societario della banca e le relazioni fra la banca, gli altri partecipanti e il candidato:

- il contesto assembleare: la frammentazione dell'azionariato (con le altre partecipazioni in mano a soggetti che non influiscono sulla gestione, anche una quota inferiore al 10 per cento può bastare) e i rapporti, anche negoziali, con altri partecipanti che consentono di esercitare congiuntamente un'influenza notevole;
- il potere sugli organi e sulle decisioni: la capacità di nominare almeno un componente dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica (esprimere componenti in rappresentanza della minoranza non è di per sé un indice) e la capacità di incidere sulle decisioni strategiche, anche con diritti di veto, senza che si configuri un controllo di fatto o congiunto;
- i legami fra candidato e banca: la presenza del candidato negli organi della banca o della sua controllante, le transazioni ricorrenti e rilevanti, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;
- gli indici di fonte statutaria o strumentale: strumenti finanziari partecipativi che conferiscono il potere di nomina o di partecipazione alle decisioni strategiche e, nelle s.r.l., i diritti particolari attribuiti al singolo socio ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c.

Non esiste una presunzione percentuale: la verifica è sempre in concreto. L'influenza notevole va distinta dall'influenza dominante dell'art. 23, comma 2: la prima è partecipazione alla determinazione delle politiche senza controllo, la seconda è una forma di controllo.

Acquisizione involontaria. Il comma 9 rinvia alle disposizioni attuative anche per i casi di acquisizione involontaria, cioè il raggiungimento o il superamento di una soglia per eventi non noti né riconducibili al soggetto. L'obbligo autorizzativo resta, ma l'istanza può essere presentata successivamente, non appena l'evento si verifica o, se posteriore, quando il soggetto ne viene a conoscenza. Le ipotesi tipizzate a titolo esemplificativo sono l'acquisto di azioni proprie da parte della banca, le operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio la riduzione del capitale con annullamento), il recesso di altri soci, l'acquisizione indiretta tramite una società non controllata che acquisisce o incrementa una partecipazione qualificata nella banca (in parti-

colare con fusioni e scissioni) e l'aggregazione di partecipazioni indirette detenute tramite gestori controllati. L'autorizzazione non è dovuta se il soggetto riduce senza indugio la partecipazione al di sotto della soglia superata involontariamente; resta ferma in ogni caso la comunicazione. Fino all'autorizzazione non possono essere esercitati i diritti di voto eccedenti le soglie oppure, se si è conseguito il controllo o l'influenza notevole, quelli relativi all'intera partecipazione: la sospensione ha qui una funzione cautelare e opera anche dove nessun illecito è stato commesso.

Trasferimenti infragruppo. Quando una partecipazione qualificata è trasferita fra soggetti dello stesso gruppo, sono tenuti all'autorizzazione i soggetti non precedentemente autorizzati a detenere una partecipazione qualificata nella banca e il soggetto che acquisisce direttamente la partecipazione; il vertice del gruppo e gli altri soggetti già autorizzati ne sono esonerati. La regola evita di duplicare la valutazione e non costituisce un'esenzione di gruppo: restano dovute le comunicazioni. Nelle catene partecipative l'istanza può essere presentata dal soggetto al vertice anche per conto del candidato diretto e dei soggetti interposti.

Requisiti soggettivi (comma 5). Il comma richiede una serie di requisiti (reputazione, idoneità, solidità finanziaria, assenza di sospetti di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, ecc.) perché possa essere autorizzata l'acquisizione di una partecipazione rilevante.

Reputazione (primo criterio). L'art. 25, comma 1, richiede che i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. Il comma 2 rimette a un decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, l'individuazione dei requisiti di onorabilità, dei criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione che il titolare può esercitare, e dei criteri di correttezza (relazioni d'affari, condotte verso le autorità di vigilanza, sanzioni o misure correttive da queste irrogate, provvedimenti restrittivi su attività professionali, ogni altro elemento rilevante). L'onorabilità è quindi un requisito tipizzato, mentre competenza e correttezza sono criteri più elastici; la competenza richiesta a chi entra con una quota minima non è quella richiesta a chi acquisisce il controllo. Per le persone giuridiche i requisiti sono accertati in capo ai soggetti individuati dalla disciplina attuativa e la verifica è svolta in prima istanza dall'organo di appartenenza, che delibera senza il voto dell'interessato, con verbale analitico trasmesso all'Autorità. Per i soggetti esteri la verifica avviene sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale: si confronta la sostanza dell'istituto straniero con quella dell'istituto italiano e, per i candidati che svolgono attività bancaria o finanziaria, l'equivalenza riguarda anche il sistema di vigilanza cui sono sottoposti.

Esponenti futuri (secondo criterio). Il criterio porta nella valutazione dell'acquirente l'idoneità degli esponenti che entreranno in carica dopo l'acquisizione, perché il mutamento del socio di controllo comporta di regola il rinnovo degli organi e la legge vuole che questo sia valutato già in sede autorizzativa. Destinatari sono soltanto coloro che svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione: non i titolari delle partecipazioni, coperti dal primo criterio, né i soggetti con funzioni di controllo. Il richiamo è all'art. 26, comma 3, cioè al decreto ministeriale e ai suoi contenuti. Se gli esponenti non sono ancora noti al momento dell'istanza, la verifica è differita e una nuova verifica va condotta entro trenta giorni dalla nomina.

Solidità finanziaria (terzo criterio). Il criterio guarda sia al soggetto sia al progetto. Le disposizioni attuative richiedono che il candidato sia in grado di finanziare un progetto economicamente sostenibile, di assicurare alla banca le risorse necessarie per il regolare esercizio dell'attività nel medio termine (di norma almeno tre anni) e di mantenere in prospettiva un'equilibrata struttura economico-patrimoniale e finanziaria. Si valutano la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del candidato e delle sue controllate; l'ammontare della partecipazione rispetto al suo patrimonio; le fonti di finanziamento dell'operazione (se l'acquisto è finanziato con debito: sostenibilità, garanzie rilasciate ai finanziatori e riflessi sull'acquirente e sulla banca); i rapporti economici in essere o attesi con la banca e il suo gruppo, anche per prevenire conflitti di interesse. L'intensità della verifica dipende dalla finalità dell'investimento (strategico o di portafoglio), dall'orizzonte temporale e dalla natura del candidato: può rilevare, ad esempio, che si tratti di un fondo di private equity o di un hedge fund. Se la partecipazione è acquisita tramite un OICR la solidità è verificata in capo all'OICR; per la società fiduciaria in capo al solo fiduciante; per il trust sul patrimonio del trust; nel concerto in modo unitario sull'insieme dei concertanti.

Capacità della banca e struttura del gruppo (quarto e quinto criterio). Il quarto criterio sposta lo sguardo dall'acquirente alla banca: l'operazione non deve pregiudicare la capacità di rispettare nel medio termine (indicativamente tre anni, a livello individuale e consolidato) le disposizioni che ne regolano l'attività; i contenuti dei requisiti prudenziali appartengono alla vigilanza regolamentare. Il quinto verifica che la struttura del gruppo dell'acquirente non ostacoli lo scambio di informazioni fra le autorità né l'attività di vigilanza, anche con riguardo alle società estere del gruppo: è il criterio che intercetta le catene partecipative opache. Lo strumento istruttorio dipende dall'entità della partecipazione: per quelle superiori al 50 per cento del capitale o dei diritti di voto, o che comportano il controllo, si esamina il piano industriale; per quelle che comportano influenza notevole o comprese fra il 20 e il 50 per cento è richiesto un documento più snello sulle finalità e sugli obiettivi di medio periodo.

Criterio antiriciclaggio (sesto criterio). Il criterio richiede la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le disposizioni attuative considerano il profilo economico del candidato e la sua compatibilità con l'acquisizione; la provenienza dei fondi, che va ricostruita a ritroso e senza soluzione di continuità, con trasferimenti effettuati tramite istituzioni finanziarie soggette alla supervisione di autorità dello Spazio economico europeo o di Stati terzi equivalenti secondo le raccomandazioni del GAFI; l'uso di strutture complesse o opache o la difficoltà di identificare chi sta al vertice della catena; l'impatto dell'acquisizione sul piano industriale e sulla struttura organizzativa della banca. La valutazione si estende ai soggetti con cui il candidato ha stretti legami personali o d'affari e al suo titolare effettivo (d.lgs. 231/2007). L'autorizzazione non può essere rilasciata se sussiste il fondato sospetto, anche in assenza di una sentenza di condanna. Accrescono di per sé il rischio, e precludono l'autorizzazione, la residenza o la sede legale del candidato o di altre società del suo gruppo in uno Stato ad alto rischio secondo il GAFI, o relazioni personali o d'affari rilevanti in tale Stato; la residenza o le relazioni in uno Stato che la Commissione europea indica come carente nei presidi antiriciclaggio sono invece valutate caso per caso.

Proporzionalità. La valutazione è condotta secondo il principio di proporzionalità: contano la natura del candidato, l'entità della partecipazione, la durata prevista della detenzione, la tipologia di impresa vigilata e il suo ruolo nel gruppo. La proporzionalità gradua l'intensità dell'istruttoria e la documentazione richiesta, non il numero dei criteri, che restano sei e tassativi: non rileva la convenienza economica dell'operazione. Nelle catene partecipative in cui gli intermedi sono imprese vigilate la valutazione può limitarsi al vertice e al candidato diretto; chi è già autorizzato in via indiretta e acquisisce una partecipazione diretta è valutato solo per le modifiche dei presupposti dell'autorizzazione già rilasciata; nel concerto con un numero elevato di aderenti la valutazione può limitarsi a quelli in grado di incidere in modo determinante sugli assetti di potere interni all'accordo.

Documentazione dell'istanza. L'istanza è corredata dalle informazioni previste dall'Allegato I al provvedimento della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021, costruito in parallelo ai criteri del comma 5: caratteristiche dell'operazione (prezzo, finalità strategica o di portafoglio, periodo atteso di detenzione, altre autorizzazioni richieste), candidato acquirente (persona fisica o giuridica), nuovi esponenti se noti, solidità finanziaria, capacità della banca e struttura del gruppo, antiriciclaggio, informazioni aggiuntive in ragione dell'entità della partecipazione (documento sulle linee strategiche o piano industriale), operazioni tramite trust, fondi sovrani o gestori di FIA (per questi ultimi, tra l'altro, l'identità dei partecipanti al fondo con quote dell'impresa target pari o superiori allo 0,5 per cento) e informazioni ridotte per chi è stato valutato dalla Banca d'Italia come partecipante qualificato nei due anni precedenti o è un intermediario italiano vigilato dalla Banca d'Italia o dalla BCE. La reputazione si documenta per fatti, con riferimento ad almeno i dieci anni precedenti e indipendentemente dallo Stato in cui si sono verificati: procedimenti penali anche in corso, misure cautelari anche provvisorie, procedure concorsuali, sanzioni e interventi delle autorità di vigilanza, provvedimenti di decadenza o rimozione, radiazione da albi.

Competenza e procedimento. La competenza della BCE riguarda tutte le banche, significative e meno significative: l'art. 4, par. 1, lett. c), del Reg. (UE) 1024/2013 le attribuisce in via esclusiva la valutazione delle notifiche di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate, tranne nel caso di risoluzione di una crisi bancaria. È uno dei procedimenti comuni del MVU, insieme all'autorizzazione e alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria, e la distinzione fra enti significativi e meno significativi, che governa la vigilanza prudenziale ordinaria, qui non rileva. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento l'istanza è presentata all'autorità nazionale (per le banche italiane, la Banca d'Italia), che valuta l'acquisizione e trasmette alla BCE l'istanza con una proposta di decisione di vietare o non vietare almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di valutazione; la BCE decide sulla base dei criteri del diritto dell'Unione. Il raccordo interno è nell'art. 6-bis, comma 2, lett. a), TUB, per cui la Banca d'Italia formula alla BCE le proposte di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'art. 19. Per gli intermediari diversi dalle banche i provvedimenti dell'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia (artt. 110, 114-quinquies.3 e 114-undecies).

Secondo le disposizioni attuative il termine di conclusione è di sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di avvio, che l'Autorità invia entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza

completa; per le banche i giorni si computano secondo il calendario della BCE. Il mancato rilascio del provvedimento entro il termine equivale al rilascio dell'autorizzazione (silenzio-assenso, coerente con l'impostazione europea in cui la valutazione è un potere di vietare). Dopo l'avvio l'Autorità può chiedere informazioni integrative e sospendere il procedimento una sola volta, non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo, per al massimo venti giorni lavorativi (trenta se il candidato risiede in uno Stato terzo o non è un soggetto vigilato europeo); gli accertamenti ispettivi, i pareri di altre autorità e la consultazione con le autorità dello Stato di origine del candidato non sospendono i termini. Il preavviso di rigetto dell'art. 10-bis della legge 241/1990 non si applica.

Rimedi contro il diniego. Poiché la decisione è della BCE, garanzie e rimedi sono quelli del Reg. (UE) 1024/2013. Il progetto di decisione del consiglio di vigilanza si considera adottato se il consiglio direttivo non muove obiezioni entro dieci giorni lavorativi (art. 26, par. 8); prima della decisione gli interessati hanno diritto di essere sentiti, di accedere al fascicolo e di ottenere una decisione motivata (art. 22). Il rimedio amministrativo è la Commissione amministrativa del riesame (art. 24), che valuta la conformità procedurale e sostanziale della decisione: la richiesta si presenta entro un mese dalla notificazione, la Commissione esprime un parere entro due mesi e rinvia al consiglio di vigilanza perché prepari un nuovo progetto di decisione, senza annullare essa stessa l'atto. Il riesame non ha effetto sospensivo e non preclude il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Contenuto del provvedimento. L'autorizzazione può fissare un termine massimo per il perfezionamento dell'operazione, scaduto il quale cessa di avere efficacia senza bisogno di un atto di revoca, e può prevedere obblighi o condizioni a carico del candidato, anche formalizzando dichiarazioni di impegno (ad esempio sulla politica di distribuzione dei dividendi o sul sostegno finanziario aggiuntivo in caso di problemi di liquidità o di adeguatezza patrimoniale). Il termine di perfezionamento (il tempo concesso all'acquirente per eseguire l'operazione) è diverso dal termine di conclusione del procedimento (il tempo dell'Autorità per decidere). Chi acquista dopo la scadenza si trova nella posizione di chi non ha l'autorizzazione: voto sospeso e obbligo di alienazione. La violazione degli impegni assunti, insieme ai comportamenti ripetuti volti a eludere la normativa e alla comunicazione di informazioni non veritiere, è motivo di revoca.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. L'ultimo periodo del comma 5 consente di sospendere o revocare l'autorizzazione se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni del rilascio, e il soggetto autorizzato deve comunicare alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a produrre questo effetto (art. 20, comma 2-bis). Secondo le disposizioni attuative si sospende quando il presupposto venuto meno può essere ripristinato in tempi brevi dal soggetto interessato, si revoca quando il ripristino non è possibile in tempi brevi o è impossibile. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro cui ripristinare i presupposti, prorogabile per giustificati motivi anche su istanza di parte; decorso inutilmente il termine, l'autorizzazione è revocata. Il provvedimento è comunicato al partecipante, alla banca e all'eventuale capogruppo; nell'azione di concerto, se i presupposti vengono meno per uno solo degli aderenti, sospensione e revoca hanno effetto nei confronti di tutti gli altri, salvo che il concerto venga meno. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni. Gli effetti si misurano sull'art. 24: sospesa o revocata

l'autorizzazione il voto è sospeso (comma 1), ma solo la revoca fa scattare l'obbligo di alienazione del comma 3. La sospensione dell'autorizzazione (provvedimento sul titolo abilitativo) è diversa dalla sospensione dei diritti di voto (effetto legale). *(pagina 1–2)*

6.4. Art. 20 TUB — Obblighi di comunicazione

Anche questo articolo è un esempio di **delegificazione**: a differenza dell'art. 19 TUB, non sono presenti soglie stabilite a monte dal legislatore, ma vengono decise da BI.

Comma 1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.

Commento. Quando viene superata la soglia limite, attualmente fissata al **3 per cento** del capitale o dei diritti di voto (con ulteriori comunicazioni, oltre il 10%, a multipli del 5%, secondo le Disposizioni della Banca d'Italia del 2022), scatta un obbligo di comunicazione. Se un soggetto supera sia la soglia che impone l'obbligo di autorizzazione sia la soglia che impone l'obbligo di comunicazione, **l'autorizzazione prevale sulla comunicazione** (nella richiesta di autorizzazione è contenuta la comunicazione).

Modalità pratiche. Attualmente, la comunicazione avviene in forma telematica tramite l'utilizzo del **modello 287** (il cui numero deriva dalla legge antitrust 287/1990). La ragione del numero è storica: alla fine della legge 287 vennero aggiunti alcuni articoli sulla disciplina delle partecipazioni al capitale delle banche, anche se non erano inerenti alla materia antitrust.

Quando un soggetto intende acquisire una partecipazione e ciò comporta o l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 19 o l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 20 TUB, deve chiedere l'autorizzazione o comunicarlo a BI compilando l'apposito modulo che si trova nelle disposizioni di vigilanza.

Altre comunicazioni del comma 1. Le disposizioni attuative non si limitano alla soglia del 3 per cento (e ai multipli del 5 per cento oltre il 10). Vanno comunicati anche il perfezionamento delle operazioni per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione o la decisione di non concluderle, il raggiungimento del 100 per cento, la riduzione della partecipazione al di sotto di ciascuna soglia autorizzativa o di comunicazione (anche per il venir meno di un concerto: in questo caso la comunicazione è preventiva), l'alienazione eseguita in adempimento degli obblighi dell'art. 24 e le modificazioni della catena partecipativa. Il termine è di dieci giorni dal verificarsi della circostanza, o dalla sua conoscenza se l'evento non era noto né riconducibile al soggetto; la comunicazione è inviata all'Autorità competente e alla banca. I due obblighi si assorbono solo quanto al superamento della soglia, perché chi presenta l'istanza non comunica anche quel medesimo superamento, mentre restano dovute le altre comunicazioni, in particolare quella sul perfezionamento dell'operazione autorizzata e quella sulla riduzione della partecipazione.

Comma 2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si ri-

ferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.

Comma 2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

Comma 3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2-bis anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2.

Comma 4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 2-bis, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Commento ai commi 2 e 2-bis. Il comma 2 riguarda i patti di sindacato e gli accordi di voto, che vanno comunicati a prescindere da qualsiasi soglia. L'accordo rileva in qualsiasi forma (anche verbale), anche se concluso nella società che controlla la banca e anche nelle banche cooperative: nel voto capitario un patto che aggreghi molti soci può alterare l'equilibrio delle decisioni senza che alcuna soglia di capitale venga in rilievo. Secondo le disposizioni attuative la comunicazione va fatta entro cinque giorni dalla stipula (dall'accertamento delle circostanze che rivelano l'esistenza dell'accordo, se non è scritto) e comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per l'assemblea; vanno comunicati anche lo scioglimento e ogni variazione dei contenuti o degli aderenti. Il potere di sospendere il voto è esercitato valutando in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali, con particolare attenzione ai patti che creano un'organizzazione stabile cui è attribuita la competenza a pronunciarsi in via continuativa sulle scelte gestionali; il procedimento si conclude entro centoventi giorni.

Il regime è diverso da quello dell'art. 22-bis: l'art. 20, comma 2, impone la comunicazione di ogni accordo di voto, l'art. 22-bis l'autorizzazione preventiva solo quando le partecipazioni dei concertanti, cumulativamente considerate, raggiungono le soglie dell'art. 19 o comportano controllo o influenza notevole. I due regimi convivono, e non ogni patto parasociale in banca va dunque autorizzato.

Il comma 2-bis è un obbligo continuativo che accompagna l'autorizzazione dopo il rilascio ed è il collegamento con l'ultimo periodo dell'art. 19, comma 5. Le disposizioni attuative fissano il termine in dieci giorni e ne esemplificano il contenuto: il venir meno della scissione fra titolarità e voto, la modifica significativa degli assetti di potere interni ai patti, le situazioni sopravvenute che incidono sui requisiti di idoneità. Per le persone giuridiche la comunicazione è effettuata dall'organo di appartenenza, previa verifica.

Obblighi della banca. Gli obblighi informativi gravano anche sulla banca. Le disposizioni attuative impongono alla banca di fornire ogni utile informazione ai soggetti interessati, in particolare in occasione di operazioni complesse come gli aumenti di capitale, e di pubblicizzare le variazioni del numero o della tipologia delle partecipazioni che compongono il capitale: un

aumento di capitale modifica i denominatori su cui ogni socio calcola la propria quota e può far sorgere obblighi in capo a chi non ha compiuto alcun atto. La banca comunica inoltre all'Autorità, appena ne ha conoscenza, le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni e, ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, l'elenco dei soci con partecipazioni pari o superiori al 2 per cento del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio (l'obbligo non si applica alle BCC né ai confidi iscritti nell'albo dell'art. 106). La soglia del 2 per cento riguarda l'elenco comunicato dalla banca ed è distinta da quelle che obbligano il socio (3 per cento e multipli del 5 per cento oltre il 10). *(pagina 2–3)*

6.5. Art. 21 TUB — Richiesta di informazioni

Comma 1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

Commento. Dal momento che il socio di una banca può anche non essere un soggetto normalmente sottoposto a vigilanza da BI, questo articolo di fatto **allarga i poteri attribuiti a BI**. BI può infatti richiedere informazioni anche a soggetti non vigilati, come le imprese industriali. Non vi è una vigilanza in senso proprio su questi soggetti, ma solo la facoltà di chiedere alcune informazioni a chi partecipa al capitale della banca, e solo per finalità connesse alla vigilanza.

Comma 2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.

Comma 3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

Comma 4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

Comma 5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

Commento ai commi 2-5. Il comma 2 è lo strumento per risalire la catena partecipativa; il comma 3 introduce una deroga al riserbo fiduciario, giustificata dalla finalità di vigilanza, perché l'intestazione fiduciaria è lo schermo più semplice per mascherare un assetto proprietario; il comma 4 consente di rivolgersi direttamente al partecipante estero, fermo restando che l'efficacia concreta dipende anche dalla cooperazione fra autorità di vigilanza; il comma 5 raccorda la vigilanza prudenziale con quella sulla trasparenza degli emittenti quotati, di competenza CONSOB. L'art. 21 si collega all'art. 20, comma 4, che consente di chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati per verificare l'osservanza degli obblighi di comunicazione, e all'art. 22, perché la ricostruzione della catena partecipativa presuppone di poter ottenere le informazioni a

ciascun livello. L'omissione delle comunicazioni dell'art. 21, commi 1, 2, 3 e 4, è punita dall'art. 140 (v. sotto). *(pagina 3)*

6.6. Art. 22 TUB — Partecipazioni indirette e acquisti di concerto

Il concetto è uguale a quello espresso nell'articolo precedente: se necessario, BI può ricostruire l'intera catena partecipativa, sia in caso di partecipazioni indirette sia nel caso di acquisti di concerto.

Comma 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche: a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall'articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Commento. Nel testo sostituito dal d.lgs. 182/2021 l'articolo riguarda le sole partecipazioni indirette; il concerto, prima trattato insieme ad esse, ha oggi una norma propria, l'art. 22-bis. Le disposizioni attuative chiamano i due criteri «del controllo» (lett. a) e «del moltiplicatore» (lett. b).

Il **criterio del controllo** imputa al soggetto le partecipazioni possedute tramite società da lui controllate, fiduciarie o interposte persone, senza demoltiplicare: se una società controllata detiene il 10 per cento della banca, anche il controllante è considerato titolare del 10 per cento. Sono tenuti all'autorizzazione, oltre al vertice della catena e al partecipante diretto, anche i soggetti intermedi, salve le semplificazioni.

Il **criterio del moltiplicatore** opera in via residuale e considera le partecipazioni possedute tramite società anche non controllate, moltiplicando le percentuali lungo la catena: è candidato acquirente indiretto il soggetto per il quale il prodotto è pari o superiore al 10 per cento (chi detiene il 40 per cento di una società, senza controllarla, che a sua volta possiede il 30 per cento della banca arriva al 12 per cento). Chi controlla un soggetto così individuato è a sua volta candidato acquirente indiretto, con una partecipazione pari a quella del controllato, senza ulteriore demoltiplicazione. Quando nella catena vi sono partecipazioni di controllo, il moltiplicatore si applica alla quota effettivamente detenuta dal partecipante indiretto individuato per controllo, non alla sua partecipazione indiretta nella banca (che per il criterio del controllo è considerata pari a quella del controllato). Per le banche entrambi i criteri si applicano separatamente su ciascun livello di ciascuna catena partecipativa. Non si arrotonda: il 9,6 per cento non raggiunge la soglia del 10.

Per le catene che passano attraverso gestori è previsto un esonero dall'aggregazione: un soggetto non deve aggregare le partecipazioni detenute tramite un soggetto abilitato da esso controllato, che opera nella gestione collettiva del risparmio o di portafogli, se questo esercita i diritti di voto

in modo indipendente dal controllante oppure secondo istruzioni scritte dei clienti. L'indipendenza deve essere sostanziata da procedure e misure organizzative formalizzate e il controllante trasmette alla Banca d'Italia l'elenco dei soggetti abilitati controllati e un'attestazione di non interferenza. *(pagina 3)*

6.7. Art. 22-bis TUB — Persone che agiscono di concerto

Comma 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Comma 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi per i quali si presume che due o più persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra più persone non configura un'azione di concerto, nonché i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.

Commento. L'articolo è stato inserito dal d.lgs. 182/2021. Gli accordi rilevano in qualsiasi forma conclusi, dunque anche non scritti, e anche se invalidi o inefficaci: il legislatore prescinde dalla sorte civilistica del patto e guarda all'esercizio concertato di fatto dei diritti. Rileva inoltre la detenzione, e non solo l'acquisizione, sicché il concerto può sorgere anche senza alcun acquisto o quando l'incremento è effettuato da uno solo dei concertanti; la verifica è condotta sulla somma delle partecipazioni. Nei casi di concerto l'istanza è presentata prima della conclusione dell'accordo.

Le disposizioni attuative (comma 2) presumono, salvo prova contraria e anche in assenza di acquisti, che agiscano di concerto: gli aderenti a un patto, anche invalido o inefficace, avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto o avente per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante; una società e i soggetti che in essa svolgono funzioni di amministrazione e direzione; un soggetto insieme al coniuge, alla persona legata da unione civile o convivenza di fatto, agli affini e ai parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado e ai figli del coniuge e del convivente. Accanto alle presunzioni vi sono indici che non presumono ma orientano: schemi di voto uniformi e ricorrenti, patti di preventiva consultazione, cooperazione per la nomina degli organi (anche con la presentazione di liste), utilizzo della stessa fonte di finanziamento, partecipazioni detenute da società sottoposte a comune controllo. Non configurano concerto gli accordi che hanno a oggetto il solo trasferimento di partecipazioni (prelazione, gradimento, drag-along, tag-along), il dialogo fra la banca e la generalità dei soci, l'esercizio congiunto dei diritti di minoranza previsti da TUB, TUF e codice civile, e l'accordo per votare allo stesso modo su specifici punti all'ordine del giorno di una singola assemblea, purché diversi dalla nomina degli organi.

L'obbligo autorizzativo si applica anche a chi aderisce successivamente a un accordo; in caso

di rinnovo non si applica agli aderenti già autorizzati, salvo che siano mutati i presupposti o che per effetto di incrementi si verifichi una delle situazioni dell'art. 19. Se l'autorizzazione non è chiesta, la sospensione dei diritti di voto si applica proporzionalmente a tutti gli aderenti.

Nel calcolo delle soglie, in presenza di concerto la partecipazione di ciascun concertante si considera pari alla somma di quelle detenute da tutti: se uno detiene il 5 per cento e l'altro il 20, entrambi sono considerati titolari del 25 per cento. Il cumulo opera fra i concertanti e non risale demoltiplicato lungo le loro catene: per il criterio del moltiplicatore si guarda alla sola quota del singolo concertante, mentre per il controllo il controllante di un concertante è considerato titolare dell'intero 25 per cento.

6.8. Art. 23 TUB — Nozione di controllo

Comma 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

Commento. Questo comma specifica che il controllo viene esercitato, oltre che sulle società (come stabilito ai sensi dell'art. 2359 c.c.), anche su soggetti diversi, come le persone fisiche. Lo scopo ultimo di questo articolo è svolgere un'azione di controllo su chiunque possa "influire" sulla banca, a prescindere dalla natura giuridica del partecipante. L'espressione «per oggetto o per effetto» fa prevalere il risultato prodotto dal contratto o dalla clausola sulla sua qualificazione formale: la nozione è funzionale, serve a individuare chi di fatto governa la banca e non chi deve redigere il bilancio consolidato.

Comma 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'**influenza dominante**, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1. esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2. possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3. sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili o delle perdite; il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4. assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Commento. In questo comma il concetto di influenza dominante non è lo stesso espresso nel codice civile ai sensi dell'articolo 2359, che nel caso delle banche risulterebbe insufficiente. Viene comunque specificato "salvo prova contraria".

Le presunzioni sono dunque relative: l'interessato può dimostrare che il controllo in concreto non sussiste. L'art. 23 richiama l'art. 2359 c.c. ai soli commi primo e secondo e non al terzo: il collegamento, cioè l'influenza notevole che il codice civile presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti (un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati), resta fuori dalla nozione di controllo. L'influenza notevole rileva ai fini dell'art. 19 come fattispecie autonoma, con gli indici fissati dalle disposizioni attuative. *(pagina 3)*

6.9. Art. 24 TUB — Sospensione del diritto di voto e obbligo di alienazione: quadro generale

Questo articolo determina le **sanzioni** applicabili laddove non venissero rispettati i contenuti degli articoli 19 e 20.

Evoluzione storica del regime sanzionatorio. Inizialmente erano previste sanzioni sia sul piano civile che penale; successivamente quelle penali sono state eliminate (o meglio, depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi). Inoltre, in precedenza si distingueva fra:

- partecipazioni **detenibili**, per le quali non fosse stata ottenuta l'autorizzazione;
- partecipazioni **non detenibili** (nel senso che non sarebbero potute proprio essere assunte).

Oggi questa distinzione non esiste più. *(pagina 4)*

6.10. Art. 24 TUB — Comma 1: sospensione del diritto di voto

Comma 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 1, 2 e 4.

Commento. Non vi è alcuna differenza, in termini sanzionatori, nel mancato rispetto dell'articolo 19 o 20: in entrambi i casi viene sospeso il diritto di voto. **Il diritto di voto è sospeso SOLO per le partecipazioni sospese, revocate, non autorizzate o per le quali siano state omesse le comunicazioni (quindi le eccedenze).**

Estensione della sospensione. Le disposizioni attuative precisano che la sospensione colpisce la parte di partecipazione eccedente la soglia per la quale l'autorizzazione non è stata richiesta o ottenuta; ma se ciò che è stato acquisito senza autorizzazione è la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole, la sospensione si estende all'intera partecipazione, perché ste-

rilizzare solo una frazione del voto non avrebbe senso quando a mancare di autorizzazione è il potere di governo. Il voto è sospeso anche sulle partecipazioni acquisite oltre il termine massimo di perfezionamento fissato nel provvedimento di autorizzazione e non possono essere esercitati i diritti derivanti da contratti o clausole statutarie non autorizzati. Il rinvio per le omesse comunicazioni è all'art. 20, commi 1, 2 e 4 e non al comma 2-bis, la cui violazione è sanzionata dall'art. 139. In caso di concerto non autorizzato la sospensione si applica proporzionalmente a tutti gli aderenti.

Accertamento in assemblea. La sospensione opera di diritto, ma in concreto è il presidente dell'assemblea a farla valere: nell'ambito dei suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammette o non ammette al voto, sulla base delle informazioni disponibili (libro dei soci, comunicazioni ricevute, informativa annuale della banca sulla compagine sociale), i soggetti che risultino possedere partecipazioni soggette ad autorizzazione o comunicazione. Dal verbale devono risultare la dichiarazione che ai partecipanti è stato chiesto di segnalare eventuali situazioni di sospensione, i riscontri effettuati e, per ogni delibera, i nominativi dei partecipanti (anche tramite delegati) con le relative partecipazioni e l'esito analitico della votazione, salvo le votazioni a scrutinio segreto previste dallo statuto. Questi elementi servono a ricostruire a posteriori la prova di resistenza richiesta dal comma 2. Il controllo del presidente è una verifica allo stato degli atti, non un procedimento di vigilanza. *(pagina 4)*

6.11. Art. 24 TUB — Comma 2: impugnabilità delle delibere

Comma 2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro **centottanta giorni** dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

> Nota a margine: il "contributo determinante" deve valere secondo la **prova di resistenza**.

Commento. Le delibere o gli atti adottati con voto determinante di partecipazioni non autorizzate o non comunicate sono impugnabili (cioè annullabili) ai sensi dell'art. 2377 c.c. Questo comma specifica inoltre che, **in deroga al diritto comune**, l'impugnazione può essere proposta anche da Banca d'Italia (le delibere assembleari possono di regola essere impugnate normalmente solo da soci assenti, dissenzienti, astenuti, amministratori, sindaci). Questa deroga è in linea con le finalità di vigilanza di BI ed è volta a garantire la sana e prudente gestione della banca.

Un'ulteriore deroga al diritto comune riguarda il termine per l'impugnazione: **180 giorni invece di 90**.

Il termine di 180 giorni vale per l'impugnazione proposta dalla Banca d'Italia: per i soci e gli altri soggetti legittimati resta il termine ordinario di 90 giorni dell'art. 2377 c.c., sicché la deroga temporale è un corollario di quella soggettiva. La ragione è che l'Autorità può venire a conoscenza dell'irregolarità solo all'esito dei propri controlli, quando il termine ordinario sarebbe spesso già decorso. La legittimazione della Banca d'Italia risponde al fatto che l'interesse tutelato è la sana e prudente gestione e non quello dei soci, che potrebbero non avere interesse a impugnare.

La delibera non è nulla ma annullabile secondo il diritto comune, e il presupposto è che il voto illegittimo sia stato determinante: con la prova di resistenza si verifica se, escluso quel voto, la delibera sarebbe stata adottata ugualmente. Le partecipazioni prive di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea: si toglie il voto, non la presenza, per non alterare i quorum costitutivi. *(pagina 4)*

6.12. Art. 24 TUB — Comma 3: obbligo di alienazione e questioni aperte

Comma 3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Evoluzione storica. Inizialmente, l'obbligo di alienazione era riferito soltanto alle partecipazioni non detenibili. Oggi, invece, è riferito alle partecipazioni per le quali non sono state ottenute o sono state revocate le autorizzazioni. Oltre alla sospensione del diritto di voto, in questo caso c'è anche l'**obbligo di alienazione** (vendita coattiva).

Problemi irrisolti. Restano tuttavia una serie di problemi irrisolti:

- se l'obbligo di alienazione sia riferito a **tutte** le partecipazioni o soltanto a quelle **oltre la soglia** (si propende per quest'ultima opzione);
- se ci fosse una forma di controllo derivante, ad esempio, da un obbligo contrattuale, cosa succederebbe? In tal caso l'alienazione non sussisterebbe, perché non ci sarebbe nulla da alienare; si potrebbe impugnare la delibera, ma resta una lacuna normativa (al massimo si potrebbe optare per atti di **moral suasion**).

  Approfondimento (ricerca ottobre 2026): sul primo punto, la prassi e le Disposizioni della Banca d'Italia (2022) propendono per l'alienazione della **sola quota eccedente** la soglia autorizzata (principio di proporzionalità), anche se il testo del comma 3 resta ambiguo nel caso di totale mancanza dell'autorizzazione. Sul secondo, la lacuna è confermata: per il controllo fondato su contratti o clausole (art. 23) l'art. 24, comma 3-bis, prevede solo la **sospensione dei diritti**, non un obbligo di alienazione (un contratto non si "aliena"); i rimedi residui sono le misure di vigilanza (artt. 53-bis, 70 ss.), la revoca dell'autorizzazione e la moral suasion. **Termini dell'alienazione.** Il termine non è fissato dal TUB ma dalla Banca d'Italia. Le disposizioni attuative prevedono che, in caso di mancata concessione dell'autorizzazione, l'alienazione avvenga entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione

> del provvedimento di rigetto o nel diverso termine stabilito dall'Autorità; negli altri casi (omessa richiesta, revoca, scadenza del termine di perfezionamento) il termine è stabilito caso per caso dall'Autorità, che lo modula in ragione della liquidità del titolo e della dimensione della partecipazione. L'alienazione eseguita va comunicata entro dieci giorni. Sospensione del voto e obbligo di alienazione sono cumulativi e non alternativi: la prima sterilizza subito il potere deliberativo, la seconda rimuove in via definitiva la situazione illecita. Se il socio non aliena nel termine, il voto resta sospeso e si applica la sanzione dell'art. 139, comma 1.

C'è poi una differenza testuale fra i commi 1 e 3: il voto è sospeso per le autorizzazioni non ottenute, sospese o revocate, mentre l'obbligo di alienare riguarda solo quelle non ottenute o revocate. La sospensione dell'autorizzazione congela il potere, la revoca impone l'uscita.

Ampiezza dell'obbligo. Un argomento testuale a favore dell'alienazione della sola eccedenza si ricava dall'art. 25, comma 3: per il partecipante che perde i requisiti, la sospensione del voto e l'obbligo di alienazione sono delimitati alle partecipazioni «eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a)». Il legislatore ha saputo delimitare l'oggetto della misura quando ha voluto, e una misura ablativa va interpretata secondo proporzionalità.

Comma 3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

Commento. Il comma, aggiunto dal d.lgs. 310/2004, è la sanzione civilistica corrispondente alla fattispecie dell'art. 19, comma 1, lett. d): il controllo o l'influenza notevole acquisiti tramite un contratto con la banca o una clausola dello statuto non comportano alcuna partecipazione da alienare, sicché il comma 3 non è applicabile e restano la sospensione dei diritti, la sanzione per l'omissione della domanda di autorizzazione prevista dall'art. 139, comma 1, e i poteri generali di intervento della Banca d'Italia. *(pagina 4–5)*

6.13. Artt. 139 e 140 TUB — Sanzioni amministrative e penali

Oltre alle conseguenze civilistiche dell'art. 24, la violazione della disciplina del Capo III è presidiata dalle sanzioni del Titolo VIII, ripartite fra due articoli contigui: l'art. 139 riguarda le violazioni degli obblighi autorizzativi e delle comunicazioni più legate alla posizione del partecipante, l'art. 140 le omissioni delle comunicazioni informative.

Art. 139, comma 1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, e dell'articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

Art. 140, comma 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, e 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria

da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.

Commento. L'art. 139 colpisce le condotte che si collocano sull'asse dell'autorizzazione: non chiederla, votare malgrado la sospensione, non alienare, restare soci qualificati senza i requisiti. L'art. 140 colpisce quelle sull'asse informativo, cioè le comunicazioni sulle partecipazioni e le risposte alle richieste della Banca d'Italia. Per questo l'art. 21 è presidiato dall'art. 140 e non dal 139: non impone un'autorizzazione ma un dovere di collaborazione informativa. Dell'art. 20 stanno nell'art. 139 i commi 2 e 2-bis e nell'art. 140 i commi 1, 3 (primo periodo) e 4.

Il presidio penale residuo è la contravvenzione per le false indicazioni. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 2 e 2-bis, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni (art. 139, comma 2); la stessa pena colpisce chi fornisce indicazioni false nelle comunicazioni dell'art. 140, comma 1 (art. 140, comma 2). Le altre condotte, un tempo penalmente rilevanti, sono state depenalizzate.

Agli artt. 139 (comma 3-bis) e 140 (comma 2-bis) si applica l'art. 144, comma 9: se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati dall'art. 144, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché determinabile. Le medesime sanzioni valgono per le violazioni delle stesse norme in quanto richiamate dall'art. 110 e dall'art. 114.13 (intermediari finanziari e gestori di crediti in sofferenza); per l'art. 139, comma 3, sanzione e pena si estendono alle partecipazioni nelle società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista autorizzate come capogruppo ai sensi dell'art. 60-bis, e la sola sanzione amministrativa a quelle autorizzate ai sensi degli artt. 69.1 e 69.2.

7 | Titolo II Banche, Capo IV: Partecipanti al capitale ed Esponenti aziendali

Fonte: LEGB1_Appunti_07_Titolo-II-Capo-IV-Esponenti-Aziendali.pdf — *6 pagine*

7.1. Introduzione al Capo IV

Il Capo IV del Titolo II del TUB si occupa dei **partecipanti al capitale** e degli **esponenti aziendali** delle banche.

I requisiti definiti ai sensi degli articoli 25 e 26 devono essere posseduti in sede di autorizzazione (come citato nell'art. 14) e devono essere **sempre mantenuti** anche dopo l'ingresso, per l'intero ciclo di vita della banca.

L'assetto attuale del Capo si deve al d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 (recepimento della CRD IV), che ha sostituito la rubrica del Capo (art. 1, comma 11), l'art. 25 (comma 12) e l'art. 26 con la sua rubrica (comma 13). L'idoneità è valutata dall'organo di appartenenza e dalla Banca d'Italia (art. 26, commi 5 e 6) e va riverificata quando sopravviene un difetto o una violazione dei limiti al cumulo; per le banche significative la competenza in materia di idoneità spetta alla BCE (v. comma 6). *(pagina 1)*

7.2. Art. 25 TUB: Partecipanti al capitale

L'articolo 25 è stato riscritto in seguito al recepimento della **CRD4** (direttiva 2013/36/UE) del 2015.

Evoluzione storica: in passato, per i partecipanti al capitale era richiesto soltanto il requisito di onorabilità; per gli esponenti aziendali erano richiesti onorabilità, professionalità (alcuni parlavano di requisiti di esperienza) e indipendenza. Attualmente la disciplina è leggermente diversa e più articolata.

7.2.1. Comma 1

"I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca."

I soggetti tenuti a possedere i requisiti sono quelli definiti ai sensi dell'art. 19, cioè i titolari di partecipazioni. A differenza del passato sono previsti anche i requisiti di **competenza** e **correttezza**, necessari sempre per garantire la sana e prudente gestione.

Le partecipazioni richiamate sono quelle soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 19, comma 1: l'acquisizione di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento (lett. a); le variazioni che portano la quota a raggiungere o superare il 20, il 30 o il 50 per cento e, in ogni caso, quelle che comportano il controllo (lett. b); le acquisizioni in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lett. a) (lett. c) e quelle di controllo, di influenza notevole o di quote del 10, 20, 30 o 50 per cento in assenza di acquisti di partecipazioni (lett. d). L'estensione si spiega perché chi può influire sulla gestione senza sedere negli organi deve essere sottoposto a un vaglio di affidabilità, altrimenti il presidio sugli esponenti sarebbe aggirabile dall'alto. Il rapporto con l'art. 19 corre anche in senso inverso: tra i criteri con cui si valuta l'acquirente, il comma 5 indica la reputazione ai sensi dell'art. 25 e l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3, di chi in esito all'acquisizione svolgerà funzioni di amministrazione e direzione nella banca: la valutazione dell'acquirente comprende così un giudizio anticipato sui futuri esponenti.

La struttura è parallela a quella dell'art. 26 (un requisito e due criteri), ma mancano professionalità e indipendenza, e il difetto comporta la sospensione dei diritti e l'obbligo di alienazione (comma 3), non la decadenza.

7.2.2. Comma 2

"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:"

- i **requisiti di onorabilità**;
- i **criteri di competenza**, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;
- i **criteri di correttezza**, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Anche questo comma è un esempio di **delegificazione**. I criteri di onorabilità (un tempo completamente discrezionali) sono stati inizialmente stabiliti dal DPR 350/1985 in attuazione della direttiva del 1977; successivamente sono stati abrogati con l'entrata in vigore del TUB. Si è trattato, tuttavia, di una forma di **abrogazione differita** (art. 161, comma 2, TUB: le norme ivi elencate, tra cui il DPR 350/1985, sono abrogate ma continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie), in quanto il decreto ministeriale contenente i requisiti di onorabilità è stato emanato solo nel 1998. Nel 2015 sono stati aggiunti

i requisiti di correttezza e competenza, ma il MEF deve ancora emanare un decreto ministeriale a tal proposito.

Per effetto della graduazione dei criteri di competenza (lettera b), la competenza richiesta al socio cresce con il peso della partecipazione, perché il socio al 10 per cento e il socio di controllo incidono sulla banca in misura molto diversa. Il d.m. 144/1998 resta applicabile in forza del regime transitorio del d.lgs. 72/2015: l'art. 2, comma 8, ha stabilito che fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa del nuovo art. 25 continuano ad applicarsi il testo anteriore dell'art. 25, che demandava al MEF, con regolamento, i soli requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni, e la relativa disciplina attuativa.

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** l'affermazione è tuttora valida: il decreto attuativo dell'art. 25 per i criteri di competenza e correttezza dei **partecipanti al capitale** non è stato emanato (solo uno schema MEF posto in consultazione nel 2022). In via transitoria si applica ancora il D.M. 144/1998, che disciplina la **sola onorabilità**. Il D.M. 169/2020 riguarda invece esclusivamente gli **esponenti aziendali** (art. 26), non i soci rilevanti.

7.2.3. Comma 3

"Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia."

Se un socio perde i requisiti di onorabilità (gli altri, competenza e correttezza, non hanno ancora un decreto attuativo), la prima conseguenza è la **perdita del diritto di voto** e la seconda è l'**obbligo di alienazione** della partecipazione eccedente entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

La sospensione colpisce soltanto le partecipazioni **eccedenti** le soglie indicate dall'art. 19, comma 1, lettera a): sul resto il socio conserva i propri diritti. Il partecipante non «decade» (la decadenza presuppone un ufficio da cui decadere e appartiene all'art. 26): conserva la proprietà della partecipazione, ne perde i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società e deve cedere l'eccedenza. Il rinvio all'art. 24, comma 2, comporta che la deliberazione o l'atto adottati con il voto o il contributo determinanti di quelle partecipazioni sono impugnabili secondo il codice civile, e che l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla deliberazione (o dall'iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta). Le partecipazioni per le quali il voto non può essere esercitato sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea: il voto è sospeso, ma la partecipazione conta ancora per il quorum costitutivo. *(pagina 1–2)*

7.3. Art. 26 TUB: Esponenti aziendali

7.3.1. Comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico."

Gli **esponenti aziendali** sono i componenti degli organi apicali: amministratori, sindaci, direttore generale, membri del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione (in base al modello di governance adottato dalla banca). Un tempo erano sufficienti i requisiti di onorabilità e professionalità; il nuovo testo parla anche di **idoneità** allo svolgimento dell'incarico.

La formula è funzionale: contano le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, quale che sia il modello di governo e la denominazione della carica. Il d.m. 169/2020 (art. 1, comma 1, lett. h) la traduce nella nozione di «incarico»: quello ricoperto nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di sorveglianza, nel consiglio di gestione, nel collegio sindacale, e quello di direttore generale «comunque denominato». Il direttore generale è dunque esponente anche se non siede in alcun organo, e l'art. 7, comma 4, estende gli stessi requisiti agli incarichi che comportano funzioni equivalenti. Lo è anche il sindaco supplente, la cui idoneità è valutata al momento della nomina (v. più avanti).

Il decreto distingue poi gli **esponenti con incarichi esecutivi** (art. 1, lett. f): i componenti esecutivi secondo la disciplina sul governo societario, più il direttore generale. La Circolare 285 li identifica nei consiglieri membri del comitato esecutivo, destinatari di deleghe o che svolgono, anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione, e in quelli con incarichi direttivi: conta la sostanza dei poteri, non l'etichetta statutaria. Accanto agli esponenti esiste la categoria dei **responsabili delle principali funzioni aziendali** (art. 1, lett. q): i responsabili delle funzioni antiriciclaggio, di conformità, di controllo dei rischi e di revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria e, se diverso, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis TUF). Non sono esponenti e sono soggetti soltanto a una parte della disciplina (v. comma 4).

Sul piano dei soggetti, l'art. 26 riguarda le banche (comma 1), comprese quelle capogruppo di gruppi bancari. Per le società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo l'estensione passa dall'art. 61, comma 5, TUB, che applica loro le disposizioni del Titolo II, Capi III e IV (tra cui gli artt. 25 e 26), salvo quanto previsto dall'art. 67-bis (per la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede in Italia l'applicazione dipende dal fatto che nel conglomerato finanziario il settore di maggiori dimensioni sia quello bancario, comma 2); l'idoneità dei loro esponenti è inoltre condizione per l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo (art. 60-bis, comma 2, lett. d), come lo è per l'autorizzazione all'attività bancaria (art. 14, comma 1, lett. e). L'art. 62 TUB è stato abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182: ai sensi dell'art. 3, comma 7, dello stesso decreto, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma 6, ogni riferimento agli artt. 62 e 63 si intende fatto all'art. 61.

7.3.2. Comma 2

"Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca."

Il comma 2 esplicita cosa si intende con il termine "idonei". I requisiti degli esponenti sono in parte gli stessi dei soci rilevanti (onorabilità, competenza e correttezza), ma se ne aggiungono altri, come **indipendenza** e **professionalità**. Gli esponenti devono inoltre dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, nel tentativo di responsabilizzarli.

Il comma 2 distingue due categorie che il d.m. 169/2020 tiene separate. I **requisiti** (onorabilità, professionalità, indipendenza) sono condizioni tassative e imprescindibili: se ne manca uno, la carica non può essere assunta né mantenuta, senza alcun margine di apprezzamento. I **criteri** (competenza, correttezza, adeguata composizione dell'organo, disponibilità di tempo) concorrono invece a qualificare l'idoneità in concreto: aprono una valutazione discrezionale nel metodo ma vincolata ai parametri che il decreto elenca, e il loro mancato rispetto non opera mai in automatico. La differenza si legge nel testo del decreto: l'art. 3 sull'onorabilità esordisce con «non possono essere ricoperti incarichi da coloro che…», mentre l'art. 5, comma 1, afferma che il verificarsi di una situazione rilevante per la correttezza «non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente», condotta avendo riguardo alla sana e prudente gestione e alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico (non a un giudizio «morale» sulla persona). L'impianto sta così a metà tra l'automatismo cieco e la discrezionalità pura, e l'onere di motivazione è rafforzato: il verbale deve dare «puntuale e analitico riscontro» delle valutazioni effettuate (art. 23, comma 6).

Dalla distinzione discende il diverso trattamento del difetto. Sui requisiti non esiste rimedio e la decadenza è un atto dovuto (per la sola qualifica di consigliere indipendente v. l'art. 13, comma 4, del decreto, più avanti). Le misure correttive sono previste dal comma 5 soltanto per le carenze riferite ai criteri del comma 3, lettera c), cioè competenza e adeguata composizione dell'organo; sul criterio di correttezza non ci sono misure correttive e, accertato il difetto, l'esito è la decadenza. Le due soglie del «quadro grave, preciso e concordante» (art. 5, comma 5, per la correttezza; art. 10, comma 5, per la competenza) condividono la logica probatoria (non basta l'episodio isolato, occorre una convergenza qualificata di elementi), ma non l'oggetto: nel primo caso la convergenza riguarda condotte contrarie alla sana e prudente gestione e alla reputazione della banca, nel secondo l'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico sulla base di conoscenza teorica ed esperienza pratica.

> **Nota (aggiornamento normativo):** il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (recepimento della CRD VI, dir. UE 2024/1619) ha modificato l'art. 26: tra i criteri del comma 2 è stata aggiunta l'**indipendenza di giudizio** (oltre a competenza e correttezza). Le nuove regole si applicano alle nomine successive all'entrata in vigore delle disposizioni attuative.

7.3.3. Comma 3

"Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua: (…)"

Il comma 3 specifica che è sempre il MEF a determinare, tramite decreto ministeriale e sentendo la Banca d'Italia, una serie di aspetti relativi ai requisiti sopra descritti (tra cui, come richiamato al comma 5, i criteri di cui alla lettera c).

Le materie delegate al decreto sono, nell'ordine:

- **a)** i requisiti di onorabilità, omogenei per tutti gli esponenti;
- **b)** i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;
- **c)** i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;
- **d)** i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
- **e)** i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;
- **f)** le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

La proporzionalità è prevista dalla delega stessa, e per questo il decreto modula le soglie in funzione della carica e delle caratteristiche della banca. Il d.m. 169/2020 attua la delega nel modo seguente:

Delega (art. 26, comma 3)	Attuazione nel d.m. 169/2020
lett. a) onorabilità	art. 3
lett. b) professionalità e indipendenza	artt. 7-9 (professionalità), artt. 13-14 (indipendenza)
lett. c) competenza e adeguata composizione	art. 10 (competenza), artt. 11-12 (composizione)
lett. d) correttezza	artt. 4-5
lett. e) limiti al cumulo	artt. 17-19 (l'art. 16 attua il dovere di disponibilità di tempo del comma 2)
lett. f) sospensione	art. 6

7.3.4. Comma 4

"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nelle banche di maggiore rilevanza."

Il comma 4 prevede una mera facoltà del Ministro, che il d.m. 169/2020 ha esercitato all'art. 20: i responsabili delle principali funzioni aziendali delle sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa (categoria da cui il decreto esclude in ogni caso le BCC) sono assoggettati

agli artt. 3, 4 e 5, quindi all'onorabilità e alla correttezza con la relativa valutazione, e all'art. 10 sulla competenza, limitatamente al comma 1 (depurato dal rinvio ai requisiti di professionalità degli artt. 7, 8 e 9) e ai commi 2 e 5. Il responsabile deve avere la competenza, cioè conoscenza teorica ed esperienza pratica, ma non la professionalità formale richiesta agli esponenti. La valutazione della competenza può essere omessa per chi abbia maturato nel medesimo incarico almeno tre anni negli ultimi sei in una banca di maggiori dimensioni o complessità operativa. Poiché la loro nomina non spetta all'assemblea, la valutazione è condotta prima della nomina (v. comma 6).

7.3.5. Comma 5

"Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati."

Il possesso dei requisiti è verificato dagli stessi organi di amministrazione e controllo, che devono documentare e motivare le decisioni (esistono sanzioni per il mancato rispetto di queste norme). La possibilità, per questi organi, di colmare alcune carenze specifiche e limitate è stata inserita nel 2015. In caso di mancato rispetto dei requisiti è prevista la **decadenza dall'incarico**, pronunciata entro trenta giorni dall'organo di appartenenza.

Il comma prevede tre esiti distinti. Se il soggetto è idoneo, l'organo lo documenta e lo motiva. Se c'è una carenza specifica e limitata riferita ai criteri del comma 3, lettera c) (competenza e adeguata composizione dell'organo), l'organo può adottare le misure necessarie a colmarla: il decreto prevede piani di formazione, la ridefinizione di compiti, ruoli e deleghe, l'esclusione da comitati (art. 10, comma 5, e art. 12, comma 2). In ogni altro caso (difetto di un requisito, carenza di correttezza, violazione dei limiti al cumulo) la decadenza è obbligata. Il superamento dei limiti al cumulo, in particolare, non è colmabile con misure correttive: l'unico rimedio è la rinuncia tempestiva agli incarichi eccedenti. La decadenza non è una revoca, non dipende da una valutazione di opportunità ed è un atto dovuto una volta accertato il difetto; i trenta giorni decorrono dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione, non dal loro verificarsi.

Il procedimento interno è disciplinato dall'art. 23 del d.m. 169/2020. L'**organo competente** è quello del quale l'esponente è componente; per il direttore generale e per i responsabili delle principali funzioni aziendali è l'organo che conferisce l'incarico; nel modello monistico, per i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, è il comitato stesso (art. 1, lett. o). La valutazione si svolge alla nomina e poi al verificarsi di **eventi sopravvenuti** che incidano sulla situazione dell'esponente, sul ruolo ricoperto o sulla composizione dell'organo. Quando la nomina non spetta all'assemblea è di norma condotta prima che l'esponente assuma l'incarico,

negli altri casi dopo, in tempo utile per rispettare il termine di trenta giorni; non si ripete ai rinnovi successivi alla prima nomina, salvo eventi sopravvenuti. L'esponente deve fornire tutte le informazioni necessarie (salvo il segreto investigativo ex art. 329 c.p.p.), e il verbale deve dare puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate e, se ci sono difetti colmabili, indicare le misure adottate e perché sono sufficienti.

La decadenza è pronunciata con l'astensione dell'interessato (art. 23, comma 7): l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui si ha un interesse in conflitto discende dall'art. 53, comma 4, TUB e la sua violazione è punita dall'art. 144-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro. Per la decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze occorre il motivato parere del comitato nomine (o, se manca, degli altri consiglieri indipendenti) e dell'organo di controllo, la decisione è presa a maggioranza dei componenti, o con la maggioranza più elevata prevista dallo statuto, e l'assemblea è informata alla prima occasione utile: è un presidio contro l'uso della decadenza per estromettere le minoranze. Per il direttore generale e per i responsabili delle principali funzioni aziendali la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro (art. 23, comma 9).

7.3.6. Comma 6

"La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica."

Se la banca non provvede a determinare la decadenza dell'incarico, può farlo la Banca d'Italia, in via sussidiaria/di controllo.

La responsabilità di individuare esponenti idonei è dell'intermediario: la Banca d'Italia interviene in seconda battuta e valuta anche sulla base dell'analisi compiuta e delle misure adottate. La procedura è fissata dal Provvedimento del 4 maggio 2021 (in attuazione dell'art. 26, comma 6, e dell'art. 24 del d.m. 169/2020), che distingue secondo che la nomina spetti o meno all'assemblea:

- **nomina assembleare** (verifica ex post): l'organo competente valuta entro trenta giorni dalla nomina e, se del caso, dichiara la decadenza o adotta le misure correttive, avviando le iniziative per reintegrare l'organo incompleto. Copia del verbale è trasmessa alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla conclusione della valutazione (cinquanta per le BCC appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, per le quali provvede la capogruppo). Entro centoventi giorni dal ricevimento la Banca d'Italia può chiedere misure idonee a colmare le carenze oppure avviare d'ufficio il procedimento di decadenza, che si conclude entro trenta giorni;
- **nomina non assembleare** (ad esempio il direttore generale nominato dal consiglio o l'amministratore cooptato ex art. 2386 c.c.) e responsabili delle principali funzioni aziendali (verifica ex ante): la valutazione precede la nomina e la nomina non può essere perfezio-

nata prima che siano trascorsi novanta giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia, salvo comunicazione anticipata di esito positivo. L'intermediario comunica l'avvenuta nomina entro cinque giorni e, entro trenta giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio il procedimento di decadenza.

Anche l'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo oltre i limiti al cumulo segue lo schema ex ante (non prima di sessanta giorni dal ricevimento del verbale). I termini di centoventi, novanta e sessanta giorni non sono termini procedimentali e non sono quindi suscettibili di interruzione o sospensione.

Per le banche qualificate come **significative** la competenza in materia di idoneità degli esponenti spetta alla BCE (art. 4, par. 1, lett. e, reg. UE 1024/2013; art. 24, comma 3, d.m. 169/2020), che applica il diritto nazionale di recepimento (art. 4, par. 3): l'art. 26 TUB e il d.m. 169/2020. A differenza dell'autorizzazione all'attività bancaria e della valutazione delle partecipazioni qualificate, il fit and proper non è un procedimento comune: rientra nella vigilanza corrente e segue il riparto ordinario fra banche significative e meno significative, per le quali vale la procedura della Banca d'Italia. La BCE non autorizza la nomina degli esponenti, ma può rimuovere in qualsiasi momento i membri dell'organo di amministrazione che non soddisfano i requisiti (art. 16, par. 2, lett. m).

7.3.7. Decadenza, rimozione e sanzioni

La **decadenza** (art. 26, commi 5 e 6) presuppone il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo ed è un atto vincolato. La **rimozione** è un istituto diverso: ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera e), la Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più esponenti «qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca»; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. La decadenza guarda alla qualità della persona, la rimozione all'effetto che la sua permanenza ha sulla banca; è una misura di vigilanza e non una sanzione. Nell'intervento precoce l'art. 69-vicies-semel consente alla Banca d'Italia di disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo (comma 1; la Banca d'Italia convoca l'assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi, comma 2) e di ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza (comma 3), approvando poi le nomine dei nuovi organi (comma 4); resta salva l'amministrazione straordinaria (comma 5), così come il potere di rimuovere singoli esponenti ai sensi dell'art. 53-bis se è sufficiente (comma 6). I provvedimenti di rimozione rilevano inoltre come elemento di correttezza (art. 4, comma 2, lett. e, d.m. 169/2020).

L'inosservanza dell'art. 26 è sanzionata anche sul piano amministrativo. L'art. 144, comma 1, lettera a), include l'art. 26 fra le norme la cui violazione comporta, per la banca, la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato. L'art. 144-ter, comma 1, prevede nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo la sanzione da 5.000 euro fino a 5 milioni, «fermo restando quanto previsto per le società e gli enti», quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle condizioni elencate; tra queste (lett. c) che le violazioni

riguardino obblighi imposti ai sensi dell'art. 26, o dell'art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, «quando l'esponente o il personale è la parte interessata». Con il provvedimento che applica la sanzione, in ragione della gravità e tenuto conto dei criteri dell'art. 144-quater, la Banca d'Italia può applicare la sanzione accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del TUB, del TUF e del codice delle assicurazioni o presso fondi pensione (art. 144-ter, comma 3); l'interdizione è accessoria e non può essere irrogata da sola. L'art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 169/2020 fa di quell'interdizione una causa impeditiva dell'assunzione dell'incarico (v. requisiti di onorabilità). Per le violazioni commesse dalle banche significative o dai loro esponenti in materie inerenti ai compiti della BCE, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni esclusivamente su richiesta della BCE quando la violazione riguarda disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili, quando la sanzione è diretta a persone fisiche nei casi previsti, tra gli altri, dall'art. 144-ter o quando ha natura non pecuniaria (art. 144-septies, comma 2).

7.3.8. Art. 25 e art. 26 a confronto

Profilo	Art. 25 (partecipanti)	Art. 26 (esponenti)
Requisiti	onorabilità	professionalità, onorabilità, indipendenza
Criteri	competenza (graduata sull'influenza) e correttezza	competenza, correttezza, adeguata composizione dell'organo, disponibilità di tempo
Attuazione	d.m. 144/1998 per la sola onorabilità; criteri del 2015 non ancora attuati	d.m. 169/2020
Conseguenza del difetto	sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti sulle partecipazioni eccedenti e obbligo di alienazione	decadenza dall'ufficio

(pagina 2–3)

7.4. Decreto ministeriale 161/98: requisiti di onorabilità e professionalità

7.4.1. Requisiti di professionalità

Per le SpA e per le BP (banche popolari) il requisito di professionalità implica un'esperienza sul campo per **almeno un triennio**, svolgendo alternativamente:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese (in generale);
- attività professionali in materie funzionali all'attività della banca;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o PA aventi attinenza col settore creditizio o finanziario.

Nel caso delle BCC (banche di credito cooperativo) è sufficiente un'esperienza di **un anno**.

7.4.2. Requisiti di onorabilità

Secondo quanto definito dal TUB, in linea di massima, il requisito di onorabilità è rispettato tramite l'assenza di precedenti penali; non tutti i reati sono però sullo stesso piano. La **perdita** dei requisiti di onorabilità si ha per:

- **Condannati con sentenza irrevocabile a pena detentiva** per uno dei reati in materia finanziaria (è indifferente che sia delitto o contravvenzione) ed è indifferente anche la durata della pena inflitta. Restano escluse le pene pecuniarie;
- **Condannati a reclusione per reati societari e fallimentari**. In questo caso non tutti i reati, ma solo i delitti rilevano; non rilevano le eventuali contravvenzioni;
- **Condannati a reclusione per un tempo non inferiore ad un anno** per delitti contro il patrimonio, in ambito pubblico o tributario;
- **Condannati a reclusione per un tempo non inferiore a due anni** per un qualunque delitto non colposo.

(pagina 3–4)

7.5. Decreto ministeriale 169/2020: requisiti di onorabilità e professionalità

Il precedente decreto ministeriale (161/98) è stato **sostituito** da questo. Ai sensi dell'art. 3 vengono definiti i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali e ai sensi dell'art. 7 quelli di professionalità.

Il decreto dà attuazione all'art. 26, comma 3, e rovescia l'impostazione del precedente: nelle premesse dichiara di voler stabilire «non solo requisiti tassativi ed imprescindibili per l'assunzione delle cariche ma anche un insieme più ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneità dell'esponente», e abroga espressamente il d.m. 161/1998 (art. 27). Si passa così dal controllo dell'accesso al controllo continuo: i requisiti vanno posseduti al momento dell'autorizzazione (art. 14, comma 1, lett. e, TUB) e mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

7.5.1. Ambito di applicazione

L'art. 2 applica il decreto per intero agli esponenti delle banche italiane e delle capogruppo di gruppi bancari (comma 1) e lo estende, in misura via via decrescente, agli altri intermediari, sulla base delle norme del TUB che richiamano l'art. 26: l'art. 110, comma 1-bis (intermediari finanziari), l'art. 112, comma 2 (confidi), l'art. 114-quinquies.3, comma 1-bis (istituti di moneta elettronica), l'art. 114-undecies, comma 1-bis (istituti di pagamento) e l'art. 96-bis.3, comma 3 (sistemi di garanzia dei depositanti). Per intermediari finanziari, IMEL, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti il TUB applica l'art. 26 «ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e)», cioè senza i criteri di competenza e di adeguata composizione e senza i limiti al cumulo; per intermediari finanziari, IMEL e istituti di pagamento il decreto può però prevedere

l'applicazione dei criteri di competenza, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa e alla natura dell'attività. Per i confidi l'art. 112, comma 2, subordina l'iscrizione al possesso, da parte dei partecipanti e degli esponenti, dei soli requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli artt. 25, comma 2, lett. a), e 26, comma 3, lett. a). Il decreto si muove entro questi confini:

Soggetto	Disciplina applicabile (art. 2, d.m. 169/2020)
Banche italiane e capogruppo di gruppi bancari	intero decreto (comma 1)
Intermediari finanziari, IMEL e istituti di pagamento	tutto tranne gli artt. 11 e 12 e le Sezioni V e VI (tempo e cumulo, responsabili delle funzioni aziendali); professionalità ridotta ex art. 8, commi 1 e 4, e art. 9; artt. 10 e 15 solo per i soggetti significativi o rilevanti (comma 3)
Confidi ex art. 112 TUB	solo requisiti di onorabilità dell'art. 3 (comma 4)
Sistemi di garanzia dei depositanti	tutto tranne gli artt. da 10 a 12 e le Sezioni V e VI; professionalità ex artt. 7 e 9 (comma 5)

Molte regole dipendono dalla classe dimensionale della banca, che il decreto non definisce da sé: l'art. 1, comma 1, lettere c) e d), rinvia alle disposizioni sul governo societario emanate ai sensi dell'art. 53 TUB, cioè alla Circolare 285. Sono banche di **maggiori dimensioni o complessità operativa** le banche significative ai sensi dell'art. 6, par. 4, reg. UE 1024/2013, le quotate e quelle che si collocano in tale categoria all'esito dell'autovalutazione; sono **intermedie** quelle con attivo compreso tra 5 e 30 miliardi di euro e di **minori dimensioni** quelle con attivo pari o inferiore a 5 miliardi (media dei quattro anni precedenti). Ai fini del decreto le BCC non rientrano in ogni caso fra le banche di maggiori dimensioni. Dalla classe dipendono, fra l'altro, i limiti al cumulo (art. 17), la disciplina dei responsabili delle principali funzioni aziendali (art. 20) e le soglie ridotte di professionalità per le BCC minori (art. 8).

7.5.2. Requisiti di onorabilità

Non possono essere ricoperti da incarichi coloro che:

- **a)** si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- **b)** sono stati condannati con sentenza definitiva:
  1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- **c)** sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **d)** si trovano, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3, TUB e dell'art. 190-bis, commi 3 e 3-bis, TUF, o in una delle situazioni dell'art. 187-quater TUF.

La lettera d) collega il sistema sanzionatorio ai requisiti di onorabilità: l'interdizione accessoria che la Banca d'Italia può applicare insieme alla sanzione pecuniaria all'esponente (da sei mesi a tre anni, art. 144-ter, comma 3, TUB) si converte, per tutta la sua durata, in una preclusione automatica all'accesso alla carica.

Le condanne rilevanti sono ordinate in tre fasce, secondo una pertinenza decrescente del reato rispetto all'attività bancaria e finanziaria e una soglia di pena crescente: per i reati di settore e per i delitti di terrorismo e criminalità organizzata richiamati basta qualsiasi pena detentiva, senza soglia minima, mentre la sola pena pecuniaria non fa perdere l'onorabilità; per i delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio e in materia tributaria occorre la reclusione non inferiore a un anno; per qualunque altro delitto non colposo occorre la reclusione non inferiore a due anni. A differenza del d.m. 161/1998, il decreto ragiona dunque per materie e per soglie di pena e, per i reati di settore, non distingue più fra delitti e contravvenzioni. L'art. 3 equipara inoltre alla condanna la pena applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti (patteggiamento) o a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. (comma 2): si guarda all'effetto e non alla natura dell'atto, pur non essendo il patteggiamento un'ammissione di responsabilità. Per le fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri la verifica si fa con una valutazione di equivalenza sostanziale (comma 3), e restano salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p. (comma 4): l'onorabilità non è perduta per sempre. La condanna non definitiva non fa perdere l'onorabilità, perché serve la sentenza definitiva, ma rileva come elemento di correttezza (art. 4, comma 2, lett. a e b) e può comportare la sospensione (art. 6).

7.5.3. Criteri di correttezza (artt. 4 e 5)

In aggiunta ai requisiti di onorabilità, gli esponenti soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse (art. 4, comma 1): mentre l'onorabilità guarda alle sole condanne definitive per reati tipizzati, la correttezza estende lo sguardo a condotte che possono non avere mai superato una soglia penale. L'art. 4, comma 2, elenca le situazioni rilevanti (lettere da a a m): tra l'altro, condanne penali anche non definitive, decreti penali di condanna ancorché non irrevocabili e misure cautelari personali; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti vigilati; sanzioni amministrative irrogate all'esponente in materia societaria, bancaria, finanziaria, assi-

curativa e antiriciclaggio; provvedimenti di decadenza, cautelari o di rimozione disposti dalle autorità di vigilanza; incarichi in soggetti vigilati sanzionati o in imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa; sospensione o radiazione da albi professionali; revoca per giusta causa da incarichi in organi di direzione, amministrazione e controllo; valutazioni negative di idoneità già espresse da un'autorità; indagini e procedimenti penali in corso; informazioni negative della Centrale dei Rischi.

Il verificarsi di una di queste situazioni non comporta automaticamente l'inidoneità: l'art. 5 impone una valutazione che tiene conto, tra l'altro, della gravità oggettiva dei fatti e della loro frequenza, della fase e del grado del procedimento penale o di impugnazione della sanzione, della tipologia e dell'importo della sanzione in proporzione, del livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza, delle condotte riparatorie, del grado di responsabilità alla luce dell'effettivo assetto dei poteri e della pertinenza delle condotte ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento e antiriciclaggio. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti non più di dieci anni prima della nomina; oltre questo limite rilevano solo se particolarmente gravi o se vi sono ragioni particolarmente qualificate per cui la sana e prudente gestione della banca potrebbe esserne inficiata (art. 5, comma 2, lett. f): è una regola di ragionevolezza, perché un fatto remoto non pesa per sempre sulla reputazione. Per le sanzioni irrogate alla banca presso cui l'esponente operava servono elementi oggettivi che comprovino il suo contributo individuale e specifico, e sono escluse le sanzioni pari al minimo edittale (art. 5, comma 3); per le crisi d'impresa è richiesta un'analoga prova del contributo individuale (comma 4). Il criterio non è soddisfatto quando le situazioni rilevanti delineano un «quadro grave, preciso e concordante» su condotte in contrasto con la sana e prudente gestione e con la salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico (comma 5). Un filtro di diritto intertemporale (art. 25, comma 3, del decreto) prevede infine che le sanzioni amministrative irrogate agli esponenti secondo il regime anteriore alle modifiche del d.lgs. 72/2015, o irrogabili solo alla persona fisica per violazioni commesse dalla società, siano prese in considerazione solo se, complessivamente considerate nel periodo rilevante, sono almeno pari al massimo edittale della sanzione con il massimale più elevato.

7.5.4. Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

Gli **esponenti con incarichi esecutivi** sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

  Nota: per l'**amministratore delegato**, il **direttore generale** e chi svolge funzioni equivalenti il requisito di professionalità sale ad almeno **cinque anni** di esperienza

(art. 7 D.M. 169/2020); il triennio vale per gli altri incarichi esecutivi.

Gli **esponenti con incarichi non esecutivi** sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 (visti sopra per gli esecutivi) o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (…);
- attività di insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche (…).

L'attività professionale deve essere connotata da **adeguati livelli di complessità**, valutati anche in relazione ai destinatari dei servizi prestati, e svolta in via continuativa e rilevante nei settori indicati: non basta l'iscrizione a un albo. L'insegnamento universitario rileva come docente di prima o seconda fascia (non basta essere ricercatore) in materie giuridiche o economiche o comunque funzionali all'attività del settore. Per i non esecutivi rilevano anche funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti al settore, purché l'ente abbia dimensione e complessità comparabili con quelle della banca. Rispetto al d.m. 161/1998 il requisito si è irrigidito per gli esecutivi: l'esperienza extra-settoriale rileva solo se maturata presso società quotate o di dimensione e complessità maggiore o assimilabile (valutata in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta), e non più presso «imprese» genericamente intese.

Per le altre cariche (art. 7, commi 3-5), il **presidente del consiglio di amministrazione** è un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti dei commi 1 o 2; l'**amministratore delegato** e il **direttore generale** devono avere una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata con attività di amministrazione, controllo o compiti direttivi per almeno cinque anni nel settore o in società quotate o assimilabili, e lo stesso vale per gli incarichi con funzioni equivalenti. Quanto al computo, si considera l'esperienza maturata nei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico, e le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si contano per il solo periodo in cui sono state svolte, senza cumularle: tre anni di sindacatura e tre anni contestuali di consiglio non fanno sei anni.

7.5.5. Banche di credito cooperativo minori (art. 8)

Il regime differenziato riguarda le sole BCC rientranti nella categoria delle banche di minori dimensioni o complessità operativa, ed è giustificato dalla proporzionalità richiamata dall'art. 26, comma 3, lett. b): la BCC è una banca a mutualità prevalente, radicata su un territorio circoscritto, che sceglie gli amministratori fra i soci e le professionalità locali. Le soglie temporali (art. 8, comma 1) si abbassano così:

Carica	Esperienza minima (art. 7)	BCC minori (art. 8, comma 1)
Amministratore con incarichi esecutivi	3 anni	1 anno

Carica	Esperienza minima (art. 7)	BCC minori (art. 8, comma 1)
Amministratore con incarichi non esecutivi	3 anni	1 anno
Presidente del consiglio di amministrazione	requisiti dei commi 1 o 2 + 2 anni	3 anni
Amministratore delegato e direttore generale	5 anni	4 anni

Il comma 2 aggiunge una deroga qualitativa: una quota degli esponenti con incarichi non esecutivi, pari al massimo alla metà, può essere scelta fra persone con almeno un anno di esperienza, anche alternativa, in attività di amministrazione, controllo o compiti direttivi presso imprese o enti del settore della cooperazione di credito; in attività di insegnamento (non necessariamente universitario) in materie giuridiche o economiche o funzionali all'attività del settore; in funzioni amministrative, direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti al settore, o presso enti pubblici purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. La deroga non si applica al presidente (comma 3), che deve soddisfare la soglia di tre anni; vale anche qui la regola dei venti anni e del divieto di cumulo delle esperienze contestuali (comma 4). Le stesse soglie ridotte (art. 8, commi 1 e 4) valgono per gli esponenti di intermediari finanziari, IMEL e istituti di pagamento (art. 2, comma 3), e l'art. 8 si applica anche nei modelli dualistico e monistico (artt. 21 e 22).

7.5.6. Organo di controllo e modelli alternativi (artt. 9, 21 e 22)

L'art. 9 costruisce la professionalità del collegio sindacale attorno a una riserva di competenza contabile: almeno uno dei sindaci effettivi, se sono tre, o almeno due, se sono più di tre, e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno tre anni (non basta l'iscrizione). Gli altri componenti sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, la revisione legale o una delle attività richieste ai non esecutivi (art. 7, comma 2). Il presidente del collegio sindacale ha almeno due anni di esperienza in più rispetto a quella richiesta a questi componenti. Vale il divieto di cumulare le esperienze contestuali, mentre la finestra dei venti anni opera solo per i sindaci non iscritti nel registro dei revisori legali (art. 9, comma 4), a differenza dell'art. 7, comma 5.

Il sindaco supplente è un esponente a tutti gli effetti, ma la sua idoneità è valutata alla nomina e in presenza di eventi sopravvenuti, e non è ripetuta quando assume la carica di sindaco effettivo (Provvedimento del 4 maggio 2021, Sez. II, par. 3.1): il subentro ai sensi dell'art. 2401 c.c. è un fatto automatico che non giustifica una nuova istruttoria. Fanno eccezione gli eventi sopravvenuti che incidono sulla disponibilità di tempo o sul rispetto dei limiti al cumulo, che possono essere valutati al momento del subentro (par. 3.2), e resta l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dal subentro, l'adozione delle misure eventualmente previste al momento della nomina. Coerentemente, gli incarichi da sindaco supplente non si computano ai fini dei limiti al cumulo (art. 18, comma 2, lett. c).

Nel **sistema dualistico** (art. 21) almeno tre componenti del consiglio di sorveglianza devono possedere sia i requisiti di professionalità dei sindaci (art. 9) sia i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'**art. 14**; gli altri consiglieri di sorveglianza hanno i requisiti dell'art. 7, comma 2, e non possono rivestire la carica il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del consiglio di gestione e degli amministratori delle società controllate o sottoposte a comune controllo, né chi sia legato alla banca o a tali società da rapporti di lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti patrimoniali che ne compromettano l'indipendenza. I consiglieri, di sorveglianza o di gestione, qualificati indipendenti dalla legge o dai regolamenti possiedono invece i requisiti dell'**art. 13**. Nel **sistema monistico** (art. 22) ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applicano l'art. 9 per la professionalità e l'art. 14 per l'indipendenza (il divieto per chi sia stato consigliere di amministrazione nella banca negli ultimi cinque anni non opera se l'incarico è stato ricoperto come componente di quel comitato, perché nel monistico il controllore è per definizione un amministratore), mentre agli altri esponenti si applica l'art. 7 e agli indipendenti l'art. 13.

7.5.7. Competenza e composizione collettiva (artt. 10-12)

I **criteri di competenza** si aggiungono ai requisiti di professionalità (art. 10): si può avere il triennio richiesto dall'art. 7 e tuttavia mancare delle conoscenze necessarie a sedere nel consiglio di quella banca. Rilevano insieme la conoscenza teorica, acquisita con gli studi e la formazione, e l'esperienza pratica, conseguita in attività lavorative precedenti o in corso, in più d'uno di nove ambiti: mercati finanziari; regolamentazione bancaria e finanziaria; indirizzi e programmazione strategica; assetti organizzativi e governo societario; gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione, comprese le responsabilità dell'esponente); sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; attività e prodotti bancari e finanziari; informativa contabile e finanziaria; tecnologia informatica. L'organo competente valuta poi se conoscenza ed esperienza siano idonee rispetto ai compiti inerenti al ruolo (comprese deleghe e partecipazione a comitati) e alle caratteristiche della banca e del gruppo (dimensioni, complessità, tipologia di attività e di rischi, mercati e paesi in cui opera). Per il presidente conta anche l'esperienza nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane (comma 3). La valutazione può essere omessa per gli esponenti che abbiano maturato i requisiti di professionalità per una durata almeno pari a quella indicata nell'allegato al decreto (comma 4): servono sia una durata maggiore sia la sua maturazione entro una finestra temporale recente (ad esempio dieci anni negli ultimi tredici per il presidente e l'amministratore delegato di una banca ordinaria), e la deroga riguarda solo la competenza, mai la correttezza o l'indipendenza. Il criterio non è soddisfatto in presenza di un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità, e in caso di specifiche e limitate carenze l'organo può adottare misure per colmarle (comma 5).

L'**adeguata composizione collettiva** (artt. 11 e 12) sposta il giudizio dal singolo all'organo, in coerenza con l'«adeguatezza complessiva dell'organo» dell'art. 26, comma 5. L'art. 11 indica le finalità (alimentare il confronto e la dialettica interna, favorire la pluralità di approcci, sostenere i processi di elaborazione strategica e di controllo, tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione) e i profili rilevanti: diversificazione per età, genere,

durata di permanenza nell'incarico e, per le banche operanti in modo significativo sui mercati internazionali, provenienza geografica; competenze collettivamente idonee; numero adeguato ad assicurare funzionalità e non pletoricità. L'art. 12 prevede che ciascun organo identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale e verifichi poi la rispondenza con quella effettiva risultante dalla nomina; in caso di carenze adotta misure (modifica di compiti, ruoli e deleghe, piani di formazione) e, se non bastano, formula raccomandazioni all'assemblea o all'organo cui competono le nomine. La Circolare 285 dà a questo profilo un contenuto numerico: il genere meno rappresentato deve essere almeno il 33 per cento dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo, e almeno un quarto dei componenti dell'organo di supervisione strategica deve possedere i requisiti di indipendenza.

7.5.8. Indipendenza (artt. 13-15)

Esistono due tipi di indipendenza. L'**indipendenza di diritto** dell'art. 13 è un requisito: si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle situazioni ostative tipizzate, quando la presenza di indipendenti è richiesta da disposizioni di legge o regolamentari (ogni indipendente è non esecutivo, ma non viceversa). Le situazioni ostative sono nove e si raggruppano in tre ambiti: i **legami familiari** (coniuge non legalmente separato, persona legata da unione civile o convivente di fatto, parente o affine entro il quarto grado del presidente, degli esponenti esecutivi, dei responsabili delle principali funzioni aziendali o di chi si trova nelle altre situazioni ostative); i **legami proprietari e gestionali** (essere partecipante nella banca; avere ricoperto negli ultimi due anni, presso un partecipante o società da questo controllate, incarichi di presidente o di esponente esecutivo, o per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di consigliere o di direzione; avere ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella banca; essere consigliere indipendente in un'altra banca del gruppo, salvo il controllo totalitario; avere ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di consigliere o di direzione nella banca; trovarsi in una situazione di incrocio personale, cioè essere esponente esecutivo in una società in cui un esponente esecutivo della banca è consigliere); i **rapporti d'affari e politici** (rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti finanziari, patrimoniali o professionali, anche non continuativi, con la banca, le controllate o un partecipante, intrattenuti anche nei due anni precedenti, tali da comprometterne l'indipendenza; cariche parlamentari, governative o di governo locale negli ultimi due anni, queste ultime solo quando la sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo ne comprometta l'indipendenza). «Partecipante», ai fini degli artt. 13 e 14, è il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni del Titolo II, Capo III (art. 19). Il difetto comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente, ma se il numero residuo di indipendenti è sufficiente a rispettare i minimi previsti, il consigliere, salvo diversa previsione statutaria, mantiene l'incarico di consigliere non indipendente (comma 4), perdendo quindi la qualifica ma non la carica. Per i sindaci l'art. 14 richiama alcune di queste situazioni, aggiunge i legami familiari con i responsabili delle funzioni aziendali ed esclude chi abbia ricoperto negli ultimi cinque anni (non due) incarichi di consigliere di amministrazione, di gestione o di direzione presso un partecipante, la banca o le società da questa controllate.

Il secondo tipo è l'**indipendenza di giudizio** (art. 15), che riguarda tutti gli esponenti, esecutivi compresi: ciascuno agisce con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione. Il meccanismo è quello della disclosure seguita da valutazione: le stesse situazioni che per un consigliere indipendente fanno perdere la qualifica diventano, per gli altri esponenti, fatti da comunicare all'organo competente, insieme alle ragioni per cui a loro avviso non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio. L'organo verifica se i presidi previsti da legge e regolamento e le ulteriori misure adottate siano efficaci: tra i presidi l'art. 15 elenca gli artt. 2391 e 2391-bis c.c., la disciplina della direzione e coordinamento di società, gli artt. 53, commi 4 e 4-quater, e 136 TUB, l'art. 6, comma 2-novies, TUF e l'art. 36 del d.l. 201/2011 sul divieto di cariche incrociate fra intermediari concorrenti. Se i presidi sono insufficienti si individuano presidi ulteriori o si modificano compiti e ruoli, comprese le deleghe, e solo se le misure non sono adottate o non bastano l'organo dichiara la decadenza (art. 23); l'efficacia dei presidi è verificata anche ex post, alla luce del comportamento tenuto in concreto. L'art. 36 è una norma antitrust esterna al sistema dell'art. 26, che il decreto affianca (art. 25, comma 2) senza assorbirla; il divieto di interlocking si differenzia dai limiti al cumulo, che sono quantitativi e proteggono la disponibilità di tempo, perché è qualitativo e protegge la concorrenza.

7.5.9. Disponibilità di tempo e limiti al cumulo (artt. 16-19)

Il dovere di dedicare il tempo necessario (art. 26, comma 2) è attuato dall'art. 16 con un procedimento a più passaggi. L'esponente comunica all'organo competente, alla nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, gli incarichi in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali e il tempo che richiedono; la banca fa conoscere all'esponente il tempo che stima necessario; l'organo valuta se il tempo che l'esponente può dedicare sia idoneo. La valutazione può essere omessa se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare almeno il tempo stimato, purché gli incarichi non superino i limiti dell'art. 17 senza avvalersi degli artt. 18 e 19 e l'esponente non sia amministratore delegato, direttore generale o presidente di un organo o di un comitato. L'organo verifica poi ex post il tempo effettivamente dedicato, anche alla luce della presenza alle riunioni, e se la disponibilità non basta può chiedere di rinunciare a incarichi o attività, di assumere impegni specifici o adottare misure come la revoca di deleghe o l'esclusione da comitati. La valutazione sulla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della decadenza, ma concorre al giudizio complessivo di idoneità (art. 16, comma 6).

I **limiti al cumulo** (art. 17) si applicano ai soli esponenti delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, quindi mai alle BCC: nessuno può assumere, in banche o altre società commerciali, un numero complessivo di incarichi superiore a un incarico esecutivo e due non esecutivi, oppure a quattro non esecutivi, computando anche l'incarico nella banca. «Società commerciale» (art. 1, comma 1, lett. s) è la società con sede legale in Italia costituita in una delle forme del libro V del codice civile (società di persone diverse dalla semplice, società di capitali, cooperative) che abbia per oggetto una delle attività dell'art. 2195, comma 1, c.c., oppure la società estera qualificabile come commerciale secondo l'ordinamento dello Stato in cui ha sede: un incarico in una fondazione, in un'associazione o in una società semplice non entra nel computo,

ma va comunque comunicato ai fini dell'art. 16. Se il limite è superato e l'esponente non rinuncia in tempo utile agli incarichi eccedenti, l'organo competente pronuncia la decadenza (art. 17, comma 3). L'art. 18 esclude dai limiti gli incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici (solo se la legge li qualifica espressamente tali) e non computa gli incarichi presso società che gestiscono interessi privati dell'esponente o dei familiari senza richiedere gestione quotidiana, quelli assunti come professionista presso società tra professionisti e quelli di sindaco supplente; considera invece come un unico incarico quelli ricoperti nel medesimo gruppo, in banche appartenenti al medesimo sistema di tutela istituzionale e in società non del gruppo in cui la banca detiene una partecipazione qualificata (art. 4, par. 1, punto 36, reg. UE 575/2013), con la precisazione che, se ricorrono contestualmente più di una di queste ipotesi, gli incarichi si sommano. L'art. 19 consente un incarico non esecutivo aggiuntivo a condizione che non pregiudichi il tempo adeguato da dedicare alla banca (l'organo valuta, fra l'altro, se l'esponente ha un incarico esecutivo o è componente di comitati, e la dimensione, la complessità e la durata dell'incarico aggiuntivo); è escluso per l'amministratore delegato, il direttore generale e i presidenti degli organi e dei comitati endo-consiliari, e per chi già beneficia dell'aggregazione dell'art. 18, comma 3.

7.5.10. Norme transitorie

Il decreto si applica alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore (art. 26, comma 1, che richiama l'art. 2, comma 7, d.lgs. 72/2015): gli esponenti in carica non sono stati rivalutati d'ufficio, ma è considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore, e lo stesso vale per la conferma da parte dell'assemblea degli amministratori nominati per cooptazione ex art. 2386 c.c. prima di tale data (comma 3). Per i responsabili delle principali funzioni aziendali già in carica le valutazioni dell'art. 23 vanno effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni dall'entrata in vigore (comma 2). Il decreto non si applica al sindaco supplente nominato prima dell'entrata in vigore che subentri come effettivo ai sensi dell'art. 2401 c.c.; è considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo del sindaco così subentrato (comma 4). *(pagina 4–5)*

7.6. Ulteriori aspetti: perdita di onorabilità e iter del processo penale

Non è sempre facile capire quando si ha o meno la perdita di onorabilità. Ad esempio, in Italia vige la **presunzione di innocenza**, per cui si è considerati innocenti fino a giudizio definitivo; ma in ottica bancaria, le condanne nel primo e nel secondo grado di giudizio sono comunque rilevanti (determinano sospensione dell'esponente, come si vedrà sotto).

Un altro caso dubbio è quello del **patteggiamento** (applicazione della pena su richiesta delle parti precedentemente accordate sulla sanzione), che di per sé non è un riconoscimento o un'ammissione di responsabilità. Ciononostante, l'eventuale patteggiamento incide negativamente sulla valutazione di onorabilità. Nel d.m. 169/2020 l'effetto è espresso: la pena applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti è equiparata alla condanna (art. 3, comma 2).

7.6.1. Le fasi del processo penale e i relativi effetti sull'esponente

- **Notizia di reato**: si aprono le indagini preliminari (d'ufficio o per querela di parte); in questo caso **non** si ha perdita di onorabilità.
- Possono essere adottate **misure restrittive**: di queste l'interessato deve dare notizia alla banca, che deciderà se sospendere o revocare il soggetto interessato.
- L'**indagato** deve essere informato tramite avviso di garanzia e può nominare un suo difensore (anche di questo bisogna dare comunicazione alla banca).
- Il PM può ritenere che non si debba proseguire e chiede l'**archiviazione** al GUP; il procedimento viene archiviato e l'interessato ne dà notizia alla banca; **OPPURE**
- Il PM ritiene sia il caso di procedere e chiede il **rinvio a giudizio** al GUP perché non ci sono elementi sufficienti per chiudere il procedimento. A questo punto l'indagato diviene **imputato**. L'imputato può auto-sospendersi o essere sospeso dalla banca.
- La **sentenza** può assolvere l'imputato; **OPPURE**
- La sentenza può condannare l'imputato in primo grado (sia in caso di sentenza di condanna di primo grado, sia di secondo grado, si ha **sospensione** dell'esponente).

Nel d.m. 169/2020 l'art. 6 attua l'art. 26, comma 3, lett. f), e prevede la sospensione quando si verificano le situazioni dell'art. 4, comma 2, lett. a) e b): condanna a pena detentiva, anche non definitiva (compreso il patteggiamento non definitivo con pena detentiva), applicazione di una misura cautelare personale o applicazione provvisoria di una misura di prevenzione. Poiché l'onorabilità richiede la sentenza definitiva, la sospensione concilia presunzione di innocenza e tutela della reputazione della banca, perché congela la posizione senza definirla. Lo statuto può estenderla ad altri casi dell'art. 4, comma 2 (art. 6, comma 2).

La procedura (Provvedimento del 4 maggio 2021, Sez. II, par. 6) è scandita in tre passaggi: l'esponente comunica la situazione all'organo competente senza indugio (par. 6.1); l'organo dichiara la sospensione senza indugio da quando ne è informato o ne viene a conoscenza (par. 6.2); della dichiarazione è data informazione alla Banca d'Italia entro cinque giorni, ed essa è informata anche della decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il sospeso (par. 6.3). La sospensione dura al massimo trenta giorni dalla delibera dell'organo competente, venti per l'amministratore delegato e il direttore generale; prima della scadenza l'organo svolge la valutazione dell'art. 5 e dichiara la decadenza (art. 23) oppure reintegra il sospeso; per la correttezza non sono previste misure correttive, coerentemente con l'art. 26, comma 5. Se la causa è una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non può essere reintegrato fino al termine della misura, ma l'organo può comunque pronunciare la decadenza (art. 6, comma 4). L'organo informa l'assemblea, alla prima occasione utile, con informazioni analitiche e motivate sulla decisione assunta. Solo la sentenza definitiva produce la perdita dell'onorabilità e quindi la decadenza dovuta. *(pagina 5–6)*

8 | Titolo II, Capo V TUB: Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo

Fonte: LEGB1_Appunti_08_Titolo-II-Capo-V-Popolari-e-BCC.pdf — *8 pagine*

8.1. Introduzione: il Capo V e il dibattito sulla natura cooperativa delle Banche Popolari

Il Capo V del Titolo II TUB si occupa delle **banche cooperative**. Si articola in due sezioni:

- **Sezione I** (artt. 29–32-ter): **Banche Popolari (BP)**;
- **Sezione II** (artt. 33–37): **Banche di Credito Cooperativo (BCC)**.

Da tempo si discute se le Banche Popolari possano ancora essere considerate cooperative. Anche se, rispetto al passato, il principio di mutualità si è fortemente attenuato (un cliente di una banca costituita in forma di SPA non riceve un trattamento molto diverso da un cliente di una BP), le BP mantengono un elemento che le distingue inequivocabilmente come cooperative: il **voto capitario** (una testa, un voto).

> **Approfondimento (ricerca ottobre 2026):** la riforma del 2015 (d.l. 3/2015, l. 33/2015) ha imposto la trasformazione in SpA alle BP con attivo oltre soglia (8 mld, poi portata a **16 mld** dalla l. 21/2024); la legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale (sent. **99/2018**, che però ha censurato l'esclusione totale e indefinita del rimborso ai soci recedenti) e dalla Corte di giustizia UE (causa **C-686/18**, 2020). Per le BP rimaste sotto soglia il dibattito sulla reale natura cooperativa (c.d. "mutualità attenuata") **resta dottrinalmente aperto**.

Questioni irrisolte dopo la riforma del 2003. A cavallo della riforma del diritto societario del 2003 ne sono rimaste aperte alcune:

- l'art. 223-*terdecies* c.c. prevedeva che le BCC fossero cooperative a mutualità prevalente (categoria aggiunta proprio dalla riforma del 2003), ma si prevedeva anche che la riforma non fosse applicabile alle banche;
- sempre con la riforma del 2003 i compiti relativi al controllo contabile sono stati sottratti al collegio sindacale per essere affidati a revisori esterni. Tuttavia l'art. 52 TUB, comma 2-bis, prevede che, laddove previsto dallo statuto, il controllo contabile nelle BCC possa essere affidato al collegio sindacale.

Tutte queste questioni sono state chiarite dall'**art. 150-bis TUB** (disposizioni in tema di banche cooperative), che ha specificato quali articoli del codice civile si applicano e quali no alle banche cooperative.

L'art. 150-bis (inserito dall'art. 38 del d.lgs. 310/2004) procede per **elenchi negativi**: il comma 1 indica le disposizioni del codice civile che non si applicano alle BCC, il comma 2 quelle che non si applicano alle BP, e tutto ciò che non è elencato continua ad applicarsi. Il codice civile resta quindi il diritto comune della cooperativa bancaria, salvo nelle parti elencate. Il confronto fra i due elenchi misura la diversa intensità mutualistica dei due tipi. Le differenze stanno in poche voci:

Disposizione del c.c.	Banche popolari (comma 2)	BCC (comma 1)
art. 2512 (definizione di cooperativa a mutualità prevalente)	esclusa	applicabile
art. 2514 (requisiti della mutualità prevalente)	esclusa per intero	esclusa solo nel secondo comma
art. 2530 (trasferimento della partecipazione)	esclusa in tutti i cinque commi	esclusa dal secondo al quinto comma
art. 2534 (morte del socio)	esclusa	applicabile
art. 2535, secondo comma, primo periodo (liquidazione della quota)	esclusa	applicabile
art. 2538 (voto in assemblea)	esclusi il secondo comma, secondo periodo, e il quarto comma	esclusi il secondo comma, secondo periodo, il terzo e il quarto comma
art. 2541	applicabile	esclusa
art. 2542 (nomina degli amministratori)	esclusi il secondo e il quarto comma	escluso il solo quarto comma

Per le BP le esclusioni sono quindi più ampie e comprendono tutte le norme sulla mutualità prevalente (artt. 2512, 2513, 2514). L'elenco del comma 2 risulta sostituito dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 73/2021, che ha inserito anche gli artt. 32-bis e 32-ter: per le BP alla morte del socio e al rimborso delle azioni provvedono questi articoli, mentre per le BCC continuano a valere le norme del codice. L'esclusione dell'art. 2542, secondo comma, c.c. fa venir meno, per le sole BP, il vincolo di scegliere la maggioranza degli amministratori fra i soci cooperatori. Per le sole BCC è escluso l'art. 2538, terzo comma, che consente di commisurare il voto allo scambio mutualistico.

Molte esclusioni coincidono invece nei due elenchi: gli artt. 2349 (secondo comma), 2513, 2519 (secondo comma), 2522, 2525 (primi quattro commi), 2527 (secondo e terzo comma), 2528 (terzo e quarto comma), 2540 (secondo comma), 2543 (primo e secondo comma) e, nella parte finale dell'elenco, gli artt. 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies (terzo comma), 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies. Dove i due elenchi coincidono la ragione sta nel fatto che entrambe sono banche: su compagine sociale, capitale e organi provvedono il TUB e la vigilanza (artt. 29, 30, 33, 34), mentre i controlli governativi sulle cooperative sono sottratti alle banche cooperative dall'art. 28, comma 2.

Gli altri commi dell'art. 150-bis non sono elenchi. Il comma 2-bis impone alle sole BP, in deroga all'art. 2539, primo comma, c.c., che lo statuto fissi il numero massimo di deleghe conferibili a un socio, in misura non inferiore a 10 né superiore a 20. Il comma 3 mantiene per le BCC gli artt. 7 e 9 della l. 59/1992, in quanto compatibili; il comma 4 impone allo statuto delle BCC le clausole dell'art. 2514, primo comma, c.c.; il comma 5 fa salvi, nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'art. 36 e di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una SpA, gli effetti di devoluzione del patrimonio dell'art. 17 della l. 388/2000; il comma 6 consente all'atto costitutivo di BP e BCC di prevedere la ripartizione di ristorni ai soci ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c.; il comma 7 fissava al 30 giugno 2005 il termine per adeguare gli statuti delle BCC all'art. 52, comma 2-bis.

Il testo consolidato del TUB riporta però il comma 2-bis dell'art. 52 come abrogato dall'art. 39, comma 2, lett. c), del d.lgs. 39/2010. Il resto dell'art. 52 (comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale) si applica anche alle BCC.

(pagina 1)

8.2. Art. 28: Norme applicabili alle banche cooperative

Articolo comune a tutte le cooperative (non si capisce perché gli articoli successivi al comma 2 siano stati classificati come 2-bis e 2-ter, pur mancando un comma 3).

Comma 1: *L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.*

Le banche che assumono la forma societaria di SPA non sono interessate da questa norma. Le società che scelgono come forma societaria la SCARL possono essere soltanto Banche Popolari (BP) o Banche di Credito Cooperativo (BCC).

Comma 2: *Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.*

Le società cooperative, visti i vantaggi fiscali dell'essere cooperative, ai sensi del codice civile sono sottoposte a controlli da parte delle autorità governative, volti ad accertare la presenza dell'elemento di mutualità. La vigilanza sulle banche cooperative è invece affidata alla Banca d'Italia.

La vigilanza bancaria sostituisce quel controllo (la cui disciplina organica è nel d.lgs. 220/2002 e che fa capo al Ministero delle imprese e del made in Italy), senza aggiungersi ad esso. Il controllo sulla mutualità passa invece per strumenti bancari: per le BCC, per esempio, l'autorizzazione all'operatività prevalente con non soci (art. 35, comma 1) e l'accertamento della Banca d'Italia sullo statuto (art. 56). Anche la sequenza dei procedimenti lo riflette: per le BCC l'iscrizione nell'albo delle società cooperative viene dopo l'autorizzazione all'attività bancaria (art. 33, comma 1-ter).

Comma 2-bis: *Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto.*

Questo comma chiarisce che le BCC sono cooperative a mutualità prevalente (laddove rispettino i requisiti previsti).

Per la BCC la mutualità prevalente discende dal combinato disposto di questo comma e dell'art. 35, perché l'art. 150-bis, comma 1, esclude per le BCC i criteri ordinari del codice civile (l'art. 2513 e l'art. 2514, secondo comma, c.c.). Il comma 4 dell'art. 150-bis impone inoltre allo statuto le clausole dell'art. 2514, primo comma, che quindi non si possono eliminare. Le BP restano fuori: sono cooperative ma non a mutualità prevalente, e per esse l'art. 150-bis, comma 2, esclude per intero gli artt. 2512, 2513 e 2514.

Comma 2-ter: *Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.*

Con questa norma al legislatore premeva occuparsi della possibilità che, a seguito della trasformazione da BP a SPA, tutti i soci esercitassero il diritto di recesso e facessero fallire la banca. Non si capisce bene perché siano state inserite anche le ipotesi di esclusione o morte del socio (nota: inizialmente il testo di legge prevedeva tutte e tre le possibilità di recesso; poi è stata esclusa la morte, e con il recepimento della CRD IV è stata reintrodotta). Viene appositamente specificato che il diritto di rimborso "è limitato" in caso di recesso, perché non dovrebbe essere possibile escludere completamente il rimborso (si tratterebbe di una sorta di confisca dei conferimenti), ma nelle norme secondarie viene prevista anche l'esclusione.

Il comma è stato inserito dal d.l. 3/2015 (conv. l. 33/2015) e poi sostituito dall'art. 1, comma 15, del d.lgs. 72/2015. La ragione della deroga è nel CRR (art. 29, par. 2): salvo che la normativa nazionale lo vieti, l'ente può rifiutare il rimborso degli strumenti emessi da cooperative; se la normativa nazionale vieta il rifiuto, deve poterlo almeno limitare; né il rifiuto né la limitazione costituiscono un caso di default. Siccome il codice civile riconosce al socio uscente il diritto alla liquidazione della quota, serviva una deroga espressa "anche a norme di legge": uno strumento rimborsabile a richiesta del titolare non è capitale permanente e non sarebbe computabile nel capitale primario di classe 1.

Nelle disposizioni di vigilanza (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 4, Sezione III) la decisione sul singolo rimborso non è della Banca d'Italia: lo statuto di BP e BCC attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo di gestione e sentito l'organo di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente (per recesso, anche a seguito di trasformazione, esclusione o morte), tenendo conto della situazione finanziaria, di liquidità e di

solvibilità della banca o del gruppo e del livello dei fondi propri rispetto ai requisiti dell'art. 92 CRR. Resta ferma l'autorizzazione dell'autorità competente alla riduzione dei fondi propri (art. 77 CRR). Gli "altri strumenti di capitale" sono gli strumenti finanziari emessi dalla banca ai sensi dell'art. 2526 c.c. che rispettano i requisiti CRR per la computabilità nel capitale primario di classe 1: l'estensione evita che il presidio sia aggirato spostando la raccolta di capitale primario su di essi. *(pagina 1–2)*

8.3. Art. 29: Norme generali sulle Banche Popolari

Comma 1: *Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.* (Comma autoesplicativo)

Comma 2: *Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.* (Comma autoesplicativo)

La formula del comma 1 condensa tre scelte: la forma cooperativa (quindi il Capo V e non il diritto delle SpA), il capitale diviso in azioni e non in quote (circolazione dei titoli, quotazione, strumenti computabili nel capitale primario) e la responsabilità limitata. Il valore nominale è fissato solo come minimo: a differenza delle BCC (art. 33, comma 4: da 25 a 500 euro) per le BP non c'è un massimo. Quanto al capitale minimo per accedere al mercato, l'art. 14, comma 1, lett. b), lo rimette alla Banca d'Italia, e le disposizioni di vigilanza lo fissano in 10 milioni di euro per le BP, come per le banche SpA (5 milioni per le BCC): la BP non ha vincoli di operatività né territoriali ed è una banca a operatività piena.

Comma 2-bis: *L'attivo della banca popolare non può superare 16 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.*

Il legislatore avrebbe potuto optare, ad esempio, per il limite di 30 miliardi (cifra che differenzia fra *more significant* e *less significant bank*), ma scelse 8 miliardi osservando quali erano le BP all'epoca in crisi.

La soglia originaria di 8 miliardi (d.l. 3/2015) è stata raddoppiata a 16 dall'art. 18, comma 1, della l. 21/2024. La soglia dei 30 miliardi di cui sopra (Reg. UE 1024/2013, art. 6, par. 4) ha una funzione diversa, perché ripartisce la vigilanza fra BCE e autorità nazionali: una BP può essere "meno significativa" e superare comunque la soglia del TUB.

Comma 2-ter: *In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.*

Comma 2-quater: *La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.*

Comma 3: *(abrogato)*

Il comma riservava ai competenti organi sociali la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ed è stato abrogato dal d.l. 3/2015. L'abrogazione agisce sulle BP che restano tali e rimuove il divieto di meccanismi di nomina diversi dalla deliberazione degli organi sociali (ad esempio i diritti amministrativi attribuibili ai titolari degli strumenti finanziari dell'art. 2526 c.c.): fa parte del disegno di apertura della BP al mercato del capitale. La regola sopravvive per le BCC nell'art. 33, comma 3.

Comma 4: *Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.*

Si tratta della cosiddetta legge Basevi sulla cooperazione: un'ulteriore conferma della specialità del regime bancario rispetto al diritto comune delle cooperative.

L'attivo di una banca popolare non può superare i 16 miliardi di euro (soglia originariamente fissata a 8 miliardi dal D.L. 3/2015, conv. L. 33/2015, poi raddoppiata dalla L. 21/2024, c.d. DDL Capitali). Se la soglia viene superata, la banca può trasformarsi in SpA, ridurre l'attivo tramite scissione o deliberare la liquidazione. Se non lo fa, può subire la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa.

Il valore dell'attivo si determina sulla base delle segnalazioni di vigilanza di fine anno (individuali per la BP non capogruppo, consolidate per la capogruppo, sul perimetro di consolidamento prudenziale e non su quello civilistico), secondo le voci dell'Allegato A al Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare 285: non è quindi l'attivo di bilancio, che interviene solo in via residuale e soltanto se il revisore ha espresso un giudizio senza rilievi. La verifica spetta all'organo di gestione, che se riscontra il superamento ne informa subito l'organo di supervisione strategica e quello di controllo e ne dà comunicazione senza indugio alla Banca d'Italia; l'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione.

Il comma 2-ter funziona a tappe. Prima tappa, interna alla società: l'assemblea sceglie fra le tre alternative viste sopra (la riduzione dell'attivo si realizza per esempio cedendo rami d'azienda o con una scissione, e la liquidazione è quella volontaria). Il decreto lascia quindi libera la scelta fra le tre alternative e impone soltanto di uscire dalla condizione di BP sovradimensionata. La norma pretende il risultato solo per la riduzione dell'attivo ("non è stato ridotto al di sotto della soglia"), mentre per trasformazione e liquidazione si accontenta che siano state deliberate, perché il loro completamento richiede tempi che non dipendono soltanto dalla banca. Seconda tappa, se entro un anno nessuna via è stata percorsa: la Banca d'Italia "può" (non c'è automatismo, e tiene conto delle circostanze e dell'entità del superamento) adottare provvedimenti di intensità crescente. Sono il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'art. 78 (che consente di vietare nuove operazioni o ordinare la chiusura di succursali per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie o per irregolarità di gestione); i provvedimenti del Titolo IV, Capo I, Sezione I, cioè l'amministrazione straordinaria (art. 70 ss.); la proposta alla BCE di revocare l'autorizzazione e la proposta al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre la

liquidazione coatta amministrativa. Il riparto discende dal Reg. UE 1024/2013, che attribuisce alla BCE la competenza esclusiva a rilasciare e revocare l'autorizzazione di tutti gli enti creditizi degli Stati partecipanti, significativi o meno (art. 4, par. 1, lett. a): per questo la Banca d'Italia "propone". Secondo la Circolare l'anno decorre dalla data di riferimento della segnalazione utilizzata per calcolare l'attivo, e non dal momento in cui la banca si avvede del superamento.

In sede di prima applicazione, le BP già autorizzate all'entrata in vigore del d.l. 3/2015 dovevano adeguarsi ai commi 2-bis e 2-ter entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia (il 9° aggiornamento della Circolare 285, del 9 giugno 2015), e non dall'entrata in vigore del decreto. *(pagina 2–3)*

8.4. Art. 30: Soci delle Banche Popolari

Comma 1: *Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.*

Questo comma "certifica" che le BP siano cooperative (voto capitario).

Il voto capitario è l'opposto del principio proporzionale della SpA: il socio conta come persona, non come capitalista, e il capitale non è uno strumento di controllo (chi compra azioni di una BP acquista diritti patrimoniali e un voto identico a quello di chi ne possiede una sola). La regola non ammette deroghe statutarie per i soci cooperatori e vale anche per il socio persona giuridica: la formula "qualunque sia il numero delle azioni possedute" non distingue, e l'art. 150-bis, comma 2, esclude per le BP l'art. 2538, secondo comma, secondo periodo, c.c., che consentiva di attribuire più voti alla persona giuridica. Il voto capitario è un elemento del tipo, non una regola di funzionamento dell'assemblea, e la riforma del 2015 non l'ha abolito né temperato: ha posto un limite all'attivo (art. 29, comma 2-bis). Il voto capitario cade solo come conseguenza del mutamento di tipo, che è una delle alternative aperte alla BP sopra soglia (art. 29, comma 2-ter). Nel TUB la deroga è quella dell'art. 150-quater, comma 2, per i soci finanziatori (v. oltre).

Comma 2: *Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.*

La soglia massima dell'1% si spiega con la volontà di far emergere l'elemento mutualistico, che si realizza proprio in ragione del numero elevato dei soci. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno, pena una sanzione sul piano patrimoniale (non avrebbe senso, in questo caso, limitare il diritto di voto per le azioni eccedenti, perché il voto è comunque sempre uno). Il comma 2-bis stabilisce delle deroghe a questa regola.

Il limite legale è l'1%: lo statuto può soltanto abbassarlo (fino a un minimo dello 0,5%), non innalzarlo, e l'abbassamento, essendo una facoltà che la norma stessa concede, non è una deroga. Il periodo è stato sostituito dal d.l. 179/2012 (conv. l. 221/2012), che ha portato il tetto dallo

0,5 all'1%. Il termine di un anno decorre dalla contestazione della banca e non dal superamento; in caso di mancato rispetto l'acquisto non è nullo e il voto non è sospeso: la banca acquisisce i diritti patrimoniali (dividendi e altri proventi) maturati sulle azioni eccedenti.

Comma 2-bis: *In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge.*

È una deroga a doppia condizione, soggettiva (fondazioni di origine bancaria) e storica (partecipazione già eccedente alla data di entrata in vigore della norma, derivante da aggregazioni), e senza possibilità di incremento: una fondazione che acquisti oggi una partecipazione non può invocarla.

Comma 3: *Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.*

Qui non c'è una soglia diversa: una categoria di soggetti viene sottratta alla regola, perché l'OICVM gestisce risparmio altrui, senza essere un socio-imprenditore, e la sua partecipazione non altera gli equilibri interni di potere. Si aggiungono due deroghe collocate fuori dall'art. 30: l'art. 149, comma 2, disposizione transitoria che consente ai soci che al 20 marzo 1992 partecipavano al capitale in misura compresa fra il limite del comma 2 e il valore nominale di euro 7.746,85 di continuare a detenere le azioni (deroga chiusa, destinata all'estinzione, che non consente incrementi), e l'art. 150-quater, comma 2, per i soci finanziatori.

Il tetto dell'1% non assorbe la disciplina delle partecipazioni del Capo III: protegge il tipo societario, mentre l'art. 19 e seguenti proteggono la sana e prudente gestione e si applicano a ogni banca. Per il socio ordinario di una BP le soglie dell'art. 19 (10%, e variazioni al 20, 30 o 50%) sono di fatto irraggiungibili, ma restano rilevanti per gli OICVM e soprattutto alla trasformazione in SpA, quando il tetto cade e l'unico filtro all'ingresso di un socio di controllo è l'autorizzazione dell'art. 19, comma 5 (rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia). Diverse sono anche le sanzioni: qui la perdita dei diritti patrimoniali sulle azioni eccedenti, per l'acquisto non autorizzato di una partecipazione qualificata la sospensione del diritto di voto e degli altri diritti e l'obbligo di alienazione (art. 24).

Comma 4: *Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.*

È un'ulteriore deroga rispetto al diritto comune, dove il numero minimo di soci per una cooperativa è 9. L'espressione "è posta in liquidazione" è volutamente equivoca: può essere la

banca stessa a porsi in liquidazione, oppure può essere Banca d'Italia a ordinare la liquidazione coatta amministrativa.

La soglia dei duecento soci sostituisce quella del codice civile: l'art. 150-bis, comma 2, dichiara inapplicabile alle BP l'art. 2522 c.c. La ratio è che una base sociale ampia dà senso al voto capitario e al tetto di possesso, che altrimenti degenererebbero in strumenti di protezione di un ristretto gruppo dirigente. La compagine si reintegra ammettendo nuovi soci, operazione agevolata dalla variabilità del capitale (art. 2524 c.c., non escluso dall'art. 150-bis), che non richiede modifica dell'atto costitutivo. Quanto alla liquidazione, non è automatica: richiede comunque un atto degli organi sociali o dell'autorità.

Comma 5: *Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.*

Nelle società cooperative il **collegio dei probiviri** (organo opzionale nelle cooperative regolate dal codice civile, ma obbligatorio nelle banche) ha il compito di dirimere controversie tra i soci e la cooperativa stessa. L'ammissione alla cooperativa è decisa dal consiglio di amministrazione, che può anche rigettare la domanda; in ogni caso il diniego deve essere motivato da almeno uno di questi tre motivi: interesse della società, prescrizioni statutarie, spirito della forma cooperativa. Chi viene rifiutato, se ritiene che siano state violate delle norme, può rivolgersi all'autorità giudiziaria oppure al collegio dei probiviri, che riesamina la pratica con la presenza di un rappresentante dell'aspirante socio. Questo comma si applica non soltanto alle BP ma anche alle BCC.

Il rigetto motivato e il riesame davanti ai probiviri sostituiscono i contrappesi codicistici, che per le BP vengono meno: l'art. 150-bis, comma 2, esclude l'art. 2528, terzo e quarto comma, c.c., cioè l'obbligo di motivare il rigetto entro sessanta giorni e la possibilità per l'aspirante socio di chiedere che si pronunci l'assemblea. La via giudiziaria ordinaria e quella dei probiviri sono rimedi concorrenti, e il collegio non decide la domanda: impone al consiglio di riesaminarla, in contraddittorio con un rappresentante dell'aspirante socio. La clausola di gradimento è, insieme al voto capitario e al tetto di possesso, il terzo elemento della governance della BP, ma ha una funzione diversa: i primi due preservano lo spirito cooperativo evitando posizioni di dominio, il gradimento limita l'apertura della compagine a nuove adesioni e rischia di trasformare la tutela del modello cooperativo in uno strumento di chiusura. Della "porta aperta" restano quindi la variabilità del capitale e la possibilità di ammettere nuovi soci, senza alcun diritto all'ingresso.

Comma 5-bis: *Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta.*

Il comma è stato inserito dal d.l. 179/2012 (conv. l. 221/2012), nello stesso contesto dell'innalzamento del tetto di possesso: si chiede al socio un impegno finanziario minimo e stabile, e il venir meno del numero minimo di azioni fa decadere dalla qualità di socio.

Comma 6: *Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.*

Si crea così la figura dell'**azionista non socio**: titolare delle azioni e dei diritti patrimoniali ma privo dei diritti amministrativi (a partire dal voto), e comunque soggetto al tetto di possesso. Il gradimento riguarda l'acquisto della qualità di socio, il tetto la quantità di azioni detenibili. Lo stesso schema vale per gli eredi del socio defunto (art. 32-bis).

Deleghe. L'art. 150-bis, comma 2-bis, dispone che, in deroga all'art. 2539, primo comma, c.c., gli statuti delle BP determinano il numero massimo di deleghe conferibili a un socio, che non può essere inferiore a 10 né superiore a 20. Il limite del codice civile diventa così il minimo di un intervallo: la deroga opera soltanto verso l'alto, e uno statuto che scelga 10 non aumenta nulla rispetto al codice. La disciplina si lega al voto capitario: se ogni socio vale un voto, il potere assembleare si costruisce aggregando teste, e la delega è lo strumento per farlo. La formulazione del testo consolidato è del d.l. 3/2015, che ha sostituito quella del d.l. 179/2012. Le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione V, par. 1.3) impongono inoltre alle BP di prevedere nello statuto un numero di deleghe adeguato a facilitare il coinvolgimento dei soci, il voto per corrispondenza o con altri mezzi a distanza (art. 2538, comma 6, c.c.) e i criteri di presentazione delle liste per la nomina dei consiglieri, e di rendere pubblico il numero di deleghe attribuibili a ciascun socio.

Azioni di finanziamento (art. 150-quater). Dal 2021 (art. 23-ter del d.l. 73/2021, conv. l. 106/2021) le BP possono emettere, previa modifica dello statuto, le azioni dell'art. 2526 c.c., con una disciplina speciale parallela a quella che l'art. 150-ter detta per le BCC. I soci finanziatori possono detenere azioni anche in deroga al tetto dell'art. 30, comma 2; lo statuto ne stabilisce i diritti patrimoniali e amministrativi e il numero dei voti spettanti, anche in deroga all'art. 30, comma 1, assicurandone la computabilità come capitale di qualità primaria, e l'emissione deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia (comma 2). Le maggioranze assembleari sono determinate dallo statuto e calcolate sul numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori (comma 3); le BP in inadeguatezza patrimoniale o in amministrazione straordinaria possono emettere azioni di finanziamento anche in deroga ai limiti dell'art. 2526, secondo comma, terzo periodo, c.c. (comma 4). Il legislatore del 2015, di fronte alla tensione fra dimensione dell'impresa e struttura proprietaria cooperativa, aveva agito sul tipo, con il limite dimensionale dell'art. 29, comma 2-bis; qui incide invece dentro il tipo, introducendo una deroga al voto capitario e al tetto di possesso senza obbligare nessuno a uscirne. La deroga riguarda i soli soci finanziatori: ai soci cooperatori l'art. 30, comma 1, continua ad applicarsi.

(pagina 3–4)

8.5. Art. 31: Trasformazioni e fusioni delle Banche Popolari

Prima della riforma del 2003 vigeva un divieto di trasformazione e di fusione eterogenea per le società cooperative; tale divieto era derogabile solo in tre casi alternativi fra loro: nell'interesse dei creditori, per esigenze di rafforzamento patrimoniale o a fini di razionalizzazione del sistema.

Comma 1: *Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate: a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca; b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.*

Con la riforma del diritto societario del 2003 sono state ammesse anche le fusioni eterogenee. Sia che si tratti di una fusione eterogenea sia di una trasformazione che coinvolge una BP, entrambe possono essere realizzate senza problemi (un modo come un altro per ridurre il numero di BP sul mercato).

Il comma 1 non subordina l'operazione ad alcuna delle tre condizioni viste sopra e fissa soltanto i quorum: la delibera richiede i due terzi dei voti espressi in entrambe le convocazioni, mentre il quorum costitutivo di un decimo dei soci vale soltanto in prima convocazione. In seconda convocazione la trasformazione può quindi essere deliberata qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e in una BP con moltissimi soci una minoranza ristretta può decidere il mutamento del tipo: il legislatore ha privilegiato la fattibilità dell'operazione rispetto alla rappresentatività della decisione, in coerenza con l'obiettivo del 2015. Le "diverse determinazioni" dell'art. 29, comma 2-ter, sono le alternative alla trasformazione dopo il superamento della soglia (riduzione dell'attivo o liquidazione), che richiedono gli stessi quorum.

Comma 2: *In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.*

Il comma si riferisce alla limitazione del diritto di rimborso vista in precedenza.

Comma 3: *Si applicano gli articoli 56 e 57.*

Si rimanda direttamente alla disciplina degli artt. 56 e 57 TUB, che si riferiscono rispettivamente alle "modificazioni statutarie" e a "fusioni e scissioni".

Il rinvio sottopone la trasformazione di una BP al controllo della Banca d'Italia. L'art. 56 prevede che la Banca d'Italia accerti che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione (comma 1) e che non si possa dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento (comma 2): è un accertamento e non un'autorizzazione, ma ne ha l'effetto pratico, perché è condizione di procedibilità dell'iscrizione. Conta in modo particolare per le BP, perché gran parte della disciplina del tipo è contenuta nello statuto (tetto di possesso abbassabile fino allo 0,5%, partecipazione delle fondazioni al 3%, collegio dei probiviri, numero minimo di azioni, deleghe, ristorni, azioni di finanziamento). L'art. 57, comma 1, sottopone ad autorizzazione della Banca d'Italia le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con una sana e prudente

gestione (l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'art. 14); il comma 2 vieta di dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o scissione senza l'autorizzazione; il comma 3 riduce a quindici giorni il termine dell'art. 2503, primo comma, c.c. per l'opposizione dei creditori; il comma 4 conserva privilegi e garanzie a favore della banca incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, senza formalità o annotazioni.

Per la SpA risultante dalla trasformazione o dalla fusione, la legge di conversione del d.l. 3/2015 (art. 1, comma 2-bis) ha consentito agli statuti di prevedere, fino a un termine indicato nello statuto e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, che nessun soggetto con diritto di voto possa esercitarlo per un quantitativo di azioni superiore al 5% del capitale con diritto di voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. Per il computo contano le azioni possedute direttamente e indirettamente (tramite controllate, fiduciarie o interposta persona) e i voti espressi da chi non è titolare delle azioni, mentre non si computano le partecipazioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio; il controllo ricorre nei casi dell'art. 23 TUB; le azioni prive del diritto di voto per questo limite non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. È una misura facoltativa, statutaria e temporanea, prevista per la SpA risultante e non per la BP, che serve a evitare scalate immediate su un capitale improvvisamente contendibile e opera in senso opposto al regime della BP. *(pagina 4–5)*

8.6. Art. 32: Utili delle Banche Popolari

La BP non è "a mutualità prevalente" come le BCC ma, trattandosi pur sempre di una cooperativa, esistono dei limiti circa la distribuzione degli utili.

Comma 1: *Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.*

La riserva legale è un mezzo per garantire un'adeguata patrimonializzazione della banca. Il diritto comune prevede invece come soglia il 30%.

Il 30% è la misura dell'art. 2545-quater c.c. (escluso per le BP dall'art. 150-bis, comma 2), dovuta nella cooperativa di diritto comune senza alcun tetto; nella SpA, invece, l'obbligo di accantonamento cessa quando la riserva legale raggiunge il quinto del capitale (art. 2430 c.c.). Il 10% è quindi una deroga in melius quanto alla misura (non un regime di rigore), ma conserva il tratto cooperativo dell'assenza di un limite superiore: l'accantonamento è dovuto su ogni esercizio in utile. Il divario fra il 10% delle BP e il 70% delle BCC (art. 37) riflette la diversa intensità mutualistica: nella BCC il patrimonio resta nella banca e nella categoria, nella BP è, entro limiti minimi, distribuibile.

Comma 2: *La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.*

Questo comma specifica ulteriormente che una BP non è libera di distribuire gli utili come preferisce (vista l'assenza di scopo di lucro), ma sussistono dei limiti.

Non ha un grande impatto quantitativo, perché la banca può sempre deliberare la distribuzione ai soci o l'accantonamento ad altre riserve, ma è un segnale: la BP resta una cooperativa e non ha la piena libertà lucrativa della SpA. L'art. 150-bis, comma 6, consente inoltre all'atto costitutivo di BP e BCC di prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., cioè la restituzione di parte del vantaggio mutualistico in proporzione agli scambi intrattenuti: anche questo conferma che la mutualità, pur attenuata, non è del tutto scomparsa dal tipo. Diversa è la quota di utili ai fondi mutualistici, dovuta dalle sole BCC (art. 37, comma 2). *(pagina 5)*

8.7. Art. 32-bis: Morte del socio

Articolo inserito dall'art. 23-bis del d.l. 73/2021 (conv. l. 106/2021), insieme all'art. 32-ter, per disciplinare la sorte della partecipazione alla morte del socio di BP. L'art. 150-bis, comma 2, esclude infatti per le BP gli artt. 2534 (morte del socio) e 2535, secondo comma, primo periodo, c.c., che restano invece applicabili alle BCC.

Comma 1: *In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.*

Non c'è quindi liquidazione automatica della quota: la partecipazione si trasmette.

Comma 2: *Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2.*

Gli eredi non diventano automaticamente soci: l'acquisto della qualità passa per la domanda di ammissione e per la valutazione del consiglio di amministrazione, secondo la logica del gradimento (art. 30, comma 5). Fino ad allora sono nella posizione dell'azionista non socio dell'art. 30, comma 6, e restano soggetti al tetto di possesso.

Comma 3: *Gli eredi ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.*

Anche il rimborso successorio è quindi soggetto alla limitazione di matrice prudenziale.

8.8. Art. 32-ter: Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso

Comma 1: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, in tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte nel caso previsto dall'articolo 32-bis, comma 3, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, secondo e quarto comma, del codice civile. Nel caso in cui*

le azioni siano quotate in mercati regolamentati si applicano i criteri di cui all'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile.

Il legislatore ha importato nella BP la tecnica di valutazione del recesso nella SpA, che lega il valore al patrimonio e alle prospettive reddituali della società (o ai prezzi di mercato per i titoli quotati). Il valore di rimborso è quindi determinato dalla legge, mentre il prezzo di ingresso nella BP non quotata è assembleare: l'art. 2528, secondo comma, c.c., non escluso dall'art. 150-bis, prevede che il nuovo socio versi, oltre all'importo dell'azione, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le tre cause di uscita (recesso, morte, esclusione) sono trattate in modo unitario quanto al *quantum* (art. 32-ter) e quanto al *se e quando* del pagamento (art. 28, comma 2-ter), ma restano distinte quanto ai presupposti: recesso ed esclusione sono regolati dagli artt. 2532 e 2533 c.c., che non figurano nell'elenco dell'art. 150-bis, comma 2, e quindi si applicano anche alle BP, integrati dalle cause previste dallo statuto; la morte è regolata dall'art. 32-bis. La limitazione dell'art. 28, comma 2-ter, incide quindi sul rimborso e non sul recesso: il socio conserva il diritto di uscire ma non quello di essere rimborsato subito.

Il d.l. 73/2021 ha inoltre previsto che le BP adeguassero gli statuti agli artt. 32-bis e 32-ter entro sei mesi dalla legge di conversione e che, anche in deroga agli statuti, ai soci non spetti il recesso dell'art. 2437, primo comma, lett. f) e g), e secondo comma, lett. b), c.c.

8.9. Art. 33: Norme generali sulle Banche di Credito Cooperativo

Le BCC sono caratterizzate necessariamente da due elementi coessenziali:

- **Mutualità**: sono società cooperative a mutualità prevalente (hanno quindi un livello di "mutualità" più accentuato rispetto alle BP);
- **Localismo**: hanno un carattere prettamente locale (una banca autorizzata può però operare liberamente in tutto il territorio dell'UE per i principi già visti; bisogna ancora trovare un modo per conciliare l'autorizzazione unica con il carattere locale delle BCC).

  Approfondimento (ricerca ottobre 2026): la soluzione è stata data dalla riforma del 2016 (gruppo bancario cooperativo): la **capogruppo SpA**, svincolata dal localismo e dal voto capitario, può raccogliere capitale sul mercato e fruire del passaporto europeo, mentre le singole BCC restano legate alla zona di competenza e all'operatività prevalente con i soci (art. 35 TUB). Parte della dottrina osserva però che la tensione concettuale permane, poiché il passaporto è di fatto fruibile solo dalla capogruppo e non dalle singole BCC.

Cenni storici. Sono nate nel XIX secolo (la più antica è quella Veneta, di Loreggia) con lo scopo di sostenere agricoltori e artigiani, i soggetti potenzialmente più esposti al fenomeno dell'usura. Inizialmente assunsero la denominazione di "Casse rurali e artigiane" (CRA). Con la seconda direttiva banche e l'apertura delle frontiere è stato necessario un processo di riforma: con una prima riforma (1992) le CRA sono diventate Casse di credito cooperativo (CCC); l'anno

dopo il TUB ha cambiato ancora la loro denominazione da CCC a BCC. Il regime transitorio della denominazione è nell'art. 150, comma 1, TUB, che consente alle BCC costituite prima del 1° gennaio 1993 di mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione "credito cooperativo".

Le BCC, per poter sopravvivere all'aumento della competizione delle banche italiane e straniere, hanno sviluppato sempre più forme di "associazionismo" (metafora per cui le BCC singole sono semi, ma tutte insieme compongono un frutto).

In buona parte la disciplina della BCC riproduce quella delle banche popolari.

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.*

Esattamente come previsto per le banche popolari (anche se la vecchia legge bancaria consentiva la responsabilità illimitata).

Comma 1-bis: *L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis.*

Il comma è stato inserito dal d.l. 18/2016 (conv. l. 49/2016), che ha riformato il credito cooperativo, e trasforma un fattore organizzativo in un requisito di accesso al mercato: all'elenco delle condizioni dell'art. 14 si aggiunge, per la sola BCC, una condizione strutturale, l'appartenenza a un gruppo. È la differenza strutturale più vistosa rispetto alla BP, che resta autorizzabile e operante in forma individuale. Per le BP sopra soglia il legislatore ha previsto la riduzione dell'attivo, la trasformazione in SpA o la liquidazione (art. 29, comma 2-ter); per le BCC ha invece conservato il tipo e ne ha compensato la fragilità dimensionale con l'aggregazione in un gruppo con capogruppo SpA (artt. 37-bis e 37-ter): le BCC non sono state "obbligate a diventare SpA", l'obbligo riguarda la capogruppo, mentre le BCC restano cooperative con voto capitario. Il richiamo finale riguarda le BCC delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono costituire autonomi gruppi provinciali o, in alternativa alla costituzione del gruppo, adottare sistemi di tutela istituzionale ai sensi dell'art. 113, par. 7, CRR (art. 37-bis, comma 1-bis); è stato aggiunto dall'art. 20-bis del d.l. 119/2018.

Comma 1-ter: *Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.*

La sequenza è quindi prima l'autorizzazione bancaria, che presuppone l'adesione al gruppo, e solo dopo l'iscrizione nell'albo delle cooperative. Il percorso inverso è l'art. 36, comma 1-bis, sull'uscita dal gruppo.

Comma 2: *La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".*

Questo comma esplicita l'obbligatorietà, per le BCC, di contenere nella denominazione l'espressione "credito cooperativo" per far emergere l'elemento della mutualità. Inoltre Banca d'Italia, nella Parte III, Capitolo IV delle disposizioni di vigilanza, ha stabilito che nella denominazione

la banca dovrà sempre inserire anche un riferimento all'area territoriale nella quale opera, per far emergere l'elemento del localismo.

Le disposizioni di vigilanza sulle BCC impongono anche di dare evidenza, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela, dell'appartenenza a un gruppo bancario cooperativo e della relativa capogruppo. Per la BP il TUB non impone di recare "popolare" nel nome. La denominazione è toccata da tre norme diverse: l'art. 133 (abuso di denominazione) vieta a soggetti diversi dalle banche l'uso di parole come "banca", "banco", "credito", "risparmio" idonee a trarre in inganno sulla legittimazione all'attività bancaria, ed è una riserva di denominazione a tutela del pubblico; l'art. 28, comma 1, è una riserva di attività; l'art. 33, comma 2, impone a un tipo di banca di qualificarsi nel nome per renderlo riconoscibile.

Comma 3: *La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.*

In una BCC non può mai esserci una nomina non assembleare (proprio come previsto per le imprese nel diritto comune). Mentre nel diritto comune è ammessa la possibilità che lo statuto di una società preveda la nomina di un soggetto anche da parte di un ente pubblico, nelle BCC questa possibilità è esclusa. Le due deroghe previste dal comma sono relative agli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.

L'art. 150-ter riguarda le azioni di finanziamento (art. 2526 c.c.): ai soci finanziatori, i cui diritti sono fissati dallo statuto anche in deroga al voto capitario (art. 34, comma 3), spetta comunque il diritto di designare uno o più componenti dell'organo amministrativo e il presidente dell'organo di controllo (comma 3). L'art. 37-bis, comma 3, riguarda il contratto di coesione del gruppo, che indica i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti. Le azioni di finanziamento possono essere emesse, previa modifica dello statuto e autorizzazione della Banca d'Italia, dalle BCC in situazione di inadeguatezza patrimoniale o in amministrazione straordinaria, e sono sottoscrivibili solo dai sistemi di garanzia istituiti fra BCC e dai fondi mutualistici della l. 59/1992, in deroga ai limiti dell'art. 34, commi 2 e 4 (art. 150-ter, commi 1 e 2). Dopo la riforma del 2016 le può sottoscrivere anche la capogruppo, e in tal caso l'emissione è consentita anche fuori dai casi di crisi (comma 4-bis): la platea dei sottoscrittori resta chiusa, ed è proprio l'impossibilità di aprire il capitale al mercato che ha spostato sulla capogruppo SpA la funzione di raccolta di capitale.

Comma 4: *Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.*

Visto il localismo, si vuole evitare che le azioni delle BCC assumano un valore particolarmente elevato (da notare l'assenza di limiti massimi per le azioni delle BP).

Il valore nominale dell'azione (fra 25 e 500 euro) riguarda il singolo titolo, mentre il limite di possesso del socio (valore nominale complessivo non superiore a 100.000 euro, art. 34, comma 4) riguarda la posizione complessiva del socio. Le BCC costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi al limite minimo (art. 150, comma 3). Il capitale minimo iniziale, che

l'art. 14, comma 1, lett. b), rimette alla Banca d'Italia, è fissato dalle disposizioni di vigilanza in 5 milioni di euro per le BCC, contro i 10 milioni delle BP e delle banche SpA: la BCC è un intermediario di dimensione locale e a operatività circoscritta. *(pagina 5–6)*

8.10. Art. 34: Soci delle Banche di Credito Cooperativo

Questo articolo è stato riscritto con la riforma delle BCC del 2016.

Comma 1: *Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.*

Prima della riforma il numero minimo di soci era 200 (come per le BP); la riforma ha alzato questa soglia a 500. Laddove il numero dei soci scenda sotto tale soglia, la banca è posta in liquidazione (come per le BP). L'innalzamento a 500 è opera del d.l. 18/2016 (art. 1, comma 2, lett. a), conv. l. 49/2016), che ha concesso alle BCC già autorizzate sessanta mesi per adeguarsi (art. 2, comma 5).

Comma 2: *Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.*

È un'ulteriore espressione degli elementi di localismo e mutualità delle BCC. Viene specificato che è necessario avere residenza (persone fisiche) o sede (persone giuridiche), oppure operare con carattere di continuità sul territorio di competenza della BCC (può trattarsi di persona fisica o giuridica che non ha residenza o sede, ma che ha almeno interessi economici nella zona).

La definizione di zona di competenza territoriale è stabilita nelle norme secondarie. Una BCC ha competenza territoriale (che nella pratica significa possibilità di aprire una propria succursale) nel comune in cui ha sede legale e nei comuni limitrofi, intesi letteralmente come confinanti. Una BCC può instaurare una succursale anche in un comune limitrofo a uno in cui abbia già una succursale, anche se non è il comune in cui ha sede legale (se la BCC ha sede legale nel comune A e confina solo con il comune B, potrà aprire una succursale solo nel comune B; se a sua volta il comune B confina con il comune C, allora la BCC potrà aprire una succursale anche nel comune C). Si può aprire una filiale (chiamata in questo caso "sede distaccata") anche in un comune non limitrofo, ma è necessario reperire un numero di soci non inferiore a quello minimo per costituire una BCC (cioè 500).

Le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione II, par. 4) descrivono la zona di competenza territoriale in modo più articolato: è il territorio entro il quale la BCC acquisisce soci, assume rischi nei confronti della clientela e apre o trasferisce succursali, ed è indicata nello statuto. Il suo nucleo comprende i comuni in cui la banca ha la sede, proprie succursali oppure un numero di soci rapportato alla popolazione residente almeno pari a quello della tabella seguente; a questi si aggiungono i comuni limitrofi, e fra tutti i comuni della zona deve esistere contiguità territoriale (che di norma manca quando i comuni sono separati dalle acque del mare o di un lago, salvo eccezioni motivate dall'organo di supervisione strategica).

Popolazione residente nel comune	Numero minimo di soci
fino a 20.000	1,5% della popolazione
oltre 20.000 e fino a 50.000	300 + 0,6% della parte eccedente 20.000
oltre 50.000 e fino a 200.000	480 + 0,3% della parte eccedente 50.000
oltre 200.000	più di 930

La zona si estende quindi a catena: una succursale in un comune limitrofo rende nucleo anche quel comune e fa entrare nella zona i suoi limitrofi, e lo stesso accade se in un comune limitrofo la banca raccoglie il numero minimo di soci (con azioni e sovrapprezzo integralmente versati), anche senza sportelli. Si contrae se il numero di soci di un comune scende sotto il minimo: la banca può presentare un piano di ripristino, di norma entro tre anni, e l'autorità può autorizzare per periodi determinati a mantenere quel comune e i suoi limitrofi nella zona. Per raggiungere un comune non contiguo serve la sede distaccata, che richiede una rete di rapporti con la clientela nel nuovo comune e nei suoi limitrofi e almeno 500 adesioni di nuovi soci, il rispetto dei requisiti prudenziali obbligatori a livello individuale e l'adeguatezza dell'organizzazione e dei controlli della banca e del gruppo; l'apertura richiede inoltre la modifica dello statuto (soggetta all'accertamento dell'art. 56 TUB), con istanza trasmessa tramite la capogruppo. Insediata la sede distaccata, la competenza si estende al comune e ai suoi limitrofi, e da lì la catena può ripartire. Quanto alla condizione di "operare con carattere di continuità", la Circolare la intende in modo non formalistico: basta che la zona sia un "centro di interessi" dell'aspirante socio (attività lavorativa con stabili organizzazioni nella zona, o titolarità di diritti reali su immobili ivi siti); per le persone giuridiche si guarda alla sede legale, alla direzione, agli stabilimenti o ad altre unità operative.

Comma 3: *Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.*

Comma 4: *Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.*

Comma 6: *Si applica l'articolo 30, comma 5.*

Commi autoesplicativi.

Il voto per testa (comma 3) è la stessa regola delle BP (art. 30, comma 1), mentre il limite di possesso (comma 4) è in valore assoluto e non in percentuale del capitale (1% nelle BP, riducibile fino allo 0,5%) e impedisce che un socio, pur non potendo pesare in assemblea più degli altri, acquisisca una posizione patrimoniale sproporzionata. I limiti dei commi 2 e 4 sono derogati per la sottoscrizione delle azioni di finanziamento (art. 150-ter, commi 2 e 4-bis).

Comma 4-bis: *Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.*

Inserito dal d.l. 18/2016, è la facoltà analoga a quella che l'art. 30, comma 5-bis, riconosce alle BP. Le disposizioni di vigilanza ne temperano l'uso: il numero deve essere tale da non ostacolare di fatto l'ingresso di nuovi soci, in coerenza con i principi di porta aperta e di parità di trattamento.

Comma 5: *(abrogato)*

Il comma vietava alle BCC di acquistare proprie azioni, di fare anticipazioni su di esse e di compensarle con le obbligazioni dei soci; è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 342/1999. *(pagina 6–7)*

8.11. Art. 35: Operatività prevalente a favore dei soci

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.*

Questo comma è una chiara manifestazione della mutualità delle BCC. Il significato di "prevalentemente" è precisato nelle disposizioni di vigilanza: almeno il 50% + 1 centesimo del credito deve essere erogato a favore dei soci (e non di semplici clienti). Banca d'Italia può autorizzare la BCC a erogare credito, entro certi limiti, prevalentemente a favore di non soci, ma solo se sussistano ragioni di stabilità.

Questa prevalenza riguarda solo gli impieghi (quindi l'attivo della banca); non ci sono vincoli dal punto di vista della raccolta, che può avvenire anche da non soci e anche fuori zona. Anche gli impieghi sono caratterizzati dal localismo: nelle norme secondarie viene infatti specificato che una BCC non può erogare credito fuori zona in misura superiore al 5% delle proprie attività.

Le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III) misurano la prevalenza sulle esposizioni, considerate ai fini del metodo standardizzato per il rischio di credito senza fattori di ponderazione (con i fattori di conversione per le poste fuori bilancio) e su base individuale. La prevalenza è rispettata se più del 50% delle esposizioni è verso soci cooperatori o garantito da soci cooperatori; sono assimilate alle esposizioni verso i soci quelle verso o garantite dalle amministrazioni centrali dell'Italia e degli altri Paesi dell'eurozona, dalla BCE e dalla Banca d'Italia, dalla capogruppo e dalle altre società del gruppo (comprese le garanzie in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido) e dai sistemi di garanzia istituiti fra BCC. Il limite del 5% fuori zona va riferito al totale delle esposizioni, comprese le partecipazioni e le poste fuori bilancio, e deve essere previsto dallo statuto; le esposizioni verso soci e quelle appena elencate non consumano il plafond, mentre le esposizioni verso non soci vanno assunte, di regola, verso soggetti residenti o operanti con continuità nella zona. I due vincoli sono distinti: uno soggettivo (chi è il prenditore), l'altro territoriale (dove si trova), e una banca può rispettare l'uno e violare l'altro.

Comma 2: *Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.*

Il comma, al quale il d.l. 18/2016 ha aggiunto il riferimento ai poteri della capogruppo, rinvia agli statuti: la legge fissa il principio e delega la determinazione ai criteri della Banca d'Italia (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 5), mentre lo statuto della singola BCC si limita a recepirli, in linea con lo schema statutario tipo del gruppo. *(pagina 7)*

8.12. Art. 36: Fusioni e trasformazioni delle Banche di Credito Cooperativo

Comma 1: *La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.*

Per le fusioni e trasformazioni eterogenee delle BCC vengono dettate condizioni diverse rispetto a quelle stabilite per le BP: interesse dei creditori e ragioni di stabilità sono condizioni che devono sussistere contemporaneamente. Sono ammesse fusioni fra BCC e BP (esempio storico: Veneto Banca era inizialmente una BP, ma negli anni '90 Banca d'Italia diede l'autorizzazione per la fusione con incorporazione di una BCC di Padova).

La norma riguarda però le fusioni da cui risulti una banca SpA: la fusione da cui residuasse una BP non vi rientra, e la trasformazione diretta di una BCC in BP è esclusa (le disposizioni di vigilanza la ricavano dal fatto che l'art. 36 non la contempla e che l'art. 150-bis, commi 1 e 4, impedisce di eliminare dallo statuto le clausole mutualistiche dell'art. 2514, primo comma, c.c.). Le disposizioni di vigilanza valutano l'uscita dalla categoria alla luce del favor per le aggregazioni interne al credito cooperativo e non la autorizzano se esistono soluzioni alternative che consentono di proseguire in forma cooperativa (fusione con un'altra BCC, ricapitalizzazione con azioni di finanziamento, intervento di un sistema di garanzia fra BCC).

Comma 1-bis: *In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.*

Chi esce dal gruppo, quindi, o cambia natura o cessa: non può restare BCC indipendente (art. 33, comma 1-bis). Le disposizioni di vigilanza fissano il termine in non più di dodici mesi.

Comma 2: *Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.*

Diversamente dalla BP (art. 31) non ci sono quorum rafforzati di legge, ma un rinvio agli statuti con applicazione della maggioranza meno elevata; il recesso dei soci resta soggetto alla limitazione del rimborso dell'art. 28, comma 2-ter.

Comma 3: *Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.*

Il rinvio è più ristretto di quello dell'art. 31, comma 3: si richiamano l'art. 56, comma 2 (non si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese senza l'accertamento) e i commi 2, 3 e 4 dell'art. 57 (iscrizione del progetto, termine di quindici giorni per l'opposizione dei creditori, conservazione di privilegi e garanzie), ma non il comma 1 dello stesso art. 57 (per le BCC l'autorizzazione è disciplinata dall'art. 36, commi 1 e 1-bis).

Devoluzione del patrimonio. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'art. 36, e di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una SpA, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio dell'art. 17 della l. 388/2000 (art. 150-bis, comma 5): le riserve, accumulate con un regime fiscale agevolato e con l'accantonamento di almeno il 70% degli utili, non sono monetizzabili dai soci e vanno ai fondi mutualistici. Una deroga a questo effetto è stata la cosiddetta *way out*, introdotta in via transitoria dalla legge di conversione del d.l. 18/2016 (art. 2, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater) per le BCC di maggiori dimensioni: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione potevano chiedere alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 58 TUB, di conferire l'azienda bancaria a una SpA (anche di nuova costituzione), purché almeno una delle banche istanti avesse al 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro; la conferente versava allo Stato un importo pari al 20% di quel patrimonio, manteneva le riserve indivisibili al netto del versamento, modificava l'oggetto sociale escludendo l'attività bancaria e conservava le clausole mutualistiche, senza che ai soci spettasse il recesso. A diventare SpA bancaria è quindi la conferitaria e non la BCC, che resta cooperativa ma non è più una banca. A differenza delle BP sopra soglia, che devono scegliere fra riduzione dell'attivo, trasformazione e liquidazione (art. 29, comma 2-ter), qui l'uscita era facoltativa e onerosa. *(pagina 8)*

8.13. Art. 37: Utili delle Banche di Credito Cooperativo

Comma 1: *Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.*

Limite molto più stringente rispetto a quello delle BP (10%).

Comma 2: *Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.*

Questa quota per le BCC è pari al 3% ed è fissata dall'art. 11 della l. 31 gennaio 1992, n. 59 (sui fondi mutualistici), non dal TUB. Ogni anno le BCC devono quindi destinare il 3% dei propri utili ai fondi mutualistici.

Comma 3: *La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.*

La quota di utili "restante" viene destinata a fini di beneficenza o mutualità (per questo motivo molte BCC finanziano eventi locali). Le BCC possono inoltre riconoscere ristorni ai soci, forniti in proporzione agli scambi mutualistici che i soci pongono in essere.

Il 70% a riserva legale dà forma contabile alla mutualità prevalente: l'utile serve a costruire un patrimonio che resta nella banca e nella categoria, e non a remunerare il capitale. La riserva legale della BCC è infatti indivisibile: lo statuto deve contenere le clausole dell'art. 2514, primo comma, c.c. (art. 150-bis, comma 4), fra cui il divieto di distribuire le riserve fra i soci, sicché il patrimonio non è appropriabile dai soci né in costanza di rapporto né allo scioglimento, e

in caso di uscita dalla categoria va devoluto ai fondi mutualistici (art. 150-bis, comma 5). I ristorni sono ammessi per BP e BCC se l'atto costitutivo li prevede, determinandone i criteri (art. 150-bis, comma 6, che rinvia all'art. 2545-sexies c.c.), e sono distinti dal dividendo, che remunera il capitale: il ristorno restituisce al socio parte del vantaggio mutualistico. Per le BCC le disposizioni di vigilanza (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 5, Sezione IV) prevedono che i ristorni non eccedano il 50% dell'utile netto residuo dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione ai fondi mutualistici, che almeno metà del ristorno sia liquidata con incremento della partecipazione sociale e che siano disciplinati da un apposito regolamento assembleare.

(pagina 8)

9 | La riforma delle BCC del 2016 e il Titolo V (soggetti operanti nel settore finanziario)

Fonte: LEGB1_Appunti_09_Riforma-BCC-2016-e-Titolo-V.pdf — *5 pagine*

9.1. Art. 33 TUB — Norme generali: l'obbligo di adesione al gruppo bancario cooperativo

Comma 1-bis: *L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis.*

Dopo la riforma del 2016 una BCC può operare solo se fa parte di un gruppo bancario cooperativo: non può più operare autonomamente. L'adesione è condizione per il rilascio dell'autorizzazione. Una BCC già esistente deve entrare in un gruppo, pena la perdita dell'autorizzazione e la liquidazione.

La novità della riforma è l'istituzione stessa del gruppo bancario cooperativo.

La clausola di salvezza. Il comma 1-bis fa salvo l'articolo 37-bis, comma 1-bis: le banche di credito cooperativo con sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano non sono obbligate ad aderire a un gruppo nazionale, perché possono costituire autonomi gruppi provinciali oppure adottare un sistema di tutela istituzionale. La clausola non faceva parte del testo del 2016 ed è stata aggiunta dall'art. 20-bis, comma 1, lett. a), del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136.

Perché la riforma. Il d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla l. 8 aprile 2016, n. 49) risponde a un problema strutturale: le BCC sono banche di dimensioni ridotte, soggette ai vincoli normativi e operativi tipici degli organismi cooperativi. La Banca d'Italia (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 5) indica come ratio dell'obbligo di appartenere a un gruppo il superamento di tali vincoli, che potrebbero ostacolare una rapida ricapitalizzazione anche attraverso l'accesso al mercato dei capitali, e delle diseconomie connesse alle ridotte dimensioni: capitale e scala. Nel gruppo ciascuna BCC resta una banca autonoma; alla capogruppo spettano la direzione e il coordinamento (art. 37-bis, comma 1, lett. a)), da esercitare nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle BCC (comma 3, lett. b)).

Oltre all'art. 33, il decreto ha inserito gli artt. 37-bis e 37-ter; ha portato a cinquecento il numero minimo dei soci (art. 34, comma 1), ha modificato il tetto di possesso azionario del comma 4 e ha introdotto il comma 4-bis (numero minimo di azioni per l'ammissione a socio); ha aggiunto all'art. 35, comma 2, il rinvio statutario ai poteri della capogruppo; ha sostituito la rubrica dell'art. 36 e vi ha inserito il comma 1-bis; ha riscritto i commi 1 e 5 dell'art. 150-bis e ha adattato l'art. 150-ter, aprendo la sottoscrizione delle azioni di finanziamento alla capogruppo (comma 4-bis).

Comma 1-ter: *Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.*

Il comma 1-ter riprende lo schema dell'art. 14, comma 3, secondo cui non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consta l'autorizzazione all'attività bancaria. La sequenza è quindi: prima l'autorizzazione bancaria, che per le BCC presuppone l'adesione al gruppo, e solo dopo l'iscrizione nell'albo delle società cooperative a mutualità prevalente. Lo stesso schema ricorre nell'art. 37-ter, comma 4, dove l'iscrizione nel registro delle imprese segue quella del gruppo nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Per la BCC di nuova costituzione la Circolare n. 285 (Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, Sezione V) richiede di allegare alla domanda di autorizzazione l'impegno ad aderire a un gruppo bancario cooperativo, l'attestazione della capogruppo sull'idoneità della banca a soddisfare i requisiti di ammissione previsti dal contratto di coesione e una relazione sul rispetto dei requisiti di mutualità prevalente, che può essere redatta da un'associazione di categoria abilitata alla revisione cooperativa. La domanda può essere presentata per il tramite della capogruppo del gruppo a cui si intende aderire. *(pagina 1)*

9.2. Art. 36 TUB — Fusioni e trasformazioni: recesso o esclusione dal gruppo

Comma 1-bis: *In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.*

In questo comma non è specificato che non si possa passare da un gruppo bancario cooperativo all'altro.

Il TUB non indica la durata del termine: il rinvio è all'art. 37-bis, comma 7, che non lo fissa, e le disposizioni di attuazione sono rimesse alla Banca d'Italia (comma 7-bis). La Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 3.2) prevede che sia l'autorità a fissarlo, in misura non superiore a dodici mesi, quando concede l'autorizzazione all'uscita dal gruppo. Alla trasformazione in società per azioni si accompagnano gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi

mutualistici che l'art. 150-bis, comma 5, mantiene fermi per i casi di fusione e trasformazione previsti dall'art. 36 (art. 17 della l. 23 dicembre 2000, n. 388).

L'uscita dal gruppo non configura abusivismo. L'autorizzazione bancaria è stata rilasciata ed è venuto meno soltanto uno dei suoi presupposti: la reazione dell'ordinamento è sul piano dell'accesso al mercato (trasformazione o liquidazione) e non penale. L'abusivismo dell'art. 131 (raccolta del risparmio fra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercizio del credito) si porrebbe soltanto se la banca continuasse l'attività senza più essere autorizzata. *(pagina 1)*

9.3. Art. 37-bis TUB — Il gruppo bancario cooperativo: composizione e capogruppo

Comma 1: *Il gruppo bancario cooperativo è composto da: a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro.*

La capogruppo non è una BCC ma una SPA. Normalmente in un gruppo di società il controllo è di tipo azionario: la capogruppo esercita un controllo in virtù del fatto che detiene la maggior parte del capitale delle controllate. In questo caso avviene l'opposto: la capogruppo è la controllata. Il suo capitale è detenuto per la maggior parte dalle BCC facenti parte del gruppo. La direzione e il coordinamento vengono realizzati per mezzo del **contratto di coesione**, e il patrimonio netto minimo della capogruppo è di un miliardo di euro.

Il controllo contrattuale. Il contratto di coesione deve assicurare l'esistenza di una situazione di controllo secondo i principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea: il controllo è quindi un requisito di sostanza, che non discende dalla catena partecipativa.

Le componenti del gruppo. Accanto alla capogruppo (lett. a), il comma 1 indica: b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie (non basta quindi aderire al contratto, il suo contenuto va recepito nello statuto); c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'art. 59; c-bis) eventuali sottogruppi territoriali, che fanno capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo e sono composti dalle altre società di cui alle lett. b) e c). Nello stesso gruppo convivono così due titoli di appartenenza: per le BCC l'adesione al contratto di coesione (lett. b), per le società della lett. c) il controllo della capogruppo, che l'art. 59, comma 1, lett. a), definisce rinviando all'art. 23.

Secondo la Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione II, par. 4), le BCC di un sottogruppo territoriale devono avere sede legale nella stessa regione o in regioni limitrofe e rappresentare almeno il 10% del totale attivo delle BCC affiliate. La banca a capo del sottogruppo

non subentra alla capogruppo: svolge funzioni di supporto per l'indirizzo e il monitoraggio, trasmette alle affiliate le disposizioni impartite dalla capogruppo e ne verifica il rispetto, mentre la responsabilità della direzione e del coordinamento resta alla capogruppo e l'adesione delle BCC resta diretta al contratto di coesione.

La stessa Circolare (Sezione I, par. 3) distingue le «banche affiliate», cioè le BCC o le banche cui fa capo un sottogruppo territoriale, soggette alla direzione e al coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione, dalle «banche aderenti», che comprendono anche la capogruppo in quanto aderente al contratto e all'accordo di garanzia. È il motivo per cui la garanzia in solido del comma 4 copre le obbligazioni assunte «dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti»: anche la capogruppo è parte del meccanismo di solidarietà.

La soglia del sessanta per cento. Nel testo del 2016 era richiesta la sola maggioranza del capitale; la soglia attuale è stata introdotta dal d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla l. 21 settembre 2018, n. 108). La Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione II, par. 2) richiede ancora, per il capitale della capogruppo, una partecipazione delle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo «per oltre il 50 per cento», formula anteriore al 2018: la soglia vincolante è quella legislativa. Il comma 7 consente che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia fissata una soglia diversa.

Lo statuto della capogruppo. Il comma 2 impone allo statuto della capogruppo di indicare il numero massimo di azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 22, comma 1. Il comma 2-bis, inserito dal d.l. 91/2018, prevede che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri: una garanzia di governo a favore della base cooperativa, che deve convivere con l'esigenza, sottolineata dalla Circolare, di non ostacolare l'apertura del capitale a investitori diversi dalle BCC.

I requisiti della capogruppo. La capogruppo deve essere autorizzata all'attività bancaria: non è una semplice holding, perché deve poter operare sui mercati interbancari e presso la banca centrale anche per conto delle affiliate. La Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione II, par. 2) richiede sede legale e direzione generale in Italia, il mantenimento nel tempo del patrimonio netto minimo (se scende sotto soglia, l'autorità assegna di norma un termine non superiore a dodici mesi per ripristinarlo), strutture idonee ad assicurare alle affiliate l'accesso ai mercati interbancari, i servizi di incasso e pagamento e la gestione del collateral per le operazioni di politica monetaria, e vieta di esternalizzare o delegare le attività di esclusiva responsabilità della capogruppo: emanazione delle disposizioni di gruppo, prerogative di nomina e revoca degli organi delle affiliate, monitoraggio e classificazione delle affiliate, misure correttive e sanzionatorie, approvazione delle operazioni di rilievo strategico.

I due gruppi effettivamente costituiti. Il legislatore aveva ideato la norma pensando che sarebbe stato costituito un solo gruppo; attualmente i gruppi sono due:

- uno in cui la capogruppo è **ICCREA** a Roma (nel quale sono presenti il maggior numero delle BCC);

- un altro in cui la capogruppo è **Cassa Centrale Banca** a Trento.

Dopo un correttivo alla riforma del 2016 c'è stata una modifica per le banche della provincia autonoma di Bolzano (le Raiffeisenkasse), per cui è stato adottato un sistema di tutela istituzionale (IPS, Institutional Protection Scheme) che non prevede una vera e propria capogruppo, ma un sistema di garanzie reciproche tra gli istituti aderenti.

Il fondamento è nell'art. 37-bis, comma 1-bis, che riguarda le BCC con sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano e offre due alternative. La prima è costituire, rispettivamente, autonomi gruppi bancari cooperativi provinciali, composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che comunque non abbiano più di due sportelli in province limitrofe, compresa la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme dell'art. 14, comma 1, lett. a) (società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata). Il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis e non coincide con il miliardo della capogruppo ordinaria (la Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione II, par. 5.1, lo fissa in duecentocinquanta milioni di euro). La seconda alternativa è adottare, in luogo della costituzione del gruppo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con l'art. 113, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 575/2013. Il sistema di tutela istituzionale è dunque un istituto alternativo al gruppo, definito dal regolamento europeo, e non un gruppo bancario cooperativo privo di capogruppo; il TUB lo ammette soltanto per le BCC delle province autonome. È un accordo di responsabilità che protegge le banche aderenti e ne garantisce liquidità e solvibilità, senza una capogruppo dotata di poteri di direzione e coordinamento. Il gruppo provinciale, invece, ha una capogruppo a tutti gli effetti. Il comma 1-bis è stato modificato dall'art. 21, comma 1-bis, del d.l. 23 dicembre 2016, n. 237 (convertito dalla l. 17 febbraio 2017, n. 15) e da ultimo dall'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del d.l. 119/2018.

Il gruppo provinciale è distinto dal sottogruppo territoriale: il sottogruppo è un'articolazione interna del gruppo nazionale con funzioni di supporto, il gruppo provinciale è un gruppo a sé, con una propria capogruppo e un proprio requisito di patrimonio netto. *(pagina 1–2)*

9.4. Art. 37-bis TUB, comma 3 — Il contenuto del contratto di coesione

Comma 3: il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

- **a)** la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;
- **b)** i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono:
    1. l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia

bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;
2. i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
3. l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

- **c)** i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;
- **d)** i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.

Se la capogruppo esclude una BCC, questa perde l'autorizzazione all'attività bancaria, non essendo più all'interno di un gruppo bancario cooperativo.

Più precisamente, l'esclusione fa venir meno il presupposto dell'autorizzazione richiesto dall'art. 33, comma 1-bis, e alla banca esclusa si applica l'art. 36, comma 1-bis: la trasformazione in società per azioni, previa autorizzazione della Banca d'Italia, o la liquidazione. D'altra parte l'esclusione è l'ultimo rimedio a disposizione della capogruppo: la lett. b), n. 3, parla di «altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione». Secondo la Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, parr. 1.4 e 1.7), a monte stanno l'attività di controllo, basata su indicatori di early warning (almeno su fondi propri, rischio di credito, redditività, liquidità e raccolta), e gli interventi preventivi e correttivi: poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell'attività e della rete territoriale. Seguono le sanzioni vere e proprie (sospensione dell'assunzione di nuovi rischi, divieto di nuove operazioni, restrizione delle attività o della rete territoriale); l'esclusione è riservata ai casi più gravi e presuppone che le altre azioni possibili e utili siano state esperite. La stessa misura può essere adottata in chiave gestionale, come intervento su una banca classificata più rischiosa, oppure in chiave sanzionatoria come reazione a una violazione: cambiano il presupposto e la procedura.

La proporzionalità dei poteri alla rischiosità delle banche aderenti (lett. b), n. 1) gradua le modalità di intervento, non l'esistenza dei poteri: secondo la Circolare i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo l'obbligo di motivazione previsto dalla legge.

Quanto ai criteri di compensazione della lett. c), la Circolare (par. 1.8) richiede che siano disciplinati in modo da assicurare il corretto esercizio della direzione e del coordinamento in conformità agli artt. 2497 e seguenti del codice civile, e che includano forme di compensazione, anche economica, degli oneri sopportati da ciascuna banca affiliata per la garanzia prestata; i corrispettivi dovuti dalle affiliate alla capogruppo per i servizi resi (ad esempio le commissioni) devono incorporare una componente variabile legata alla performance della banca affiliata. Fra i

doveri della capogruppo rientrano il riconoscimento e la salvaguardia delle finalità mutualistiche (sostenendo lo scambio mutualistico con i soci e l'operatività nei territori di competenza), la tutela della stabilità e della sana e prudente gestione delle affiliate, anche attivando le forme di sostegno previste dall'accordo di garanzia, e la promozione della loro competitività ed efficienza.

La Circolare articola poi il contenuto minimo del contratto in aree. La capogruppo definisce regole e criteri vincolanti sull'intero processo di concessione del credito, sull'area finanza, sugli investimenti partecipativi e immobiliari e sui conflitti d'interesse, e assicura l'allineamento delle affiliate al Risk Appetite Framework di gruppo. Approva preventivamente le operazioni di rilievo strategico (fusioni e scissioni, cessioni soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 58, acquisto di partecipazioni e di immobili, apertura di succursali in Italia e all'estero) e predispone il piano di sviluppo territoriale del gruppo. Emana disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali e definisce in via esclusiva le metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari: le affiliate redigono l'ICAAP a livello individuale secondo regole, criteri e scenari di stress stabiliti dalla capogruppo. Le funzioni di controllo interno delle affiliate sono svolte in regime di esternalizzazione dalla capogruppo o da altre società del gruppo, fatta salva la possibilità di mantenere strutture di supporto operativo presso le affiliate di maggiore dimensione. Il contratto deve infine prevedere, o richiamare come parte integrante, l'accordo di garanzia in solido, la cui sottoscrizione è condizione per l'adesione al gruppo. *(pagina 2)*

9.5. Art. 37-bis TUB, commi 3-bis e 3-ter — La consultazione delle banche aderenti e l'autonomia delle banche meno rischiose

I due commi sono stati inseriti dall'art. 11, comma 2, lett. e), del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, come correttivo sul piano dell'autonomia delle singole BCC.

Comma 3-bis: con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito, nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Per tenere conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle BCC, i cui pareri **non sono vincolanti** per la capogruppo.

Comma 3-ter: le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori:

- **a)** definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da questa definite;
- **b)** comunicano tali piani alla capogruppo, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi;
- **c)** nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 26.

Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia. Il criterio con cui si misura la rischiosità, che apre o chiude l'autonomia della singola banca, non è quindi nella disponibilità esclusiva della capogruppo: da quella classificazione dipendono sia l'autonomia riconosciuta alle banche migliori sia l'attivazione degli interventi e delle sanzioni.

La procedura del comma 3-ter (nomina da parte della banca, mancato gradimento della capogruppo, lista di tre candidati) è più rispettosa delle prerogative locali, ma, come precisa la Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.2), i poteri di opposizione, nomina e revoca della capogruppo restano esercitabili incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata.

9.6. Art. 37-bis TUB, comma 4 — La garanzia in solido tra le banche del gruppo

Comma 4: *Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.*

Da un punto di vista finanziario è una forma di mutua assistenza: se una BCC dovesse trovarsi in difficoltà, la capogruppo potrebbe intervenire sostenendola finanziariamente.

La garanzia è reciproca (una cross-guarantee: la capogruppo garantisce le affiliate e ciascuna affiliata garantisce la capogruppo e le altre affiliate) e, secondo la Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 2), ha due dimensioni. La prima è esterna: le passività della capogruppo e delle banche affiliate sono qualificate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti, ciascuna delle quali risponde entro il limite del proprio obbligo individuale. La seconda è interna: le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali, e per evitare, ove necessario, la risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa. Sempre secondo la Circolare, gli interventi di sostegno, di capitale e di liquidità, sono effettuati soltanto dalla capogruppo, anche con risorse messe a disposizione dalle affiliate, e nella ripatrimonializzazione la sottoscrizione delle azioni di finanziamento è riservata alla capogruppo. L'art. 150-ter, comma 4-bis, abilita la capogruppo a sottoscriverle in deroga ai limiti dell'art. 34, commi 2 e 4, anche fuori dai casi di inadeguatezza patrimoniale o di amministrazione straordinaria del comma 1.

Il limite è quello che il comma 4 esprime con il rispetto della disciplina prudenziale: secondo la Circolare l'obbligazione di ciascuna banca è commisurata alle sue esposizioni ponderate per il rischio ed è contenuta entro le risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale, sicché nessuna banca può essere portata sotto i propri minimi per salvarne un'altra. La partecipazione all'accordo è condizione per l'adesione al contratto e quindi al gruppo. La provvista è ripartita fra una quota costituita ex ante presso la capogruppo (azioni della capogruppo computabili come capitale primario di classe 1 oppure fondi dedicati patrimonialmente separati) e una quota richiamabile ex post. In caso di recesso o esclusione gli obblighi reciproci

di garanzia esterna permangono per almeno dieci anni, in capo alla banca uscente e a quelle che restano, per le passività garantite esistenti al momento dell'uscita. *(pagina 3)*

9.7. Art. 37-bis TUB, commi 5-8 — Autorizzazione della Banca d'Italia, deroghe civilistiche e fonti di attuazione

Comma 5: *L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.*

È un controllo sui singoli atti, ricorrente nel tempo, distinto dall'accertamento con cui la Banca d'Italia verifica la costituzione del gruppo (art. 37-ter, comma 2). La Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 3) sviluppa il precetto del comma 3, lett. d):

- **ammissione**: i requisiti devono far riferimento a condizioni oggettive e non discriminatorie; non sono coerenti con il principio di solidarietà le clausole che condizionino l'ammissione o la permanenza a requisiti di capitale o di liquidità superiori ai minimi obbligatori, né le clausole di gradimento o i criteri discrezionali non ancorati a parametri oggettivi;
- **recesso**: l'adesione ha carattere sostanzialmente permanente; il recesso è ammesso solo nei casi indicati dal contratto con riferimento a giustificati motivi, con preavviso non inferiore a ventiquattro mesi, ferme le garanzie per almeno dieci anni, e non si perfeziona prima che siano sciolti i rapporti derivanti dagli interventi di sostegno o adempiuti gli obblighi di garanzia;
- **esclusione**: i casi sono tassativi (gravi o ripetute violazioni del contratto di coesione o dell'accordo di garanzia, oppure mancata applicazione delle disposizioni della capogruppo o impedimento all'esercizio dei suoi poteri di direzione e coordinamento) e l'esclusione è possibile solo dopo che i poteri correttivi e sanzionatori siano stati esperiti inutilmente;
- **procedimento**: decide l'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo, sentito l'organo di controllo; le delibere di esclusione e di diniego dell'ammissione sono motivate; tutte le delibere (recesso, esclusione, ammissione, diniego) sono comunicate all'autorità competente entro cinque giorni, non sono efficaci fino all'autorizzazione, e questa non è concessa se dall'esecuzione derivi o rischi di derivare l'inosservanza dei requisiti prudenziali da parte del gruppo.

Comma 6: *Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.*

È la norma che rende praticabile lo schema in cui le controllate possiedono la controllante: senza la deroga la disciplina civilistica delle partecipazioni reciproche ne avrebbe impedito la costruzione.

Comma 7: il primo periodo attribuisce a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire una soglia di partecipazione delle BCC al capitale della capogruppo diversa da quella

del comma 1, lett. a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo: il sessanta per cento è quindi modificabile con decreto, senza passare dalla legge. Il secondo periodo attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo, il potere di stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia: **a)** il numero minimo di BCC di un gruppo; **c)** le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle BCC con sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. La lett. b) è stata soppressa dall'art. 11, comma 2, lett. g), del d.l. 91/2018.

Comma 7-bis: la Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione degli artt. 37-bis e 37-ter, con particolare riferimento: **a)** ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo; **b)** al contenuto minimo del contratto di coesione, alle caratteristiche della garanzia in solido, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione; **c)** ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, dei gruppi provinciali del comma 1-bis. Queste disposizioni sono confluite nella Parte Terza, Capitolo 6, della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013: la Sezione II per i requisiti della capogruppo e del gruppo provinciale, la Sezione III per il contratto e la garanzia, la Sezione V per il procedimento di costituzione. **Comma 8**: *Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.*

Il gruppo bancario cooperativo è quindi una specie del genere gruppo bancario e non un istituto parallelo. Gli artt. 37-bis e 37-ter costruiscono i tre elementi che la disciplina generale non conosce (controllo di fonte contrattuale, capogruppo partecipata in misura maggioritaria dalle proprie affiliate, appartenenza al gruppo come condizione dell'autorizzazione); per il resto la clausola «in quanto compatibili» adatta al controllo contrattuale le regole pensate per il controllo partecipativo. Se ne ricavano, ad esempio, l'art. 61 (la capogruppo esercita la direzione e il coordinamento ed è soggetta ai controlli di vigilanza del Capo; emana alle componenti del gruppo le disposizioni necessarie per l'esecuzione dei provvedimenti impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo, e gli amministratori delle società del gruppo devono fornire dati, informazioni e collaborazione) e l'art. 64 (il gruppo è iscritto nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia, cui rinvia l'art. 37-ter, comma 4, e le società del gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione). Alla capogruppo del gruppo cooperativo la Circolare (Sezione III, par. 1.5) attribuisce di conseguenza il compito di dare attuazione, anche con disposizioni indirizzate alle banche affiliate, alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo.

9.8. Art. 37-ter TUB — Costituzione del gruppo bancario cooperativo

Comma 1: la banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:

- a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;
- b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

Comma 2: la Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

Comma 3: a seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

Comma 4: il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.

Accertamento, non autorizzazione. Il comma 2 parla di accertamento e non di autorizzazione: la Banca d'Italia verifica la sussistenza dei presupposti di un gruppo che ancora non esiste, e il provvedimento precede la stipula del contratto (comma 3). Si distingue dall'autorizzazione dell'art. 37-bis, comma 5, che riguarda i singoli atti di adesione, diniego, recesso ed esclusione. Il rinvio del comma 3 all'art. 31, comma 1, fa valere per le modifiche statutarie le maggioranze previste per le trasformazioni e le fusioni delle banche popolari. L'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis, secondo comma, del codice civile rende pubblica la soggezione a direzione e coordinamento, da cui discende un regime di responsabilità.

Secondo la Circolare n. 285 (Parte Terza, Capitolo 6, Sezione V), all'istanza si allegano lo schema del contratto di coesione (compreso l'accordo di garanzia in solido), l'elenco delle banche aderenti e delle altre società del gruppo e gli schemi di statuto della capogruppo e delle banche del gruppo. La Banca d'Italia provvede entro centoventi giorni, sentita la BCE se il gruppo sarebbe significativo ai fini del Meccanismo di vigilanza unico, e assegna un termine non superiore a dodici mesi per stipulare il contratto e adottare le modifiche statutarie; se si propone come capogruppo una banca di nuova costituzione, l'accertamento è subordinato all'autorizzazione all'attività bancaria che la BCE rilascia ai sensi dell'art. 14. Entro il termine fissato la capogruppo trasmette il contratto, gli statuti delle banche aderenti e l'istanza di iscrizione nell'albo dei gruppi: in caso contrario l'accertamento decade. Se dalla documentazione risulta una situazione difforme da quella accertata (ad esempio aderiscono banche diverse da quelle dell'elenco), la Banca d'Italia può avviare un procedimento che si conclude con la revoca dell'accertamento. Sulle modifiche statutarie conformi agli schemi già valutati non si avviano autonomi accertamenti ai sensi dell'art. 56, ma la Banca d'Italia rilascia un'attestazione di conformità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese; le modifiche del contratto di coesione vanno comunicate in progetto alla Banca d'Italia prima di essere inviate alle banche aderenti per l'accettazione.

Questioni aperte. Restano comunque aperte diverse questioni, fra cui: cosa succede se un gruppo esclude una BCC e questa si unisce a un altro gruppo? Si può cambiare gruppo? E se sì, la scelta è reversibile o irreversibile?

Approfondimento (ricerca ottobre 2026): allo stato la risposta è in gran parte negativa o non disciplinata. Il cambio di gruppo non è vietato ma è strutturalmente quasi impossibile: ogni adesione, recesso o esclusione richiede l'autorizzazione della Banca d'Italia (art. 37-bis, comma 5) e il recesso dal contratto di coesione è ammesso solo per "giustificato motivo" tassativo; non esiste un meccanismo di "portabilità" e non risultano casi dopo la costituzione dei due gruppi (2019). L'art. 36, comma 1-bis, prevede testualmente **solo due esiti** (trasformazione in SpA o liquidazione), senza contemplare l'adesione a un altro gruppo come terza via: restare BCC richiederebbe una nuova ammissione presso un diverso gruppo, ma il coordinamento uscita-rientro **non è disciplinato** (lacuna confermata, anche in dottrina). La scelta è quindi di fatto **irreversibile**.

(pagina 3)

9.9. La prima applicazione della riforma: Fondo temporaneo, recesso dei soci e conferimento dell'azienda bancaria

Le regole transitorie non sono nel TUB ma negli artt. 2 e 2-bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito dalla l. 8 aprile 2016, n. 49).

Il Fondo temporaneo. L'art. 33, comma 1-bis, condiziona l'autorizzazione all'adesione a un gruppo, ma nel 2016 nessun gruppo esisteva e nessuno poteva esistere prima che la Banca d'Italia emanasse le disposizioni attuative. Durante la fase di costituzione dei gruppi, e fino alla data di adesione, l'obbligo era assolto dall'adesione al Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo (art. 2-bis), promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane: uno strumento di natura privatistica, che non è un gruppo bancario cooperativo e non ne produce gli effetti.

I termini. La comunicazione dell'art. 37-ter, comma 1, andava inviata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art. 37-bis, commi 7 e 7-bis, e il contratto concluso entro il termine che l'art. 2, comma 1, fa decorrere dall'accertamento. Entro il termine che l'art. 2, comma 2, fa decorrere dall'iscrizione del gruppo nel registro delle imprese una BCC poteva ancora chiedere di aderire a un gruppo già costituito, alle stesse condizioni degli aderenti originari (con silenzio-assenso della capogruppo trascorsi trenta giorni dalla domanda). La banca che non aderiva doveva assumere le deliberazioni dell'art. 36 oppure deliberare la liquidazione; in caso contrario la Banca d'Italia assumeva le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione. Il numero minimo di soci portato a cinquecento dall'art. 34, comma 1, andava raggiunto entro sessanta mesi.

Nessun recesso dei soci. Alle modifiche statutarie necessarie per entrare nel gruppo non si applicano le cause di recesso dell'art. 2437, primo comma, lett. a) e g), e dell'art. 2497-quater, primo comma, lett. c), del codice civile, sia per le modifiche propedeutiche all'assunzione del ruolo di capogruppo sia per quelle delle società contraenti: consentire il recesso avrebbe significato drenare capitale proprio nel momento in cui la riforma mirava a rafforzarlo.

La way out. L'art. 150-bis, comma 5, conserva gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici (art. 17 della l. 23 dicembre 2000, n. 388) nei casi di fusione e trasformazione dell'art. 36 e di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni: è la sanzione che rende costoso l'abbandono della forma cooperativa, perché le riserve sono indivisibili e il patrimonio si è formato grazie a un regime fiscale agevolato e all'obbligo di accantonare almeno il settanta per cento degli utili (art. 37, comma 1). Il d.l. 18/2016 (art. 2, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, introdotti dalla legge di conversione) ha previsto una sola deroga, di portata limitata, per le BCC che non intendevano entrare nel gruppo: la devoluzione non si produce per le banche che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, abbiano presentato alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 58 TUB, istanza (anche congiunta) di conferimento delle proprie aziende bancarie a una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'attività bancaria. L'opzione era riservata alle banche di dimensione significativa: la banca istante, o almeno una delle banche istanti in caso di istanza congiunta, doveva avere al 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, risultante da un bilancio su cui il revisore avesse espresso un giudizio senza rilievi. Il prezzo era un versamento al bilancio dello Stato pari al 20% del patrimonio netto a quella data. La cooperativa conferente non si estingue: mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento, modifica l'oggetto sociale per escludere l'attività bancaria e si obbliga a conservare le clausole mutualistiche dell'art. 2514 del codice civile e ad assicurare ai soci servizi di formazione, informazione e assistenza; ai soci non spetta il recesso dell'art. 2437, primo comma, lett. a), del codice civile; in caso di inosservanza il patrimonio è devoluto ai sensi dell'art. 17 della l. 388/2000. Se le autorizzazioni non venivano ottenute entro il termine, la banca poteva chiedere l'adesione a un gruppo già costituito nei novanta giorni successivi e, in caso di diniego, ricadeva nell'alternativa trasformazione o liquidazione.

9.10. Titolo V TUB — Soggetti operanti nel settore finanziario: introduzione

Il Titolo V del TUB ("Soggetti operanti nel settore finanziario") si collega agli articoli 11 e 12 (già trattati in precedenza) e deriva dalla legge antiriciclaggio.

L'origine antiriciclaggio è un dato storico: oggi il Titolo V ha una ratio propria, prudenziale e di tutela della clientela. L'intermediario finanziario non impiega risparmio raccolto presso il pubblico con obbligo di rimborso, e viene quindi meno la ragione più forte della vigilanza bancaria, cioè la tutela del risparmio (art. 47 Cost.); restano però in gioco la stabilità complessiva del sistema finanziario e la correttezza dei comportamenti verso la clientela, su cui si reggono una riserva di attività e un regime di vigilanza propri, più leggeri di quelli bancari. L'ordinamento presidia così separatamente i due termini del binomio dell'art. 10: la raccolta del risparmio (art. 11) e l'erogazione del credito (art. 106).

Il Titolo V è articolato in due Capi. Il Capo I, «Concessione di finanziamenti e soggetti operanti nel settore finanziario» (artt. 106-114), regola l'albo unico degli intermediari finanziari (art. 106), l'autorizzazione (art. 107), la vigilanza (art. 108), la vigilanza consolidata sul gruppo

finanziario (art. 109), i rinvii alla disciplina bancaria (art. 110), il microcredito (art. 111), la finanza etica e sostenibile (art. 111-bis), i confidi e gli altri soggetti minori (artt. 112 e 112-bis), i controlli sull'elenco del microcredito (art. 113), la crisi dell'intermediario (artt. 113-bis e 113-ter) e le norme finali (art. 114). Il Capo II, inserito dal d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116, disciplina agli artt. da 114.1 a 114.14 l'acquisto e la gestione dei crediti in sofferenza. Ai due Capi si affiancano il Titolo V-bis (moneta elettronica e istituti di moneta elettronica) e il Titolo V-ter (istituti di pagamento), che ritagliano una porzione dell'attività tradizionalmente bancaria, la gestione dei mezzi di pagamento, per affidarla a soggetti non banche con riserve e albi propri. *(pagina 4)*

9.11. Art. 106 TUB — L'albo degli intermediari finanziari

Il vecchio art. 106. All'interno del vecchio articolo 106 erano presenti 4 diversi tipi di attività, fra cui la "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", il cui esercizio nei confronti del pubblico era riservato agli intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi (si trattava di una forma di vigilanza anagrafica). Colui il quale concedeva finanziamenti sotto qualsiasi forma svolgeva un'attività riservata.

Comma 1 (testo vigente): *L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.*

Il comma si concentra direttamente sulla concessione di finanziamenti (nota: "concessione di finanziamenti" è esattamente identico a "erogazione del credito"), senza nominare le attività che erano presenti nel vecchio art. 106, poiché per esse esistono discipline specifiche diffuse nel TUB.

L'erogazione del credito è comune a banche e ad altri intermediari finanziari, ma la discriminante è la fonte di finanziamento: la banca utilizza i risparmi raccolti presso il pubblico, mentre la società finanziaria usa fondi propri. Il nome completo del TUB è "testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": il TUB si occupa quindi anche dei soggetti che erogano credito senza raccogliere risparmi fra il pubblico (come le finanziarie, ad esempio).

L'intermediario finanziario non raccoglie risparmio fra il pubblico ed è soggetto a una riserva di attività e a una vigilanza proprie, più leggere di quelle bancarie. I fondi propri si contrappongono qui al risparmio raccolto presso il pubblico, ma non esauriscono la provvista dell'intermediario: questo può raccogliere con strumenti finanziari entro i limiti che il CICR fissa ai sensi dell'art. 11, comma 4-quater, a tutela della riserva dell'attività bancaria e anche in deroga al codice civile. La disciplina di dettaglio è nella Sezione VIII del Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016: per chi concede finanziamenti al pubblico il tetto è il patrimonio, per gli iscritti all'albo dell'art. 106 è il doppio del patrimonio (il quintuplo se gli strumenti sono destinati alla quotazione), e concorrono ai limiti anche le garanzie prestate per emissioni di altri soggetti; restano comunque precluse la raccolta a vista e quella collegata a mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (art. 11, comma 5).

Comma 2: oltre alla concessione di finanziamenti, gli intermediari finanziari possono: **a)** emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell'art. 114-

quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; **b)** prestare servizi di investimento, se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del TUF; **c)** esercitare le altre attività eventualmente consentite dalla legge e le attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia.

Comma 3: il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività del comma 1 e stabilisce in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. La nozione non è definita dal TUB ed è quindi rimessa alla normativa secondaria (d.m. 2 aprile 2015, n. 53).

Dal vecchio al nuovo art. 106. Le altre attività del vecchio art. 106 (assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi) sono uscite dal Titolo V con la riscrittura operata dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141: i servizi di pagamento hanno una riserva e un albo propri nel Titolo V-ter; l'intermediazione in cambi è stata assorbita da discipline di settore; l'assunzione di partecipazioni ha cessato di essere attività riservata. I due elenchi preesistenti (quello generale e quello speciale del vecchio art. 107) sono stati fusi in un albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, e all'iscrizione si è sostituita l'autorizzazione. *(pagina 4)*

9.12. Art. 107 TUB — L'autorizzazione degli intermediari finanziari

Il vecchio articolo 107 prevedeva che per gli intermediari di una certa dimensione fosse necessaria l'iscrizione anche in un secondo elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, a cui veniva anche affidata la vigilanza. La materia è stata riscritta nel 2010, facendo scomparire questa distinzione: esiste ora un unico albo, quello degli Intermediari Finanziari.

Oggi l'articolo indica le condizioni per ottenere l'autorizzazione (forma giuridica, capitale versato minimo, etc.), come previsto per le banche.

Comma 1: la Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

- **a)** forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
- **b)** sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica;
- **c)** capitale versato non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al tipo di operatività;
- **d)** presentazione di un programma sull'attività iniziale e sulla struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- **e)** sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate;
- **e-bis)** idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 110;

- **f)** assenza di stretti legami, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- **g)** oggetto sociale limitato alle sole attività dei commi 1 e 2 dell'art. 106.

Comma 2: la Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni del comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. **Comma 3**: la Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e la decadenza quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta le disposizioni attuative.

Il parallelismo con l'art. 14 non è totale. Quanto alla forma giuridica, la banca può essere soltanto società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. a), mentre l'intermediario può essere anche una società a responsabilità limitata o in accomandita per azioni; per i confidi iscritti all'albo l'art. 112, comma 3, ammette in deroga all'art. 106 anche la società consortile a responsabilità limitata. Quanto all'autorità, l'autorizzazione bancaria è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 2), mentre quella dell'intermediario finanziario è interamente nazionale: gli intermediari del Titolo V non sono enti creditizi e restano fuori dal perimetro della vigilanza unica europea, che riguarda le banche (artt. 4 e 6 del Reg. (UE) n. 1024/2013). Quanto all'oggetto sociale, quello dell'intermediario è vincolato alle sole attività dell'art. 106, mentre la banca può esercitare anche ogni altra attività finanziaria e le attività connesse o strumentali (art. 10, comma 3). *(pagina 4)*

9.13. Art. 108 TUB — La vigilanza sugli intermediari finanziari

Anche in questo articolo ricorrono le stesse formule dell'art. 53 TUB (vigilanza regolamentare), dell'art. 51 (vigilanza informativa) e dell'art. 54 (vigilanza ispettiva). Poiché queste norme sono riprodotte per gli intermediari finanziari, essi sono vigilati esattamente come le banche.

Commi dell'art. 108:

- **comma 1** (vigilanza regolamentare): la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale su governo societario, adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione e informativa al pubblico; può adottare provvedimenti specifici verso singoli intermediari e dettare disposizioni per assicurare il regolare esercizio di determinati tipi di attività;
- **comma 2**: le disposizioni prevedono che gli intermediari possano utilizzare le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni (art. 53, comma 2-bis, lett. a) e sistemi interni di misurazione dei rischi per i requisiti patrimoniali, previa autorizzazione;
- **comma 3** (poteri di intervento): convocare amministratori, sindaci e dirigenti; ordinare la convocazione degli organi collegiali fissandone l'ordine del giorno e proporre determinate decisioni, e convocarli direttamente se gli organi competenti non ottemperano; adottare provvedimenti specifici, fino alla restrizione delle attività o della struttura territoriale, al divieto di determinate operazioni (anche societarie) e di distribuire utili o altri elementi

del patrimonio, al divieto di pagare interessi sugli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza; disporre la rimozione di uno o più esponenti quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (lett. d-bis), misura non adottata se ricorrono gli estremi della decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo urgenza. Il comma 3-bis estende la convocazione ai soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali;

- **comma 4** (vigilanza informativa): segnalazioni periodiche, ogni altro dato e documento richiesto, bilanci; i commi 4-bis e 4-ter consentono di chiedere informazioni al personale, anche per il tramite dell'intermediario, ed estendono gli obblighi ai soggetti cui siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale;
- **comma 5** (vigilanza ispettiva): ispezioni presso gli intermediari o presso i soggetti cui sono esternalizzate funzioni aziendali e richiesta di documenti e atti;
- **comma 6**: nell'esercizio dei poteri la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari e alla natura specifica dell'attività svolta. Il principio è scritto in norma primaria perché la platea degli intermediari è molto eterogenea.

Per tutti gli altri intermediari e le relative discipline si rimanda al libro di Capriglione.

(pagina 5)

9.14. Artt. 109 e 110 TUB — Il gruppo finanziario e i rinvii alla disciplina bancaria

Art. 109. Fra i soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, o del TUF, la Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, da banche di Stato terzo e da società finanziarie come definite dall'art. 59, comma 1, lett. b); capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti (comma 1). La vigilanza su base consolidata può essere esercitata anche nei confronti di intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società del gruppo finanziario o da un intermediario finanziario, di quelle non comprese nel gruppo ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo o un intermediario, e di società diverse controllate da un intermediario finanziario o in cui società del gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo (comma 2). Alla capogruppo la Banca d'Italia può impartire disposizioni sulle materie dell'art. 108, comma 1 (l'art. 108 si applica anche al gruppo finanziario), può richiedere informazioni alle società del gruppo ed effettuare ispezioni (comma 3). Il gruppo finanziario è la categoria residuale che consente la vigilanza consolidata su aggregati non già coperti dalla vigilanza sui gruppi bancari.

Art. 110. Il comma 1 estende agli intermediari finanziari, in quanto compatibili, gli artt. 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61 (commi 4 e 5), 62, 63, 64, 78 e 82 (gli artt. 62 e 63 sono oggi abrogati), precisando che i provvedimenti dell'art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. Il comma 1-bis applica l'art. 26 ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con esclusione del comma 3, lett. c) ed e), e il comma 1-ter applica l'art. 25 ai

titolari delle partecipazioni, con esclusione del comma 2, lett. b); i decreti attuativi possono comunque prevedere l'applicazione dei criteri di competenza avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari e alla natura specifica dell'attività svolta.

9.15. Artt. 111 e 111-bis TUB — Microcredito e finanza etica e sostenibile

Il microcredito è costruito come deroga alla riserva dell'art. 106, comma 1: i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere finanziamenti pur non essendo intermediari finanziari autorizzati, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche tassative indicate dalla norma. Resta concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico: senza la deroga ricadrebbe nella riserva dell'art. 106 e, in difetto di iscrizione, nella sanzione dell'art. 132. Il titolo per operare è l'iscrizione stessa nell'elenco, senza autorizzazione.

Microcredito imprenditoriale (comma 1): finanziamenti a persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis del codice civile), associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, di ammontare non superiore a 75.000 euro, non assistiti da garanzie reali e accompagnati da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. Il comma 1-bis consente finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni della lett. a) e comunque per un importo non superiore a 100.000 euro.

Microcredito sociale (comma 3): finanziamenti erogati in via non prevalente a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, di importo massimo di 10.000 euro, non assistiti da garanzie reali, accompagnati da servizi ausiliari di bilancio familiare, finalizzati all'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. Il comma 3-bis impone l'esercizio congiunto di questa attività e di quella del comma 1; il comma 4 consente ai soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 e dei requisiti di onorabilità del comma 2, lett. c), di svolgere la sola attività del comma 3 a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese.

Iscrizione (comma 2): forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa; capitale versato non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5; requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti e di onorabilità e professionalità degli esponenti; oggetto sociale limitato alle attività del comma 1 e a quelle accessorie e strumentali; programma di attività. Il comma 5 delega al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, le disposizioni attuative, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni; il comma 5-bis subordina l'uso del sostantivo «microcredito» alla concessione di finanziamenti con le caratteristiche dei commi 1 e 3.

L'art. 111-bis non riguarda un soggetto del Titolo V in senso proprio: definisce gli **operatori bancari di finanza etica e sostenibile**, che sono banche e restano soggette all'autorizzazione

dell'art. 14 e alla vigilanza ordinaria. Sono tali le banche che: **a)** valutano i finanziamenti a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale; **b)** danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti così erogati; **c)** devolvono almeno il 20% del portafoglio crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica; **d)** non distribuiscono profitti e li reinvestono nell'attività; **e)** adottano una governance a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzata da azionariato diffuso; **f)** adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza fra la remunerazione maggiore e quella media, il cui rapporto non può superare 5. Gli effetti espressi della qualificazione sono fiscali: una quota pari al 75% delle somme destinate a incremento del capitale proprio non concorre a formare il reddito imponibile (art. 81 TUIR), nel rispetto dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis» (commi 2 e 4).

9.16. Artt. 112, 112-bis e 113 TUB — I confidi, l'Organismo e i controlli sull'elenco del microcredito

I confidi sono consorzi e cooperative di garanzia collettiva dei fidi, e l'art. 112 costruisce un doppio regime. I confidi minori sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo dell'art. 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni del Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge; possono detenere partecipazioni nei soggetti del microcredito (comma 1). I confidi tenuti a iscriversi nell'albo dell'art. 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco (comma 1-bis). L'iscrizione nell'elenco è subordinata alle condizioni di forma giuridica, capitale sociale o fondo consortile, patrimonio, oggetto sociale e assetto proprietario individuate dall'art. 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326) e ai requisiti di onorabilità dei partecipanti e degli esponenti; sede legale e amministrativa devono essere in Italia (comma 2).

Superate certe dimensioni il confidi diventa un intermediario vigilato: il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria, in base ai quali i confidi sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo dell'art. 106, e la Banca d'Italia stabilisce gli elementi per il calcolo di tale volume; per l'iscrizione all'albo, in deroga all'art. 106, possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata (comma 3). I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente la garanzia collettiva dei fidi (comma 4), possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le attività del comma 5 (garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria per i rimborsi d'imposta, gestione di fondi pubblici di agevolazione ai sensi dell'art. 47, comma 2, contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia ai sensi dell'art. 47, comma 3) e, fermo l'esercizio prevalente della garanzia, possono concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106, comma 1 (comma 6): la prevalenza impedisce al confidi di trasformarsi in una finanziaria ordinaria.

L'art. 112-bis istituisce un Organismo con personalità giuridica di diritto privato e autonomia

organizzativa, statutaria e finanziaria, competente per la gestione dell'elenco; lo statuto è approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, e il Ministro nomina un proprio rappresentante nell'organo di controllo. L'Organismo determina i contributi a carico degli iscritti entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse, vigila sul rispetto della disciplina, può chiedere dati e documenti ed effettuare ispezioni, può disporre la cancellazione dall'elenco (venir meno dei requisiti, gravi violazioni normative, mancato pagamento del contributo, inattività protratta per almeno un anno) e può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni o la riduzione delle attività. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo criteri di proporzionalità ed economicità (comma 6) e, su proposta della Banca d'Italia, il Ministro può sciogliere gli organi dell'Organismo in caso di gravi irregolarità (comma 7): è lo schema a due livelli di un registro tenuto da un soggetto privato sotto vigilanza pubblica di secondo grado.

Il comma 7 dell'art. 112 consente ai soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della disposizione, che senza fine di lucro raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, di continuare la propria attività in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR: è la norma che copre oggi le casse peote veneziane, categoria ad esaurimento che non è banca. Il vecchio art. 155, che le disciplinava, è abrogato e l'unico riferimento vigente è questo comma. Lo stesso comma consente di continuare l'attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo dell'art. 106, agli enti e alle società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 fra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale dell'art. 106 vigente al 4 settembre 2010, se ricorrono le condizioni dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, e, in via transitoria, alle società cooperative esistenti al 1° gennaio 1996 che concedono finanziamenti esclusivamente ai propri soci, a condizione che non raccolgano risparmio, il volume complessivo dei finanziamenti non superi quindici milioni di euro, il finanziamento unitario non superi 20.000 euro e le condizioni siano più favorevoli di quelle di mercato: per queste ultime il testo indica un termine (31 dicembre 2014), più volte prorogato da disposizioni successive (l'ultima proroga riportata nel testo consolidato arriva al 31 maggio 2026). Il comma 8 sottopone alle disposizioni dell'art. 106 le agenzie di prestito su pegno dell'art. 115 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, consentendo alla Banca d'Italia di escludere l'applicazione di alcune disposizioni del Capo.

L'art. 113 disciplina i controlli sull'elenco del microcredito. La Banca d'Italia tiene l'elenco e vigila sul rispetto della disciplina da parte degli iscritti, potendo chiedere dati, notizie e documenti ed effettuare ispezioni (comma 1); può disporre la cancellazione per venir meno dei requisiti, per gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del TUB o per inattività protrattasi per almeno un anno (comma 2), e può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni o la riduzione delle attività (comma 3). Quando il numero degli iscritti è sufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, è costituito un Organismo cui passano i poteri dei commi 1, 2 e 3; l'Organismo determina i contributi entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi e può disporre la cancellazione anche per il mancato pagamento dei contributi (comma 4); si applica l'art. 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8-bis (comma 5). Poiché i soggetti del microcredito sono iscritti e non autorizzati, per rimuovere il titolo basta la cancellazione dall'elenco, senza revoca di un'autorizzazione.

9.17. Artt. 113-bis e 113-ter TUB — Sospensione degli organi, revoca dell'autorizzazione e liquidazione

Per gli intermediari iscritti nell'albo dell'art. 106 il TUB prevede un apparato di uscita che riproduce in scala ridotta lo schema delle crisi bancarie, con tre stadi: una misura conservativa a termine, la revoca con liquidazione volontaria vigilata, la liquidazione coatta amministrativa.

Art. 113-bis. Se risultano gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario; le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese e il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale (comma 1). Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia, che nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali (comma 2). La gestione provvisoria non può avere una durata superiore ai sei mesi: i commissari restituiscono l'azienda agli organi sospesi secondo le modalità dell'art. 73, comma 1, oppure, se sono state rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi; si applicano in quanto compatibili alcune norme sull'amministrazione straordinaria delle banche (artt. 71, 72, 73, 74 e 75), segno che l'istituto è costruito per analogia (comma 3). Non è un'amministrazione straordinaria: è più snello e più breve, ed è una misura di supplenza degli organi e non una procedura di risanamento.

Art. 113-ter. La Banca d'Italia può disporre la revoca dell'autorizzazione dell'art. 107, comma 1, quando risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie (lett. a), quando siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità (lett. b), o su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari dell'art. 113-bis o dei liquidatori (lett. c). La soglia è «gravi» per la sospensione, «eccezionalmente gravi» per la revoca. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale e l'intermediario deve darne idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela (comma 2). La revoca costituisce causa di scioglimento della società: entro sessanta giorni dalla comunicazione l'intermediario comunica il programma di liquidazione alla Banca d'Italia, che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 96-quinquies e può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio dell'attività ai sensi dell'art. 2487 del codice civile; nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie (comma 3). La regola è dunque la liquidazione volontaria vigilata: la liquidazione coatta amministrativa è disposta solo se la Banca d'Italia accerta, in sede di revoca o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della liquidazione (comma 3-bis). In deroga, per gli intermediari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento la revoca e la liquidazione coatta amministrativa possono essere disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia (comma 6). Le disposizioni dell'articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari con sede legale all'estero ammessi all'esercizio in Italia delle attività dell'art. 106, comma 1 (comma 7).

9.18. Art. 114 TUB — Norme finali

Il comma 1 rimette al Ministro dell'economia e delle finanze, fermo l'art. 18, la disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti con sede legale all'estero, delle attività dell'art. 106. Il comma 2 esclude l'applicazione del Capo ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti per legge a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta. Il comma 2-bis stabilisce che non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace, entro i limiti del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e delle relative disposizioni attuative dell'IVASS; questi soggetti inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche e partecipano alla Centrale dei rischi.

9.19. Capo II del Titolo V (artt. 114.1-114.14) — I crediti in sofferenza

Il Capo II, inserito dal d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116 in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167, disciplina l'acquisto e la gestione dei crediti in sofferenza e introduce una nuova riserva di attività con un nuovo albo. Il problema all'origine è europeo: lo smaltimento dei crediti deteriorati ha generato un mercato secondario di acquisto e di servicing in larga parte non regolato, con rischi per la stabilità e soprattutto per i debitori ceduti, esposti a pratiche di recupero aggressive da parte di soggetti privi di presidi di correttezza. La direttiva ha costruito uno statuto europeo del gestore di crediti, che il d.lgs. 116/2024 ha inserito nel Titolo V.

Definizioni (art. 114.1). I «crediti in sofferenza» sono i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia. La «gestione» comprende la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali in linea con le istruzioni dell'acquirente (purché non costituisca concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 106: l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento non la costituiscono), la gestione dei reclami dei debitori e l'informativa al debitore su variazioni di tassi e oneri e su ogni pagamento dovuto. I «gestori di crediti in sofferenza» sono le società iscritte nell'albo dell'art. 114.5; l'«acquirente» è la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza.

Ambito (art. 114.2). Salvo diversa disposizione, il Capo non si applica alla gestione svolta da gestori di OICR per conto degli organismi gestiti, da banche e da intermediari iscritti nell'albo dell'art. 106 (anche per i crediti da essi concessi o acquistati), né alla gestione effettuata nell'ambito di cartolarizzazioni ai sensi della l. 30 aprile 1999, n. 130 quando l'acquirente è una società veicolo ai sensi del Reg. (UE) 2017/2402.

Riserva e nomina del gestore (art. 114.3). La gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo dell'art. 106, ai gestori

autorizzati ai sensi dell'art. 114.6 e ai gestori dell'Unione europea che operano in Italia ai sensi dell'art. 114.9 (comma 1). L'acquirente nomina un gestore, una banca o un intermediario ex art. 106, e l'acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza non costituisce di per sé concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 106 (comma 2): per questo l'acquirente non deve essere autorizzato come intermediario. L'acquirente con sede in uno Stato terzo nomina un rappresentante in Italia o in un altro Stato dell'Unione (comma 3); il contratto di gestione è stipulato in forma scritta (comma 4); il gestore comunica alla Banca d'Italia la propria nomina e, con periodicità almeno semestrale, i dati delle cessioni successive (comma 5); gli acquirenti partecipano alla Centrale dei rischi per il tramite di banche, intermediari o gestori (comma 7). Il gestore può esternalizzare alcune attività, ferma la propria responsabilità (comma 6). L'acquirente non è un soggetto vigilato in quanto tale: gli obblighi di condotta dell'art. 114.8 lo riguardano direttamente, ma i poteri di vigilanza si esercitano sul gestore che è obbligato a nominare, e la Banca d'Italia chiede informazioni agli acquirenti per il tramite dei gestori (art. 114.11, comma 3).

Albo e autorizzazione (artt. 114.5-114.7). L'albo è tenuto dalla Banca d'Italia, è consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet; i gestori indicano l'iscrizione negli atti e nella corrispondenza e vi sono iscritti anche i gestori dell'Unione europea che operano in Italia. L'autorizzazione (art. 114.6) richiede la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa; sede legale e direzione generale in Italia, ove sia svolta almeno una parte dell'attività di riscossione e recupero; i presupposti dell'art. 19 per i titolari di partecipazioni; l'idoneità degli esponenti; un programma di attività con governo societario, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni e politiche e procedure per la tutela dei debitori. L'autorizzazione copre anche la detenzione dei fondi dei debitori se il gestore intende riceverli e sono rispettate le condizioni dell'art. 114.7; in caso contrario il gestore ne dà atto nell'istanza (comma 4).

Fondi dei debitori (art. 114.7). Il gestore può ricevere e detenere fondi dai debitori, ai fini del trasferimento agli acquirenti, solo se le somme sono accreditate in un conto separato aperto presso una banca e ivi mantenute fino al trasferimento. Tali somme costituiscono patrimoni distinti a tutti gli effetti da quello del gestore: non sono ammesse azioni dei creditori del gestore né dei creditori della banca depositaria (le azioni dei creditori dei singoli acquirenti sono ammesse nei limiti delle somme di spettanza di questi ultimi); in caso di procedura concorsuale a carico del gestore o della banca le somme sono restituite immediatamente e integralmente agli acquirenti, senza domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto; non operano la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita quella convenzionale. I pagamenti effettuati dal debitore al gestore lo liberano verso l'acquirente, e per ciascun pagamento il gestore rilascia quietanza (comma 2).

Condotta e tutela del debitore (artt. 114.8, 114.10 e 114.14). Acquirenti e gestori si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza, forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli, garantiscono la riservatezza dei dati personali e, nelle comunicazioni, agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento (art. 114.8). Il debitore ceduto riceve notizia individuale della cessione, su supporto cartaceo o durevole, dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero (art. 114.10); l'obbligo si estende, in deroga

all'art. 114.2, anche alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da banche, intermediari ex art. 106 e OICR e a quelle effettuate nell'ambito di cartolarizzazioni, sicché la tutela informativa segue il credito e non la qualità del cessionario. La Banca d'Italia disciplina le procedure di gestione dei reclami e i debitori ceduti possono presentarle esposti (art. 114.14).

Operatività transfrontaliera, vigilanza e rinvii (artt. 114.9, 114.11 e 114.13). I gestori italiani possono operare negli altri Stati dell'Unione, anche senza succursali, e i gestori dell'Unione possono operare in Italia previa comunicazione dell'autorità dello Stato di origine (art. 114.9). La Banca d'Italia vigila sui gestori con poteri regolamentari, informativi, di intervento e ispettivi (art. 114.11). Ai gestori si applicano in quanto compatibili gli artt. 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24 e 52 e l'intero Titolo VI, con autorizzazione ex art. 19 rilasciata valutando esclusivamente la reputazione del potenziale acquirente, l'art. 26 in modo selettivo per gli esponenti e gli artt. 78, 82, 113-bis e 113-ter (a eccezione del comma 7), cioè lo stesso regime di crisi degli intermediari finanziari (art. 114.13).